

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第360號

上 訴 人 財 政 部 北 區 國 稅 局

代 表 人 王 綉 忠

訴 訟 代 理 人 徐 慧 茹

被 上 訴 人 傅 阿 妹

訴 訟 代 理 人 王 鴻 珣 律 師

上列當事人間贈與稅事件，上訴人對於中華民國108年5月2日臺北高等行政法院107年度訴字第1639號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除確定部分外廢棄，發回臺北高等行政法院。

理 由

一、緣被上訴人於民國102年9月2日自配偶曾水宣受贈取得葡萄王生技股份有限公司股票1,201,574股（下稱系爭股票），並於102年9月5日辦竣股票過戶登記。嗣曾水宣於103年8月26日死亡，被上訴人與其子曾盛斌、曾盛肇、曾盛誌及曾盛瑞4人（下稱曾盛斌等4人）則於104年4月2日簽訂「解除贈與契約暨遺產分割協議書」（下稱解除贈與暨分割協議書），將系爭股票轉回曾水宣名下證券帳戶，由曾盛斌等4人以繼承方式取得系爭股票。經上訴人審認被上訴人對系爭股票並無贈與之法定撤銷權，被上訴人將系爭股票移轉予曾盛斌等4人，符合遺產及贈與稅法（下稱遺贈稅法）第4條第2項所定贈與要件，惟未依同法第24條規定申報贈與稅，乃以渠等合意移轉股票日（104年4月2日）之收盤價每股新臺幣（下同）147.5元，核定贈與總額177,232,165元（147.5元×1,201,574股），應納稅額17,503,216元，並按應納稅額處以0.5倍罰鍰8,751,608元。被上訴人申請復查，經上訴人以107年5月3日北區國稅法二字第1070006298號復查決定（下稱原處分）追減罰鍰5,250,965元（即改按應納稅額處以0.2倍之罰鍰3,500,643元），其餘復查駁回。被上訴人乃對不利於其之部分，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處

01 分不利於被上訴人之部分。經原判決將訴願決定及原處分關
02 於罰鍰部分撤銷，並駁回被上訴人其餘之訴。上訴人對於不
03 利其之原判決部分（即撤銷罰鍰部分；另關於被上訴人敗訴
04 部分，因未據其上訴已告確定），遂提起本件上訴。

05 二、被上訴人起訴之主張及上訴人在原審的答辯，均引用原判決
06 所載。

07 三、原判決將訴願決定及原處分關於罰鍰部分均撤銷之理由略以
08 ：

09 (一)、系爭股票由曾水宣於生前贈與被上訴人，於102年9月5日過
10 戶為被上訴人所有，被上訴人與曾盛斌等4人於103年8月26
11 日曾水宣死亡後，先於104年4月2日簽訂解除贈與暨分割協
12 議書，約定將曾水宣業已履行完畢之贈與契約解除，由被上
13 訴人將系爭股票返還回復為曾水宣遺產，另協議系爭股票由
14 曾盛斌等4人取得，繼而於臺灣桃園地方法院（下稱桃園地
15 院）成立調解，被上訴人同意依協議內容將系爭股票移轉予
16 曾盛斌等4人，由被上訴人於104年11月13日將系爭股票轉回
17 曾水宣帳戶，再於104年11月30日依調解筆錄所載股數，分
18 別轉入曾盛斌等4人帳戶。被上訴人既於102年9月5日已取得
19 系爭股票之所有權，則系爭股票嗣後若由被上訴人無償移轉
20 予曾盛斌等4人，即該當遺贈稅法第4條第2項所定贈與，依
21 同法第7條第1項前段規定，被上訴人負有繳納贈與稅之義務
22 。然渠等經由一連串安排，使曾盛斌等4人以繼承曾水宣遺
23 產之名義取得系爭股票，被上訴人亦因此無須負擔系爭股票
24 由其直接無償移轉予曾盛斌等4人時應納之贈與稅。是以被
25 上訴人係透過與曾盛斌等4人以締結解除贈與暨分割協議及
26 成立調解等非通常之法律形式，將其前因受贈而取得所有權
27 之系爭股票無償移轉至曾盛斌等4人名下，達成贈與之實質
28 經濟效果並規避贈與稅構成要件之該當，所為核屬稅捐稽徵
29 法第12條之1第3項及納稅者權利保護法（下稱納保法）第7
30 條第3項規定所稱租稅規避，稅捐稽徵機關於此際應本於實
31 質課稅原則，就被上訴人事實上予以規避，然與其經濟實質

相當之法形式（即贈與）作為課稅之基礎，則上訴人以被上訴人與曾盛斌等4人於104年4月2日訂定該協議書，達成移轉系爭股票之合意，依該日系爭股票之收盤價147.5元核定被上訴人贈與總額177,232,165元（147.5元×1,201,574），贈與淨額175,032,165元，應納贈與稅額17,503,216元，經核尚無不合。

(二)、被上訴人及曾盛斌等4人在上訴人於106年7月25日對被上訴人送達原核定通知書，對被上訴人補徵本件贈與稅前，曾於105年3月23日向上訴人所屬桃園分局（下稱桃園分局）提出申請書，載明其等之被繼承人曾水宣持有系爭股票，於102年9月3日贈與配偶即被上訴人，嗣撤銷贈與並經法院調解成立，回復為曾水宣所有財產，再由曾盛斌等4人以繼承方式取得，系爭股票前經桃園分局認定為贈與但視為遺產，核課遺產稅，並經被上訴人及曾盛斌等4人繳清，請該分局說明渠等與曾水宣間就系爭股票移轉有無應納之遺產稅及贈與稅疑義，經桃園分局於105年4月7日函復稱：被上訴人移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為涉有贈與，請儘速申報贈與稅，倘本案於申報前業經檢舉或調查，仍應依遺贈稅法第44條規定處罰等語，有申請書及桃園分局105年4月7日北區國稅桃園營字第1050205557號函（下稱上訴人105年4月7日函）可稽。另觀諸桃園分局就回復被上訴人及曾盛斌等4人所詢事項之函文，於105年4月2日所擬簽呈載明系爭股票移轉之相關資料中，包括被上訴人與曾盛斌等4人所訂解除贈與暨分割協議書及桃園地院調解筆錄等，顯見被上訴人於上訴人就其藉由與曾盛斌等4人訂定上開協議及於法院成立調解之形式，無償移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為，根據與實質上經濟利益相當之法律形式即贈與，對其核定補徵贈與稅前，已將系爭股票業經曾水宣於生前贈與且移轉予被上訴人，惟被上訴人及曾盛斌等4人嗣後係經由訂定解除贈與暨分割協議及於桃園地院成立調解等方式，先將系爭股票回復為曾水宣名義，再由曾盛斌等4人以繼承名義取得之過程，對

上訴人完全據實以告。是被上訴人與曾盛斌等4人藉由前述合意解除贈與契約、訂定分割協議及成立調解等法律形式外觀，達成由被上訴人將其所有之系爭股票贈與曾盛斌等4人之實質經濟效果，並規避贈與稅要件之該當，所為固然構成稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第7條第3項所定租稅規避，惟被上訴人於稅捐申報及上訴人進行課稅調查時，既無納保法第7條第8項但書規定所稱對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料之行為，致使主管機關陷於錯誤，因而短漏核定稅捐之情事，則上訴人除得根據與實質上經濟利益相當之法律形式對被上訴人補徵贈與稅，並加徵滯納金及利息外，不得另裁處罰鍰。惟上訴人卻以被上訴人於收受其105年4月7日函後，迄未辦理贈與稅申報，核有應注意、能注意而未注意之過失，依遺贈稅法第44條規定，先按應納稅額17,503,216元處0.5倍罰鍰，嗣以原處分改按依應納稅額處0.2倍罰鍰3,500,643元，自屬違法，應予撤銷等詞，茲為其論據。

四、上訴意旨略謂：(一)、本件贈與行為發生於000年0月0日被上訴人自其配偶曾水宣受贈取得系爭股票，同年9月3日辦理贈與稅申報，同年9月5日辦竣股票過戶登記，贈與契約即生效力。被上訴人與曾盛斌等4人原本對曾君生前贈與系爭股票予被上訴人並無異議，其後卻執意將曾君已移轉至被上訴人名下而履行完畢之贈與契約效力解除，係出於規避高額稅負之動機。因此被上訴人移轉系爭股票之行為涉有贈與，惟迄未依限辦理贈與稅申報，核有應注意、能注意而未注意之過失，自應裁處罰鍰，本件實非屬納保法第7條所規定之租稅規避類型，原判決顯有適用法規不當之違誤。(二)、退一步言，倘本件為納保法施行前之租稅規避案件，惟上訴人係於106年6月29日裁處系爭罰鍰，屬納保法施行前「已裁罰尚未確定」之租稅規避案件，依納保法第7條第10項後段規定，其處罰金額係最高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額，而非不得裁罰；此與同法第7條第10項前段規定納保法施行

前「應裁罰而尚未裁罰」之租稅規避案件，應依同法第3項、第7項及第8項規定加徵滯納金及利息之情形有間。原判決以上訴人對被上訴人補徵贈與稅並加徵滯納金及利息外，不得另裁處罰鍰，亦有適用法規不當之違法等語。

五、本院查：

(一)、遺贈稅法第3條第1項規定：「凡經常居住中華民國境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。」第7條第1項前段規定：「贈與稅之納稅義務人為贈與人。……」第20條第1項規定：「左列各款不計入贈與總額：……。」第22條規定：「贈與稅納稅義務人，每年得自贈與總額中減除免稅額220萬元。」第24條第1項規定：「除第20條所規定之贈與外，贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。」第44條規定：「納稅義務人違反第23條或第24條規定，未依限辦理遺產稅或贈與稅申報者，按核定應納稅額加處2倍以下之罰鍰。」準此，贈與稅納稅義務人對於贈與稅之申報負有誠實申報之義務。

(二)、次依105年12月28日制定公布、106年12月28日施行之納保法第7條第3項規定：「納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。」第7項規定：「第3項之滯納金，按應補繳稅款百分之15計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅款，依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。」第8項規定：「第3項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，

01 不在此限。」第10項規定：「本法施行前之租稅規避案件，
02 依各稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第3項、第7項及第
03 8項規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第7
04 項所定滯納金及利息之總額。但有第8項但書情形者，不適
05 用之。」可知，於納保法施行後，對於租稅規避行為，稅捐
06 稽徵機關雖根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租
07 稅上請求權，並加徵滯納金及利息，然除非納稅者於申報或
08 調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資
09 料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐，否則不得另課予逃漏
10 稅捐之處罰；且對於納保法施行前之租稅規避案件，已裁罰
11 而於納保法施行後尚未確定者，除能證明納稅者於申報或調
12 查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料
13 ，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者外，其處罰金額最高不
14 得超過同條第7項所定滯納金及利息之總額。核其立法意旨
15 無非鑑於於納保法施行後，無上述逃漏稅捐情事之租稅規避
16 案件，固不再處罰，惟應加徵之滯納金及利息，是就此類案
17 件，已於納保法施行前經裁罰者，直接明文規定以應加徵之
18 滯納金及利息為其裁罰金額之上限，而免去撤銷原罰鍰，須
19 另為加徵滯納金及利息之勞費。故於納保法施行前，因租稅
20 規避而遭裁罰尚未確定者，於納保法施行後，倘無納保法第
21 7條第8項但書情形，乃應依立法者意思，逕減縮其裁罰金額
22 至滯納金及利息之總額，不再另為滯納金及利息之加徵。

23 (三)、原判決以被上訴人與曾盛斌等4人藉由前述合意解除贈與契
24 約、訂定分割協議及成立調解等法律形式外觀，達成由被上
25 訴人將其所有之系爭股票贈與曾盛斌等4人之實質經濟效果
26 ，並規避贈與稅要件之該當，雖構成稅捐稽徵法第12條之1
27 第3項及納保法第7條第3項所定租稅規避，惟被上訴人於稅
28 捐申報及上訴人進行課稅調查時，既無納保法第7條第8項但
29 書所稱對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料
30 之行為，致使主管機關陷於錯誤，因而短漏核定稅捐之情事
31 ，則上訴人除對被上訴人補徵贈與稅，並加徵滯納金及利息

01 外，不得另裁處罰鍰為由，而將訴願決定及原處分關於罰鍰
02 部分撤銷，固非無見。惟查，被上訴人上開租稅規避行為，
03 係於106年7月25日經上訴人為裁罰，乃原審依法確定之事實
04 。核屬納保法施行前已裁罰尚未確定之租稅規避案件，應將
05 被上訴人所處罰鍰逾應加徵之滯納金及利息總額部分，予以
06 撤銷，始符納保法第7條第10項後段之規定。原判決未注意
07 及此，逕將罰鍰全部予以撤銷，容有未適用上開過渡規定之
08 疏漏。上訴人執此主張原判決違法，即屬可採。從而，原判
09 決就本件納保法施行前已裁罰尚未確定之租稅規避裁罰案件
10 ，既有漏未適用納保法第7條第10項後段規定之違誤，且影
11 響裁判之結果，上訴意旨，求為廢棄原判決，即有理由；又
12 因上述有關本件應加徵滯納金及利息數額尚有未明，有由原
13 審法院再為調查之必要，本院無從自為判決，爰將原判決廢
14 棄，發回原審法院予以查明後，另為適法之裁判。

15 六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項
16 、第260條第1項，判決如主文。

17 中 華 民 國 109 年 7 月 9 日

18 最高行政法院第四庭

19 審判長法官 鄭 小 康

20 法官 劉 介 中

21 法官 林 文 舟

22 法官 帥 嘉 寶

23 法官 林 玫 君

24 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

25 中 華 民 國 109 年 7 月 9 日

26 書記官 高 玉 潔

臺北高等行政法院判決

109年度訴更一字第59號

111年12月1日辯論終結

原告 曾盛斌（即原告傅阿妹之承受訴訟人）

曾盛肇（即原告傅阿妹之承受訴訟人）

曾盛誌（即原告傅阿妹之承受訴訟人）

曾盛瑞（即原告傅阿妹之承受訴訟人）

共同

訴訟代理人 蔡慧玲律師

蔡佩蓉律師

王鴻珣律師

被告 財政部北區國稅局

代表人 蔡碧珍（局長）

訴訟代理人 徐慧茹

蔡淑華

上列當事人間贈與稅事件，原告不服財政部中華民國107年11月2日台財法字第10713930320號訴願決定，提起行政訴訟，經本院108年5月2日107年度訴字第1639號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院109年7月9日109年度判字第360號判決發回更審，本院判決如下：

主 文

訴願決定、復查決定及原核定關於罰鍰逾新臺幣3,086,611元部分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

01 除確定部分外，第一審及上訴審訴訟費用由原告負擔二分之一，餘
02 由被告負擔。

03 事實及理由

04 一、程序事項：

05 (一)被告代表人原為王綉忠，嗣於訴訟進行中變更為蔡碧珍，業
06 據新任代表人蔡碧珍具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准
07 許。

08 (二)按當事人死亡者，訴訟程序在有繼承人承受其訴訟以前當然
09 停止，行政訴訟法第186條準用民事訴訟法第168條定有明
10 文；又訴訟程序當然停止後，依法律所定之承受訴訟之人，
11 於得為承受時，應即為承受之聲明，行政訴訟法第181條第1
12 項亦有明文。本件原起訴原告傅阿妹於110年7月5日死亡，
13 而原告曾盛斌、曾盛肇、曾盛誌、曾盛瑞為傅阿妹之共同繼
14 承人，有戶籍謄本在卷可按，則原告曾盛斌、曾盛肇、曾盛
15 誌、曾盛瑞（下稱原告4人）於110年11月17日具狀聲明承受
16 訴訟，核無不合，應予准許。

17 二、事實概要：

18 本件原告之母傅阿妹於民國（下同）102年9月2日自配偶曾
19 水宣受贈取得葡萄王生技股份有限公司股票1,201,574股
20 （下稱系爭股票），並於102年9月5日辦竣股票過戶登記。
21 嗣曾水宣於103年8月26日死亡，傅阿妹與其子曾盛斌、曾盛
22 肇、曾盛誌及曾盛瑞4人（下稱曾盛斌等4人）則於104年4月
23 2日簽訂「解除贈與契約暨遺產分割協議書」（下稱解除贈
24 與暨分割協議書），將系爭股票轉回曾水宣名下證券帳戶，
25 由曾盛斌等4人以繼承方式取得系爭股票。經被告審認傅阿
26 妹對系爭股票並無贈與之法定撤銷權，傅阿妹將系爭股票移
27 轉予曾盛斌等4人，符合遺產及贈與稅法（下稱遺贈稅法）
28 第4條第2項所定贈與要件，惟未依同法第24條規定申報贈與
29 稅，乃以渠等合意移轉股票日（104年4月2日）之收盤價每
30 股新臺幣（下同）147.5元，核定贈與總額177,232,165元
31 （147.5元×1,201,574股），應納稅額17,503,216元，並按

01 應納稅額處以0.5倍罰鍰8,751,608元。經申請復查，被告以
02 107年5月3日北區國稅法二字第1070006298號復查決定（下
03 稱原處分）追減罰鍰5,250,965元（即改按應納稅額處以0.2
04 倍之罰鍰3,500,643元），其餘復查駁回。原告循序提起行
05 政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分不利於原告之部分。經
06 原審以107年度訴字第1639號判決（下稱原判決）將訴願決
07 定及原處分關於罰鍰部分撤銷，並駁回原告其餘之訴。被告
08 不服，乃就原判決不利於己部分（即撤銷罰鍰部分；另關於
09 原告敗訴部分，因未據其上訴已告確定），提起上訴。經最
10 高行政法院109年度判字第360號判決（下稱發回判決）原判
11 決除確定部分外廢棄，發回本院更為審理（本稅部分已確
12 定，不在本件審理範圍）。

13 三、本件原告主張：

14 （一）本件緣起於原告之父曾水宣於102年9月2日將其所有系爭股
15 票贈與本件原告之母傅阿妹，嗣曾水宣於103年8月26日死
16 亡，傅阿妹即於104年4月2日與曾盛斌等4人簽訂解除贈與暨
17 分割協議，協議之雙方同意系爭股票由曾盛斌等4人平均各4
18 分之1繼承之。曾盛斌等4人繼而以傅阿妹為相對人，向桃園
19 地院聲請調解，於104年7月30日成立內容為：傅阿妹願依上
20 開解除贈與暨分割協議書，將系爭股票移轉予曾盛斌、曾盛
21 肇各300,394股，另移轉予曾盛誌、曾盛瑞各300,393股之調
22 解後，由傅阿妹於104年11月13日將系爭股票轉回曾水宣帳
23 戶，再於104年11月30日依調解筆錄所載股數，分別轉入曾
24 盛斌等4人帳戶。

25 （二）本件嗣後經認定，係傅阿妹與曾盛斌等4人藉由前述合意解
26 除贈與契約、訂定分割協議及成立調解等法律形式外觀，達
27 成由傅阿妹將其所有之系爭股票贈與曾盛斌等4人之實質經
28 濟效果，並規避贈與稅要件之該當，構成稅捐稽徵法第12條
29 之1第3項及納保法第7條第3項所定租稅規避，被告乃核定補
30 徵贈與稅17,503,216元，原告不服前開稅額之補徵，提起行
31 政爭訟，案經原審法院以107年度訴字第1639號判決，駁回

01 本稅之訴請撤銷，原告就此敗訴部分，未提起上訴，已告確
02 定。

03 (三)然者，租稅規避並非違法行為，又僅消極不申報所規避之稅
04 捐，並不當然構成逃漏稅捐之故意或過失。再者，原審法院
05 亦認本件原告不具備故意或過失等行政罰要件，被告除得根
06 據與實質上經濟利益相當之法律形式，對原告補徵贈與稅，
07 並加徵滯納金及利息外，不得另外裁處罰鍰。是以，本件應
08 認原告並無逃漏稅捐之故意或過失，被告對原告裁處罰鍰3,
09 500,643元，自屬違法，應予撤銷。

10 (四)此外，縱使本件構成稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第
11 7條第3項所定租稅規避，惟原告於稅捐申報及稽徵機關進行
12 課稅調查時，無納保法第7條第8項但書所稱對重要事項隱匿
13 或為虛偽不實陳述或提供不正確資料之行為，致使主管機關
14 陷於錯誤，因而短漏核定稅捐之情事，則被告除對原告補徵
15 贈與稅，並加徵滯納金及利息外，亦不得另裁處罰鍰。又納
16 保法第7條第10項之適用前提，應以「該租稅規避行為符合
17 行政罰之構成要件」為必要，本件原告既不具備故意或過失
18 等行政罰要件，亦應認本件並無納保法第7條第10項規定之
19 適用餘地，縱將本件裁罰金額減縮至相當於滯納金及利息總
20 額3,086,611元，仍屬違法，不應維持。

21 (五)再者，行政罰鍰係國家為確保行政法秩序之維持，對於違規
22 之行為人所施之財產上制裁，而違規行為之行政法上責任，
23 性質上不得作為繼承之對象。按司法院大法官解釋第621號
24 理由意旨，罰鍰繳納義務具有一身專屬性，自不得繼承。此
25 外，如違規行為人於罰鍰處分之行政訴訟程序中死亡者，其
26 當事人能力即行喪失，尚未確定之罰鍰處分，對該違規行為
27 人也喪失繼續存在之意義而失效，自不應對繼承人處以裁罰
28 處分。是以，本件原告之母傅阿妹於110年7月5日死亡，則
29 本件罰鍰處分不能繼續維持，被告不予以撤銷，於法係有不
30 合。

31 (六)並聲明：

01 1. 訴願決定、復查決定及原核定除確定部分外，不利於原告之
02 部分均撤銷。

03 2. 除確定部分外第一審及發回前上訴審訴訟費用，均由被告負
04 擔。

05 四、被告則以：

06 (一) 傅阿妹及曾盛斌等4人曾於105年3月24日向被告所屬桃園分
07 局（下稱桃園分局）詢問渠等與被繼承人曾水宣間就系爭股
08 票移轉有無遺產稅及贈與稅疑義，經該分局於105年4月7日
09 函復，傅阿妹移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為涉有贈
10 與，請盡速申報贈與稅，倘申報前經檢舉或調查，仍應依遺
11 贈稅法第44條規定處罰，惟贈與人迄未依規定辦理贈與稅申
12 報，核有應注意、能注意而未注意之過失，且無稅務違章案
13 件減免處罰標準第13條之適用，自應受罰。

14 (二) 被告考量贈與人對系爭股票移轉之課稅問題已主動申請釋疑
15 並檢附相關事證供參，其雖經通知仍未為補申報，然其主觀
16 可責性顯較一般違章情節為輕，依據納保法規定，並參酌稅
17 務違章案件裁罰金額或倍數參考表使用須知第4點，酌予從
18 輕改按應納稅額17,503,216元處0.2倍罰鍰3,500,643元。

19 (三) 由於受處分人對罰鍰處分不服，提起行政爭訟，案經最高行
20 政法院109年度判字第360號判決闡明，本件既經被告於106
21 年7月25日為裁罰，乃屬納保法施行前已裁罰尚未確定之租
22 稅規避案件，應將被告所處罰鍰逾應加徵之滯納金及利息總
23 額部分，予以撤銷，始符納保法第7條第10項本文之規定。
24 是以，本件乃將罰鍰金額縮減計算成為3,086,611元（計算
25 表參本院卷第63頁）。應認本件適用納保法第7條第10項本
26 文「本法施行前之租稅規避案件，依各稅法規定……已裁罰
27 尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第7項所定滯納金及
28 利息之總額」規定，則前述罰鍰3,086,611元（相當於滯納
29 金及利息之總額），並無違誤，應予維持。

30 (四) 並聲明：

31 1. 駁回原告之訴。

01 2. 第一審及上訴審訴訟費用由原告負擔。

02 五、如事實概要欄所載之事實，有贈與契約書、贈與稅申報書、
03 贈與稅不計入贈與稅總額證明書、解除贈與暨分割協議書、
04 桃園地院調解筆錄、遺產稅繳清證明書、桃園分局105年4月
05 7日對傅阿妹及曾盛斌等4人之函復、核定通知書、裁處書、
06 原處分書、訴願決定書，附原處分卷第17、22至23、36、32
07 至34、30至31、35、37至44、88至95、72、386至394及534
08 至549頁可稽，並有罰鍰上限金額計算表等附本院卷第63至6
09 5頁可稽，且為兩造所不爭執，堪信為真實。經核本件爭點
10 為：被告審認本件原告之母將系爭股票移轉予原告4人，符
11 合遺贈稅法第4條第2項所定贈與要件，惟未依同法第24條規
12 定申報贈與稅，按同法第44條規定處以罰鍰，原告就被告罰
13 鍰處分聲明不服，其訴請撤銷罰鍰處分有無理由？

14 六、本院之判斷：

15 (一)應適用之法令：

16 1. 遺贈稅法第3條第1項規定：「凡經常居住中華民國境內之中
17 華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，
18 應依本法規定，課徵贈與稅。」第4條第1項及第2項規定：
19 「（第1項）本法稱財產，指動產、不動產及其他一切有財
20 產價值之權利。（第2項）本法稱贈與，指財產所有人以自
21 己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為。」第
22 7條第1項前段規定：「贈與稅之納稅義務人為贈與人。
23 ……。」第10條第1項規定：「遺產及贈與財產價值之計
24 算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；
25 ……。」第24條第1項規定：「除第20條所規定之贈與外，
26 贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，
27 應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關
28 依本法規定辦理贈與稅申報。」第44條規定：「納稅義務人
29 違反……第24條規定，未依限辦理……贈與稅申報者，按核
30 定應納稅額加處2倍以下之罰鍰。」同法施行細則第28條第1
31 項規定：「凡已在證券交易所上市（以下簡稱上市）或證券

01 商營業處所買賣（以下簡稱上櫃或興櫃）之有價證券，依繼
02 承開始日或贈與日該項上市或上櫃有價證券之收盤價或興櫃
03 股票之當日加權平均成交價估定之……。」

- 04 2. 稅捐稽徵法第12條之1第1至3項規定：「（第1項）涉及租稅
05 項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律
06 之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為
07 之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實
08 時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與
09 享有為依據。（第3項）納稅義務人基於獲得租稅利益，違
10 背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該
11 當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。」

- 12 3. 納稅者權利保護法（下稱納保法）第7條第3項、第7項、第8
13 項、第10項規定：「（第3項）納稅者基於獲得租稅利益，
14 違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租
15 稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為
16 租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法
17 律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。……

18 （第7項）第3項之滯納金，按應補繳稅款15%計算；並自該
19 應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳
20 納通知書之日止，按補繳稅款，依各年度1月1日郵政儲金一
21 年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。（第8
22 項）第3項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但
23 納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述
24 或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不
25 在此限。……（第10項）本法施行前之租稅規避案件，依各
26 稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第3項、第7項及第8項
27 規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第7項
28 所定滯納金及利息之總額。但有第8項但書情形者，不適用
29 之。」其立法意旨明揭：「納稅者不選擇稅法上通常之法律
30 形式，卻以取巧方式、迂迴行為或非常規之法律形式，以避
31 免稅捐構成要件的滿足，而減輕其稅負。此情形即屬故意濫

01 用法律形式，規避稅捐之行為，並無值得保護之信賴利益，
02 仍應本於實質課稅原則加以調整補稅。……稅捐規避雖非屬
03 違法行為，而與違背稅法上誠實義務之逃漏稅違法行為有
04 間，但性質上屬於鑽法律漏洞之脫法行為。於法理上亦無容
05 許納稅者得主張其脫法行為，以獲取實質經濟利益之可能，
06 主管機關應依處罰法定原則進行調整補稅。因稅捐規避行
07 為，其性質與延遲繳納相近……於第3項明定……加課補徵
08 稅額15%的延滯金……以及……加計利息，以維公平。惟若
09 納稅者於稅捐申報或於主管機關進行課稅調查時，隱匿事
10 實、為虛偽不實陳述或提供不正確資料等行為，致使主管機
11 關陷於錯誤之虞，因而短漏核定稅捐者，應予裁處漏稅之罰
12 鍰。」是前揭納保法條文，雖於106年12月28日起始生效，
13 惟其規定其實為名詞解釋性立法，就現行租稅稽徵上關於租
14 稅規避、租稅逃漏等名詞，予以定義性規定，自得於本案中
15 予以適用，無待於法規生效後始得援用（最高行政法院106
16 年度判字第245號判決、106年度判字第234號判決意旨參
17 照）。

18 （二）就贈與人應補繳稅款17,503,216元部分（已告確定）：

- 19 1. 本件原告之父曾水宣於生前委由代理人檢附其與配偶傅阿妹
20 於102年9月2日就系爭股票所訂贈與契約書，及其2人於凱基
21 證券股份有限公司（下稱凱基公司）所開設證券帳戶存摺影
22 本，於102年9月3日向桃園分局辦理贈與稅申報，經被告核
23 發贈與稅不計入贈與總額證明書後，於102年9月5日辦竣系
24 爭股票由曾水宣過戶予傅阿妹事宜。曾水宣嗣於103年8月26
25 日死亡，傅阿妹與其子曾盛斌等4人先於104年4月2日簽訂解
26 除贈與暨分割協議書，其第2、3條約定：傅阿妹與曾盛斌等
27 4人合意解除曾水宣與傅阿妹前就系爭股票所訂贈與契約，
28 傅阿妹於即日起無條件全數返還系爭股票並納入曾水宣之遺
29 產；傅阿妹與曾盛斌等4人同意，系爭股票由曾盛斌等4人平
30 均各4分之1繼承之。曾盛斌等4人繼而以傅阿妹為相對人，
31 向桃園地院聲請調解，於104年7月30日成立內容為：傅阿妹

願依上開解除贈與暨分割協議書，將系爭股票移轉予曾盛斌、曾盛肇各300,394股，另移轉予曾盛誌、曾盛瑞各300,393股之調解後，由傅阿妹於104年11月13日將系爭股票轉回曾水宣帳戶，再於104年11月30日依調解筆錄所載股數，分別轉入曾盛斌等4人帳戶等情，有贈與契約書、贈與稅申報書、曾水宣及傅阿妹於凱基公司所開設帳戶之證券存摺、贈與稅不計入贈與稅總額證明書、解除贈與暨分割協議書、桃園地院調解筆錄及曾盛斌等4人於105年4月19日所具說明書等，附原處分卷第17至36頁及54至56頁可稽。

2. 依上所述，可知系爭股票業由曾水宣於生前贈與傅阿妹，並於102年9月5日過戶為傅阿妹所有，傅阿妹與曾盛斌等4人於曾水宣死亡後，卻先簽訂解除贈與暨分割協議，約定將曾水宣業已履行完畢之贈與契約解除，由傅阿妹將系爭股票返還回復為曾水宣遺產，另協議系爭股票由曾盛斌等4人取得，繼而於桃園地院成立調解，傅阿妹同意依上開協議內容，將系爭股票移轉予曾盛斌等4人，以使曾盛斌等4人輾轉自傅阿妹受贈系爭股票，惟傅阿妹竟亦脫免其對曾盛斌等4人贈與系爭股票之贈與稅負擔。按行為時稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第7條第3項乃有關租稅規避之規定，此觀其文義自明；而稅捐規避係納稅者不選擇稅法上通常之法律形式，卻以取巧方式、迂迴行為或非常規之法律形式，以避免稅捐構成要件的滿足，而減輕其稅負，故意濫用法律形式，性質上屬於鑽法律漏洞之脫法行為（最高行政法院109年度判字第249號判決意旨參照）。換言之，就曾水宣生前102年9月5日業已履行完畢之贈與契約，傅阿妹竟於曾水宣死後多時之104年4月2日，始為曾水宣贈與契約之解除，並於104年11月13日將系爭股票返還予業已死亡（已喪失權利能力）之曾水宣，充當曾水宣103年8月26日死亡時之遺產，嗣由曾盛斌等4人形式上以繼承之名義取得系爭股票，傅阿妹（贈與系爭股票予曾盛斌等4人之贈與人）則藉以避免贈與稅構成要件之滿足。可見傅阿妹等人係利用上開取巧、迂迴及非常規之

法律形式，實際使曾盛斌等4人自傳阿妹受贈系爭股票，然傳阿妹卻脫免贈與人應有之稅捐負擔，核屬稅捐規避行為。

3. 本件原告就此雖主張：曾水宣生前曾表示，系爭股票將由原告4人繼承，系爭股票乃傳阿妹擅自過戶至伊自己名下，為免母子對簿公堂，是於104年4月2日簽訂解除曾水宣之贈與暨分割協議，將系爭股票回復原狀返還為曾水宣之遺產，再由原告4人繼承，傳阿妹與原告4人嗣並成立調解，同意依上開解除贈與暨分割協議履行云云；然而，觀之傳阿妹對原核定申請復查後，向被告提出之陳報書中，自承其證券存摺平常由其自行保管，每上、下半年度會例行性地請曾水宣或子女代為補登，103年1月6日、103年9月18日、104年1月8日、104年11月15日均曾為例行性補登餘額等情（參見原處分卷第232、233頁），實則在系爭股票由傳阿妹受贈取得，並於102年9月5日完成過戶手續後之103年1月6日，曾盛斌等4人既曾代傳阿妹補登證券存摺，渠等於斯時自是已然知悉系爭股票業經曾水宣贈與傳阿妹，並移轉權利完畢之事。復參諸傳阿妹與曾盛斌等4人於103年11月27日（被告收文日期）共同辦理遺產稅申報時，於申報書內係自行將系爭股票列為曾水宣死亡前2年贈與之財產（參見原處分卷第149至151頁之遺產稅申報書），益見原告對系爭股票業由曾水宣於死亡前2年贈與並過戶給傳阿妹所有之事，非但知悉，且無爭執。至原告所稱：曾水宣生前曾表示系爭股票應由曾盛斌等4人繼承，傳阿妹擅自將系爭股票過戶至自己名下，渠等嗣後對曾水宣有無贈與系爭股票生有爭議，為免母子對簿公堂，渠等乃簽訂解除贈與暨分割協議及成立調解云云，未據提出證據以實其說，且與曾盛斌等4人至遲於103年1月6日即知悉傳阿妹已受贈取得系爭股票所有權，甚且於時隔10個月餘後申報遺產稅時，就此均無任何爭執等情，顯不相符；另觀諸渠等所訂解除贈與暨分割協議書，及曾盛斌等4人向桃園地院聲請調解時，提出之民事聲請調解狀及所附證物即存證信函（參見原處分卷第304至309頁），亦無任何有關傳阿妹與曾

01 盛斌等4人因曾水宣是否贈與系爭股票一事，發生爭議之記
02 載，是原告所述上情，因乏證據可佐，尚難遽予採信。

03 4. 被告核定之贈與人應補繳稅款：

04 (1). 傅阿妹既於102年9月5日已取得系爭股票之所有權，則
05 系爭股票嗣後由傅阿妹無償移轉予曾盛斌等4人，即該
06 當遺贈稅法第4條第2項所定贈與，依同法第7條第1項前
07 段規定，贈與人傅阿妹負有繳納贈與稅之義務。然渠等
08 經由上述一連串安排，使傅阿妹受贈取自曾水宣之系爭
09 股票，得以贈與契約事後經曾水宣全體繼承人合意解
10 除，傅阿妹應負回復原狀責任為由，先回復至已死亡多
11 時之曾水宣名下，充當為曾水宣遺產之外觀，進而藉由
12 協議分割遺產，使曾盛斌等4人以繼承曾水宣遺產之名
13 義取得系爭股票，傅阿妹亦因此規避贈與稅之負擔。參
14 諸曾水宣於102年9月3日辦理系爭股票贈與傅阿妹之申
15 報，列報贈與總額為159,208,555元（參見原處分卷第2
16 2頁）、傅阿妹與曾盛斌等4人於103年11月27日申報遺
17 產稅，經被告核定之系爭股票遺產價額為158,006,981
18 元（參見原處分卷第35頁），另葡萄王生技股份有限公
19 司股票於104年4月1日至30日之收盤價最低為138元（參
20 見原處分卷第11頁），依系爭股票股數計算之價值為16
21 5,817,212元（138元×1,201,574股），足見傅阿妹如直
22 接贈與系爭股票予曾盛斌等4人，就扣除遺贈稅法第22
23 條所定220萬元免稅額後之課稅贈與淨額，必須負擔行
24 為時依同法第19條第1項所定稅率10%計算之逾上千萬元
25 贈與稅，由此不難想見傅阿妹與曾盛斌等4人原本對曾
26 水宣生前贈與傅阿妹系爭股票並無異議，其後卻執意將
27 曾水宣已移轉至傅阿妹名下而履行完畢之贈與契約效力
28 解消，係出於規避高額稅負之動機。是以，傅阿妹係透
29 過與曾盛斌等4人以締結解除贈與暨分割協議及成立調
30 解等非通常之法律形式，將其前因受贈而取得所有權之
31 系爭股票，無償移轉至曾盛斌等4人名下，達成贈與之

01 實質經濟效果，並規避贈與稅構成要件之該當，所為核
02 屬行為時稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第7條第3
03 項所稱租稅規避，揆諸前揭說明，稅捐稽徵機關於此際
04 應本於實質課稅原則，就傳阿妹事實上予以規避，然與
05 其經濟實質相當之法形式（即贈與）作為課稅之基礎。

06 (2). 復因被告對於傳阿妹上開規避租稅行為，應根據與實質
07 上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，且傳
08 阿妹與曾盛斌等4人於104年4月2日所訂解除贈與暨分割
09 協議書第2、3條，約明傳阿妹於該日將系爭股票返還納
10 入曾水宣之遺產，由曾盛斌等4人各取得4分之1，堪認
11 傳阿妹於該訂約日已為贈與系爭股票之意思，並為曾盛
12 斌等4人於同日允受。被告乃依遺贈稅法第10條第1項規
13 定，按該日之時價計算系爭股票價值，對傳阿妹核課贈
14 與稅。又被告確係以傳阿妹與曾盛斌等4人於104年4月2
15 日訂定上開協議書，達成移轉系爭股票之合意，依該日
16 系爭股票之收盤價每股147.5元（參見原處分卷第11
17 頁），核定傳阿妹贈與總額177,232,165元（147.5元×
18 1,201,574股），贈與淨額175,032,165元（贈與總額17
19 7,232,165元－免稅額2,200,000元），並按稅率10%，
20 對傳阿妹開單補徵應納稅款17,503,216元（參原處分卷
21 第88至95頁），此部分雖經傳阿妹聲明不服並為行政爭
22 訟，惟案經原審以107年度訴字第1639號判決駁回原告
23 之訴，傳阿妹就此敗訴部分，因未上訴，已告確定。則
24 當事人就此，不得於其他訴訟中與確定判決意旨為相反
25 之主張，法院亦不得為相反之認定，此即撤銷訴訟判決
26 既判力之確認效（最高行政法院109年度判字第436號判
27 決意旨參照）。

28 (三)就本件罰鍰部分：

29 1. 本件構成規避租稅行為：

30 (1). 本件系爭股票由曾水宣於生前贈與並過戶給傳阿妹所
31 有，傳阿妹與曾盛斌等4人於103年8月26日曾水宣死亡

01 後，先於104年4月2日簽訂解除贈與暨分割協議書，約
02 定將曾水宣業已履行完畢之贈與契約解除，由傅阿妹將
03 系爭股票返還回復為曾水宣遺產，另協議系爭股票由曾
04 盛斌等4人取得，繼而於桃園地院成立調解，傅阿妹同
05 意協議之內容，乃先於104年11月13日將系爭股票轉回
06 曾水宣帳戶，再於104年11月30日依調解筆錄所載股
07 數，分別轉入曾盛斌等4人帳戶等情，已如上述。傅阿
08 妹既於102年9月5日已取得系爭股票之所有權，則系爭
09 股票嗣後由傅阿妹無償移轉予曾盛斌等4人，即該當遺
10 贈稅法第4條第2項所定贈與，依同法第7條第1項前段及
11 第24條第1項等規定，贈與人傅阿妹負有申報繳納贈與
12 稅之義務。然傅阿妹經由一連串安排，使曾盛斌等4人
13 以繼承曾水宣遺產之名義取得系爭股票，傅阿妹亦因此
14 未為贈與稅之申報。是以，傅阿妹係透過與曾盛斌等4
15 人以締結解除贈與暨分割協議及成立調解等非通常之法
16 律形式，將其前因受贈而取得所有權之系爭股票無償移
17 轉至曾盛斌等4人名下，達成贈與之實質經濟效果並規
18 避贈與稅構成要件之該當，洵堪認定。

- 19 (2). 被告雖將上開解除贈與暨分割協議書，解為係傅阿妹與
20 曾盛斌等4人（以下合稱渠等5人）依民法第417條前段
21 規定，撤銷曾水宣生前與傅阿妹就系爭股票所訂贈與契
22 約，進而認定渠等5人不具有前揭民法條文所定撤銷
23 權，無從藉由訂定上開協議，使傅阿妹已經受贈取得所
24 有權之系爭股票，回復至曾水宣名下，再由曾盛斌等4
25 人以繼承名義取得，故傅阿妹實際將系爭股票無償移轉
26 予曾盛斌等4人，涉及直接贈與情事，非屬手段迂迴之
27 租稅規避。然而，觀諸上開解除契約暨分割協議書，係
28 約定由渠等5人合意解除曾水宣生前贈與契約，其內容
29 並無一語提及渠等5人係因民法第417條前段所定情形
30 （即受贈人因故意不法行為，致贈與人死亡或妨礙其為
31 贈與之撤銷），故而以曾水宣繼承人身分撤銷贈與。則

01 被告所稱渠等5人係以上開協議書，行使民法第417條前
02 段所定贈與撤銷權云云，與該協議書之文義不符，已難
03 採取。再者，被告未慮及渠等5人係利用訂定上開協議
04 書及至法院成立調解之手法，製造系爭股票為曾水宣遺
05 產，由曾盛斌等4人依繼承法律關係而取得之形式外
06 觀，達成由傅阿妹贈與系爭股票予曾盛斌等4人之實質
07 上經濟效果，迂迴規避贈與稅構成要件之該當，業已構
08 成租稅規避之情，被告逕認系爭股票係由傅阿妹直接贈
09 與曾盛斌等4人，並非租稅規避云云，其法律涵攝亦非
10 妥洽。

11 2. 本件核有納保法第7條第10項本文規定之適用：

12 (1). 依105年12月28日制定公布、106年12月28日施行之納保
13 法第7條第3項規定：「納稅者基於獲得租稅利益，違背
14 稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租
15 稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效
16 果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利
17 益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金
18 及利息。」第7項規定：「第3項之滯納金，按應補繳稅
19 款15%計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次
20 日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅
21 款，依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利
22 率，按日加計利息，一併徵收。」第8項規定：「第3項
23 情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者
24 於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或
25 提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，
26 不在此限。」第10項規定：「本法施行前之租稅規避案
27 件，依各稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第3項、
28 第7項及第8項規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最
29 高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額。但有第8項
30 但書情形者，不適用之。」可知，於納保法施行後，對
31 於租稅規避行為，稅捐稽徵機關雖根據與實質上經濟利

01 益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金
02 及利息，然除非納稅者於申報或調查時，對重要事項隱
03 匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵
04 機關短漏核定稅捐，否則不得另課予逃漏稅捐之處罰；
05 且對於納保法施行前之租稅規避案件，已依各稅法規定
06 為裁罰，而於納保法施行後尚未確定者，除能證明納稅
07 者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述
08 或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者
09 外，其處罰金額最高不得超過同法條第7項所定滯納金
10 及利息之總額。核其立法意旨無非鑑於納保法施行後，
11 無上述隱匿、虛偽、不正確情事之租稅規避案件，若尚
12 未裁罰，固不再處罰，惟應加徵滯納金及利息，是就此
13 類案件，已於納保法施行前經依各稅法規定裁罰者，立
14 法直接明文規定以應加徵之滯納金及利息為其裁罰金額
15 之上限，而免去撤銷原罰鍰，須另為加徵滯納金及利息
16 之勞費。故於納保法施行前，租稅規避案件已依各稅法
17 規定為裁罰惟尚未確定者，於納保法施行後，倘無納保
18 法第7條第8項但書情形，乃應依立法者意思，逕減縮其
19 裁罰金額至滯納金及利息之總額，不再另外施加滯納金
20 及利息之負擔（最高行政法院109年判字第360號判決意
21 旨參照）。

- 22 (2). 經查，本件在被告於106年7月25日對傅阿妹送達原核定
23 通知書（參原處分卷第95頁），補徵本件贈與稅前，傅
24 阿妹及其子4人曾於105年3月24日（郵戳日）向桃園分
25 局提出申請書，載明曾水宣生前持有系爭股票，於102
26 年9月3日贈與配偶即傅阿妹，嗣渠等5人撤銷曾水宣前
27 述贈與並經法院調解成立，回復為曾水宣所有財產，再
28 由曾盛斌等4人以繼承方式取得，系爭股票前經桃園分
29 局認定為配偶間贈與（免徵贈與稅），但視為曾水宣之
30 遺產，核課遺產稅，並經傅阿妹繳清，請該分局說明渠
31 等與曾水宣間就系爭股票移轉有無應納之遺產稅及贈與

01 稅疑義，經被告於105年4月7日函復稱：傳阿妹移轉系
02 爭股票予曾盛斌等4人之行為涉有贈與，請儘速申報贈
03 與稅，倘本案於申報前業經檢舉或調查，仍應依遺贈稅
04 法第44條規定處罰等語，有申請書及桃園分局105年4月
05 7日北區國稅桃園營字第1050205557號函（下稱被告105
06 年4月7日函），附原處分卷第37至44頁可稽。另觀諸桃
07 園分局就上開函文之回復，於105年4月2日所擬簽呈，
08 載明系爭股票移轉之相關資料中，包括傳阿妹渠等5人
09 所訂解除贈與暨分割協議書及桃園地院調解筆錄等（參
10 見原處分卷第46頁），顯見本件於被告核定補徵贈與稅
11 17,503,216元之前，傳阿妹已將系爭股票經曾水宣生前
12 贈與且移轉、渠等5人嗣後訂定解除贈與暨分割協議及
13 於桃園地院成立調解、傳阿妹將系爭股票回復為曾水宣
14 名義、再由曾盛斌等4人以繼承名義取得系爭股票等行
15 為過程，對被告據實以告，被告亦循線查獲而對傳阿妹
16 補徵上述稅款17,503,216元確定在案。是傳阿妹固與曾
17 盛斌等4人藉由前述法律形式外觀為贈與稅之規避，以
18 致未為贈與稅之申報，惟傳阿妹於被告進行課稅調查
19 時，既「未」對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供
20 不正確資料，則本件應認尚「無」納保法第7條第8項但
21 書之適用，即「無」同法條第10項但書不設罰鍰上限之
22 適用。

- 23 (3). 次按遺贈稅法第3條第1項規定：「凡經常居住中華民國
24 境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財
25 產為贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。」第7條第1
26 項前段規定：「贈與稅之納稅義務人為贈與人。……」
27 第20條第1項規定：「左列各款不計入贈與總額
28 ：……。」第22條規定：「贈與稅納稅義務人，每年得
29 自贈與總額中減除免稅額220萬元。」第24條第1項規定：
30 「除第20條所規定之贈與外，贈與人在1年內贈與他人
31 之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈

與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。」第44條規定：「納稅義務人違反第23條或第24條規定，未依限辦理遺產稅或贈與稅申報者，按核定應納稅額加處2倍以下之罰鍰。」準此，贈與稅納稅義務人對於超過免稅額之贈與，負有依規定期限辦理贈與稅申報，以及誠實申報等公法上義務（最高行政法院109年判字第360號判決意旨參照）。

(4). 又遺贈稅法第4條第2項規定：「本法稱贈與，指財產所有人以自己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為。」行為時（即106年5月10日修正前）第19條第1項規定：「贈與稅按贈與人每年贈與總額，減除第21條規定之扣除額及第22條規定之免稅額後之課稅贈與淨額，課徵10%。」第24條第1項規定：「除第20條所規定之贈與外，贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。」查依上揭規定可知，贈與稅於贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時成立。故贈與稅係就「偶然發生」之課稅事實課徵之租稅，依法應由納稅義務人申報繳納，若未在規定期間內申報繳納者，自規定申報期間屆滿之翌日起算其核課期間。並且，贈與稅之性質屬於「非週期稅」，核與按一定週期反覆課徵之租稅即「週期稅」者，明顯有別（最高行政法院108年度上字第829號判決意旨參照）。

(5). 是以，基於贈與稅具有「偶然發生」之「非週期稅」性質，相較於按一定週期反覆課徵之「週期稅」而言，前者非週期稅之「不可預見性」更高於後者，即稽徵機關對非週期稅處於資訊劣勢之程度更甚於後者，則贈與稅租稅債權之及時具體有效實現，更是高度依賴納稅義務人之儘速主動履行誠實申報繳納義務。是以，「贈與稅未依限申報、漏報、短報或隱匿不報者，現行條文第44

01 條至第46條已有處罰規定」（遺贈稅法第10條第1項立
02 法意旨參照）。就其中「未依限申報」之處罰，即按同
03 法第44條規定：「納稅義務人違反……第24條規定，未
04 依限辦理……贈與稅申報者，按核定應納稅額加處2倍
05 以下之罰鍰。」其立法意旨係基於輕稅重罰原則、督促
06 人民自動申報、防堵逾期不申報及長期或永久不申報，
07 以達租稅公平（參立法院公報第62卷第37期委員會紀錄
08 第45至46頁）。

09 (6). 再者，依遺贈稅法第24條第1項規定，贈與人在1年內贈
10 與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅
11 額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與
12 稅申報。本件依實質之經濟利益歸屬判斷贈與關係，應
13 以104年4月2日為贈與日，贈與人應於30日內申報，其
14 規定申報期間屆滿日為104年5月4日（104年5月2日為星
15 期六，申報期間屆滿日應為104年5月4日），倘申報期
16 間屆滿，惟贈與人未為申報，即屬未在規定期間內申報
17 贈與稅者（最高行政法院110年度上字第256號判決意旨
18 參照）。

19 (7). 另查，傅阿妹及曾盛斌等4人於105年3月24日向桃園分
20 局詢問渠等與曾水宣間就系爭股票移轉有無遺產稅及贈
21 與稅疑義，經桃園分局以105年4月7日北區國稅桃園營
22 字第1050205557號函復表明：傅阿妹移轉系爭股票予曾
23 盛斌等4人之行為涉有贈與，請儘速申報贈與稅，倘本
24 案於申報前業經檢舉或調查，仍應依遺贈稅法第44條規
25 定處罰等旨在案。並且，前開桃園分局105年4月7日函
26 文亦於105年4月11日合法送達傅阿妹等人（送達證書等
27 參原處分卷第44至37頁）。是認，經由被告前述105年4
28 月7日函之明確告知，傅阿妹等人就本件必須主動辦理
29 申報繳納贈與稅，若不為申報將受有遺贈稅法第44條規
30 定之處罰等公法義務，自難諉為不知；然而，傅阿妹始
31 終並未申報本件贈與稅。又傅阿妹就自己經被告通知後

01 仍未申報本件贈與稅等違章情事，亦難諉為不知。嗣10
02 6年7月25日桃園分局乃依查得資料，對傅阿妹核定補徵
03 本件贈與稅，並按遺贈稅法第44條規定為處罰，相關核
04 定通知及裁處書等亦經合法送達在案（裁處書等參原處
05 分卷第95至87頁）。

06 (8). 綜言之，本件贈與人傅阿妹應依遺贈稅法第24條第1項
07 期限規定辦理贈與稅申報，惟申報期間於104年5月4日
08 屆滿之後，甚至桃園分局105年4月7日函已明確告知本
09 件必須申報贈與稅，惟傅阿妹雖已知悉其依法申報義務
10 並未獲有解免，卻仍長期甚至始終不為本件贈與稅之申
11 報，則被告本件認贈與人傅阿妹「未依限申報」贈與稅
12 之違章，係具備故意過失主觀責任要件，乃按遺贈稅法
13 第44條「納稅義務人違反第24條規定，未依限辦理贈與
14 稅申報者，按核定應納稅額加處2倍以下之罰鍰」，並
15 按行政罰法第7條第1項等規定為準據，對本件贈與人傅
16 阿妹裁處罰鍰，經核於法並無不合。從而，本件原告主
17 張消極不申報不應處罰云云，係有誤會，尚難憑採。至
18 於原告所稱本件不履行贈與稅申報義務並無故意過失云
19 云，與事實不相符合，亦難憑採。

20 (9). 然按納保法第7條第10項規定：「本法施行前之租稅規
21 避案件，依各稅法規定……已裁罰尚未確定者，其處罰
22 金額最高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額。但
23 有第8項但書情形者，不適用之。」揆其意旨，係就納
24 保法發布施行前，因租稅規避衍生違章情節，已依其他
25 各稅法規定為裁罰但尚未確定者，則於納保法發布施行
26 以後，其他各稅法與納保法關於處罰規定，其間如何調
27 合以消弭紛歧，而為過渡性條款。雖然，本件於被告進
28 行課稅調查時，納稅義務人未對重要事項隱匿或為虛偽
29 不實陳述或提供不正確資料，尚無納保法第7條第8項但
30 書情形，即無同法條第10項但書不設罰鍰上限之適用；
31 惟者，因本件未依限申報贈與稅之違章，源自納稅義務

人之租稅規避，係「納保法施行前之租稅規避案件，依各稅法（註：本件係依遺贈稅法第44條）規定，已裁罰尚未確定者」，應認有上引納保法第7條第10項本文「其處罰金額最高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額」之處罰上限適用。則原告主張本件並無納保法第7條第10項之適用餘地云云，容有誤會，亦難憑採。

3. 本件適用納保法第7條第10項本文所定「處罰金額最高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額」，茲分述如下：

(1). 就滯納金之金額計算而言（參本院卷第63頁），被告核定本件應補繳稅款為17,503,216元，已如上述。按納保法第7條第7項規定，滯納金係按應補繳稅款15%計算，則本件所涉滯納金金額係2,625,482元（應補繳稅款17,503,216元 $\times$ 15%）。

(2). 再就利息之金額計算而言（參本院卷第63頁），按納保法第7條第7項規定，計息期間為應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止。又本件贈與日係104年4月2日，贈與人應於30日內申報，贈與稅申報期間為104年4月3日至104年5月2日（104年5月2日為星期六，其申報期間屆滿日應為104年5月4日）。再者，本件稅額及罰鍰填單日為106年7月5日（該日北區國稅桃園營字第1061111474號函等參見原處分卷第80至72頁），可知本件利息計算之起日（申報期間屆滿之次日）為104年5月5日，且利息計算之迄日為稅捐機關填單日106年7月5日。再因104年度、105年度、106年度之1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率分別為1.37%、1.20%、1.04%（參見本院卷第65頁），則104年度、105年度、106年度之利息分別為15,329元（應補繳稅款17,503,216元 $\times$ 年利率1.37% $\times$ 241日 $\div$ 365日）、210,038元（17,503,216元 $\times$ 1.20% $\times$ 365日 $\div$ 365日）、92,762元（17,503,216元 $\times$ 1.04% $\times$ 186日 $\div$ 365

日），其等合計即為461,129元（158,329+210,038+92,762）。

(3). 綜上言之，被告本件所處罰鍰，不得逾越上述滯納金及利息二者總額3,086,611元（滯納金2,625,482元+利息461,129元），始能無違納保法第7條第7項、同法條第10項本文等規定意旨。

4. 違章者死亡前已作成之裁罰處分，不因違章者死亡影響原裁罰處分之效力，僅將擔保該裁罰金額實現之責任財產，限於違章者之遺產：

(1). 按「行政罰鍰係人民違反行政法上義務，經行政機關課予一定金錢之行政處分。行政罰鍰之科處，係對受處分人之違規行為加以處罰，若處分作成前，違規行為人死亡者，受處分之主體已不存在……且對已死亡者再作懲罰性處分，已無實質意義，自不應再行科處。……罰鍰處分後，義務人未繳納前死亡者，其罰鍰繳納義務具有一身專屬性，至是否得對遺產執行，於法律有特別規定者，從其規定。……行政執行法第2條規定：『本法所稱行政執行，指公法上金錢給付義務、行為或不行為義務之強制執行及即時執行』、第15條規定：『義務人死亡遺有財產者，行政執行處得逕對其遺產強制執行』，行政執行法施行細則基於該法第43條之授權，於第2條規定：『本法第2條所稱公法上金錢給付義務如下：……二、罰鍰……』，明定為公法上金錢給付義務之一種……故依現行法規定，罰鍰之處分作成而具執行力後，義務人死亡並遺有財產者，依上開行政執行法第15條規定意旨，該基於罰鍰處分所發生之公法上金錢給付義務，得為強制執行……罰鍰處分生效後、繳納前，受處分人死亡而遺有財產者，依行政執行法第15條規定，該遺產既得由行政執行處強制執行，致對其繼承人依民法第1148條規定所得繼承之遺產，有所限制，自應許繼承人以利害關係人身分提起或續行行政救濟（訴願法第1

01 4條第2項、第18條、行政訴訟法第4條第3項、第186條，
02 民事訴訟法第168條及第176條等參照……」業經司法院
03 釋字第621號理由書闡述甚明。是在違章者死亡前，未作
04 成裁罰者，固不得於違章者死亡後再行裁罰。惟若違章
05 者死亡前已作成之裁罰處分，則不因違章者死亡影響原
06 裁罰處分之效力，僅將擔保該裁罰金額實現之責任財
07 產，限於違章者之遺產（最高行政法院97年度判字第268
08 號判決、103年度判字第328號判決意旨參照）。

09 (2). 次按罰鍰處分生效後，在相對人不自動履行該金錢給付
10 義務時，通常行政機關即得依行政執行法等相關規定，
11 以強制手段使其履行義務，此即罰鍰處分之執行力。又
12 依稅捐稽徵法第49條準用同法第39條第1項規定：「納稅
13 義務人應納稅捐，於繳納期間屆滿30日後仍未繳納者，
14 由稅捐稽徵機關移送強制執行。但納稅義務人已依第35
15 條規定申請復查者，暫緩移送強制執行。」第50條之2規
16 定：「依本法或稅法規定應處罰鍰者，由主管稽徵機關
17 處分之……受處分人如有不服，應依行政救濟程序辦
18 理。但在行政救濟程序終結前，免依本法第39條規定予
19 以強制執行。」等旨，稅捐稽徵法第50條之2既規定稅捐
20 罰鍰處分，「於行政救濟程序終結前」，免依稅捐稽徵
21 法第39條關於「納稅義務人於繳納期間屆滿30日後仍未
22 繳納者，移送強制執行」之規定，可知其本質上屬一
23 「暫緩」移送強制執行之規定，「並非」終局不得執行
24 （最高行政法院103年度判字第328號判決意旨參照）。

25 (3). 是以，無論依稅捐稽徵法、行政訴訟法、行政執行法之
26 規定，均認罰鍰處分於提起行政救濟時均已生執行力，
27 依上開司法院釋字第621號解釋意旨，自得為強制執行。
28 原告曲解司法院上開解釋意旨，誤以已作成之裁罰處分
29 會因受處分人死亡，而在實體法上失其規制效力；逕而
30 主張行政罰鍰裁處尚未確定前，義務人死亡，原裁處目
31 的已無法達成，喪失繼續存在之意義，且罰鍰無確定之

可能云云，亦係原告對法律規定有所誤解，洵屬無據
（最高行政法院103年度判字第328號判決意旨參照）。

（四）從而，本件罰鍰爭議涉及納保法106年12月28日施行以前已
按遺贈稅法第44條裁罰，迄今尚未確定之租稅規避案件，復
因本件並無納保法第7條第8項但書情形，自應適用同法條第
10項本文規定，裁罰金額最高不得超過同法條第7項所定滯
納金及利息之總額。則被告本件所處罰鍰應以滯納金2,625,
482元，及利息461,129元，其二者之總額3,086,611元為
限，被告所處罰鍰逾越3,086,611元部分，應予以撤銷，始
符納保法第7條第10項本文之規定（最高行政法院109年度判
字第360號判決意旨參照）。

（五）是以，本件未依規定辦理贈與稅申報，構成違章事實，並有
主觀責任要件，應依遺贈稅法第44條規定裁處罰鍰，均如上
述。次按稅務違章案件減免處罰標準第13條第2款規定：

「依遺產及贈與稅法第44條規定應處罰鍰案件，有下列情事
之一者，免予處罰：……二、未依限辦理贈與稅申報，經核
定應納稅額在新臺幣10,000元以下。」基於本件核定應納稅
額17,503,216元，顯然超過10,000元，並無前開免予處罰規
定之適用，自應受罰。被告原核定依遺贈稅法第44條規定，
按應納稅額處0.5倍罰鍰計8,751,608元，嗣復查決定考量贈
與人對系爭股票移轉之課稅問題已主動向原處分機關申請釋
疑並檢附相關事證供參，其雖經通知仍未為補申報，然衡酌
其主觀可責性顯較一般違章情節為輕，爰參酌裁罰金額倍數
參考表使用須知第4點，酌予減輕裁罰，改按應納稅額17,50
3,216元處0.2倍罰鍰3,500,643元（17,503,216×0.2），則
前述罰鍰未逾3,086,611元部分，核係已考量本件違章情
節，於法尚無不合。

七、綜上所述，本件罰鍰逾3,086,611元部分，違反納保法第7條
第10項本文規定，復查決定及訴願決定就此部分未予糾正，
即有未洽，是原告訴請撤銷訴願決定、復查決定及原核定有
關罰鍰逾3,086,611元部分，為有理由，應予准許。至於本

件裁處罰鍰3,086,611元部分，並未超過納保法第7條第10項
本文所定上限，於法即無不合，復查決定及訴願決定遞予維
持，亦無不合，原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回，爰判
決如主文。

八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐
一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴
訟法第104條、民事訴訟法第79條、第85條第1項前段，判決如主
文。

中 華 民 國 111 年 12 月 22 日

臺北高等行政法院第五庭

審判長法 官 陳心弘

法 官 林妙黛

法 官 畢乃俊

一、上為正本係照原本作成。

二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判
決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴
訟法第241條之1第1項前段）

四、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同
條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟 代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一 者，得不委任律師 為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資 格或為教育部審定合格之大學或獨 立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代 理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代 理人具備專利師資格或依法得為專

01

	利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02

中 華 民 國 111 年 12 月 22 日

03

書記官 李依穎

臺北高等行政法院判決

107年度訴字第1639號

) FKT64W1Z1X5L0;@108年4月11日 辯

原告 傅阿妹

訴訟代理人 王鴻珣 律師

被告 財政部北區國稅局

代表人 王綉忠

訴訟代理人 徐慧茹

上列當事人間贈與稅事件，原告不服財政部中華民國107年11月2日發文字號台財法字第10713930320號（案號：第00000000號）訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分（即復查決定）關於罰鍰不利於原告之部分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告於民國102年9月2日自配偶曾水宣受贈取得葡萄王生技股份有限公司股票1,201,574股（下稱系爭股票），並於102年9月5日辦竣股票過戶登記。曾水宣嗣於103年8月26日死亡，原告與其子曾盛斌、曾盛肇、曾盛誌及曾盛瑞4人（下稱曾盛斌等4人）則於104年4月2日簽訂「解除贈與契約暨遺產分割協議書」（下稱解除贈與暨分割協議書），將系爭股票轉回曾水宣名下證券帳戶，由曾盛斌等4人以繼承方式取得系爭股票。經被告審認原告對系爭股票並無贈與之法定撤銷權，原告將系爭股票移轉予曾盛斌等4人，符合遺產及贈與稅法（下稱遺贈稅法）第4條第2項所定贈與要

件，惟未依同法第24條規定申報贈與稅，乃以渠等合意移轉股票日（104年4月2日）之收盤價每股新臺幣（下同）147.5元，核定贈與總額177,232,165元（147.5元×1,201,574股），應納稅額17,503,216元（下稱原核定），並按應納稅額處以0.5倍罰鍰8,751,608元。原告不服，申請復查，經被告107年5月3日北區國稅法二字第1070006298號復查決定（下稱原處分），追減罰鍰5,250,965元（即改按應納稅額處以0.2倍之罰鍰3,500,643元），其餘復查駁回。原告仍不服，提起訴願復經決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、原告主張：

（一）本稅部分：被繼承人曾水宣生前已明確表示，系爭股票將來均由曾盛斌等4人依法繼承，系爭股票係伊擅自以贈與原因過戶給自己，曾盛斌等4人因對伊與曾水宣就系爭股票曾否訂定贈與契約存有爭議，乃要求伊返還系爭股票作為曾水宣之遺產，伊為免母子對簿公堂，於104年4月2日與曾盛斌等4人簽訂解除贈與暨分割協議，惟伊事後未依約履行，曾盛斌等4人遂向臺灣桃園地方法院（下稱桃園地院）聲請調解，伊與曾盛斌等4人嗣成立調解，即該法院104年度司桃調字第144號調解筆錄（下稱桃園地院調解筆錄），伊同意將系爭股票回復原狀返還為曾水宣之遺產，再由曾盛斌等4人繼承。故上開解除贈與暨分割協議書，係伊與曾盛斌等4人合意解除曾水宣與伊所訂系爭股票贈與契約，將系爭股票返還納入曾水宣之遺產，該協議並經桃園地院調解筆錄確認，本院92年度訴字第2362號判決亦肯認類此協議之效力。故就系爭股票之整體變動過程觀察，伊與曾盛斌等4人對於系爭股票完全欠缺贈與及允受贈與之意思表示，曾盛斌等4人係依據與伊就曾水宣之遺產所訂分割協議，依法繼承系爭股票，非

來自於伊之贈與，自不該當民法上之贈與行為，且與民法第408條、第416條所定贈與之法定撤銷權無關，依稅法附從性原則，本件自不應核課贈與稅。況且，伊就系爭股票業已繳納遺產稅，被告復就系爭股票核課贈與稅，顯有重複課稅之不當。再者，伊為免親屬間之遺產爭議必須經由訴訟及法院判決解決，而選擇由法院成立調解，被告竟認定該調解內容構成贈與，應核課贈與稅，無異要求親屬必須透過法院解決紛爭，有違一般人民倫理觀念，既不公平且非合理。

(二) 罰鍰部分：伊主觀上係依上開桃園地院調解筆錄內容，將系爭股票回復原狀歸還曾水宣，並不涉及贈與，故非為逃避稅捐而不申報贈與稅，亦無對被告隱瞞或故意提供不實資料等違反協力義務行為。況且，伊國小未畢業，亦不識字，對於國家稅捐相關法律規定，實無能力理解，雖與么子曾盛瑞同住，但曾盛瑞因罹患小兒麻痺而智能不足，無法協助處理稅務事項，乃委由代書處理，惟代書未將被告諭知系爭股票辦理移轉登記後不得撤銷贈與，及應申報贈與稅之事轉告伊，致伊未能依被告要求申報贈與稅，考量伊之學識狀況及本案之專業性、特殊性，伊之可責性應甚低，被告應審酌伊及子女過往無違章逃漏稅情形，予以免罰。退萬步言，縱認伊應受處罰，惟伊係因不知法律而誤觸章典，與規避租稅之納稅義務人相較，惡意顯然更低，基於舉重以明輕之法理，縱應對伊裁處罰鍰，其總額亦不應高於納稅者權利保護法（下稱納保法）第7條第10項，就該法施行前已發生，惟裁罰尚未確定之租稅規避案件所定罰鍰，即最高不得超過同條第7項規定，按應補繳稅額加徵15%滯納金及利息之總額，是被告所處罰鍰數額，明顯過高，自屬違誤。

(三) 並聲明：訴願決定及原處分不利於原告之部分均撤銷。

01 三、被告抗辯：

02 (一)本稅部分：原告於102年9月2日自曾水宣受贈取得系爭股票
03 ，並於同年月5日辦竣過戶登記，且於持有期間獲配股利，
04 是系爭股票已屬原告所有，依財政部80年1月31日台財稅第0
05 00000000號函及92年10月17日台財稅字第0920456222號函意
06 旨，自不得申請撤銷贈與。另原告於復查及訴願階段，自承
07 係因維持家庭和諧，於104年4月2日與曾盛斌等4人簽訂解除
08 贈與暨分割協議書，故曾水宣將系爭股票贈與原告之行為，
09 不符民法第417條所定撤銷贈與事由，原告與曾盛斌等4人皆
10 無法定撤銷權，原告不得於受贈系爭股票後，再以該贈與契
11 約業經合意解除並回復登記予被繼承人為由，使曾盛斌等4
12 人以繼承名義無償取得系爭股票。本院92年度訴字第2362號
13 判決，案情係贈與標的尚未辦妥所有權移轉登記前，受贈人
14 與贈與人之繼承人雙方合意解除贈與契約，並共同申請撤銷
15 贈與稅申報，與本案贈與標的業於申報贈與稅後完成移轉過
16 戶登記者，並不相同，且該判決並非判例，僅具個案拘束力
17 ，尚不得比附援引。又桃園地院調解筆錄內容，係督促原告
18 履行解除贈與暨分割協議書內容，該法院未就當事人是否具
19 備解除贈與契約之權利為實質審查，原告執以主張系爭股票
20 非屬其財產，而係曾水宣死亡時所遺應繼財產，曾盛斌等4
21 人得依解除贈與暨分割協議書以繼承取得，自非可採。至系
22 爭股票核課遺產稅，乃因曾水宣係於其死亡前2年內將系爭
23 股票贈與原告，依法應擬制為曾水宣遺產之故，惟因係曾水
24 宣與原告夫妻間之贈與，故於贈與當時免課徵贈與稅，二者
25 間並無以稅減稅之問題。另本件為原告贈與系爭股票予曾盛
26 斌等4人，與曾水宣前將系爭股票贈與原告者，贈與主體不
27 同，並無重複課稅問題。是以，被告認定原告係將系爭股票

無償移轉予曾盛斌等4人，屬遺贈稅法第4條第2項規定之贈與，依渠等合意移轉股票日之收盤價，依法課徵贈與稅，並無不合。

(二)罰鍰部分：原告及曾盛斌等4人曾於105年3月24日向被告所屬桃園分局（下稱桃園分局）詢問渠等與被繼承人曾水宣間就系爭股票移轉有無遺產稅及贈與稅疑義，經該分局於105年4月7日函復，原告移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為涉有贈與，請盡速申報贈與稅，倘申報前經檢舉或調查，仍應依遺贈稅法第44條規定處罰，惟原告迄未依規定辦理贈與稅申報，核有應注意、能注意而未注意之過失，且無稅務違章案件減免處罰標準第13條之適用，自應受罰。被告考量原告對系爭股票移轉之課稅問題已主動申請釋疑並檢附相關事證供參，其雖經通知仍未為補申報，然其主觀可責性顯較一般違章情節為輕，依據納保法規定，並參酌稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表使用須知第4點，酌予從輕改按應納稅額17,503,216元處0.2倍罰鍰3,500,643元，已考量原告違章情節而為適切裁罰。又原告未依規定辦理贈與稅申報，非屬納保法第7條所定租稅規避，故無同條第10項前段規定之適用，被告依遺贈稅法第44條規定，處以漏稅罰，並無違誤。

(三)並聲明：駁回原告之訴。

四、如事實概要欄所載之事實，有贈與契約書、贈與稅申報書、贈與稅不計入贈與稅總額證明書、解除贈與暨分割協議書、桃園地院調解筆錄、遺產稅繳清證明書、核定通知書、裁處書、原處分書及訴願決定書，附原處分卷第17、22至23、36、32至34、30至31、35、88至89、72、386至394及534至549頁可稽，且為兩造所不爭執，堪信為真實。

五、經核本件爭點為：被告審認原告將系爭股票移轉予曾盛斌等

4人，符合遺贈稅法第4條第2項所定贈與要件，惟未依同法第24條規定申報贈與稅，按渠等合意移轉系爭股票日之收盤價，核定原告贈與總額177,232,165元，應納稅額17,503,216元，並按應納稅額處以0.2倍罰鍰3,500,643元，有無違法？經查：

(一)應適用之法令：

1.遺贈稅法第3條第1項規定：「凡經常居住中華民國境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。」第4條第1項、第2項規定：「（第1項）本法稱財產，指動產、不動產及其他一切有財產價值之權利。（第2項）本法稱贈與，指財產所有人以自己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為。」第7條第1項前段規定：「贈與稅之納稅義務人為贈與人。……。」第10條第1項規定：「遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；……。」第24條第1項規定：「除第20條所規定之贈與外，贈與人在1年內贈與他人之財產總值超過贈與稅免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生後30日內，向主管稽徵機關依本法規定辦理贈與稅申報。」第44條規定：「納稅義務人違反……第24條規定，未依限辦理……贈與稅申報者，按核定應納稅額加處2倍以下之罰鍰。」同法施行細則第28條第1項規定：「凡已在證券交易所上市（以下簡稱上市）或證券商營業處所買賣（以下簡稱上櫃或興櫃）之有價證券，依繼承開始日或贈與日該項上市或上櫃有價證券之收盤價或興櫃股票之當日加權平均成交價估定之……。」

2.稅捐稽徵法第12條之1第1至3項規定：「（第1項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法

律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。（第3項）納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。」租稅規避行為因有違租稅公平原則，故於效果上，應本於實質課稅原則，就其事實上予以規避，然卻與其經濟實質相當之法律形式作為課稅之基礎。

3. 納保法第7條第3項、第8項規定：「（第3項）納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。……（第8項）第三項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。」其立法意旨明揭：「納稅者不選擇稅法上通常之法律形式，卻以取巧方式、迂迴行為或非常規之法律形式，以避免稅捐構成要件的滿足，而減輕其稅負。此情形即屬故意濫用法律形式，規避稅捐之行為，並無值得保護之信賴利益，仍應本於實質課稅原則加以調整補稅。……稅捐規避雖非屬違法行為，而與違背稅法上誠實義務之逃漏稅違法行為有間，但性質上屬於鑽法律漏洞之脫法行為。於法理上亦無容許納稅者得主張其脫法行為，以獲取實質經濟利益之可能，主管機關應依處罰法定原則進行調整補稅。……惟若納稅者於稅捐申報或於主管機關進行課稅調查

時，隱匿事實、為虛偽不實陳述或提供不正確資料等行為，致使主管機關陷於錯誤之虞，因而短漏核定稅捐者，應予裁處漏稅之罰鍰。」是前揭納保法條文，雖於106年12月28日起生效，惟其規定其實為名詞解釋性立法，就現行租稅稽徵上關於租稅規避、租稅逃漏等名詞，予以定義性規定而已，並未變更現行稅法上納稅者之權利義務，自得於本案中予以適用，無待於法規生效後始得援用。

(二)經查：

- 1.原告之配偶曾水宣於生前委由代理人檢附其與原告於102年9月2日就系爭股票所訂贈與契約書，及其2人於凱基證券股份有限公司（下稱凱基公司）所開設證券帳戶存摺影本，於同年月3日向桃園分局辦理贈與稅申報，經被告核發贈與稅不計入贈與總額證明書後，於同年月5日辦竣系爭股票由曾水宣過戶予原告事宜。曾水宣嗣於103年8月26日死亡，原告與其子曾盛斌等4人先於104年4月2日簽訂解除贈與暨分割協議書，其第2、3條約定：原告與曾盛斌等4人合意解除曾水宣與原告前就系爭股票所訂贈與契約，原告於即日起無條件全數返還系爭股票並納入曾水宣之遺產；原告與曾盛斌等4人同意，系爭股票由曾盛斌等4人平均各4分之1繼承之。曾盛斌等4人繼而以原告為相對人，向桃園地院聲請調解，於104年7月30日成立內容為：原告願依上開解除贈與暨分割協議書，將系爭股票移轉予曾盛斌、曾盛肇各300,394股，另移轉予曾盛誌、曾盛瑞各300,393股之調解後，由原告於104年11月13日將系爭股票轉回曾水宣帳戶，再於104年11月30日依調解筆錄所載股數，分別轉入曾盛斌等4人帳戶等情，有贈與契約書、贈與稅申報書、曾水宣及原告於凱基公司所開設帳戶之證券存摺、贈與稅不計入贈與稅總額證明書、解除

贈與暨分割協議書、桃園地院調解筆錄及曾盛斌等4人於105年4月19日所具說明書，附原處分卷第22、23、27、29、30至34、36、54至56頁可稽。

2. 依1.所述，可知系爭股票業由曾水宣於生前贈與原告，並於102年9月5日過戶為原告所有，原告與曾盛斌等4人於曾水宣死亡後，卻先簽訂解除贈與暨分割協議，約定將曾水宣業已履行完畢之贈與契約解除，由原告將系爭股票返還回復為曾水宣遺產，另協議系爭股票由曾盛斌等4人取得，繼而於桃園地院成立調解，原告同意依上開協議內容，將系爭股票移轉予曾盛斌等4人，渠等5人以上行為之目的為何，殊值存疑。原告就此雖主張：曾水宣生前曾明確表示，系爭股票將來均由曾盛斌等4人依法繼承，系爭股票乃伊擅自過戶至自己名下，嗣因曾盛斌等4人對伊與曾水宣曾否訂定贈與契約有所爭議，伊為免母子對簿公堂，而於104年4月2日與曾盛斌等4人簽訂解除贈與暨分割協議，同意將系爭股票回復原狀返還為曾水宣之遺產，再由曾盛斌等4人繼承，惟伊事後未依約履行，曾盛斌等4人因而又向桃園地院聲請調解，伊與曾盛斌等4人嗣成立調解，同意依上開解除贈與暨分割協議履行云云。惟由原告對原核定申請復查後，向被告提出之陳報書中，自承其證券存摺平常由其自行保管，每上、下半年度會例行性地請曾水宣或子女代為補登，103年1月6日、103年9月18日、104年1月8日、104年11月15日均曾為例行性補登餘額等情（參見原處分卷第232、233頁）觀之，曾盛斌等4人在系爭股票由原告受贈取得，並於102年9月5日完成過戶手續後之103年1月6日，既曾代原告補登證券存摺，於斯時自己知悉系爭股票業經曾水宣贈與原告，並移轉贈與物權利完畢之事。復參諸原告與曾盛斌等4人於103年11月27日（被

告收文日期)共同辦理遺產稅申報時，於申報書內係自行將系爭股票列為曾水宣死亡前2年贈與之財產(參見原處分卷第143至151頁之遺產稅申報書)，益見曾盛斌等4人對系爭股票業由曾水宣於死亡前2年贈與原告並過戶為原告所有之事，非但知悉，且無爭執。至原告所稱：曾水宣生前曾表示系爭股票應由曾盛斌等4人依法繼承，惟伊擅自將系爭股票過戶至自己名下，曾盛斌等4人嗣後對曾水宣有無贈與系爭股票予伊有所爭議，伊為免母子對簿公堂，始與曾盛斌等4人簽訂解除贈與暨分割協議及成立調解云云，未據原告提出任何證據以實其說，且與曾盛斌等4人至遲於103年1月6日即知悉原告已受贈取得系爭股票所有權，惟於時隔10個月餘後申報遺產稅時，就此均無任何爭執之情，顯不相符；另觀諸原告與曾盛斌等4人所訂解除贈與暨分割協議書，及曾盛斌等4人向桃園地院聲請調解時，提出之民事聲請調解狀及所附證物即存證信函(參見原處分卷第304至309頁)，亦無任何有關原告與曾盛斌等4人曾因曾水宣是否贈與系爭股票予原告一事，發生爭議之記載，是原告所述上情，因乏證據可佐，尚難遽予採信。

3.再查：

- (1)原告既於102年9月5日已取得系爭股票之所有權，則系爭股票嗣後若由原告無償移轉予曾盛斌等4人，即該當遺贈稅法第4條第2項所定贈與，依同法第7條第1項前段規定，原告負有繳納贈與稅之義務。然渠等經由上述一連串安排，使原告因受贈自曾水宣而取得所有權之系爭股票，得以該贈與契約業經曾水宣全體繼承人合意解除，原告應負回復原狀責任為由，先回復至曾水宣名下，具有為曾水宣遺產之外觀，原告與曾盛斌等4人進而得以協議分割遺產為名，使曾盛斌等4人

以繼承曾水宣遺產之名義，取得系爭股票，原告亦因此無須負擔系爭股票由其直接無償移轉予曾盛斌等4人時，應納之贈與稅。參諸曾水宣於102年9月3日辦理系爭股票贈與原告之贈與稅申報時，列報之贈與總額為159,208,555元（參見原處分卷第22頁）、原告與曾盛斌等4人於103年11月27日申報遺產稅，經被告核定之系爭股票遺產價額為158,006,981元（參見原處分卷第35頁），另葡萄王生技股份有限公司股票於104年4月1日至30日之收盤價最低為138元（參見原處分卷第11頁），依系爭股票股數計算之價值為165,817,212元（138元×1,201,574股），足見原告如直接贈與系爭股票予曾盛斌等4人，就扣除遺贈稅法第22條所定220萬元免稅額後之課稅贈與淨額，必須負擔依同法第19條第1項所定稅率計算之高達上千萬元贈與稅，由此不難想見原告與曾盛斌等4人原本對曾水宣生前贈與系爭股票予原告並無異議，其後卻執意將曾水宣已移轉至原告名下而履行完畢之贈與契約效力解消，係出於規避高額稅負之動機。是以，原告係透過與曾盛斌等4人以締結解除贈與暨分割協議及成立調解等非通常之法律形式，將其前因受贈而取得所有權之系爭股票，無償移轉至曾盛斌等4人名下，達成贈與之實質經濟效果，並規避贈與稅構成要件之該當，所為核屬稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第7條第3項所稱租稅規避，揆諸前揭說明，稅捐稽徵機關於此際應本於實質課稅原則，就原告事實上予以規避，然與其經濟實質相當之法形式（即贈與）作為課稅之基礎。

- (2) 被告雖將上開解除贈與暨分割協議書，解為係原告與曾盛斌等4人依民法第417條前段規定，撤銷曾水宣生前與原告就系爭股票所訂贈與契約，進而認定原告與曾盛斌等4人不具有

前揭民法條文所定撤銷權，無從藉由訂定上開協議，使原告業經受贈取得所有權之系爭股票，回復至曾水宣名下，再由曾盛斌等4人以繼承名義取得，故原告實係將系爭股票無償移轉予曾盛斌等4人，涉及贈與情事，非屬租稅規避。惟觀諸上開解除契約暨分割協議書，係約定由原告與曾盛斌等4人合意解除系爭股票贈與契約，其內容並無一語提及其5人係因民法第417條前段所定情形（即受贈人因故意不法行為，致贈與人死亡或妨礙其為贈與之撤銷），而以曾水宣繼承人身分撤銷贈與，被告稱原告與曾盛斌等4人係以上開協議書，行使民法第417條前段所定贈與撤銷權云云，與該協議書之文義不符，已難採取。再者，被告未慮及原告與曾盛斌等4人係利用訂定上開協議書及至法院成立調解之手法，製造系爭股票為曾水宣遺產，由曾盛斌等4人依繼承法律關係而取得之形式外觀，達成由原告贈與系爭股票予曾盛斌等4人之實質上經濟效果，並規避贈與稅構成要件之該當，業已構成租稅規避之情，逕認系爭股票係由原告直接贈與曾盛斌等4人，法律涵攝亦非妥洽。然因被告對於原告上開規避租稅行為，應根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，且觀諸原告與曾盛斌等4人於104年4月2日所訂解除贈與暨分割協議書第2、3條，約明原告於該日將系爭股票返還納入曾水宣之遺產，由曾盛斌等4人各取得4分之1等情，堪認原告於該訂約日已為贈與系爭股票之意思，並為曾盛斌等4人於同日允受，則被告應依遺贈稅第10條第1項規定，按該日之時價計算系爭股票價值，對原告核課贈與稅。而被告確係以原告與曾盛斌等4人於104年4月2日訂定上開協議書，達成移轉系爭股票之合意，依該日系爭股票之收盤價147.5元（參見原處分卷第11頁），核定原告贈與總額177,232

01 ,165元 (147.5元 × 1,201,574) , 贈與淨額 175,032,165元
02 , 應納贈與稅額 17,503,216元 , 則其核定原告應納上述稅額
03 之結論 , 經核尚無不合。

04 4.原告雖主張：伊與曾盛斌等4人所訂解除贈與暨分割協議書
05 , 業經桃園地院調解筆錄確認 , 本院 92年度訴字第 2362號判
06 決亦肯認類此協議之效力 , 故曾盛斌等4人係依遺產分割協
07 議 , 依法繼承系爭股票 , 非由伊贈與而取得 , 被告竟認定上
08 開業經法院調解成立之協議內容構成贈與 , 應核課贈與稅 ,
09 無異要求親屬間關於遺產所生爭議 , 一律必須透過法院以訴
10 訟及判決方式解決紛爭 , 有違一般人民倫理觀念 , 既不公平
11 且非合理。況且 , 伊就系爭股票業已繳納遺產稅 , 被告復就
12 系爭股票核課贈與稅 , 顯有重複課稅之不當云云。惟查：

13 (1)本院 92年度訴字第 2362號判決 , 所涉情節為該案原告甲之夫
14 (即贈與人) , 於生前與甲訂立贈與契約 , 由甲受贈其夫所
15 有之土地 , 並已辦理贈與稅申報 , 獲核發贈與稅不計入贈與
16 總額證明書在案 , 惟甲之夫未辦妥上開贈與土地之所有權移
17 轉登記即死亡 , 甲遂檢附與其他繼承人共同出具之同意撤銷
18 贈與契約書 , 申請撤銷贈與稅申報 , 經本院上開另案判決認
19 為應予准許 , 此與本件原告之配偶曾水宣在生前業依與原告
20 所訂贈與契約 , 將系爭股票移轉為原告所有 , 原告與曾水宣
21 其他繼承人嗣後訂立上開解除贈與暨分割協議書及於法院成
22 立調解 , 意在利用此等法律行為之形式 , 使系爭股票於外觀
23 上回復為曾水宣之遺產 , 得經全體繼承人協議分割後 , 由曾
24 盛斌等4人以繼承之名目取得 , 藉此達成由原告將系爭股票
25 贈與該4人之實質上經濟效果 , 及規避贈與稅構成要件該當
26 等目的 , 並非僅止於將未移轉贈與物權利之贈與撤銷者 , 情
27 形迥異 , 原告執本院就不同情節所為上開另案判決 , 主張曾

01 水宣生前對其贈與系爭股票之契約，業經其與曾盛斌等4人
02 所訂解除贈與暨分割協議書而合意解除，曾盛斌等4人其後
03 係繼承取得系爭股票，即非由其贈與，被告對其補徵贈與稅
04 ，係屬違誤云云，比附援引明顯失據，自非可採。又原告與
05 曾盛斌等4人於桃園地院成立調解之內容，乃原告願依上開
06 解除贈與暨分割協議書，將系爭股票移轉予曾盛斌等4人，
07 該調解筆錄依民事訴訟法第416條第1項及第380條第1項所生
08 與確定判決同一之效力，僅係原告日後如與曾盛斌等4人再
09 因該協議書而涉訟，不得反於上開調解筆錄內容，主張其對
10 曾盛斌等4人不負有移轉系爭股票之義務，至原告與曾盛斌
11 等4人訂定該協議書所欲達成之經濟上實質效果為何，及有
12 無規避稅捐問題，並非該調解事件爭訟之標的，本應由稅捐
13 稽徵機關以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬
14 與享有為依據，予以判斷，則原告另主張其與曾盛斌等4人
15 所訂解除贈與暨分割協議書，業經桃園地院調解筆錄確認，
16 故曾盛斌等4人係依遺產分割協議繼承取得系爭股票，被告
17 認定係由伊贈與而取得，對伊補徵贈與稅，於法有違云云，
18 亦無足取。再依前述，原告與曾盛斌等4人對原告於曾水宣
19 生前業因受贈而取得系爭股票所有權之事，本無爭議，渠等
20 嗣後於法院就上開解除贈與暨分割協議成立調解，意在將系
21 爭股票無償移轉予曾盛斌等4人，及規避贈與稅，非在解決
22 其間關於遺產所生爭議，是原告又稱被告認定上開業經法院
23 調解成立之協議內容構成贈與，應核課贈與稅，無異強求親
24 屬間就遺產所生爭執，一律必須透過法院以訴訟及判決方式
25 解決紛爭，有違一般人民倫理觀念，既不公平且非合理云云
26 ，仍難採憑。

27 (2)復按贈與稅之課徵，係以財產所有人將自己之財產無償給予

他人，經他人允受而生效力之贈與行為作為對象；原告配偶曾水宣生前贈與原告系爭股票，與原告藉由與曾盛斌等4人訂定解除契約暨分割協議書及成立調解等方式，迂迴達成將系爭股票贈與曾盛斌等4人之實質經濟效果之行為，因無償給與財產者與收受者各自有別，應評價為不同之2次贈與行為，均為贈與稅之課徵客體，僅前一贈與行為因係曾水宣與原告之配偶間相互贈與，依遺贈稅法第20條第1項第6款規定，不計入贈與總額課稅而已，惟該次贈與行為，因係曾水宣在死亡前2年內所為，依同法第15條第1項第1款規定：「被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承人之配偶。……。」系爭股票應擬制為曾水宣遺產，課徵遺產稅。是被告將系爭股票計入曾水宣遺產總額課徵遺產稅，及對原告其後透過與曾盛斌等4人訂立協議及成立調解等形式，實質上將系爭股票贈與曾盛斌等4人之結果，核定補徵贈與稅，均係依法所為，並無原告所指重複課稅之問題，原告再指稱：伊就系爭股票已繳納遺產稅，被告復核課贈與稅，顯有重複課稅之不當云云，洵非可採。

(二)末查，原告及曾盛斌等4人在被告於106年7月25日對原告送達原核定通知書（參見原處分卷第95頁），對原告補徵本件贈與稅前，曾於105年3月23日向桃園分局提出申請書，載明其等之被繼承人曾水宣持有系爭股票，於102年9月3日贈與配偶即原告，嗣撤銷贈與並經法院調解成立，回復為曾水宣所有財產，再由曾盛斌等4人以繼承方式取得，系爭股票前經桃園分局認定為贈與但視為遺產，核課遺產稅，並經原告及曾盛斌等4人繳清，請該分局說明渠等與曾水宣間就系爭股票移轉有無應納之遺產稅及贈與稅疑義，經被告於105年4

月7日函復稱：原告移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為涉有贈與，請儘速申報贈與稅，倘本案於申報前業經檢舉或調查，仍應依遺贈稅法第44條規定處罰等語，有申請書及桃園分局105年4月7日北區國稅桃園營字第1050205557號函（下稱被告105年4月7日函），附原處分卷第37至39、43、44頁可稽。另觀諸桃園分局就上開回復原告及曾盛斌等4人所詢事項之函文，於105年4月2日所擬簽呈，載明系爭股票移轉之相關資料中，包括原告與曾盛斌等4人所訂解除贈與暨分割協議書及桃園地院調解筆錄等（參見原處分卷第46頁），顯見原告於被告就其藉由與曾盛斌等4人訂定上開協議及於法院成立調解之形式，無償移轉系爭股票予曾盛斌等4人之行為，根據與實質上經濟利益相當之法律形式即贈與，對其核定補徵贈與稅前，已將系爭股票業經曾水宣於生前贈與且移轉予原告，惟原告及曾盛斌等4人嗣後係經由訂定解除贈與暨分割協議及於桃園地院成立調解等方式，先將系爭股票回復為曾水宣名義，再由曾盛斌等4人以繼承名義取得之過程，對被告完全據實以告。是原告與曾盛斌等4人藉由前述合意解除贈與契約、訂定分割協議及成立調解等法律形式外觀，達成由原告將其所有之系爭股票贈與曾盛斌等4人之實質經濟效果，並規避贈與稅要件之該當，所為固然構成稅捐稽徵法第12條之1第3項及納保法第7條第3項所定租稅規避，惟原告於稅捐申報及被告進行課稅調查時，既無納保法第7條第8項但書所稱對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料之行為，致使主管機關陷於錯誤，因而短漏核定稅捐之情事，則被告除得根據與實質上經濟利益相當之法律形式，對原告補徵贈與稅，並加徵滯納金及利息外，不得另裁處罰鍰。惟被告卻以原告於收受其105年4月7日函後，迄未

辦理贈與稅申報，核有應注意、能注意而未注意之過失，依遺贈稅法第44條規定，先按應納稅額17,503,216元處0.5倍罰鍰，嗣以原處分改按上開應納稅額處0.2倍罰鍰3,500,643元，依上說明，自屬違法，應予撤銷。

六、綜上所述，被告核定原告將系爭股票無償移轉予曾盛斌等4人，應納贈與稅額17,503,216元之結論，並無違誤，訴願決定就此予以維持，核無不合。惟原處分關於裁處原告罰鍰3,500,643元部分，違反納保法第7條第8項規定，訴願決定就該部分未予糾正，即有未洽，原告訴請撤銷，為有理由，應予准許。

七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中華民國 108 年 5 月 2 日

臺北高等行政法院第三庭

審判長法官 李 玉 卿

法官 王 俊 雄

法官 鍾 啟 煒

一、上為正本係照原本作成。

二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段）

四、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟	所需要件
-----------	------

01	代理人之情形	
02		
03	(一)符合右列情形之一	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。
04	者，得不委任律師	2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。
05	為訴訟代理人	3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12	(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
13		2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
14		3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
15		4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	
24		
25		
26		

中華民國 108 年 5 月 2 日

臺北高等行政法院裁定

109年度訴更一字第59號

原告 傅阿妹

訴訟代理人 王鴻珣 律師

被告 財政部北區國稅局

代表人 王綉忠（局長）

訴訟代理人 徐慧茹

上列當事人間因贈與稅事件，前經本院於民國110年4月1日言詞
辯論終結。茲查本案尚有應行調查之處，爰命再開辯論並再行準
備程序，特此裁定。

中華民國 110 年 4 月 23 日

臺北高等行政法院第四庭

審判長法官 楊 得 君

法官 畢 乃 俊

法官 侯 志 融

上為正本係照原本作成。

不得抗告。

中華民國 110 年 4 月 23 日

書記官 徐 偉 倫

臺北高等行政法院判決

108年度訴更一字第70號

112年2月2日辯論終結

原告 大東電業股份有限公司

訴訟代理人 黃合文 律師

施博文 會計師

被告 財政部臺北國稅局

代表人 宋秀玲（局長）

訴訟代理人 鄭錦凰

上列當事人間營利事業所得稅事件，原告不服財政部中華民國107年6月13日台財法字第10613950300號（案號：第10601378號）訴願決定，提起行政訴訟，經本院107年度訴字第978號判決後，最高行政法院發回更審，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

第一審及發回前上訴審訴訟費用均由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

原告起訴時，被告代表人原為局長許慈美，嗣於本件更審訴訟程序進行中，變更為局長宋秀玲，並據其具狀聲明承受訴訟（本院卷一第557-562頁），經核並無不合，應予准許。

貳、實體方面

一、爭訟概要：

原告民國96年度營利事業所得稅結算申報，列報出售資產增益新臺幣（下同）292,077,212元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，被告原核定出售資產增益291,329,025元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，嗣依財政部北區國稅局（下稱北區國稅局）通報，原告短漏報房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元等情，經被告審理結果，重行核定原告96年度出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補

稅額18,766,587元，並按所漏稅額18,766,587元處以1倍罰鍰18,766,587元（下稱原處分，含96年度營利事業所得稅核定稅額繳款書、違章案件罰鍰繳款書、裁處書）。原告不服，申請復查，未獲被告106年9月1日財北國稅法一字第1060034071號復查決定（下稱復查決定）變更，提起訴願，亦遭財政部107年6月13日台財法字第10613950300號（案號：第10601378號）訴願決定駁回（下稱訴願決定），續提行政訴訟，前經本院107年度訴字第978號判決駁回原告之訴（下稱原判決），原告不服，提起上訴，經最高行政法院108年度判字第357號判決將原判決廢棄，發回本院（下稱發回判決）。

二、原告起訴主張及聲明：

（一）主張要旨：

1. 本件交易之經濟活動係因原告之老董事長林德旺過世，原告名下財產為此家族之家產，家族成員欲就財產重新分配，原告名下坐落臺北市○○區○○段0小段384、385-1、385-2地號等3筆土地（應有部分各為936/1000），及其上門牌號碼臺北市○○區○○路0段000號1樓、10樓、地下1樓、203號1至12樓、地下1樓、205號1至10樓、地下1樓房屋（下分稱系爭土地、系爭房屋，合稱系爭房地），依現行法律無法以個人遺產方式為家族成員所繼承、分割，必須透過交易行為，使家族成員取得後，方能進行分配。是本件係因林德旺過世後所衍生繼承而進行「分析家產」，經濟目的在由林志明持有原告股權繼續經營公司，而林銀、駱金生、駱俊銘、姚建安、卓維和、林美櫻、林美娥、林美麗（下稱林銀等8人）家族成員則分得系爭房地，退出原告持股。為達成前述經濟目的，其法律形式之安排，先由原告以「合理價格」將系爭房地出售林志明，再由林志明轉售林銀等8人，由林銀等8人以獲配現金股利及所持公司股權（淨值）作價清償系爭房地之買賣價金，本件交易本質上是「家族析產」，具有「正當合理」之理由，絕無虛偽不實。被告未提出相關證據

01 資料，亦未實質查核，復未依所得稅法第43之1規定，報經
02 財政部核准按營業常規予以調整，即逕援引98年5月13日始
03 增訂之稅捐稽徵法第12條之1規定，採推計課稅方式，認定
04 原告與林志明間就系爭房地之買賣交易，係屬虛偽安排，實
05 際交易對象為林銀等8人，且未就系爭房地另予鑑價，逕將
06 林志明轉售系爭房地予林銀等8人之售價1,074,271,189元，
07 作為原告出售系爭房地之價格，致高估原告出售房地之增
08 益，違反法律不溯及既往原則、行為時營利事業所得稅查核
09 準則（下稱查核準則）第114條第1項及納稅者權利保護法所
10 定之實質課稅原則。

11 2.縱依被告所認定原告實質交易對象為林銀等8人，則原告與
12 林志明間之交易及林志明與林銀等8人間之交易，理應均屬
13 本件系爭房地交易之一部分，自無分割適用所得部分與交易
14 費用部分之理；又所得稅法第38條規定僅規定各種稅法之滯
15 報金、怠報金及各項罰鍰不得列為費用或損失，並未將各項
16 補稅羅列在內，理應得以扣除。是林志明轉售系爭房地予林
17 銀等8人所產生之契稅2,547,576元、登記費125,642元、書
18 狀費2,240元、印花稅267,000元等自應當成為原告之費用；
19 另系爭房地應補繳之營業稅為3,753,317元，罰鍰為5,629,9
20 75元，亦經最高行政法院106年度判字第268號判決確定（本
21 院104年度訴字第1681號營業稅事件）在案，被告於核課本
22 件營利事業所得稅時，卻未將上開稅費予以扣除，違反稅捐
23 稽徵法第12條之1第6項規定，並有稅上加稅之違誤，亦與憲
24 法第15條人民之財產權應予保障之規定不符。

25 3.縱依被告認定本件系爭房地交易屬稅捐規避，其交易價格應
26 以林銀等8人買賣契約書所載價金計算，但因裁罰尚未確
27 定，自有納稅者權利保護法第7條第10項、稅捐稽徵法第48
28 條之3規定、財政部97年3月12日台財稅字第09704513290號
29 函釋之適用，其處罰金額最高自不得逾滯納金及利息之總
30 額。而本件被告按所漏稅額1倍罰鍰18,766,587元，顯已超
31 過納稅者權利義務保護法第7條第10項所定之滯納金上限2,8

14,988元（計算式：18,766,587元×15%=2,814,988元）及利息之總額，實已違法。另原告於97年5月31日前即辦理96年度營利事業所得稅結算申報，核課期間當於102年5月31日屆滿，被告於102年6月方核定本件補稅及裁罰，已逾行為時稅捐稽徵法第21條第2項規定之5年核課期間。

(二)聲明：

訴願決定及原處分（含復查決定）均撤銷。

三、被告答辯及聲明：

(一)答辯要旨：

1.原告銷售系爭房地之對象自始即為林銀等8人，原告乃形式上藉由林志明先低價購入系爭房地，連同林志明繼承取得之臺北市○○區○○段0小段384、385-1、385-2地號土地（應有部分各為64/1000），與坐落其上門牌號碼臺北市○○區○○○路0段000號11樓房屋（下分稱繼承土地、繼承房屋，合稱繼承房地），旋即加價出售予林銀等8人，致數億元之鉅額價差利益流入林志明名下，顯係濫用私法自治之法律形式，被告基於北區國稅局通報之同一漏報營業稅事實，重行核定原告96年度營利事業所得稅出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補稅額18,766,587元，自屬有據。又被告係以林銀等8人買賣契約書所載價金，作為原告實際出售系爭房地之價格，此與納稅義務人未能提示帳簿文據備查，依所得稅法第83條規定，以同業利潤標準核定所得額之情況有別。

2.原告96年度營利事業所得稅結算申報，係屬會計師簽證案件，依簽證報告中出售資產增益之查核報告所載，可知原告就出售系爭房地之成本，已於當年度營利事業所得稅申報時全額列報，並經被告全數核認，自無再次減除之理。另依行為時查核準則第90條第1款規定，依營業稅法第51條、第52條規定追繳或繳納之營業稅，不得列為本事業之費用或損失；同條第6款規定各種法規所科處之罰鍰，不予認定，故原告經北區國稅局核定補徵之營業稅額及所裁處罰鍰，自不

01 得列為費用或損失。再者，原告為系爭房地之出賣人，並非
02 買受人，其負擔之土地增值稅已列報扣除，另其所提繳納契
03 稅、印花稅、登記費、書狀費之憑證上所載納稅義務人並非
04 原告，該等費用自不得減除。

05 3.原告96年度漏報上述出售資產增益及免徵所得稅之出售土地
06 增益，逃漏應繳納之稅賦，違章事證明確，已非單純不作
07 為，核屬故意，且原告未於裁罰處分核定前，以書面或於談
08 話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰，則
09 被告依行為時所得稅法第5條第5項規定之稅率計算核定稅
10 額，再依同法第110條規定，按所漏稅額18,766,587元處以1
11 倍罰鍰18,766,587元，並無違誤。又原告係於97年5月29日
12 以網路辦理96年度營利事業所得稅結算申報，核課期間自其
13 申報日起算至102年5月28日屆滿，被告核定原告短漏報系爭
14 房地交易所得之核定通知書、罰鍰裁處書及繳款書，係於10
15 2年5月7日送達，未逾核課期間。

16 (二)聲明：

17 原告之訴駁回。

18 四、爭點：

19 (一)原告代表人林志明代表原告與自己交易，而低價買入系爭房
20 地；再於短期間內又以自己名義將買入之系爭房地高價出售
21 予林銀等8人，以完成雙方約定之分拆處置原告資產約定，
22 並重新建構股權分配之行為及其結果，是否為稅捐規避？被
23 告以原告96年度營利事業所得稅結算申報，漏報系爭房屋交
24 易所得75,066,349元，核定補徵原告稅額18,766,587元，是
25 否違誤？原告為稅捐規避所支出之各項費用，能否在稅上列
26 為當期費損？

27 (二)原告就前開行為及其結果，是否違反誠實義務，而在客觀上
28 具有違法性，在主觀上具有可責性，而應被處以漏稅行政
29 罰？被告按其所漏稅額18,766,587元處以1倍之罰鍰計18,76
30 6,587元，有無過重之裁量違法？

31 五、本院的判斷：

01 (一)前提事實：

02 上開爭訟概要欄所述之事實，為兩造不爭執，並有北區國稅
03 局102年3月27日北區國稅審二字第1020006211號函（原處分
04 卷第745頁）、林德旺遺產稅核定通知書（原處分卷第730
05 頁）、系爭房地之登記異動索引查詢資料（原處分卷第1097
06 -1132、709-723頁）、原告與林志明96年12月6日簽訂之房
07 屋買賣契約書（原處分卷第655-656頁）、原告之建築物及
08 土地96年出售明細（原處分卷第653-654頁）、林志明與林
09 銀等8人96年12月26日簽訂之房屋買賣契約書（原處分卷第
10 648-649、640-641、634-635、630-631、626-627、620-621
11 、608-609、598-599）、林銀等8人房屋買賣資金說明及文
12 件憑證（原處分卷第650、642-647、636-639、632-633、62
13 8-629、624-625、622、612-620、610、600-608、594-597
14 頁、本院卷一第253-291、443-537頁）、證券交易稅繳款書
15 （原處分卷第781-788頁）、原告96年度營利事業投資人明
16 細及分配盈餘表（本院卷一第101頁）、原告96年度股票轉讓
17 通報表（本院卷一第103-111頁）、被告核定通知書暨調整
18 法令及依據說明書（原處分卷第1037-1038頁）、96年度營
19 利事業所得稅核定稅額繳款書（原處分卷第1067頁）、違章
20 案件罰鍰繳款書（原處分卷第1065頁）、裁處書（原處分卷
21 第1036 頁）、復查決定（原處分卷第1265-1275頁）、訴願
22 決定（原處分卷第1287-1300頁）可查，並經本院依職權調
23 取本院104年度訴字第1681號營業稅事件全卷（外放）查
24 明，堪信為真。

25 (二)原告代表人林志明代表原告與自己交易，而低價買入系爭房
26 地；再於短期間內又以自己名義將買入之系爭房地高價出售
27 予林銀等8人，以完成雙方約定之分拆處置原告資產約定，
28 並重新建構股權分配之行為及其結果，為稅捐規避：

29 1.應適用的法令及法理的說明：

30 (1)行為時所得稅法第4條第1項第16款規定：「左列各種所得，
31 免納所得稅……十六、個人及營利事業出售土地……其交易

之所得。」第9條規定：「本法稱財產交易所得及財產交易損失，係指納稅義務人並非為經常買進、賣出之營利活動而持有之各種財產，因買賣或交換而發生之增益或損失。」又行為時營利事業所得稅查核準則第32條第1款前段規定：「出售資產之售價，大於資產之未折減餘額部分，應列為出售資產收益課稅。但出售土地……免納所得稅；如有損失，應自該項增益項下減除。」

- (2)「憲法第19條規定人民有依法律納稅之義務，係指人民僅依法律所定之納稅主體、稅目、稅率、納稅方法及納稅期間等項而負納稅之義務。至於課稅原因事實之有無及有關證據之證明力如何，乃屬事實認定問題，不屬於租稅法律主義之範圍。」「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。」業經司法院釋字第217號、第420號解釋在案。嗣稅捐稽徵法參照上開420號解釋意旨，於98年5月13日增訂公布第12條之1第1、2項規定：「（第1項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。」102年5月29日再修正增訂同條第3項規定：「納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。」將租稅規避行為之認定作為一般性之法律規範，以避免實質課稅原則與租稅法律主義之衝突。又105年12月28日制訂公布、106年12月28日施行之納稅者權利保護法第7條第1至3項規定，內容與前引稅捐稽徵法第12條之1第1至3項完全相同，旨在重申實質課稅原則為租稅法上重要原則。是稅捐稽徵機關依據實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有，認定課徵租稅之構成要件事實，並就此實質經濟事實關係依稅法規範之

納稅主體、稅目、稅率等為租稅之核課，難謂有違租稅法律主義（最高行政法院106年度判字第268號判決意旨參照）。

2.原告代表人林志明代表原告與自己交易，而低價買入系爭房地；再於短期間內又以自己名義將買入之系爭房地高價出售予林銀等8人，係為完成雙方約定之分拆處置原告資產約定，並重新建構股權分配：

(1)原告於96年11月26日改選董事及監察人，由林志明擔任董事長，林美櫻擔任監察人，林志明嗣於96年12月6日代表原告與林志明個人簽訂買賣契約，將原告所有之系爭房地出售予林志明，契約總價為500,000,000元，分別載明房屋售價為75,000,000元、土地售價為425,000,000元，林志明並於96年12月14日向地政機關申辦系爭房地所有權移轉登記，登記移轉日為96年12月27日等情，有股東臨時會議紀錄（原處分卷第615-619頁）、原告與林志明簽訂之買賣契約書（原處分卷第655、656頁）、土地及建築改良物所有權買賣移轉契約書（原處分卷第691-697頁）、異動索引查詢資料（原處分卷第713、717、722頁）可稽。

(2)林志明旋於96年12月26日，將系爭房地連同其繼承取得之繼承房地，依序以354,539,956元、241,592,254元、21,303,416元、249,418,206元、21,299,000元、139,785,261元、105,468,588元及21,303,416元，合計總價1,154,710,097元，分別出售予林銀、姚建安、林美麗、卓維和、林美櫻、駱金生及駱俊銘，亦有林志明與林銀等8人簽訂之買賣契約書（原處分卷第648、649、634、635、608、609、640、641、598、599、630、631、626、627、620、621頁）足憑。

(3)林銀等8人就上開買賣總價1,154,710,097元，係分3期對林志明為給付：

①第1期款：原告96年11月26日臨時股東會議決議分配現金股利410,000,000元，其中林銀等8人獲配共計179,953,557元（410,000,000元×林銀等8人持有股數27,651,400股÷原告已發行股份總數63,000,000股，原處分卷第615-619頁會議紀

錄），林銀等8人並將獲配股利之支票交付林志明，供其於96年12月27日存入銀行帳戶兌現（原處分卷第801、804、807、810、813、816、819、822頁支票及第799頁存摺影本）。

②第2期款：係由林銀等8人將所持原告股票共27,651,400股出讓林志明，以抵繳房地價款799,756,540元（27,651,400股×平均每股淨值28.92282271元）。

③第3期款：係由林銀、林美櫻、駱金生、林美麗、林美娥分別匯款17,678,215元、32,522,886元、20,916,207元、51,255,514元、52,627,178元至林志明銀行帳戶（原處分卷第797、824、809、806、815、821頁存摺影本及房屋買賣契約書影本），亦即其等對林志明給付尾款共計175,000,000元（17,678,215+32,522,886+20,916,207+51,255,514+52,627,178）。

④綜上3期給付，林銀等8人係對林志明共支付前述房地總價1,154,710,097元（179,953,557+799,756,540+175,000,000），其中第1期款179,953,557元及第3期款175,000,000元資金，係由林銀等8人對林志明應付之買賣價金中扣除等情，此據原告訴訟代理人於本院108年12月24日準備程序當庭陳明：第1期款係林銀等8人以獲配之股利179,953,557元支付、第2期款是林銀等8人以股票去抵償、第3期款175,000,000元是林銀等人給付現金，且前開共3期款項均已從林銀等8人應付之房地買賣價金中扣除完畢等語（本院卷一第324頁）在卷，並有原告提出之資金表（原證21）可參，其間並無資金回流之情形。

⑤基於上述179,953,557元及175,000,000元資金已自林銀等8人應付之房地買賣價金中為扣除，則本件涉及原告應稅所得之稅基量化計算，依發回判決之判決意旨，即「無須」再重複加計該等179,953,557元及175,000,000元資金。

(4)林銀等8人購買前述房地，按房屋評定標準價格及土地公告現值計算之總現值為332,667,815元，其中原告所有系爭房

01 地之現值為309,493,656元，而林志明所有繼承房地之現值
02 為23,174,159元（原處分卷第732頁），兩者現值占比分別
03 為93.00000000%（ $309,493,656 \div 332,667,815$ ）及6.000000
04 00%（ $23,174,159 \div 332,667,815$ ），依前開占比分算實際成
05 交價額，原告所有系爭房地之售價為1,074,271,189元（ $1,1$
06 $54,710,097 \times 93.00000000\%$ ），林志明所有繼承房地之售價
07 為80,438,906元（ $1,154,710,097 \times 6.00000000\%$ ）。

08 (5)可知，原告於96年12月6日以500,000,000元出售予林志明之
09 系爭房地，於短短20日後（即96年12月26日），即由林志明
10 以超過其買進價格1倍有餘之1,074,271,189元，出售予林銀
11 等8人。顯見原告係以低價出賣系爭房地，致使高達574,27
12 1,189元（ $1,074,271,189 - 500,000,000 = 574,271,189$ ）之
13 價差利益在形式外觀上流向林志明，此一交易行為，與原告
14 係以營利為目的之事業，應追求自身利益極大化之商業常情
15 明顯不符。是原告主張其以500,000,000元出售系爭房地予
16 林志明，係合理價格等語，自無可取。

17 (6)參佐林志明以102年5月27日安建（102）稅(一)字第00342D號
18 函所為之說明：「……說明人為大東公司創辦人林德旺先生
19 繼承人之一，林德旺先生於民國90年逝世，其繼承人除說明
20 人一子外，另有收養之長子林永順君及7女等計9人……繼承
21 人張林美女家族及林永順家族所持有大東公司股權係由說明
22 人以現金購入方式換取，故分別於95年11月5日及96年11月9
23 日與張林美女家族及林永順家族簽訂股票買賣契約書……各
24 以……201,560,000元及215,000,000元換得大東公司股權5,
25 968,600股及9,866,600股……此二人家族之大東公司股權均
26 透過說明人給付現金取得，故此二人自始並未參與說明人與
27 其他繼承人股權之換取過程……其餘繼承人林銀君、林美娥
28 君、林美麗君及林美櫻君……等人，因說明人已無鉅額現金
29 可再取得其股權，經雙方協議後乃改以大東公司名下位於臺
30 北市○○○路0段……房地之產權交換……然因系爭不動產
31 非遺產標的，無法由林銀君等4位繼承人直接繼承取得，故

01 安排由說明人於96年12月6日先以5億元購買名義取得系爭不
02 動產後，再於同年度12月26日簽訂房屋買賣契約書並依約支
03 付價金……將該不動產讓與林銀、林美娥家族（含姚建安
04 君）、林美麗家族（含卓維和君）及林美櫻家族（含駱金生
05 及駱俊銘君），以交換該等人員原所持有大東公司之全部股
06 權……」等語（原處分卷第836-838頁），以及林志明於102
07 年3月27日代表原告出具之函文載稱：「……經家族成員商
08 議結果，決定由林志明取得所有其他股東之大東公司股份，
09 但大東公司位於臺北市○○○路0段……房地……須讓予其
10 餘……股東……於此共識下，大東公司須先將系爭不動產出
11 售予林志明，以與其他股東交換大東公司之股份。亦即整個
12 交易『形式上』為大東公司出售系爭不動產予林志明，另由
13 林志明向其他股東購買大東公司股權」等語（原處分卷第74
14 1頁）。足認林志明與林銀等8人明知系爭房地屬原告所有，
15 並非林志明等人之被繼承人林德旺所留遺產，林銀等8人欲
16 取得系爭房地，無法以繼承方式為之；原告遂於96年11月5
17 日由林志明、林銀、林美麗、林美娥、林美櫻等董事決議，
18 將系爭房地售予林志明（原處分卷第744頁），實質上乃為
19 使林銀等8人取得系爭房地之所有權，以完成雙方約定之分
20 拆處置原告資產約定，並重新建構股權分配。

21 3.林志明上開低價買入又高價出售系爭房地所得價差利益，即
22 房屋交易利得75,066,349元及土地交易利得495,451,522
23 元，其歸屬主體為原告：

24 (1)行為時所得稅法第4條第1項第16款規定：「下列各種所得，
25 免納所得稅：……十六、個人及營利事業出售土地，…其交
26 易之所得。」第14條第1項第1類規定：「個人之綜合所得總
27 額，以其全年下列各類所得合併計算之：第一類：營利所
28 得：公司股東所獲分配之股利……屬之。」稅捐稽徵主管機
29 關財政部依上開規定作成75年12月8日台財稅第7518357號解
30 釋函：「營利事業出售土地之交易所得，依所得稅法第4條
31 第16款（按即87年6月20日修正公布後之同法第4條第1項第1

6款)規定，免納所得稅，惟該項盈餘分配予股東時，依同法第14條第1項第1類規定，屬營利所得，應由股東合併各類所得申報繳納綜合所得稅。」因所得稅之稅捐主體區分為「自然人」與「營利事業」二大類，為二個不同類別之權利主體。而其等均利用國家與社會所提供之各類公共服務，從事各類活動，活動結果也會增加國家及社會之善後成本，自應負擔國家社會之公共支出。又此二類主體活動內容不同，對國家及社會之影響也不同，因此在所得稅法制上，二類主體被分開看待，而有不同之所得稅負標準。而營利事業將活動成果之稅後盈餘，分配予股東或資本主等自然人時，對自然人而言，取得之營利所得，正用以支應自然人在社會中所從事之新活動，自有重新計算個人所得稅負之理由。即使營利事業有免稅之「土地交易所得」產生，等到分給股東或資本主時，仍應定性為應稅之「營利所得」。財政部75年12月8日函所載之論點，乃是依所得稅法制之規範體系作出之正確法律解釋（最高行政法院105年度判字第629號判決意旨參照）。從而，營利事業出售土地之交易所得，於營利事業所得稅中固屬免稅所得，然該項土地交易所得（盈餘）由營利事業分配或歸予投資個人（包括公司之自然人股東、合作社社員、合夥人、獨資資本主）時，即屬營利所得，依前述所得稅法第14條第1項第1類之規定，仍應計入當年度個人之綜合所得總額，依法課徵綜合所得稅。如該出售土地之交易所得係來自個人的財產交易行為，則非屬營利事業所得額的範圍，且於綜合所得稅中係屬免稅所得（最高行政法院106年度判字第11號判決意旨參照）。由此觀之，就土地出售而言，稽徵實務及法院見解均認為，營利事業出售土地所得固為免稅所得，然仍屬營利事業之盈餘，於該盈餘分配予股東時，應計入個人股東之綜合所得總課徵綜合所得稅，而出售土地交易若以個人名義為之，則該土地交易所得於個人綜合所得稅中係屬免稅所得，且並無如同營利事業出售土地時，

01 後續尚有土地交易所屬盈餘，該盈餘分配股東課徵綜所稅
02 等問題。

03 (2)揆之林志明以102年5月27日安建（102）稅(一)第00342D號函
04 所為之說明：「……說明人為大東公司創辦人林德旺先生繼
05 承人之一，林德旺先生於民國90年逝世，其繼承人……計9
06 人。茲因林德旺先生之遺產主要為大東公司股權，說明人與
07 各繼承人商議遺產分配時，因無人願意承接大東公司事業，
08 幾經協議乃由說明人另以現金或向大東公司購入之不動產交
09 換其他繼承人及其家族所持有大東公司股權，……繼承人張
10 林美女家族及林永順家族所持有大東公司股權係由說明人以
11 現金購入方式換取，故分別於95年11月5日及96年11月9日與
12 張林美女家族及林永順家族簽訂股票買賣契約書……各
13 以……201,560,000元及215,000,000元換得大東公司股權5,
14 968,600股及9,866,600股……此二人家族之大東公司股權均
15 透過說明人給付現金取得，故此二人自始並未參與說明人與
16 其他繼承人股權之換取過程……其餘繼承人林銀君、林美娥
17 君、林美麗君及林美櫻君……等人，因說明人已無鉅額現金
18 可再取得其股權，經雙方協議後乃改以大東公司名下位於臺
19 北市○○○路0段……房地之產權交換……然因系爭不動產
20 非遺產標的，無法由林銀君等4位繼承人直接繼承取得，故
21 安排由說明人於96年12月6日先以5億元購買名義取得系爭不
22 動產後，再於同年度12月26日簽訂房屋買賣契約書並依約支
23 付價金……將該不動產讓與林銀、林美娥家族（含姚建安）
24 、林美麗家族（含卓維和）及林美櫻家族（含駱金生及
25 駱俊銘），以交換該等人員原所持有大東公司之全部股權」
26 等語（原處分卷第836-838頁，另原告102年3月27日、102年
27 6月21日、102年9月17日以及林志明102年4月19日所出具之
28 函文亦為相同之說明，原處分卷第741、1042、1073、775-7
29 76頁）。足見林德旺對於實質上為其所有之系爭房地，主要
30 係安排由其創辦之原告所持有，再透過對原告持股之方式，
31 以間接取得對系爭房地實際享有所有權之權利，而非採取其

01 個人取得系爭房地所有權之方式，以直接享有系爭房地之權
02 利；且於其死亡後，各繼承人經由繼承原告股權而各自按持
03 股比例享有系爭房地之權益，而非分由各繼承人個別繼承直
04 接取得系爭房地之所有權。

05 (3)又營利事業與自然人其等均利用國家與社會所提供之各類公
06 共服務，從事各類活動，活動結果也會增加國家及社會之善
07 後成本，自應負擔國家社會之公共支出（最高行政法院105
08 年度判字第629號判決意旨參照）。基此，林德旺既以原告
09 持有系爭房地，則原告就系爭房地所生稅捐自有負擔之義
10 務。是以，林德旺繼承人間事後固基於家族財產重分配之協
11 議，而必須移轉系爭房地所有權予特定繼承人（或其配偶、
12 子女），惟對於系爭房地所有權及繼承等事宜之安排，林德
13 旺既然選擇以原告持有，再由其繼承人依各該持股比例享有
14 系爭房地權益為之，則繼承人間以遺產重分配為目的再為系
15 爭房地所有權移轉所產生之所得（盈餘），其稅捐之主體自
16 當亦認為歸屬於原告。

17 (4)林志明為原告之主要股東，且原告係以林志明個人為主導之
18 家族公司：

19 ①觀之林志明於102年3月27日代表原告出具之函載稱：「大東
20 公司創立於民國51年，創辦人為林德旺先生，股東成員皆為
21 林氏家族，林德旺先生於民國90年往生後，……除現任董事
22 長林志明先生有意願繼續經營公司外，其餘股東部分欲取得
23 現金，部分欲取得公司所擁有之不動產。……經家族成員商
24 議結果，決定由林志明取得所有其他股東之大東公司股份，
25 但大東公司位於臺北市○○○路0段……房地……須讓予其
26 餘……股東，……」等語（原處分卷第741頁），可知原告
27 係一家族公司，且於林志明等繼承人重為財產分配後，將由
28 林志明取得其他股東之股份，並由其繼續經營原告公司。

29 ②原告於96年11月5日召開董事會決議將系爭房地出售予林志
30 明（本院卷一第155頁董事會議事錄）後，於96年12月6日與
31 林志明簽立房屋買賣契約書，約定系爭房地售價為5億元

（原處分卷第655-656頁房屋買賣契約書），並於96年12月14日將系爭房地登記予林志明，且於96年12月13日即帳列土地交易所得271,124,660元及建築物交易所得14,110,523元（原處分卷第697頁土地建物所有權買賣移轉契約書收件章及第1257頁轉帳傳票）。

③原告為上開系爭房地出售之同時，林志明於該段期間前、後，陸續向原告之原有股東購入持股（例如：96年11月9日向林君瑋等5人收購持股；96年12月4日向張錦昆等3人收購持股；96年12月12日向吳星佑等2人收購持股；96年12月14日向張佳玲等2人收購持股，本院卷一第103-105頁原告96年度股份轉讓通報表）。而經林志明為上開股權之收購後，原告於96年12月14日之股東僅餘林銀等8人、林志明及呂清淼共10人（原處分卷第615-616頁原告96年12月10日股東名冊，按：此名冊所載股東林美琴持股3,068,000股及股東吳星佑持股444,000股，業經林志明於96年12月12日所收購）。

④嗣林志明與林銀等8人進行系爭房地及繼承房地與原告股權之資產交換契約，林志明遂於96年12月26日取得原告所餘股東林銀等8人持有之原告股權（本院卷一第103頁原告96年度股份轉讓通報表），至此，原告股東自是日起僅存林志明及呂清淼2人，且呂清淼亦有依其持股比例獲配原告96年度發放之現金股利（本院卷一第101頁分配盈餘表）。換言之，系爭房地因林志明低買高賣所生之價差所得，受該價差所得歸屬結果而受影響之原告股東，除林志明外，尚有呂清淼。

⑤然林志明對原告投資金額為623,700,000元，呂清淼投資金額則為6,300,000元（本院卷一第101頁原告96年度營利事業投資人明細及分配盈餘表），而原告之資本總額為630,000,000元（623,700,000元+6,300,000元），換算該2人對原告之持股比例，林志明持有原告股權高達99%（即623,700,000元/630,000,000元），而呂清淼持有原告股權僅有1%（即6,300,000元/630,000,000元）。換言之，林志明享有99%

之原告股東權益（含原告盈餘），呂清淼僅享有1%之原告股東權益，2人對原告之持股比例差距懸殊。

⑥原告代表人林志明於其歷次出具函文均稱，原告係其父林德旺創辦之家族公司，因其他繼承人無意經營原告公司，故由其取得持股繼續經營，上述原告之股權結構變化情形核與林志明前揭所述相符。顯見林志明為原告之主要股東，且原告係以林志明個人為主導之家族公司，至為明確。再者，林志明因持有原告股權高達99%，而得以享有原告盈餘99%之權益，故林志明低買高賣系爭房地之價差所得（即房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元）歸屬於原告，林志明透過對原告持股仍可對該等所得（盈餘）享有將近全額（即99%）之權益，此與該價差所得若歸屬於林志明本人，二者並無顯著差異。易言之，林志明將該價差所得歸屬於己或歸屬於原告，就林志明個人而言，其所受利益並無明顯差別。然將該價差所得（盈餘）歸屬原告，於分配時即屬林志明之營利所得，應計入其個人綜合所得額課稅，則原屬免稅徵所得稅之土地交易所得495,451,522元，因屬原告盈餘而於分配時應課徵林志明綜合所得稅（最高稅率達40%），將導致其稅捐負擔大幅增加，此方為林志明權衡將該價差所得歸屬於己或歸屬於原告時，會真正考慮之事項。而原告另一股東呂清淼就該價差所得若歸屬於原告時，亦同樣面臨原屬免稅徵所得稅之土地交易所得將課徵高額之個人綜合所得稅，是其與林志明應均有降低稅賦負擔之相同目標。因此，呂清淼固為原告公司另一有獨立效用函數之股東（即其持有原告1%股權得以享有原告盈餘1%之權益），惟以原告實質上係由林志明一人為主導之家族公司，且原告僅餘林志明與呂清淼2名股東，此2人又有降低稅捐負擔之共同目標，則渠等就交易形式應為如何安排相對容易達成協議，自不能逕以原告尚有呂清淼此一獨立效用之股東，即遽認林志明將該價差所得歸屬於自己係源於其本意，而非出於上開降低稅捐負擔之考量。

01 (5)林志明於97年度綜合所得稅第2、3次核定處分行政爭訟程序
02 中，未曾就該價差利益所得係歸屬於己為主張，遲至原告另
03 案96年度11-12月份營業稅補稅及罰鍰事件，經本院於105年
04 5月11日以104年度訴字第1681號判決敗訴後，始就該價差利
05 益所得係歸屬於己而為主張：

06 ①本件緣於林志明就其出售系爭房地予卓維和、林美麗、林美
07 娥、林美櫻及駱金生間2等親買賣，於97年1月7日為贈與稅
08 之申報（本院卷一第118-127頁、本院卷二第367-421頁），
09 北區國稅局為瞭解系爭房地價款動支情形，衍生查得原告、
10 林志明與林銀等8人間就系爭房地之2次交易模式涉及原告短
11 列報土地交易獲利之未分配盈餘、短列報出售房屋獲利之課
12 稅所得，以及短報出售房屋之銷售額與營業稅，且林銀等8
13 人股權轉讓涉及以顯不相當之代價讓與財產應課徵贈與稅等
14 情，北區國稅局乃作成綜合所得稅審查報告（下稱系爭審查
15 報告，原處分卷第1015-1021頁），並將上開查核結果通報
16 各稅目之稽徵權責單位。營業稅部分經北區國稅局於102年6
17 月17日對原告補稅3,753,317元並處罰鍰（原處分卷第946
18 頁），綜合所得稅部分經北區國稅局於102年7月10日將林志
19 明97年度綜合所得稅原核定系爭房地財產交易所得均註銷為
20 0元（本院卷一第373、98-99頁），贈與稅部分通報被告後
21 經查明逾核課期間而未予開徵（訴願可閱卷第78-80頁），
22 營利事業所得稅部分被告接獲通報後於102年4月19日重行核
23 定應補稅額18,766,587元（原處分卷第1037-1038頁），並
24 處罰鍰18,766,587元（原處分卷第1065頁）。

25 ②林志明於96年12月26日與林銀等8人簽訂買賣契約，約定將
26 其以500,000,000元價格向原告購入之系爭房地連同其本身
27 繼承之繼承房地，以總價額1,154,710,097元出售予林銀等8
28 人，並於97年2月26日將上述房地登記予林銀等8人（原處分
29 卷第701-708、1097-1132頁土地建物查詢資料、異動索引查
30 詢資料）。惟觀諸林志明96年度綜合所得稅核定資料（本院
31 卷一第95-96頁），納稅義務人林志明申報案件歸戶所得清

單計19筆所得，並無任何一筆之所得類別屬財產交易所得（按：財產交易所得類別代號為「7」），可見林志明並未將系爭房地所生之財產交易所得列報於其96年度綜合所得稅申報，北區國稅局亦未於林志明96年度綜合所得稅案件核定系爭房地之財產交易所得。

③另觀諸林志明97年度綜合所得稅第1次核定資料（本院卷一第363-371頁），北區國稅局核定系爭房地之房屋部分財產交易所得25筆（序號23-47）所得額共計12,313,284元〔876,583元+876,554元×3（共3筆）+866,056元+816,930元×3（共3筆）+635,274元+427,257元+425,517元+366,821元+346,753元+280,923元×5（共5筆）+269,671元×6（共6筆）+265,930元〕、林志明繼承房地之房屋部分財產交易所得額1,426,162元（序號22），而申報與歸戶之差額（即林志明漏申報所得額）為13,629,314元，與北區國稅局前揭財產交易核定之所得額計13,739,446元（12,313,284元+1,426,162元）相近，可知林志明亦未將出售系爭房地所生之財產交易所得列報於其97年度綜合所得稅申報。

④觀之北區國稅局第1次核定林志明97年度綜合所得稅之各筆所得額，其金額恰與各該房屋依照財政部核定財產交易所得標準所計算之所得額相符（原處分卷第731頁北區國稅局製作計算表末欄資料），可知北區國稅局此次核定應係依據地政機關登記資料，再按財政部頒佈標準所為推計，並非依據系爭審查報告所查得之實際出售及買入交易價格覈實認定。換言之，北區國稅局就林志明97年度綜合所得稅之第1次核定，僅單純依系爭房地於97年2月26日由林志明以買賣原因移轉登記予林銀等8人，即將系爭房地出售予林銀等8人之財產交易所得認定歸屬於林志明。又北區國稅局此次核定應補稅額5,058,163元，原訂繳納期間99年1月20日至29日，經展延至99年11月11日至20日，林志明已於99年11月18日繳納。

⑤嗣北區國稅局於102年初完成系爭審查報告〔依被告於102年3月27日接獲營利事業所得稅部分通報，以及北區國稅局與

01 被告於102年4月至7月間作成前揭各稅目更正核定等時間
02 點，可推知北區國稅局係在98至102年間（第1次發函調查是
03 在98年7月29日，本院卷一第135頁）進行調查，約於102年
04 初作成系爭審查報告〕，並於102年7月10日就林志明97年度
05 綜合所得稅為第2次核定，認定系爭房地出售予林銀等8人之
06 財產交易所得應歸屬於原告，而將第1次核定之序號23-47
07 所得均註銷，另依實際出售及買入交易價格覈實認定林志明
08 繼承房地之房屋部分財產交易所得，增加序號49所得12,54
09 5,107元（本院卷一第373頁核定通知書見、原處分卷第732
10 頁林志明繼承房屋所得額計算）。嗣又於103年3月3日就林
11 志明97年度綜合所得稅為第3次核定，更正林志明繼承房屋
12 部分財產交易所得為12,538,311元（見本院卷一第99頁核定
13 通知書）。

14 ⑥北區國稅局99年間第1次核定林志明97年度綜合所得稅時，
15 雖將系爭房地交易所得歸屬於林志明，而林志明亦將此次核
16 定補徵之稅款於99年11月18日完納。惟該次核定係北區國稅
17 局個人綜合所得稅稽徵權責單位尚未掌握林志明短期間低買
18 高賣系爭房地之交易全貌，僅單純依照地政機關登記資料即
19 進行核課，已如前述。且於斯時，林志明業因北區國稅局贈
20 與稅稽徵權責單位於98年間對其贈與稅申報案件展開調查，
21 而得知北區國稅局已掌握其與原告及林銀等8人移轉系爭房
22 地之2次交易模式，則林志明所為前開第1次核定補徵稅額之
23 繳納，是否確係基於將2次系爭房地買賣之價差利得歸屬於
24 自己之本意，尚非無疑。況且，林志明雖曾就97年度綜合所
25 得稅事件提起行政救濟，惟林志明於該行政救濟程序中所爭
26 執者，僅北區國稅局第2、3次核定處分關於其繼承房地財產
27 交易所得依實際交易價格覈實認定部分，但對於註銷系爭房
28 地財產交易所得部分，則未為任何爭執，迄至105年12月16
29 日始向北區國稅局申請核發第1次核定補繳97年度綜合所得
30 稅額5,058,163元之繳款書等情，亦有林志明97年度綜合所
31 得稅及罰鍰事件之復查決定（原處分卷第1247-1251頁）可

01 按，並經本院依職權調取林志明另案本院106年度訴字第148
02 8號綜合所得稅事件全卷查明（外放）。質言之，林志明於
03 北區國稅局第2、3次退稅核定處分（核定時間點分別為102
04 年7月10日、103年3月3日）所進行之復查及訴願（訴願決定
05 時間點為104年3月31日）程序中，林志明均未曾主張其出售
06 系爭房地予林銀等8人之交易所得歸屬於其個人，迄至105年
07 12月16日向北區國稅局申請核發97年度綜合所得稅補稅稅額
08 5,058,163元之繳款書，經北區國稅局否准提起行政爭訟
09 時，方就該交易所得歸屬於自己而為主張。然林志明105年1
10 2月16日申請核發第1次核定繳款書時，系爭房地交易所涉原
11 告營利事業所得稅部分及營業稅部分，早經被告及北區國稅
12 局於102年4月19日及102年6月17日補徵稅額並處罰鍰，且原
13 告營業稅補徵稅額及罰鍰處分經原告提起行政訴訟後，業經
14 本院於105年5月11日以104年度訴字第1681號判決駁回，則
15 林志明於此際所為該交易所得歸屬於自己之主張，其意顯在
16 脫免原告各項捐債務及罰鍰負擔，亦難遽信為真。

17 (6)綜上，原告之創辦人林德旺既以原告持有系爭房地，則其繼
18 承人間因遺產分配所為系爭房地移轉所生之所得，其稅捐之
19 主體自當歸屬於原告。況且，原告係實質由林志明一人主導
20 之家族公司，林志明持有原告之股權又高達99%，享有原告
21 將近全額之股東權益，因此該爭議所得歸屬於其本人或原
22 告，兩者並無顯著差異。再者，林志明於97年度綜合所得稅
23 第2、3次核定處分行政救濟程序中，未曾就所得係歸屬於其
24 自己而為主張，反而於原告出售系爭房地遭補徵營業稅稅額
25 之另案營業稅爭訟事件經本院104年度訴字第1681號判決敗
26 訴後，始為此項主張，並向北區國稅局申請第1次核定97年
27 度綜合所得稅補稅稅額之繳款書，實難據此即認其本意係將
28 2次系爭房地買賣之價差利得歸屬於自己。從而，林志明代
29 表原告與自己交易，而低價買入系爭房地；再於短期間內又
30 以自己名義將買入之系爭房地高價出售予林銀等8人，以完
31 成雙方約定之分拆處置原告資產約定，並重新建構股權分

01 配，其出售系爭房地之價差利益，即房屋交易利得75,066,3
02 49元及土地交易利得495,451,522元，已實質歸屬於原告。
03 綜上事證，被告認定本件系爭房地之交易，已具備納稅者權
04 利保護法第7條第3項所定「獲得租稅利益之意圖」、「濫用
05 法律形式」、「以非常規交易規避租稅構成要件之該當」、
06 以及「稅捐客體已『實質歸屬』於本件原告，達成與交易常
07 規相當之經濟效果」之「稅捐規避」要件，即非無據。

08 (三)被告以原告96年度營利事業所得稅結算申報，漏報系爭房屋
09 交易所得75,066,349元，核定補徵原告稅額18,766,587元，
10 核無違誤，原告為稅捐規避所支出之各項費用，不能在稅上
11 列為當期費損：

- 12 1.行為時所得稅法第5條第5項第3款規定：「營利事業所得稅
13 起徵額、課稅級距及累進稅率如左：……三、超過10萬元以
14 上者，就其超過額課徵25%。」第24條第1項前段規定：
15 「營利事業所得之計算，以其本年度收入總額減除各項成本
16 費用、損失及稅捐後之純益額為所得額。」
- 17 2.林銀等8人向林志明購買系爭房地及繼承房地，按房屋評定
18 標準價格及土地公告現值計算之總現值為332,667,815元，
19 其中原告所有系爭房地之現值為309,493,656元，而林志明
20 繼承房地之現值為23,174,159元（原處分卷第732頁），兩
21 者現值占比分別為93.00000000%（ $309,493,656 \div 332,667,815$ ）及6.00000000%（ $23,174,159 \div 332,667,815$ ），是依前
22 開占比分算實際成交價額，原告所有系爭房地之售價為（含
23 稅）1,074,271,189元（ $1,154,710,097 \times 93.00000000\%$ ），
24 林志明所有繼承房地之售價為80,438,906元（ $1,154,710,097 \times 6.00000000\%$ ）。
- 27 3.因被告認定原告實際交易對象為系爭房地之最終所有人林銀
28 等8人，系爭房地實際交易價格應以林銀等8人買賣合約書所
29 載價金計算之，故為1,074,271,189元（含稅）。惟因買賣
30 契約書未分別載明土地及房屋之售價，乃就系爭房地售價按
31 房屋評定標準價格占土地公告現值及房屋評定標準價格之比

01 例，核算房屋售價（含稅）為153,819,667元 $\{1,074,271,18$
02 $9 \times (42,494,400 \times 1.05) \div [266,999,256 + (42,494,400 \times 1.$
03 $05)]\}$ 及土地銷售額為920,451,522元 $(1,074,271,189 - 1$
04 $53,819,667)$ 。

05 4.另依原告委任辦理96年度營利事業所得稅結算申報查核簽證
06 之會計師所出具之查核報告，就固定資產部分之查核說明：

07 「本期出售土地成本102,546,266元，售價425,000,000元，
08 繳納土地增值稅51,329,074元，認列出售土地利益271,124,
09 660元；出售房屋成本79,582,450元，沖轉累積折舊22,791,
10 868元，售價71,428,571元，認列出售房屋利益14,637,989
11 元。」等語（原處分卷第72頁），被告乃據以計算原告漏報
12 出售房屋增益75,066,349元 $[(房屋含稅售價核定數153,81$
13 $9,667元 \div 1.05) - (房屋購入成本79,582,450元 - 累計折舊$
14 $22,791,868元) - 已申報出售房屋增益14,637,989元]$ 、漏
15 報出售土地增益495,451,522元 $(土地售價核定數920,451,5$
16 $22元 - 購入成本102,546,266元 - 土地增值稅51,329,074元$
17 $- 已申報出售土地增益271,124,660元)$ ，最終核定原告出
18 售資產增益為861,846,896元 $(原核定291,329,025元 + 75,0$
19 $66,349元 + 495,451,522元)$ 及免徵所得稅之出售土地增益
20 為766,576,182元 $(原核定271,124,660元 + 495,451,522$
21 $元)$ ，乃就原告漏報出售房屋增益75,066,349元補徵營所稅
22 之稅額18,766,587元 $(75,066,349 \times 25\%)$ 。

23 5.就系爭房地於出售時之「市價」判斷而言，林志明自原告取
24 得系爭房地後，連同其繼承房地，旋與林銀等8人立約，以
25 總價1,154,710,097元出售上述房地。當林志明再出售房地
26 予林銀等8人時，既為終局移轉，買受人林銀等8人就全部價
27 款1,154,710,097元，又係以貨幣或有客觀淨值評價基礎之
28 股票支付，亦符合忠實履約之標準，且無資金回流之事實，
29 均如前述。則在本件系爭房地於出售時之「市價」判斷，在
30 未查得買賣雙方具備「合謀影響公、私第三方利益，刻意偏
31 離市價」之動機，或有「履約資金回流」之情況下，雙方依

01 約忠實履行之實際售價，即是最佳參考基準點，自屬判斷系
02 爭房地市價之最佳參考座標（本院卷一第45頁發回判決意旨
03 參照）。

04 6.從而，被告以前述房地市價1,154,710,097元為基礎，按原
05 告系爭房地之占比93.00000000%（詳前述），分算實際成
06 交價額為（含稅）1,074,271,189元，並據以核算原告出售
07 本件系爭房地之增益，尚非無據。是原告主張被告未就系爭
08 房地另予鑑價，逕以原告另案營業稅判決所認定之事實為依
09 據，違反行為時查核準則第32條第4項規定，違法高估系爭
10 房地之市價及出售房地之增益等語，尚難採據。又被告既係
11 依其查得系爭房地出售予林銀等8人之實際價格，覈實認定
12 系爭房地之售價，自亦無原告指稱未實質進行查核，有違行
13 為時查核準則第114條第1項規定之情形。另被告核定原告漏
14 報出售系爭房地之資產增益，係以系爭房地最終出售予林銀
15 等8人之實際價格為據，並非依所得稅法第83條規定按同業
16 利潤標準推計核定其所得額，是原告指摘被告未報經財政部
17 核准即違法推計課稅，違反所得稅法第43條之1規定等語，
18 亦無足取。

19 7.原告雖又主張林志明轉售系爭房地予林銀等8人所產生之契
20 稅、登記費、書狀費、印花稅元等費用，以及系爭房地應補
21 繳之營業稅及罰鍰，均應屬計算本件營利事業所得稅時應許
22 可如實認列之正常損費等語。惟稅捐規避行為所為支出，實
23 證上屬於因「脫法行為」所生之「競租」費用。此等費用支
24 出不會造成社會福利之增加，是一種純粹的資源浪費。如果
25 容許納稅者申報此等費用支出，即等同於鼓勵納稅者刻意拖
26 延稽徵，增加稅捐機關的稽徵成本，降低社會總體福利。因
27 此在對應之稅捐法制規範評價上，自然不能將此等費用列為
28 計算稅負減項，從而原告此部分主張，於法顯非有據（本院
29 卷一第46頁發回判決意旨參照）。

30 8.原告係故意以將系爭房地賣價壓低，出售予其代表人林志明
31 之不正當方法，逃漏稅捐，已如前述，而原告係於97年5月2

01 9日以網路辦理96年度營利事業所得稅結算申報（原處分卷
02 第302-304頁），依行為時稅捐稽徵法第21條第1項第3款及
03 第22條第1款等規定，其核課期間為7年，應至104年5月28日
04 始屆滿；而被告核定原告短漏報系爭房地交易所得之核定通
05 知書，於102年5月7日即已送達原告（原處分卷第1238、128
06 0頁更正核定通知書及中華郵政掛號郵件收件回執），並未
07 逾核課期間，是原告主張被告對其核定補稅已逾核課期間等
08 語，亦非可採。

09 (四)原告本件稅捐規避行為，違反誠實義務，而在客觀上具有違
10 法性，在主觀上具有可責性，而應被處以漏稅行政罰，被告
11 按其所漏稅額18,766,587元處以1倍之罰鍰計18,766,587
12 元，並無過重之裁量違法：

13 1.所得稅法第110條第1項規定：「納稅義務人已依本法規定辦
14 理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所
15 得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額2倍以下之罰
16 鍰。」行政罰法第7條第1項規定：「違反行政法上義務之行
17 為非出於故意或過失者，不予處罰。」又納稅者權利保護法
18 第7條第8項規定：「第3項情形，主管機關不得另課予逃漏
19 稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或
20 為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏
21 核定稅捐者，不在此限。」準此，所得稅之納稅義務人若違
22 反誠實申報義務，仍構成稅捐逃漏違章行為，而得對之處以
23 以所漏稅額2倍以下之罰鍰。

24 2.原告代表人林志明代表原告與自己交易，而低價買入系爭房
25 地；再於短期間內又以自己名義將買入之系爭房地高價出售
26 予林銀等8人，以完成雙方約定之分拆處置原告資產約定，
27 並重新建構股權分配之行為及其結果，為稅捐規避，前已認
28 定。則判斷本件原告有無「隱匿」重要事項之關鍵事項，即
29 在於：原告在申報稅捐及調查階段所提出之書面資料，是否
30 僅限於「證明原告出售系爭房地予林志明」之第1次交易事

實，並未及於「同時亦能證明林志明出售系爭房地予林銀等8人」之第2次交易事實。查：

(1)原告於97年5月27日辦理96年度營利事業所得稅結算申報，並未揭露有第2次交易之事實，且原告96年度營利事業所得稅列報出售資產增益292,077,212元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元（原處分卷第302-304頁），係以原告對林志明出售房地之價金5億元為出售資產增益之計算基礎，此屬第1次交易之內容（原處分卷第72、79、656頁）。又原告僅對被告揭露前開第1次交易情事，被告無從知悉尚有第2次交易（林志明將系爭房地高價出售予林銀等8人）之安排。

(2)嗣北區國稅局桃園縣分局（下稱桃園縣分局）分別以98年7月29日北區國稅桃縣一字第0980003313號書函及98年12月8日北區國稅桃縣一字第0980030165號書函請林志明提示出售房地價款動支情形並提供存摺影本供核（本院卷二第167-179頁），惟林志明並未提示。案經桃園縣分局調查資金往來，查得林志明於96年12月27日匯款179,953,557元予原告，桃園縣分局即以99年5月28日北區國稅桃縣一字第0990006672號書函請原告說明其股東林志明轉帳存入原告帳戶179,953,557元之原因（本院卷二第181頁），原告始以99年6月11日九九東電字第028號函說明係出售房地予林志明（第1次交易）之價款收回（本院卷二第183頁）。桃園縣分局再以99年6月17日北區國稅桃縣一字第0991025304號函請原告提示出售房地予林志明收取179,953,557元之買賣契約書（本院卷二第185頁），原告始以99年6月29日九九東電字第036號函提示系爭房地買賣契約書（第1次交易之合約）。可知，原告所提示者僅係第1次交易之買賣契約及決議出售不動產之會議紀錄，並未對被告揭露後續第2次交易之相關情節。

(3)嗣後事後桃園縣分局自行查得林銀等8人向林志明購買房地，乃以100年8月23日北區國稅桃縣二字第1000007905C號

01 等函向林銀等8人調查房地交易情形（原處分卷第652-594
02 頁，本院卷二第189頁），經林銀等8人於100年9月2日及7日
03 函復並提示第2次交易之買賣契約書（私契）、支票款等付
04 款憑證及相關資料，桃園縣分局始具體查得第2次交易之內
05 容（原處分卷第622-594、650-625頁）。亦即，有關第2次
06 交易之事證，於林銀等8人提供相關買賣資料及桃園縣分局
07 自行查得第2次交易以前，原告並未揭露此次交易之事實。

08 (4)是於稽徵機關自行查獲第2次交易事實以前，本件原告提供
09 之資料僅提示第1次交易之資料，並未揭露第2次交易之事
10 實，應可評價為原告引用片斷事實，掩飾全貌，仍屬「隱匿
11 重要事實」，而有納稅者權利保護法第7條第8項但書之適
12 用，構成稅捐逃漏違章行為，而在客觀上具有違法性，在主
13 觀上具有可責性，而應被處以漏稅違章行政罰，且其裁罰上
14 限，不受納稅者權利保護法第7條第10項中段或稅捐稽徵法
15 第48條之3規定之節制，實屬法理上之當然（發回判決意旨
16 參照，本院卷一第48頁）。又罰鍰金額是否過高，與原告之
17 實收資本額多寡無涉，因為「公司實收資本額」並不是確認
18 公司資力高低之最佳判準（應以公司實質資產淨值為準）。
19 是被告以原告漏報系爭房屋交易利得75,066,349元，構成稅
20 捐逃漏違章行為，而依所得稅法第110條第1項規定，按所漏
21 稅額18,766,587元處1倍之罰鍰18,766,587元，核屬有據，
22 相對於原告出售系爭房地之利得，上開罰鍰並無過重之裁量
23 違法情事。

24 (五)綜上所述，被告對原告補徵96年度營利事業所得稅額18,76
25 6,587元及裁處同額罰鍰18,766,587元，並無違誤，復查決
26 定及訴願決定遞予維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤
27 銷，為無理由，應予駁回。

28 六、本件判決基礎已經明確，兩造其餘攻擊防禦方法及訴訟資料
29 經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述之必
30 要，一併說明。

31 中 華 民 國 112 年 2 月 23 日

臺北高等行政法院第三庭

審判長法官 高愈杰

法官 楊坤樵

法官 孫萍萍

一、上為正本係照原本作成。

二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書。（須按他造人數附繕本）

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段）

四、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、四親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所

01

屬專任人員辦理法制、法務、訴願
業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，
上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係
之釋明文書影本及委任書。

02

中 華 民 國 112 年 2 月 23 日

03

書記官 李虹儒

最 高 行 政 法 院 判 決

112年度上字第275號

上 訴 人 大東電業廠股份有限公司

代 表 人 林志明

訴訟代理人 黃合文 律師

施博文 會計師

被 上 訴 人 財政部臺北國稅局

代 表 人 吳蓮英

上列當事人間營利事業所得稅事件，上訴人對於中華民國112年2月23日臺北高等行政法院108年度訴更一字第70號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人民國96年度營利事業所得稅結算申報，列報出售資產增益新臺幣（下同）292,077,212元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，被上訴人原核定出售資產增益291,329,025元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，嗣依財政部北區國稅局（下稱北區國稅局）通報，上訴人短漏報房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元等情，重行核定上訴人96年度出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補稅額18,766,587元，並按所漏稅額18,766,587元處以1倍罰鍰18,766,587元（下稱原處分）。上訴人不服，申請復查，未獲變更，提起訴願經決定駁回，續提行政訴訟，前經臺北高等行政法院（下稱原審）107年度訴字第978號判決（下稱前判決）駁回，上訴人不服，提起上訴，經本院108年度判字第357號判決將前判決廢棄，發回原審更為審理。嗣原審以108年度訴更一字第70號判決（下稱原判決）駁回上訴人在原審之訴，上訴人仍不服，遂提起本件上訴，並聲明：（一）原判決廢

棄。(二)訴願決定及原處分(含復查決定)均撤銷；或發回原審更為審理。

二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

(一)上訴人於96年11月26日改選董事及監察人，由林志明擔任董事長，林志明嗣於96年12月6日代表上訴人與其個人簽訂買賣契約，買受上訴人所有之門牌號碼臺北市○○區○○○路0段000號1樓、10樓、地下1樓、000號1至12樓、地下1樓、000號1至10樓、地下1樓房屋（下合稱系爭房地），契約總價為5億元，分別載明房屋售價為75,000,000元、土地售價為425,000,000元（下或稱第1次交易）。林志明於96年12月14日向地政機關申辦系爭房地所有權移轉登記（登記移轉日為96年12月27日）後，旋於96年12月26日，將系爭房地連同其繼承取得之臺北市○○區○○段0小段000、000-1、000-2地號土地（應有部分各為64/1000）及坐落其上之門牌號碼臺北市○○區○○○路0段000號11樓房屋（下合稱繼承房地），依序以354,539,956元、241,592,254元、21,303,416元、249,418,206元、21,299,000元、139,785,261元、105,468,588元及21,303,416元，合計總價1,154,710,097元，分別出售予林銀、林美娥、姚建安、林美麗、卓維和、林美櫻、駱金生及駱俊銘（以上8人下合稱林銀等8人；林志明與林銀等8人就系爭房地之上述買賣交易，下或稱第2次交易）。林銀等8人就上開買賣總價1,154,710,097元，係分3期給付林志明：1.第1期款：林銀等8人將因上訴人96年11月26日臨時股東會議決議而獲配之現金股利支票（面額共計179,953,557元）交付林志明，供其於96年12月27日存入銀行帳戶兌現；2.第2期款：由林銀等8人將所持有上訴人股票共27,651,400股出讓林志明，抵繳房地價款799,756,540元；3.第3期款：由林銀、林美櫻、駱金生、林美麗、林美娥分別匯款共計175,000,000元至林志明銀行帳戶。上述第1、3.

期款資金業由林銀等8人對林志明應付之買賣價金中扣除，並無資金回流情形。

(二)系爭房地與繼承房地按房屋評定標準價格及土地公告現值計算之總現值為332,667,815元，依2者占比（分別為93.03384399%及6.96615601%）計算實際成交價額，系爭房地售價為1,074,271,189元。可知，上訴人於96年12月6日係以5億元低價出售系爭房地予林志明，於短短20日後即由林志明以超過買進價格1倍之1,074,271,189元，出售予林銀等8人，致使高達574,271,189元之差價利益在形式外觀上流向林志明，此與上訴人係營利事業，應追求自身利益極大化之商業常情明顯不符。參諸林志明於102年5月27日所具函文說明：上訴人創辦人林德旺於90年逝世，繼承人除伊一子外，另有收養之長子林永順及7女等計9人，林德旺之遺產主要為上訴人股權，因其他繼承人無意承接上訴人事業，經協議後由伊以現金或向上訴人購入之不動產交換其他繼承人及其家族所持有上訴人股權，繼承人張林美女家族及林永順家族所持有股權由伊以現金購入方式換取，其餘繼承人林銀、林美娥、林美麗及林美櫻等人，因伊已無鉅額現金可再取得其股權，經雙方協議後，改以上訴人所有之系爭房地產權交換，然因系爭房地非遺產標的，無法由林銀等4位繼承人直接繼承取得，故安排由伊於96年12月6日先以5億元購買名義取得系爭房地後，再於同年12月26日簽訂買賣契約並支付價金，將系爭房地讓與林銀、林美娥家族（含姚建安）、林美麗家族（含卓維和）及林美櫻家族（含駱金生及駱俊銘），以交換該等人員原所持有上訴人之全部股權等語，可知林德旺對實質上為其所有之系爭房地，係安排由其創辦之上訴人持有，再透過對上訴人持股，間接享有對系爭房地之所有權，則上訴人就系爭房地所生稅捐自有負擔之義務，林德旺繼承人間以遺產重分配為目的再為系爭房地所有權移轉而產生之所得（盈餘），其稅捐之主體自當亦認係上訴人。林志明因與林銀等8人進行系爭房地及繼承房地與上訴人股權之資產交

換，於96年12月26日取得林銀等8人原持有上訴人之股權，自該日起，上訴人股東僅存林志明及呂清淼2人，以其2人對上訴人之投資金額換算結果，林志明持股高達99%，故林志明低買高賣系爭房地之差價所得（即房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元，下稱本件差價所得）歸屬於上訴人，林志明透過對上訴人持股，仍可對該等所得（盈餘）享有將近全額（即99%）之權益。然上訴人將本件差價所得（盈餘）分配予林志明時，即屬其營利所得，應計入個人綜合所得額課稅，原屬免稅之土地交易所得495,451,522元，將因上訴人為盈餘分配，致林志明稅負大幅增加（最高稅率達40%），此方為林志明權衡將本件差價所得歸屬於己或上訴人時，會真正考慮之事項。而呂清淼與林志明應均有降低稅負之相同目標，故渠等就交易形式應為如何安排，相對容易達成協議，不能逕以尚有呂清淼此一股東，遽認林志明將本件差價所得歸屬於自己，非出於降低稅負之考量。

(三)本件緣於林志明因出售系爭房地予卓維和、林美麗、林美娥、林美櫻及駱金生，涉及2等親間之買賣，於97年1月7日申報贈與稅，北區國稅局為瞭解系爭房地價款動支情形，衍生查得上訴人、林志明與林銀等8人間就系爭房地之2次交易模式，將查核結果通報各稅目之稽徵權責單位。營業稅部分經北區國稅局於102年6月17日對上訴人補稅3,753,317元並處罰鍰，綜合所得稅部分經北區國稅局於102年7月10日將林志明97年度綜合所得稅原核定系爭房地財產交易所得均註銷為0元，贈與稅部分通報被上訴人後經查明逾核課期間而未予開徵，營利事業所得稅部分，被上訴人接獲通報後，於102年4月19日重行核定應補稅額18,766,587元，並處罰鍰18,766,587元。林志明96年度綜合所得稅核定資料，並無任何一筆之所得類別屬代號「7」之財產交易所得，可見其未列報系爭房地之財產交易所得。至林志明97年度綜合所得稅部分，北區國稅局第1次核定系爭房地之房屋部分財產交易所

得額共12,313,284元，繼承房地之房屋部分財產交易所得額1,426,162元，合計13,739,446元，與林志明漏未申報之所得額13,629,314元相近，可知林志明97年度亦未列報出售系爭房地之財產交易所得，且北區國稅局僅單純依系爭房地於97年2月26日由林志明以買賣原因移轉登記予林銀等8人，即認定出售系爭房地之財產交易所得歸屬林志明，核定應補稅額5,058,163元（下稱97年1核處分），林志明已於99年11月18日繳納。又北區國稅局於102年7月10日就林志明97年度綜合所得稅為第2次核定（下稱97年2核處分），認定系爭房地出售予林銀等8人之財產交易所得應歸屬於上訴人，將97年1核處分之序號23-47所得均註銷，另覈實認定林志明繼承房地之房屋部分財產交易所得，增加序號49所得12,545,107元，嗣於103年3月3日就林志明97年度綜合所得稅為第3次核定，更正林志明繼承房屋部分財產交易所得為12,538,311元（下稱97年3核處分）。林志明就97年2核、3核處分提起行政救濟之程序中，亦未曾主張出售系爭房地之財產交易所得歸屬於己，迄至105年12月16日向北區國稅局申請核發97年1核處分之繳款書遭否准而提起行政爭訟時，始為此項主張，此時上訴人就系爭房地交易遭補徵營業稅及罰鍰之處分所提行政訴訟，業經原審於105年5月11日104年度訴字第1681號判決（下稱營業稅判決）駁回，顯見林志明此際主張系爭房地交易所得歸屬於自己，意在脫免上訴人各項稅捐債務與罰鍰負擔，難以遽信。綜上，被上訴人認定系爭房地之交易，具備納稅者權利保護法（下稱納保法）第7條第3項所定稅捐規避之要件，並非無據。

(四)被上訴人認定上訴人實際交易對象為系爭房地之最終所有人林銀等8人，系爭房地實際交易價格應以林銀等8人買賣合約書所載價金計算為1,074,271,189元（含稅）。惟因買賣契約書未分別載明土地及房屋之售價，乃就系爭房地售價按房屋評定標準價格占土地公告現值及房屋評定標準價格之比例，核算房屋售價（含稅）為153,819,667元及土地銷售額

為920,451,522元；另依上訴人委任辦理96年度營利事業所得稅結算申報查核簽證之會計師所出具之查核報告，據以計算上訴人漏報出售房屋增益75,066,349元、漏報出售土地增益495,451,522元，最終核定上訴人出售資產增益為861,846,896元（原核定291,329,025元+75,066,349元+495,451,522元）及免徵所得稅之出售土地增益為766,576,182元（原核定271,124,660元+495,451,522元），乃就上訴人漏報出售房屋增益75,066,349元補徵營利事業所得稅18,766,587元（75,066,349×25%）。又稅捐規避行為所為支出，實證上屬於因「脫法行為」所生「競租」費用，不能列為計算稅負減項，故上訴人主張林志明轉售系爭房地予林銀等8人所生契稅、登記費、書狀費、印花稅，及就系爭房地應補繳之營業稅及罰鍰，屬可如實認列之正常費損，並非可採。又上訴人故意以將系爭房地賣價壓低，出售予其代表人林志明之不正當方法，逃漏稅捐，依行為時稅捐稽徵法第21條第1項第3款及第22條第1款等規定，其核課期間為7年，自其於97年5月27日以網路辦理96年度營利事業所得稅結算申報時起算，至104年5月28日始屆滿；被上訴人於102年5月7日即已送達核定通知書上訴人，未逾核課期間。

(五)上訴人於97年5月27日辦理96年度營利事業所得稅結算申報，未揭露有第2次交易之事實，嗣後係北區國稅局桃園縣分局（下稱桃園縣分局）自行查得林銀等8人向林志明購買系爭房地，於100年8月23日函詢林銀等8人後，始具體查知第2次交易之內容，故可評價為上訴人引用片斷事實，掩飾全貌，屬「隱匿重要事實」，有納保法第7條第8項但書之適用，構成稅捐逃漏違章行為，且在主觀上具可責性，應予處罰。被上訴人依所得稅法第110條第1項規定，按所漏稅額18,766,587元處1倍罰鍰18,766,587元，相對於上訴人出售系爭房地之利得，並無過重之裁量違法情事，因將原處分（含復查決定）及訴願決定均予維持，駁回上訴人在原審之訴。

01 四、經核原判決駁回上訴人在原審之訴，結論尚無違誤，茲就上
02 訴意旨補充論述如下：

03 (一)按「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精
04 神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅
05 之公平原則為之。」業經司法院釋字第420號解釋在案。是
06 以，租稅法所重視者，乃足以表徵稅捐能力之經濟事實，非
07 僅以形式外觀之法律行為或關係為依據，若所得之法律上歸
08 屬名義人與經濟上實質享有人不一致時，於租稅法律解釋
09 上，即應以經濟上實質取得利益者為課稅對象。申言之，人
10 民就私有財產之管領、使用及處分行為，如未違反強行法令
11 或公共秩序與善良風俗者，基於私法自治原則，固得自由為
12 之，但涉及租稅事項之法律效果，則非得任由私人之意思表
13 示決定或規避之，如利用法律形式達到特定之實質經濟目的
14 者，本應轉換成與該經濟事實相當之法律行為態樣，依其對
15 應之稅法規定課徵應納之稅捐。從而，前述司法院釋字第42
16 0號解釋於86年1月17日公布後，如納稅義務人基於獲得租稅
17 利益，違背稅法之立法目的，以合法但非常規的交易形式
18 （濫用法律形式），規避租稅構成要件之該當，以達成與交
19 易常規相當之經濟效果，稅捐稽徵機關為正確計算應納稅
20 額，自得本於該號解釋揭示之實質課稅原則，依其交易常規
21 所對應之稅法規定予以調整。105年12月28日制定公布、公
22 布後1年施行之納保法第7條第1項至第3項規定：「（第1
23 項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精
24 神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅
25 之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之
26 構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟
27 利益之歸屬與享有為依據。（第3項）納稅者基於獲得租稅
28 利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易
29 規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效
30 果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相
31 當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利

息。」係將早因上開解釋公布而對全國各機關及人民有拘束力之實質課稅原則予以明文化，非謂納保法施行前，稅捐稽徵機關依據實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有，認定課徵租稅之構成要件事實，並就此實質經濟事實關係依稅法規範之納稅主體、稅目、稅率等為租稅之核課，即與租稅法律主義有違。

(二)以下事實為原審依職權所確認，核與卷內證據相符，得採為判決之基礎：

- 1.上訴人為林志明之父林德旺創辦之公司，林德旺死亡後，除林志明外，包括林銀等8人在內之其他上訴人股東均無意繼續經營上訴人公司，林志明與林銀等8人乃約定由林志明取得林銀等8人持有之上訴人股權，林銀等8人取得系爭房地。林志明與林銀等8人均明知系爭房地為上訴人所有，並非林德旺所留遺產，林銀等8人無法以繼承方式取得，上訴人乃於96年11月5日由林志明、林銀、林美麗、林美娥、林美櫻等董事決議，將系爭房地售予林志明。
- 2.上訴人於96年11月26日改選董事及監察人，由林志明擔任董事長，林志明於96年12月6日代表上訴人與其個人簽訂系爭房地之買賣契約書，契約總價為5億元，並分別載明房屋售價75,000,000元、土地售價425,000,000元，林志明於96年12月14日向地政機關申辦所有權移轉登記後（移轉登記日為96年12月27日），旋於同年12月26日將系爭房地連同繼承房地售予林銀等8人，契約總價共計1,154,710,097元（系爭房地部分價金為1,074,271,189元）。林銀等8人分3期給付林志明上開買賣價款，第1期款係以其8人因上訴人96年11月26日臨時股東會議決議所獲配現金股利179,953,557元之支票，交由林志明存入其銀行帳戶兌現；第2期款由林銀等8人將所持有上訴人股票共27,651,400股出讓林志明，抵繳房地價款合計799,756,540元；第3期款由林銀、林美櫻、駱金生、林美麗、林美娥分別匯款合計175,000,000元至林志明銀行帳戶，該3期款項均已從林銀等8人應付之房地買賣價金

01 中扣除完畢，並無資金回流情形。又林志明取得林銀等8人
02 持有之上訴人股權後，上訴人之股東自96年12月26日起，僅
03 餘林志明及呂清淼2人，林志明持股比例高達99%。

04 3.林志明並未將出售系爭房地所生財產交易所得列報於其96、
05 97年度綜合所得稅申報。北區國稅局雖於99年間以97年1核
06 處分，對林志明補徵系爭房地交易所得之應納稅額5,058,16
07 3元，惟於102年7月10日、103年3月3日所為2核、3核處分，
08 均認定系爭房地出售予林銀等8人之財產交易所得應歸屬上
09 訴人，林志明對97年2核、3核處分進行行政救濟時，亦未曾
10 主張其出售系爭房地予林銀等8人之交易所得歸屬於其個
11 人，迨至上訴人因對出售系爭房地遭補徵營業稅及裁罰之處
12 分不服，所提行政訴訟，經原審於105年5月11日以營業稅判
13 決駁回後，始於105年12月16日主張該交易所得係歸其所
14 有，而向北區國稅局申請核發97年1核處分對其個人補徵稅
15 額之繳款書。

16 (三)原判決基於以上事實，論明：1.上訴人於96年12月6日以5億
17 元將系爭房地出售予林志明，較諸林志明於短短20日後之同
18 年月26日，以超過1倍有餘之1,074,271,189元，出售予林銀
19 等8人，顯係低價出賣系爭房地，不符上訴人為營利事業，
20 應追求自身利益極大化之商業常情；此舉實質上乃為使林銀
21 等8人取得系爭房地之所有權，以完成雙方約定之分拆處置
22 上訴人資產約定，並重新建構股權分配。2.林志明於96年12
23 月26日取得林銀等8人持有之上訴人股權後，得以享有上訴
24 人盈餘99%之權益，本件差價所得歸屬於林志明自己或上訴
25 人，就林志明個人而言，所受利益並無明顯差別。惟林志明
26 96、97年度綜合所得稅結算申報，並未列報系爭房地交易所
27 得，對97年2核、3核處分所為行政救濟程序中，亦未曾主張
28 本件差價所得歸屬於其個人，迨至上訴人出售系爭房地遭補
29 徵營業稅額及裁處罰鍰之行政爭訟事件，經原審於105年5月
30 11日以營業稅判決駁回後，始為此主張，並於105年12月16
31 日向北區國稅局申請發給97年1核處分核定其應就本件差價

01 所得補繳綜合所得稅之繳款書，其意顯在脫免上訴人各項稅
02 捐債務及罰鍰負擔，難以遽信為真，應認本件差價所得已實
03 質歸屬於上訴人。3.被上訴人綜上事證，認定系爭房地之交易
04 已具備納保法第7條第3項所定「獲得租稅利益之意圖」、
05 「濫用法律形式」、「以非常規交易規避租稅構成要件之該
06 當」，及「稅捐客體已『實質歸屬』於上訴人，達成與交易
07 常規相當之經濟效果」之「稅捐規避」要件，並非無據等
08 語。經核原判決認定系爭房地之2次買賣交易，係上訴人濫
09 用形式所為非常規交易，且獲得租稅利益，乃根據第1、2次
10 交易之買賣契約，顯示系爭房地在極短時間內為兩度交易，
11 售價落差竟高達1倍以上之異常不合理情形，及上訴人因形
12 式上並非第2次交易之相對人，得以免就本件差價所得之應
13 稅部分負擔營利事業所得稅之結果，所為論斷；另就本件差
14 價所得實質上係歸屬上訴人一節，則係綜合林志明持有上訴
15 人公司股權之比例高達99%，對於該差價所得應歸屬自己或
16 上訴人，具有主導決定權，惟林志明96、97年綜合所得稅申
17 報並未列報本件差價所得，直至上訴人因系爭房地交易遭補
18 徵營業稅額及裁罰處分所提行政訴訟，經原審以營業稅判決
19 駁回後，始為此主張等間接證據與情況證據，本於推理作
20 用，為認定待證事實之基礎，核與證據法則、經驗法則與論
21 理法則尚無違背。至於原判決援引本院105年度判字第629號
22 及106年度判字第11號判決，有關營利事業出售土地所得固
23 為免稅所得，惟仍屬營利事業之盈餘，於分配予股東時應計
24 入其個人綜合所得總額課稅之見解，敘及本件差價所得如歸
25 屬上訴人，於上訴人分配盈餘予林志明時，將致林志明個人
26 之綜合所得稅負大幅增加等語，既非針對上訴人本身因前揭
27 非常規交易所獲稅捐利益而為論述，核屬旁論，並不影響上
28 訴人所為該當租稅規避要件之認定。從而，原判決維持被上
29 訴人依實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享
30 有，以上訴人實際交易對象為林銀等8人，及以林銀等8人買
31 受系爭房地之總價金1,074,271,189元為實際交易價格，核

01 算上訴人漏報出售房屋增益75,066,349元【（房屋含稅售價
02 核定數153,819,667元÷1.05）－（房屋購入成本79,582,450
03 元－累計折舊22,791,868元）－已申報出售房屋增益14,63
04 7,989元】，就該漏報之應稅所得補徵營利事業所得稅額18,
05 766,587元（75,066,349×25%），結論並無違誤。上訴意旨
06 仍執詞主張：本件差價所得係由林志明個人取得，且上訴人
07 因對林志明請求返還差價利益之損害賠償請求權已罹於時效
08 而消滅，無從請求返還，原判決竟認定該差價利益歸屬上訴
09 人，顯與林志明於原審到庭陳述其絕非為規避稅務才做這些
10 交換等語，及其確實取得林銀等8人股權等事證相違背，並
11 忽略本件主要係家族分產之性質，非純粹公司出售房地云
12 云，核係就原審取捨證據、認定事實之職權行使為指摘，並
13 非可採。

14 (四)再按行為時所得稅法第110條第1項規定：「納稅義務人已依
15 本法規定辦理結算申報，但對依本法規定應申報課稅之所得
16 額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額2倍以下之罰鍰。」
17 行政罰法第7條第1項規定：「違反行政法上義務之行為非出
18 於故意或過失者，不予處罰。」又納保法第7條第8項規定：
19 「第3項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納
20 稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或
21 提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在
22 此限。」第10項規定：「本法施行前之租稅規避案件，依各
23 稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第3項、第7項及第8項
24 規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第7項
25 所定滯納金及利息之總額。但有第8項但書情形者，不適用
26 之。」稅捐逃漏與稅捐規避並非互斥之法律概念，單一案件
27 中之納稅義務人可能同時該當稅捐規避與稅捐逃漏之要件。
28 依前揭納保法第7條第8項但書規定，納稅義務人如先有租稅
29 規避行為存在，其後在申報稅捐階段，又違反誠實義務，對
30 於與稅捐規避行為有關之重要事實予以隱匿、陳述不實或提
31 供不正確資料，致使稅捐稽徵機關因而短漏核定稅捐者，即

違反誠實申報義務，並因其事前之租稅規避行為，已彰顯其主觀上有利用稅捐實證法存在之法律漏洞，進行避稅之意圖，足認其就事後申報稅捐階段之違反誠實義務亦具主觀歸責事由，而構成稅捐逃漏之違法行為。原判決依調查證據之辯論結果，敘明：判斷本件上訴人有無隱匿重要事項之關鍵，在於上訴人申報稅捐及調查階段所提出之書面資料，是否僅限於證明上訴人出售系爭房地予林志明之第1次交易事實，並未及於同時能證明林志明出售系爭房地予林銀等8人之第2次交易事實。上訴人於97年5月27日辦理96年度營利事業所得稅結算申報，並未揭露系爭房地有第2次交易之事實，第2次交易之事實係稽徵機關所自行查得，是上訴人引用片段事實，掩飾全貌，乃隱匿重要事實，應有納保法第7條第8項但書規定之適用，因而構成稅捐逃漏違章行為，並在主觀上具有可責性，應處以漏稅違章行政罰，且不受納保法第7條第10項中段規定之限制，被上訴人依行為時所得稅法第110條第1項規定，按所漏稅額處1倍罰鍰18,766,587元，相對於上訴人出售系爭房地之利得，並無過重之裁量違法情事，認事用法並無違誤，原判決予以維持，亦無不合。

(五)復按營利事業所得稅查核準則（下稱查核準則）第32條第4款，係規定出售或交換房屋或土地等資產時，房屋款或土地款之時價，應參酌該款第1目至第9目所列資料予以認定，其中第8目為「其他具參考性之時價資料」。依原審確認之事實，被上訴人係根據林志明與林銀等8人所訂買賣契約書，約定系爭房地與繼承房地之買賣總價合計1,154,710,097元，按房屋評定標準價格及土地公告現值計算之總現值為332,667,815元，其中系爭房地之現值為309,493,656元，占比為93%，計算系爭房地之售價為1,074,271,189元。原判決論明：林志明出售系爭房地與繼承房地予林銀等8人，既為終局移轉，買受人林銀等8人就系爭房地與繼承房地之全部價款1,154,710,097元，又係以貨幣或有客觀淨值評價基礎之股票支付，且無資金回流，在未查得其間具備「合謀影響

公、私第三方利益，刻意偏離市價」之動機，或有「履約資金回流」之情況下，雙方依約忠實履行之實際售價，自屬判斷系爭房地市價之最佳參考座標等語，詳述其認定系爭房地第2次交易之價格，為判斷上訴人出售系爭房地增益之具參考性時價資料，兩相對照之下，第1次交易價格5億元明顯偏低而非合理之理由，並無違反證據法則、經驗法則及論理法則之違法，且與前揭查核準則第32條第4款第8目規定尚無不符，亦無判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等理由不備情形。上訴意旨主張：上訴人將系爭房地以每坪33.24萬元售予林志明，參諸各不動產仲介公司所提供系爭房地鄰近物件當時實際成交價格，每坪約介於30.87至72.4萬元間，及系爭房地緊臨大安超高壓變電所等情，並未較市價偏低。原判決未實地進行查核，亦未考慮減除收購林銀等8人對上訴人持股之價格，逕以林志明轉售系爭房地予林銀等8人之價格，認定上訴人低價賤賣系爭房地，與查核準則第32條第4款規定不符，且有判決理由不備之違法云云，自無可採。且由上可知，原判決所肯認被上訴人核計之系爭房地售價1,074,271,189元，並非以林銀等8人原持有上訴人股權之淨值為計算基準，要不生上訴意旨所指系爭房地之價格與林銀等8人股票帳面淨值產生連動，將因股權價值漲跌而變動情事。上訴意旨另主張：原判決認定上訴人售予林志明之系爭房地應為1,074,271,189元而非5億元，則上訴人應列報出售資產增值變為866,248,401元（292,677,212元+574,271,189元），上訴人公司股票每股淨值如被上訴人稅務員查簽之38.24元，林銀等8人股票帳面淨值則由799,756,540元調升為1,057,389,536元，再假設上訴人出售價格為15億元，則上訴人股票每股淨值將因此調升為46.177元，林銀等8人股票帳面淨值再由1,057,389,536元調升為1,276,858,697元，造成系爭房地不斷提高價格才能與股票帳面淨值相吻合之惡性循環，原判決對此未予詳查，係屬違誤云云，乃出於對原

處分核計系爭房地出售增益方式之錯誤理解，及執於本件實際上並未發生之假設情形，而為指摘，無從憑認原判決有何違背法令情事，自無足取。

(六)上訴意旨雖又主張：被上訴人既認林志明以第2次出售系爭房地予林銀等8人之收入應歸屬上訴人，則林志明因第2次交易所繳納之契稅、登記費、書狀費、印花稅等費用，自應為上訴人之費用，方符合稅法上收入與費用配合原則，原判決否准認列，顯違納保法第7條規定云云。惟按契稅條例第4條規定：「買賣契稅，應由買受人申報納稅。」土地法第76條第1項規定：「聲請為土地權利變更登記，應由權利人按申報地價或權利價值千分之一繳納登記費。」是以，系爭房地由林志明以第2次交易出售予林銀等8人所生契稅及登記費，依法應由買受系爭房地及經移轉登記而取得所有權之林銀等8人負擔，非由出賣人林志明支付。另依原判決引為認定事實依據之林志明與林銀等8人所訂買賣契約書「五、稅捐負擔」(3)約定：「買方取得產權登記所須支付……登記規費，即應貼印花稅等費用，由買方負擔。」有關係爭房地第2次買賣交易之契據應貼印花稅及買受人取得房地所有權狀所須支付之書狀費，亦歸林銀等8人負擔，卷內復查無林志明與林銀等8人訂定系爭房地第2次交易之買賣契約後，為履約而繳納契稅、登記費、書狀費、印花稅之單據或憑證，上訴人主張林志明曾為第2次交易而支出該等稅費，計算上訴人出售系爭房地之交易所得時，應將該等稅費數額扣除云云，自非可採。原判決就上訴人於原審已提出之此項主張，認前述費用乃其從事稅捐規避行為所為支出，如容許納稅者申報，等同鼓勵納稅者刻意拖延稽徵，增加稅捐機關的稽徵成本，自不能將此等費用列為計算稅負減項，因而未予採認，理由雖有不同，惟結論並無不合。上訴意旨再執業經原判決論駁不採之上述陳詞，重複爭議，洵無足取。

五、綜上所述，原判決將原處分（含復查決定）及訴願決定均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。上訴論旨，仍

01 執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應
02 予駁回。

03 六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1
04 項、第98條第1項前段，判決如主文。

05 中 華 民 國 113 年 8 月 26 日

06 最高行政法院第四庭

07 審判長法官 王 碧 芳

08 法官 許 瑞 助

09 法官 王 俊 雄

10 法官 侯 志 融

11 法官 鍾 啟 煒

12 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

13 中 華 民 國 113 年 8 月 26 日

14 書記官 廖 仲 一

臺北高等行政法院判決

) FKT64W1Z1X5L0;@107年度訴字第

) FKT64W1Z1X5L0;@108年1月10日辯

原告 大東電業股份有限公司

代表人 林志明

訴訟代理人 黃合文 律師

施博文 會計師

被告 財政部臺北國稅局

代表人 許慈美

訴訟代理人 劉淑珍

上列當事人間營利事業所得稅事件，原告不服財政部中華民國107年6月13日發文字號台財法字第10613950300號（案號：第00000000號）訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：原告民國96年度營利事業所得稅結算申報，列報出售資產增益新臺幣（下同）292,077,212元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，被告原核定出售資產增益291,329,025元及免徵所得稅之出售土地增益271,124,660元，嗣依財政部北區國稅局（下稱北區國稅局）通報，原告短漏報房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元等情，審理結果，重行核定出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補稅額18,766,587元，並按所漏稅額18,766,587元處以1倍罰鍰18,766,587元。原告不服，申請復查，未獲被告106年9月1日財北

01 國稅法一字第1060034071號復查決定（下稱復查決定）變更
02 ，提起訴願復經決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

03 二、原告主張：伊於97年5月31日前即辦理96年度營利事業所得
04 稅結算申報，故核課期間於102年5月31日屆滿，被告於102
05 年6月方核定補稅及裁罰，已逾稅捐稽徵法第21條第2項規定
06 之5年核課期間。又伊出售臺北市○○區○○段2小段384、3
07 85-1、385-2地號等3筆土地（應有部分各為936/1,000），
08 及坐落該等土地內之臺北市○○區○○路○段○○○號1樓、
09 10樓、地下1樓（3間）、203號1至12樓、地下1樓（13間）
10 、205號1至10樓、地下1樓（11間）等合計27間房屋（前開
11 房地合稱系爭房地）之對象為訴外人林志明，並非訴外人
12 林銀、駱金生、駱俊銘、姚建安、卓維和、林美櫻（駱金生
13 之配偶、駱俊銘之母）、林美娥（姚建安之母）、林美麗（
14 卓維和之配偶）等8人（下稱林銀等8人），出售價格與鄰近
15 物件斯時之實際交易價格相近，並無偏低情形，且伊與林志
16 明於法律上為不同權利主體，對林志明轉售系爭房地予林銀
17 等8人，無權干涉，林志明轉售所得差額款項，亦未匯入伊
18 帳戶，故伊並非透過林志明作為人頭戶而實際與林銀等8人
19 交易。被告未提出相關證據資料亦未實質查核，復未依所得
20 稅法第43之1規定，報經財政部核准按營業常規予以調整，
21 逕行援引98年5月13日始增訂之稅捐稽徵法第12條之1規定，
22 採推計課稅方式，認定伊與林志明間就系爭房地之買賣交易
23 ，係屬虛偽安排，實際交易對象為林銀等8人，將林志明轉
24 售系爭房地之價格1,074,271,189元，作為伊出售系爭房地
25 之價格，違反法律不溯及既往原則、行為時營利事業所得稅
26 查核準則（下稱查核準則）第114條第1項及納稅者權利保護
27 法所定實質課稅原則。又被告既將林志明轉售系爭房地之收

入，全額認定為伊出售資產之增益，卻未依法扣除林志明因轉售系爭房地而繳納之契稅2,547,576元、登記費125,642元、書狀費2,240元、印花稅267,000元，自有違誤；又系爭房地應補繳之營業稅為3,753,317元，罰鍰為5,629,975元，既經最高行政法院106年度判字第268號判決確定在案，被告核課營利事業所得稅時，未將應補繳之營業稅及罰鍰數額予以扣除，實有稅上加稅之違誤。再者，伊辦理96年度營利事業所得稅結算申報時，對於出售系爭房地之資產增益291,329,025元，已全數揭露，並無隱瞞，被告以推計方式課稅，復處以罰鍰，有違行政罰法第4條處罰法定主義及稅捐稽徵法第12條之1規定。退步言之，被告裁處時，營利事業所得稅之稅率已由25%降為17%，被告未依調降後之稅率計算應補稅額再處罰鍰，有違稅捐稽徵法第48條之3之從新從輕原則，自屬違誤。並聲明：訴願決定、原處分（含復查決定）均撤銷。

三、被告抗辯：本件同一事實營業稅部分，經北區國稅局查得，原告與林志明之房地買賣交易係屬虛偽安排之不實交易，原告之實際交易對象為系爭房地之最終所有人林銀等8人，因其交易合約書未分別載明土地及房屋之售價，乃就系爭房地售價1,074,271,189元（含稅），按房屋評定標準價格占土地公告現值及房屋評定標準價格合計總額之比例，核算房屋售價為153,819,667元 { 含稅， $1,074,271,189 \times (42,494,400 \times 1.05) \div 266,999,256 + (42,494,400 \times 1.05) \vee$ }，減除已申報之房屋售價75,000,000元後，核算漏報銷售75,066,349元（ $153,819,667 - 75,000,000$ ） $\div 1.05 \vee$ ，核定補徵營業稅額3,753,317元。原告不服，循序申請復查、提起訴願及行政訴訟，經最高行政法院106年

度判字第268號判決駁回上訴而告確定。是以，原告銷售系爭房地之對象，自始即為林銀等8人，原告乃形式上藉由林志明先低價購入系爭房地，連同林志明繼承所得之房地，旋即於同年月加價出售予林銀等人，致數億元之鉅額價差利益流入林志明名下，顯係濫用私法自治之法律形式，被告基於同一漏報營業稅事實，重行核定原告96年度營利事業所得稅出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補稅額18,766,587元，自屬有據，且與納稅義務人未能提示帳簿文據備查，依所得稅法第83條規定，以同業利潤標準核定所得額之情況，並不相同。又原告96年度營利事業所得稅結算申報，係屬會計師簽證案件，依簽證報告中出售資產增益之查核報告所載，可知原告就出售系爭房地之成本，已於當年度營利事業所得稅申報時全額列報，並經被告全數核認，自無再次減除之理。另依查核準則第90條第1款規定，依營業稅法第51條、第52條規定追繳或繳納之營業稅，不得列為本事業之費用或損失；同條第6款規定各種法規所科處之罰鍰，不予認定，故原告經北區國稅局核定補徵之營業稅額及所裁處罰鍰，自不得列為費用或損失。再者，原告為系爭房地之出賣人，非買受人，其負擔之土地增值稅已列報扣除，且其所提繳納契稅、印花稅、登記費、書狀費之憑證上所載納稅義務人並非原告，該等費用自不得減除。又原告係於97年5月29日以網路辦理96年度營利事業所得稅結算申報，核課期間自其申報日起算至102年5月28日屆滿，被告核定原告短漏報系爭房地交易所得之核定通知書、罰鍰裁處書及繳款書，係於102年5月7日送達原告，未逾核課期間。原告96年度漏報上述出售資產增益及免徵所得稅之出售土地增益，逃漏應繳納之稅負，違章事證明確，已非

單純不作為，核屬故意，且原告未於裁罰處分核定前，以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰，則被告依原告行為時有效之所得稅法第5條第5項規定之稅率計算核定稅額，再依同法第110條規定，按所漏稅額18,766,587元處以1倍罰鍰18,766,587元，並無違誤。並聲明：駁回原告之訴。

四、如事實概要欄所載之事實，有原告96年度營利事業所得稅網路申報書、被告96年度營利事業所得稅結算申報核定通知書、96年度營利事業所得稅結算申報更正核定通知書、被告申報核定通知書調整法令及依據說明書、復查決定書及訴願決定書，附原處分卷第301至304、1239、1238、1240、1265至1275及1287至1300頁可稽，且為兩造所不爭執，堪信為真實。

五、經核本件爭點為：被告以原告96年度營利事業所得稅結算申報，漏報系爭房屋交易所得75,066,349元及土地交易所得495,451,522元，核定原告出售資產增益861,846,896元及免徵所得稅之出售土地增益766,576,182元，應補稅額18,766,587元，並按所漏稅額18,766,587元處以1倍之罰鍰18,766,587元，有無違誤？經查：

（一）漏報出售資產增益及免徵所得稅之出售土地增益部分：

1.按行為時所得稅法第4條第1項第16款規定：「左列各種所得，免納所得稅……十六、個人及營利事業出售土地……其交易之所得。」第5條第5項第3款規定：「營利事業所得稅起徵額、課稅級距及累進稅率如左：……三、超過十萬元以上者，就其超過額課徵百分之二十五。」第9條規定：「本法稱財產交易所得及財產交易損失，係指納稅義務人並非為經常買進、賣出之營利活動而持有之各種財產，因買賣或交

換而發生之增益或損失。」第24條第1項前段規定：「營利事業所得之計算，以其本年度收入總額減除各項成本費用、損失及稅捐後之純益額為所得額。」第38條規定：「經營本業及附屬業務以外之損失，或家庭之費用，及各種稅法所規定之滯報金、怠報金、滯納金等及各項罰鍰，不得列為費用或損失。」次按行為時查核準則第32條第1款前段規定：「出售資產之售價，大於資產之未折減餘額部分，應列為出售資產收益課稅。但出售土地及依政府規定儲備戰備物資而處理財產之增益，免納所得稅；如有損失，應自該項增益項下減除。」第90條第1款規定：「稅捐：一、個人綜合所得稅及依加值型及非加值型營業稅法第51條、第52條規定追繳或繳納之營業稅，不得列為本事業之費用或損失。……六、各種稅法所規定之滯納金、滯報金、怠報金等及各種法規所科處之罰鍰，暨未依法扣繳而補繳之稅款不予認定。」

2. 次按「憲法第19條規定人民有依法律納稅之義務，係指人民僅依法律所定之納稅主體、稅目、稅率、納稅方法及納稅期間等項而負納稅之義務。至於課稅原因事實之有無及有關證據之證明力如何，乃屬事實認定問題，不屬於租稅法律主義之範圍。」「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。」業經司法院釋字第217號、第420號解釋在案。嗣稅捐稽徵法參照上開420號解釋意旨，於98年5月13日增訂公布第12條之1第1、2項規定：「（第1項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利

01 益之歸屬與享有為依據。」102年5月29日再修正增訂同條第
02 3項規定：「納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立
03 法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成
04 與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。」將租稅規避行
05 為之認定作為一般性之法律規範，以避免實質課稅原則與租
06 稅法律主義之衝突。又105年12月28日制訂公布、106年12月
07 28日施行之納稅者權利保護法第7條第1至3項規定，內容與
08 前引稅捐稽徵法第12條之1第1至3項完全相同，旨在重申實
09 質課稅原則為租稅法上重要原則。是稅捐稽徵機關依據實質
10 經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有，認定課
11 徵租稅之構成要件事實，並就此實質經濟事實關係依稅法規
12 範之納稅主體、稅目、稅率等為租稅之核課，難謂有違租稅
13 法律主義。

14 3.經查：

- 15 (1)原告於96年11月26日改選董事及監察人，由林志明擔任董事
16 長，林美櫻擔任監察人，林志明嗣於96年12月6日代表原告
17 與林志明個人簽訂買賣契約，將原告所有之系爭房地出售予
18 林志明，合約總價為500,000,000元，分別載明房屋售價75,
19 000,000元、土地售價425,000,000元，林志明並於96年12月
20 14日向地政機關申辦系爭房地所有權移轉登記，登記移轉日
21 為96年12月27日等情，有股東臨時會議紀錄（原處分卷第61
22 5至619頁）、原告與林志明所訂買賣契約書（同卷第655、6
23 56頁）、土地及建築改良物所有權買賣移轉契約書（同卷第
24 691至697頁）、異動索引查詢資料（同卷第713、717、722
25 頁）附卷可稽。林志明旋於96年12月26日，將系爭房地及其
26 繼承取得之臺北市○○區○○段2小段384、385-1、385-2地
27 號土地（應有部分各為64/1000），與坐落該等土地內之臺

01 北市○○區○○○路○段○○○號11樓房屋，分別以354,539,95
02 6元、241,592,254元、21,303,416元、249,418,206元、21,
03 299,000元、139,785,261元、105,468,588元及21,303,416
04 元，合計總價1,154,710,097元，出售予林銀、姚建安、林
05 美麗、卓維和、林美櫻、駱金生及駱俊銘等8人，另有林志
06 明與林銀等8人所訂買賣契約書，附原處分卷第648、649、6
07 34、635、608、609、640、641、598、599、630、631、626
08 、627、620、621頁足憑。林銀等8人購買前述房地，按房屋
09 評定標準價格及土地公告現值計算之總現值為322,667,815
10 元，其中原告所有系爭房地之現值為309,493,656元，而林
11 志明繼承而得房地之現值為23,174,159元（參見原處分卷第
12 732頁），兩者現值占比分別為93.00000000%（ $309,493,656 \div 332,667,815 = 93.00000000\%$ ）及6.00000000%（ $23,174,159 \div 332,667,815 = 6.00000000\%$ ），依前開占比分算實際
13 成交價額，原告所有系爭房地之售價為1,074,271,189元（ $1,154,710,097 \times 93.00000000\% = 1,074,271,189$ ），林志明
14 繼承而得房地之售價為80,438,906元（ $1,154,710,097 \times 6.00000000\% = 80,438,906$ ）。是以，原告於96年12月6日以500
15 ,000,000元出售予林志明之系爭房地，於短短20日後（即96
16 年12月26日），竟由林志明以超過其買進價格1倍有餘之1,0
17 74,271,189元，出售予林銀等8人，顯見原告係低價賤賣系
18 爭房地，致使高達5億7千餘萬元（ $1,074,271,189 - 500,000,000 = 574,271,189$ ）之價差利益流向林志明，此一交易行為
19 ，與原告係以營利為目的之事業，應追求自身利益極大化之
20 商業常情明顯不符。

21
22
23
24
25
26 (2)次查，觀諸林志明以102年5月27日安建（102）稅（一）第00342
27 D號函（原處分卷第836至838頁）所為之說明：「……說明

01 人為大東公司創辦人林德旺先生繼承人之一，林德旺先生於
02 民國00年逝世，其繼承人除說明人一子外，另有收養之長子
03 林永順君及7女等計9人……繼承人張林美女家族及林永順家
04 族所持有大東公司股權係由說明人以現金購入方式換取，故
05 分別於95年11月5日及96年11月9日與張林美女家族及林永順
06 家族簽訂股票買賣契約書……各以……201,560,000元及215
07 ,000,000元換得大東公司股權5,968,600股及9,866,600股…
08 …此二人家族之大東公司股權均透過說明人給付現金取得，
09 故此二人自始並未參與說明人與其他繼承人股權之換取過程
10 ……其餘繼承人林銀君、林美娥君、林美麗君及林美櫻君…
11 …等人，因說明人已無鉅額現金可再取得其股權，經雙方協
12 議後乃改以大東公司名下位於臺北市○○○路○段……房地
13 之產權交換……然因系爭不動產非遺產標的，無法由林銀君
14 等4位繼承人直接繼承取得，故安排由說明人於96年12月6日
15 先以5億元購買名義取得系爭不動產後，再於同年度12月26
16 日簽訂房屋買賣契約書並依約支付價金……將該不動產讓與
17 林銀、林美娥家族（含姚建安君）、林美麗家族（含卓維和
18 君）及林美櫻家族（含駱金生及駱俊銘君），以交換該等人
19 員原所持有大東公司之全部股權」，暨林志明於102年3月27
20 日代表原告出具之函（原處分卷第741頁）載稱：「……經
21 家族成員商議結果，決定由林志明取得所有其他股東之大東
22 公司股份，但大東公司位於臺北市○○○路○段……房地…
23 …須讓予其餘……股東……於此共識下，大東公司須先將系
24 爭不動產出售予林志明，以與其他股東交換大東公司之股份
25 。亦即整個交易『形式上』為大東公司出售系爭不動產予林
26 志明，另由林志明向其他股東購買大東公司股權」等語，可
27 見林志明與林銀等8人明知系爭房地屬原告所有，並非林志

明等人之被繼承人林德旺所留遺產，林銀等8人欲取得系爭房地，無法以繼承方式為之；原告於96年11月5日由林志明、林銀、林美麗、林美娥、林美櫻等董事決議，將系爭房地出售林志明（參見原處分卷第744頁），實質上乃為使林銀等8人取得系爭房地所有權。

- (3) 按「董事為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，由監察人為公司之代表。」乃行為時公司法第223條所明定。其立法意旨在禁止雙方代表，以保護公司（本人）之利益，非為維護公益而設，自非強行規定，故董事與公司為買賣等法律行為違反該規定，並非當然無效（最高法院98年度台上第2050號判決意旨參照）。惟林志明擔任原告董事長，就其自身與原告所為系爭房地之買賣法律行為，卻未依法由監察人林美櫻為原告之代表，而於96年12月6日代表原告與自己締結系爭房地買賣契約，逕由原告以500,000,000元之價額出售系爭房地予林志明；且觀之原告與林志明締結之房屋買賣契約書，第6條「違約處罰」第(一)項：「乙方（即原告）除因不可抗力之事由外，其逾期交屋每逾1日按房地總價千分之□計算違約金與甲方（即林志明，下同）。」及第(二)項：「甲方全部或一部分不履行本約第3條附件(二)付款表之規定付款時，其逾期部分，甲方應加付按千分之□計算之滯納金。」關於違約金及滯納金之計算標準，竟為空白而未填具內容；另同契約第7條雖約定賣方應依合約「第12條」及「第14條」履行責任，惟該契約書內並無所稱「第12條」及「第14條」之條款內容；又同契約第10條雖約定由連帶保證人執有一份合約為憑，惟該契約根本未記載「連帶保證人」為何人等草率之情（參見原處分卷第655、656頁），則原告出售系爭房地予林志明，買賣雙方間是否徒具形式，而

01 未有實際議約及磋商，已非無疑。又林志明自原告取得系爭
02 房地後，連同其繼承所得之房地，旋即與林銀等8人立約，
03 以總價1,154,710,097元出售系爭房地，已如上述；林志明
04 於96年12月28日給付原告之第一期房地款179,953,557元，
05 係來自林銀等8人將原告96年11月26日臨時股東會議決議分
06 配現金股利410,000,000元中，林銀等8人獲配共計179,953,
07 557元（410,000,000元X林銀等8人持有股數27,651,400股/ $\sim$ x5；
08 原告已發行股份總數63,000,000股）（參見原處分卷第615
09 至619頁會議紀錄），林銀等8人並將獲配股利之支票交付林
10 志明，供其於96年12月27日存入銀行帳戶兌現（參見原處分
11 卷第801、804、807、810、813、816、819、822頁支票及第
12 799頁存摺影本）；而林志明於97年9月30日支付原告第2期
13 房地款320,046,443元前，林銀於97年2月27日，林美櫻、駱
14 金生、林美麗及林美娥於同年月29日，分別將其等各自與林
15 志明所訂買賣契約約定之第三期款金額（依序為17,678,215
16 元、32,522,886元、20,916,207元、51,255,514元、52,627
17 ,178元，總計75,000,000元），匯至林志明銀行帳戶（參見
18 原處分卷第797頁之存摺影本及第824、809、806、815、821
19 頁買賣契約書所載），足見林志明交付原告之系爭房地買賣
20 價款，多由林銀等8人支應。再者，依原告之資產負債表顯
21 示，其於96年12月31日帳載公司淨值（即股東權益合計數）
22 為1,834,879仟元、發行股數為63,000仟股（股本630,000仟
23 元 $\div$ 每股面額10元=發行股數63,000仟股，參見原處分卷第
24 301頁），每股淨值為29.13元（公司淨值1,834,879仟元 $\div$
25 63,000仟股=每股淨值29.13元）；原告95年12月31日帳載
26 公司淨值為1,879,729仟元、發行股數為63,000仟股（股本
27 630,000仟元 $\div$ 每股面額10元=發行股數63,000仟股，參見

原處分卷第53頁)，每股淨值為29.84元（公司淨值1,879,729仟元÷63,000仟股＝每股淨值29.84元）；而林銀等8人與林志明所訂買賣契約書，約定第2期款係將林銀等8人持有之原告公司股票，以每27.2元至30元之價格計價，以合計799,756,540元價格出讓林志明（參見原處分卷第649、635、609、641、599、631、627、621頁），核與原告公司95及96年每股淨值約29元，亦屬相當。是以，系爭房地之銷售，原即係以林銀等8人為對象，且林銀等8人以獲配原告股利、匯款及所持有之原告股票作價等方式，支付之系爭房地價金為1,154,710,097元，遠高於原告出售系爭房地予林志明之價格500,000,000元，復參酌林志明以其本人或代表原告所提上開書面說明，及原告與林志明所訂買賣契約存有前述諸多顯而易見之漏洞等情，足徵原告未將系爭房地逕行出售林銀等8人，而迂迴先售予林志明，無非係因林志明擬取得林銀等8人於原告公司之股權，惟無鉅額現金可以支付，乃藉由林志明於96年12月6日，「形式上」以5億元低價購入原告所有系爭房地，旋即於同年月26日加價至1,154,710,097元而出售予林銀等8人，致數億元之鉅額價差利益流入林志明名下，以充足林志明向林銀等8人購買原告公司股票之財力，而林銀等8人則達成終局取得系爭房地之目的。且就原告而言，其出售系爭房屋之增益達153,819,667元（計算方式詳見以下(4)所述），惟其僅列報形式上售予林志明部分之房屋價格75,000,000元，其餘未申報之房屋銷售額【含營業稅為78,819,667元（153,819,667元-75,000,000元=78,819,667元），未稅銷售額為75,066,349元（78,819,667元÷1.05=75,066,349元）】，則轉換為林志明個人僅按財政部頒標準核定之財產交易所得12,313,284元（計算方式參見原處分卷第732

頁)；另北區國稅局依系爭房地銷售之實質經濟事實關係，認原告之實際交易對象為系爭房地之最終所有人林銀等8人，核定原告漏報系爭房屋之銷售額75,066,349元，依加值型及非加值型營業稅法(下稱營業稅法)第51條第1項第3款規定，核定補徵營業稅額3,753,317元及裁處罰鍰5,629,975元，原告不服，循序提起行政訴訟，由本院104年度訴字第1681號判決駁回，原告所提上訴復經最高行政法院106年度判字第268號判決駁回而確定等情，復有上述本院及最高行政法院判決附原處分卷第1152至1198頁足憑。故原告藉由與林志明間就系爭房地所為形式上之買賣交易，致有短漏報營利事業所得稅及營業稅之情，亦甚明確。

- (4)按租稅法所重視者，乃足以表徵稅捐能力之經濟事實，非僅以形式外觀之法律行為或關係為依據，若所得之法律上歸屬名義人與經濟上實質享有人不一致時，於租稅法律解釋上，即應以經濟上實質取得利益者為課稅對象，此即實質課稅原則，早經司法院於86年1月17日作成釋字第420號解釋。綜觀上開事證，可知原告先於96年12月6日以500,000,000元將系爭房地出售林志明，旋由林志明於同年12月26日以總價1,074,271,189元轉售予林銀等8人，乃透過刻意壓低原告出售系爭房地予林志明價格之安排，使林志明取得資金能力以購買林銀等8名家族成員股份，及使林銀等8人終局取得系爭房地所有權，原告亦藉此規劃安排而逃漏營業稅及營利事業所得稅，則被告認定原告實際交易對象為系爭房地之最終所有人林銀等8人，系爭房地實際交易價格應以林銀等8人買賣合約書所載價金計算，而為1,074,271,189元(含稅)，惟因買賣合約書未分別載明土地及房屋之售價，乃就系爭房地售價按房屋評定標準價格占土地公告現值及房屋評定標準價格之

比例，核算房屋售價為153,819,667元{含稅，1,074,271,189元 $\times$ (42,494,400元 $\times$ 1.05) $\div$ 266,999,256元+(42,494,400元 $\times$ 1.05) $\vee$ }及土地銷售額920,451,522元(1,074,271,189元-153,819,667元)，另依原告委任辦理96年度營利事業所得稅結算申報查核簽證之會計師所出具之查核報告，就出售資產增益部分記載：「出售固定資產售價大於未折減餘額，列為財產交易增益，經核有關會計紀錄及開立發票金額相符(詳固定資產說明)。」(參見原處分卷第79頁)及就固定資產部分之查核說明：「本期出售土地成本102,546,266元，售價425,000,000元，繳納土地增值稅51,329,074元，認列出售土地利益271,124,660元；出售房屋成本79,582,450元，沖轉累積折舊22,791,868元，售價71,428,571元，認列出售房屋利益14,637,989元。經核出售合約、土地增值稅繳款書及開立發票金額等有關憑證相符。」(參見原處分卷第72頁)據以計算原告漏報出售房屋增益75,066,349元(153,819,667元 $\div$ 1.05)-(房屋購入成本79,582,450元-累計折舊22,791,868元)-已申報出售房屋增益14,637,989元 $\vee$ 、漏報出售土地增益495,451,522元(920,451,522元-購入成本102,546,266元-土地增值稅51,329,074元-已申報出售土地增益271,124,660元)，核定原告出售資產增益為861,846,896元(原核定291,329,025元+75,066,349元+495,451,522元)及免徵所得稅之出售土地增益為766,576,182元(原核定271,124,660元+495,451,522元)，就其漏報出售房屋增益75,066,349元補徵稅額18,766,587元(75,066,349 $\times$ 25%=18,766,587)，核與原告、林志明、林銀等8人就系爭房地於96年12月間為上開交易時，業經司法院釋字第420號解釋予以肯認之實質課稅原則相符，於法並無違誤

，且無原告所指違反法律不溯及既往原則及納稅者權利保護法第7條第1至3項規定可言；又被告既係依其查得系爭房地出售予林銀等8人之實際價格，核實認定系爭房地之售價，自亦無原告指稱未實質進行查核，有違行為時查核準則第114條第1項規定之情。原告主張：伊係出售系爭房地予林志明，且售價與鄰近物件斯時之實際交易價格相近，並無偏低情形，林志明與伊在法律上為不同主體，伊對林志明轉售系爭房地之事，無權干涉，且林志明轉售所得差額款項，未匯入伊帳戶，被告未實質查核，逕將林志明轉售系爭房地予林銀等8人之價格1,074,271,189元，作為伊出售系爭房地之價格，於法有違云云，無非以其一己主觀見解，爭執被告應以其與林志明間刻意壓低售價且空有形式之系爭房地交易，作為課稅基礎，與前述實質課稅原則之意涵有悖，殊非可採。

4. 原告另主張：被告既認系爭房地之交易流程為非常規交易，卻未依所得稅法第43條之1規定，報經財政部核准按營業常規予以調整，逕採推計課稅方式，認定伊之實際交易對象為林銀等8人，係屬違法云云。惟查，所得稅法第43條之1係針對營利事業與具有從屬關係之國內外其他營利事業間，或該營利事業與對其直接間接享有控制權之另一事業間，就收益、成本、費用與損益之攤計，有以不合營業常規之安排，藉以規避或減少稅負之情形，規定稽徵機關為正確計算該事業之所得額，得報經財政部核准按營業常規予以調整。惟本件原告係與其代表人林志明以違反行為時公司法第223條規定之方式，由林志明代表原告銷售系爭房地予其個人，並刻意規劃壓低系爭房地之買賣價格，使林志明獲取鉅額價差利益，原告並規避應繳納之稅負，故不涉及原告與其他有從屬或控制關係之營利事業間，不合營業常規之安排，自無所得稅

01 法第43條之1規定之適用。又被告核定原告漏報出售系爭房
02 地之資產增益，係以系爭房地最終出售予林銀等8人之實際
03 價格為據，並非依所得稅法第83條規定，以推計方式，依同
04 業利潤標準核定所得額，是原告另指稱被告認定伊出售系爭
05 房地之價格，為林銀等8人買受系爭房地之實際價格，有違
06 所得稅法第43條之1，且係違法推計課稅云云，亦無足取。

07 5.原告又主張：被告既將林志明轉售系爭房地之收入，認係伊
08 之出售資產增益，自應扣除林志明因轉售系爭房地而支出之
09 契稅2,547,576元、登記費125,642元、書狀費2,240元、印
10 花稅267,000元；且伊因銷售系爭房地遭北區國稅局核定補
11 繳之營業稅3,753,317元及罰鍰5,629,975元，亦應扣除云云
12 ，惟查：

13 (1)被告核算原告漏報出售系爭房屋之增益為75,066,349元，係
14 以系爭房屋未含稅之銷售額146,494,920元（153,819,667元
15 ÷ 1.05），扣除原告所委任會計師出具之原告96年度營利事
16 業所得稅查核簽證報告，所列房屋購入成本79,582,450元及
17 累計折舊22,791,868元，再減除原告前已申報出售房屋增益
18 14,637,989元之結果；另被告核定原告漏報出售系爭土地之
19 增益為495,451,522元，則係以土地銷售額920,451,522元，
20 減去上開會計師查核簽證報告所載土地購入成本102,546,26
21 6元及土地增值稅51,329,074元，再減去原告已申報出售土
22 地增益271,124,660元後，所得數額，業如上述。故被告核
23 定原告漏報出售系爭房地之增益，已將原告列報之成本、累
24 計折舊及土地增值稅全數扣除。

25 (2)次查，依營業稅法第51條、第52條規定追繳或繳納之營業稅
26 ，及各種法規所處罰鍰，均不得列為本事業之費用或損失，
27 前引查核準則第90條第1款及第6款規定甚明。承前所述，原

告前係經北區國稅局依營業稅法第51條第1項第3款核定補徵營業稅額3,753,317元及裁處罰鍰5,629,975元，揆諸前揭查核準則條文規定，上述依營業稅法第51條追繳之營業稅及罰鍰，不得列為原告之費用或損失，自其該年度收入總額中扣除，原告主張應予減除，自難採取。

(3)再查，原告所提臺北市稅捐稽徵處大安分處96年契稅繳款書25紙，納稅義務人均為林志明，繳款日期皆在96年12月21日至24日間（參見本院卷第86至99頁），另臺北市稅捐稽徵處96年12月印花稅大額憑證應納稅額繳款書，所載納稅義務人為林志明，繳款日期為96年12月14日（參見本院卷第109頁），又臺北市地政規費及其他收入存根所載申請人及繳款義務人為林志明，繳費日期為96年12月24日（參見本院卷第108頁）。亦即，上開繳款書及存根所列契稅合計2,547,576元、印花稅額267,000元、登記費125,642元及書狀費2,240元，均為林志明在96年12月26日與林銀等8人訂立買賣契約，將系爭房地出售予其8人以前所繳納，故應係林志明因於96年12月6日與原告就系爭房地訂立買賣契約，依該契約第5條約定：「稅捐負擔：……產權登記費、印花稅、契稅、監證費、代辦費、各項規費及臨時或附加之稅捐由甲方（即林志明）負擔。」（參見原處分卷第656頁）而支出之稅費，原告主張該等稅費係林志明因將系爭房地轉售林銀等8人而產生，核與前述繳款書及存根上由收款單位經辦人員所蓋章戳顯示之日期不符，並非可採。惟依前述，林銀等8人既願以1,074,271,189元之價格購買系爭房地，原告卻未直接將系爭房地售予林銀等8人，而基於使林志明取得購買林銀等8人對原告公司之持股所需資金，及使原告逃漏稅捐等目的，於形式上規劃安排由林志明先向原告購買系爭房地；故原告與

林志明間就系爭房地所為上開買賣交易，顯非屬原告經營本業或附屬業務之範疇，林志明基於該項交易之買受人身分，所為上述稅費支出，揆諸前引所得稅法第38條規定，自不得列為原告經營業務及附屬業務之費用，予以減除，是原告主張上開繳款書及存根列載之契稅共2,547,576元、印花稅額267,000元、登記費125,642元及書狀費2,240元，均應自其出售系爭房地之資產增益中扣除，要屬無憑。

6.原告再主張：伊於97年5月31日前即辦理96年度營利事業所得稅結算申報，故核課期間於102年5月31日屆滿，被告於102年6月始核定補稅，已逾稅捐稽徵法第21條第2項規定之5年核課期間云云。惟按稅捐稽徵法第21條第1項第3款、第2項規定：「（第1項）稅捐之核課期間，依左列規定：……三、……故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為7年。……（第2項）在前項核課期間內，經另發現應徵之稅捐者，仍應依法補徵或並予處罰；在核課期間內未經發現者，以後不得再補稅處罰。」第22條第1款規定：「前條第1項核課期間之起算，依左列規定：一、依法應由納稅義務人申報繳納之稅捐，已在規定期間內申報繳納者，自申報日起算。」原告係於97年5月29日以網路申報方式，辦理96年度營利事業所得稅結算申報，有被告所屬大安分局於原告96年度營利事業所得稅網路申報書上所蓋收件章可稽（參見原處分卷第304頁），惟原告係故意以將系爭房地賣價壓低，出售予其代表人林志明之不正當方法，逃漏稅捐，依前引稅捐稽徵法第21條第1項第3款及第22條第1款等規定，其核課期間應至104年5月28日始屆滿；而被告核定原告短漏報系爭房地交易所得之核定通知書，於102年5月7日即已送達原告，有更正核定通知書及中華郵政掛號郵件收件回執，附原

處分卷第1238、1280頁足憑，從而並未逾核課期間，原告主張被告對其核定補稅已逾核課期間云云，仍非可採。

(二) 罰鍰部分：

1. 按所得稅法第110條第1項規定：「納稅義務人已依本法規定辦理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額2倍以下之罰鍰。」次按行政罰法第7條第1項規定：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」又財政部本於中央主管機關地位，為協助所屬稅捐稽徵機關就法律授予裁罰裁量權之行使，斟酌各種稅務違章案件之違章情狀及違章後情形等事項，訂有稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表（下稱裁罰倍數參考表），供其下級機關作為行使裁量權之基準；且其除作原則性或一般性裁量基準外，另有例外情形之裁量基準，核與法律授權目的尚無牴觸。行為時裁罰倍數參考表，關於所得稅法第110條第1項（營利事業所得稅）部分，係分別「一、漏稅額在10萬元以下，處所漏稅額0.5倍之罰鍰。但於裁罰處分核定前，以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰者，處所漏稅額0.4倍之罰鍰。」「二、漏稅額超過10萬元者，處所漏稅額1倍之罰鍰。但於裁罰處分核定前，以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰者，處所漏稅額0.8倍之罰鍰。」及「三、逾期辦理結算申報，符合稅捐稽徵法第48條之1規定，惟嗣後經查明有短漏報所得情事者，按本條第1項規定之倍數處罰。」等不同違章情狀，訂定按所漏稅額裁處自0.4倍至2倍不等之罰鍰，已考量違章行為應受責難程度、所生影響等情狀，無違法律授權裁量之目的，得為所屬稅捐稽徵機關援引為裁罰之準據。至財政部於107年5月22

日修正發布之裁罰倍數參考表，就所得稅法第110條第1項（營利事業所得稅）部分規定：「二、漏稅額超過10萬元者，處所漏稅額0.8倍之罰鍰。但於裁罰處分核定前，以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰者，處所漏稅額0.7倍之罰鍰，其屬下列情形之一者，處所漏稅額0.6倍罰鍰……。三、經查屬故意有本條文第1項漏報或短報依本法規定應申報課稅之所得額者。處所漏稅額1倍之罰鍰。」故營利事業如係故意短漏報所得額，且漏稅額超過10萬元，於裁罰處分核定前，復未以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並願意繳清稅款及罰鍰者，依上開修正後裁罰倍數參考表第三點規定，得裁處所漏稅額1倍之罰鍰，與行為時裁罰倍數參考表第二點相較，並無更有利於納稅義務人之情形。

2. 原告係早於51年7月16日即經核准設立之營利事業（參見本院卷第8頁之公司基本資料），對於營利事業出售資產之售價，大於資產之未折減餘額部分，應列為出售資產收益課稅之規定，自應知悉，詎其由林志明代表銷售系爭房地，卻刻意規劃壓低系爭房地之實際買賣交易價格，以低於實際售價數億元之價格出售系爭房地予林志明，並以前開刻意壓低之500,000,000元售價為據，辦理96年度營利事業所得稅結算申報（其列報土地售價425,000,000元，房屋售價71,428,571元，參見原處分卷第72頁），致短漏報出售房屋增益75,066,349元及免徵所得稅之出售土地增益495,451,522元，核屬故意短漏報所得額甚明，自應受罰。被告審酌原告係故意逃漏應納稅負，漏稅額遠超過10萬元，且未於裁罰處分核定前，以書面或於談話筆（紀）錄中承認違章事實，並繳清稅款及罰鍰，按所漏稅額18,766,587元（ $75,066,349 \times 25\% = 18,766,587$ ）

6,587) 裁處1倍罰鍰18,766,587元，經核並無裁量逾越、濫用或怠惰之違法。又被告係依查得資料，核認原告出售系爭房地之實際對象為林銀等8人，故以林銀等8人之買賣契約書所載價金，認定系爭房地實際交易價格為1,074,271,189元，並據以對原告補稅，非如原告所稱，係推計課稅，業如前述，則原告主張被告以推計之稅額為據對伊裁罰，有違行政罰法第4條處罰法定主義及稅捐稽徵法第12條之1規定云云，殊非可採。再按「稅捐稽徵法第48條之3從新從輕原則僅適用於違反作為或不作為義務而裁處之行政罰，如罰鍰金額或倍數修正之情形，尚不及於除此以外之事項。課徵本稅有關之法律規定或漏稅額之計算等，雖於行為後法律經修正，本稅及據以科處之行政罰所涉及之漏稅額計算，如免稅額、扣除額、稅率等，均適用行為時法律。」（最高行政法院86年1月份庭長評事聯席會議補充決議參照）被告對原告漏報於96年間出售系爭房屋之增益補徵稅額，係針對原告96年度之所得所為，則被告適用行為時有效之所得稅法第5條第5項第3款所定稅率（即25%），核定原告應補稅額18,766,587元，再按該漏稅額，依所得稅法第110條規定裁處1倍罰鍰18,766,587元，揆諸前揭決議意旨，與稅捐稽徵法第48條之3從新從輕原則並無違背，原告復主張：被告裁處時，營利事業所得稅之稅率已由25%降為17%，被告未依調降後之稅率計算應補稅額再處罰鍰，有違稅捐稽徵法第48條之3規定云云，亦難採取。

六、綜上所述，被告對原告補徵96年度營利事業所得稅額18,766,587元及裁處同額罰鍰，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經核均對判

01 決結果不生影響，爰不分別斟酌論述，附此敘明。
02 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
03 1項前段，判決如主文。

04 中 華 民 國 108 年 1 月 31 日

05 臺北高等行政法院第三庭

06 審判長法官 李 玉 卿

07 法官 李 君 豪

08 法官 鍾 啟 煒

09 一、上為正本係照原本作成。

10 二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
11 明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判
12 決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

13 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴
14 訟法第241條之1第1項前段）

15 四、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同
16 條第1項但書、第2項）

17

18 得不委任律師為訴訟
19 代理人之情形

所 需 要 件

20

21 (一)符合右列情形之一
22 者，得不委任律師
23 為訴訟代理人

1.上訴人或其法定代理人具備律師資
格或為教育部審定合格之大學或獨
立學院公法學教授、副教授者。

24

25

26

27

2.稅務行政事件，上訴人或其法定代
理人具備會計師資格者。

3.專利行政事件，上訴人或其法定代
理人具備專利師資格或依法得為專

01		利代理人者。
02		
03	(二)非律師具有右列情	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、
04	形之一，經最高行	二親等內之姻親具備律師資格者。
05	政法院認為適當者	2.稅務行政事件，具備會計師資格者
06	，亦得為上訴審訴	。
07	訟代理人	3.專利行政事件，具備專利師資格或
08		依法得為專利代理人者。
09		4.上訴人為公法人、中央或地方機關
10		、公法上之非法人團體時，其所屬
11		專任人員辦理法制、法務、訴願業
12		務或與訴訟事件相關業務者。
13		
14	是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴	
15	人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明	
16	文書影本及委任書。	
17		

18 中 華 民 國 108 年 1 月 31 日
19 書記官 李 建 德

高雄高等行政法院判決

109年度訴字第322號

民國111年1月5日辯論終結

原告 劉蒼明

劉國樑

劉耀聖

被告 高雄市稅捐稽徵處

代表人 黃惠玲

訴訟代理人 簡莓蓉

林金賢

上列當事人間土地增值稅事件，原告不服高雄市政府中華民國109年7月10日高市府法訴字第10930713400號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、訴願決定、復查決定及原核定處分關於原告劉蒼明移轉高雄市岡山區和平段549地號土地之土地增值稅1,332,188元部分均撤銷。

二、原告其餘之訴駁回。

三、訴訟費用由被告負擔2分之1，餘由原告劉國樑負擔。

事實及理由

一、程序事項：

原告之代表人原為李瓊慧，嗣於本件訴訟繫屬中變更為黃惠玲，已由其具狀聲明承受訴訟（見本院卷第267-271頁），核無不合，應予准許。

二、爭訟概要：

緣原告劉蒼明、劉國樑、劉耀聖（下稱原告3人）原分別共有高雄市岡山區和平段549地號土地（下稱549地號土地），應有部分各為3分之1，該土地使用分區為農業區，面積3,413.05平方公尺。另劉國樑原單獨所有同區大德段104地號土地（下稱104地號土地），該土地使用分區為住宅區，面積3

97.73平方公尺，劉國樑於民國106年8月30日與劉蒼明、劉耀聖訂立贈與契約，將104地號土地應有部分各100分之1分別贈與劉蒼明、劉耀聖形成共有關係，並於同日向被告岡山分處（下稱岡山分處）申報土地移轉現值，經核課土地增值稅共計新臺幣（下同）24,629元。嗣原告3人於107年11月13日將104地號土地分割為同段104、104-1地號土地（下稱分割後104、104-1地號土地），面積分別為184.86平方公尺、212.87平方公尺；復於同年月14日將分割後104、104-1地號土地與549地號土地辦理共有物分割，由劉蒼明單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，549地號土地則由劉國樑取得應有部分100,000分之79,383、劉蒼明取得應有部分100,000分之11,963、劉耀聖取得應有部分100,000分之8,654，經計算原告3人分割前、後應有部分價值增減情形，劉國樑增加143.5元、劉蒼明減少89.5元、劉耀聖減少54元，均在公告土地現值1平方公尺單價6,200元以下，依土地稅法施行細則第42條第2項規定及財政部92年1月14日台財稅字第0910456670號令釋（下稱財政部92年1月14日令），免徵土地增值稅及免申報土地移轉現值。嗣岡山分處查得原告3人藉由贈與小面積土地創設共有關係，再辦理共有物分割，行實質交換移轉土地所有權之實，與常規交換土地經濟效果相同，乃依稅捐稽徵法、土地稅法等規定，以108年9月16日高市稽岡增字第1088569298號函核定按一般用地稅率補徵應納之土地增值稅額為劉國樑1,131,467元、劉蒼明1,332,188元，而劉耀聖則係於106年4月11日因繼承取得549地號土地，故為0元。原告3人不服，申請復查，未獲變更，原告3人仍不服，提起訴願，亦遭決定駁回，於是提起行政訴訟。

三、原告起訴主張及聲明：

(一)主張要旨：

1.本件屬於共有家產分割問題：

(1)被繼承人劉福登於生前購買土地借名登記於其長子劉哲朗、次子劉蒼明及三子劉國樑名下，並要求其子劉哲朗、劉蒼明及劉國樑對其所出資購買或持有土地之全部財產皆為共有（劉福登有4位女兒取得現金），其子並於95年11月15日共同簽立契約同意書，載明劉福登死亡遺留財產第(1)項土地為共有，而死亡遺留財產第(2)項係三人平均繼承共有，故未列入，契約同意書第2行與第3行分別借名登記為劉蒼明與劉國樑之土地，亦載明為3人共有。又劉國樑所有文化段936、1207、1208、1211及1218-1地號土地參與市地重劃，分配取得岡山區大德段104、105地號等2筆土地。嗣因劉哲朗於106年4月11日死亡，全部不動產皆由其子即劉耀聖繼承，原告3人為避免上開家產於日後生變，遂於106年8月30日訂立贈與契約，並同日申報移轉劉國樑所有上揭岡山區文化段890地號土地予劉蒼明，暨岡山區大德段104地號土地各100分之1予劉蒼明及劉耀聖2人形成共有關係，繼於107年11月13日將系爭104地號土地分割成系爭分割後104、104-1地號等2筆土地，復於同年月14日將3人共有之系爭分割後104、104-1地號及549地號土地辦理共有物分割，由劉蒼明取得系爭分割後104地號土地（全部），劉耀聖取得系爭分割後104-1地號土地（全部），而系爭549地號土地，則由劉國樑取得應有部分100,000分之79,383、劉蒼明取得100,000分之11,963、劉耀聖取得100,000分之8,654，茲因上揭3筆共有土地分割後，各共有人所取得之土地價值與其分割前應有部分土地價值相差均在公告土地現值1平方公尺單價下，依規定屬於免申報土地移轉現值之案件。系爭549地號土地改變3人持有土地權利範圍，而劉蒼明取得文化段890地號及系爭分割後104號土地，面積合計212.86平方公尺，劉耀聖取得系爭分割後104-1地號土地，面積212.87平方公尺，上開2人取得土地面積相近，但低於劉國樑所有大德段105地號土地，面積279.96平方公尺，此因劉蒼明與劉耀聖所取

01 得之土地位於三角窗，而劉國樑所有之土地面積雖大，卻
02 較為狹長，故3人所持有之土地市價相近。原告3人依法得
03 以共有物分割方式，各別取得如上揭事實所示之土地，整
04 體過程並未違背共有物分割之意旨。

05 (2)原告3人於109年9月11日提出行政訴訟起訴狀中之「劉福
06 登遺留財產明細表」，載明以自有資金購買土地，並以無
07 行為能力之兒子名義登記為不動產之所有權人，此等財產
08 借名登記法律行為，常見於過去重男輕女之父系社會之習
09 慣，係為當時社會常態，並無不法或不當之處。劉福登雖
10 未留下直接證據證明生前購買之土地屬於借名登記契約之
11 財產，惟借名登記財產之出名人即原告劉蒼明、劉國樑與
12 繼承人劉哲朗皆承認劉福登生前購買及死後遺留之財產為
13 3人共有，並於95年11月15日親自簽名之契約同意書為
14 證；上開3人所立之契約同意書如非事實，則劉蒼明與劉
15 國樑將有損失鉅額利益之風險，即劉耀聖得以上揭契約同
16 意書及本件訴狀中陳述之證據，向劉蒼明與劉國樑請求返
17 還借名登記之財產，畢竟原告3人持有借名登記之財產價
18 值比較，劉耀聖持有之土地價值所佔之比例最低，劉蒼明
19 與劉國樑無須為此節稅問題，偽造假的契約同意書，除須
20 負擔損失財產風險外，亦涉偽造文書之刑事責任；在共有
21 物分割過程中，劉國樑於106年8月30日除了贈與系爭分割
22 後104、104-1地號土地予劉蒼明及劉耀聖外，另於同日贈
23 與高雄市岡山區文化段890地號土地予劉蒼明，並繳納土
24 地增值稅額211,456元，上揭3筆土地如非屬借名登記財
25 產，劉國樑無須將文化段土地贈與劉蒼明。

26 2.被告認為原告3人係憑空故意製造土地共有關係，實質上顯
27 從事土地交換行為，被告之認知明顯錯誤：

28 (1)對於贈與小面積土地創設共有關係，現行法律並未規定共
29 有人至少應持有多少之土地面積，當事人有自由選擇權，
30 無庸置疑；而被告認為上揭共有物分割，在一般正規交易
31 常態，應由劉國樑以系爭分割後104、104-1地號土地，分

別與劉蒼明及劉耀聖交換系爭549地號土地之應有部分，但被告所指在一般正規交易是劉國樑所有系爭分割後104、104-1地號土地之產權均為其單獨所有才能成立，劉國樑持有家產系爭分割後104、104-1及大德段105地號土地之所有權利範圍3分之2歸屬於劉蒼明與劉耀聖，劉國樑豈能以部分劉蒼明與劉耀聖所享有權利之土地再與劉蒼明及劉耀聖之土地從事交換，如若本件改為土地交換結果，則劉國樑將留下積欠劉蒼明與劉耀聖之土地債權、債務之瑕疵；另外，系爭549地號土地，原為共有土地，應當進行共有物分割，豈有被強制以共有土地去做土地交換之事。而且原告3人持有之家產價值相差太大（長男劉哲朗持有之土地價值最少），無法以交換土地方式達到家產分割之結果，是以被告所提出之正常交易當事人、標的物與本件之實情不同，本件之當事人均為劉福登之繼承人，標的物皆為劉福登之土地，原告以共有物分割方式處理家產分配之行為完全符合事實。

(2)所謂土地交換之法律效果適用於民法第398條規定，即當事人雙方約定互相移轉金錢以外財產權者，準用關於買賣之規定。惟本件借名登記之每一筆土地屬於原告3人共有，按照被告陳述可以交換方式達到原告所為共有物分割之結果，此項說法成立之要件，應以交換之每1筆土地標的為當事人單方單獨所有為前提，故被告之陳述已違背土地登記規則之2人交換移轉契約登記規定，即每1筆土地必須單獨所有。況且，原告3人所為共有物分割完全符合原物分配事實，屬於借名登記財產之分割，並非借名登記財產之返還，即劉國樑分割取得岡山區大德段105地號土地（即劉蒼明與劉耀聖不再主張上開土地為共有）；劉蒼明分割取得岡山區文化段890地號與系爭分割後104地號土地；劉耀聖分割取得系爭分割後104-1地號土地。被告逕自認定本件應以「交換」方式作為上揭土地所有權移轉之原因，顯已違背契約自由原則。

01 (3)創設共有土地並非皆屬不法，毗鄰土地因形狀不佳，可依
02 合併、分割及共有物分割登記，將原有土地改變成優良型
03 態之土地，以提高土地利用價值，惟若分割前與分割後土
04 地應有部分價值差額在公告現值1平方公尺以下者，免徵
05 土地增值稅，此為創設共有土地之一種，亦為常見之土地
06 登記案例。原告3人將系爭分割後104、104-1、大德段105
07 地號及文化段890地號與和平段549地號等家產土地分割，
08 並非因土地所有權移轉而有自然漲價之經濟利益，原告僅
09 就原共有家產土地按協議持分分割，將原共有人之共有權
10 利變更為單獨所有，並非蓄意製造外觀上或形式上存在之
11 法律關係或法律狀態，規避或免除應納之土地增值稅，且
12 被告將家產共有誤解為家產單獨所有，故無免徵土地增值
13 稅規定作為類比土地稅法第28條規定之意旨，顯然忽略土
14 地法第72條「土地總登記後，土地權利有移轉、分割、合
15 併、設定、增減或消滅時，應為變更登記。」規定就土地
16 權利移轉及分割二者係為不同類別之定義（最高行政法院
17 56年判字第144號判決意旨參照），故被告向原告課徵土
18 地增值稅之處分，於法無據。

19 3.原告於家產分割後，並無租稅規避及逃漏稅之問題：

20 (1)被告所稱應稅土地為系爭104地號土地，該筆土地為重劃
21 土地，享有第1次移轉之優惠減稅利益，即土地重劃費用
22 扣減（土地稅法第31條第1項第2款）及土地增值稅減徵百
23 分之40（土地稅法第39條第4項），經過贈與、分割後之
24 土地為系爭分割後104、104-1地號土地。而106年8月30當
25 日之贈與移轉土地剩餘98/100面積之增值稅額，依據岡山
26 分處課徵系爭104地號土地，面積397.73平方公尺，權利
27 範圍2/100，核定土地增值稅額為24,629元（即附件六中
28 之稅額110元、24,519元），換算該筆土地其餘權利範圍9
29 8/100，應核課之土地增值稅.額為1,206,821元（附件
30 七），被告認定此筆應核課之金額係原告租稅規避之金
31 額。惟本件分割後之土地，已喪失重劃土地於增值稅享有

之費用扣減及減徵之利益，原告劉蒼明取得之系爭分割後104地號土地，面積184.86平方公尺，前次移轉現值有2項，即75年11月之每平方公尺1,213.3元，權利範圍9,861/10,000，106年8月之每平方公尺25,000.3元，權利範圍139/10,000，107年公告現值每平方公尺25,000元，應核課之土地增值稅額為1,343,845元（附件九）；原告劉耀聖因繼承其父劉哲朗之土地，取得系爭分割後104-1地號，面積212.87平方公尺，該土地之前次移轉現值有2項，106年4月與106年8月每平方公尺皆為25,000.2元（待岡山分處說明），應核課之土地增值稅額為0元；因此，經共有物分割後之土地再移轉所應課徵之土地增值稅額合計為1,343,845元，上開金額大於被告聲稱應稅土地應核課之土地增值稅金額1,206,821元，此即原告強調並未逃避租稅之依據。

(2)原告如若將家產分割後所取得之土地為出售或為贈與之處分，所繳納之土地增值稅大於被告指稱以交換方式所計算之土地增值稅，此係原告犧牲系爭104地號土地重劃費用扣減及百分之40減徵土地增值稅權益，因此，本件以共有物分割之行為，並非將共有土地移轉予不相干之第3人，且以後應繳納之土地增值稅之條件亦未消失，本件之增值稅是延後繳納而已，絕非如被告所說原告係在規避租稅繳納之情形，顯然，被告誤解共有物分割與交換之法律意旨。

(3)被告認定原告3人應以交換原因作為移轉土地所有權補課土地增值稅額2,463,655元（含系爭分割後104地號土地增值稅額525,892元、104-1地號土地增值稅額605,575元、系爭549地號土地增值稅額1,332,188元），遠高於其述之系爭104地號土地之應稅土地增值稅額1,206,821元，顯已違背實質課稅之公平原則；原告於完成借名登記土地之共有物分割，屬於原物分配予共有人之法律行為，符合共有土地於分割後再移轉予第3人，將被課徵土地增值稅之事

實，惟被告於行政訴訟答辯狀中第8頁第11列至第13列載明「應稅土地之前次移轉現值總額由共有物分割前384,231.46元，增加為5,6072,551.71元（詳卷第221頁），……」等詞，查其增加前次移轉現值之原因，在於原告劉耀聖取得系爭分割後104-1地號土地之前次移轉現值被調高為25,000.2元/平方公尺，而劉耀聖係因繼承劉哲朗之土地，導致所繼承系爭549地號土地之前次移轉現值調高至死亡時（106年4月11日）之當年度之公告現值6,200元/平方公尺，如若原告改為劉哲朗生前辦理共有物分割，其應稅土地應繳納之土地增值稅額同於原告劉蒼明之1,343,845元，原告皆不希望被誤解以劉哲朗之死亡作為換取規避租稅之手段，被告劉耀聖持有土地之前次移轉現值被調高之事，顯然是意料之外，如若原告蓄意要規避租稅，當選取第3人之土地代替系爭549地號土地，除了調高劉耀聖取得土地之前次移轉現值外，連原告劉蒼明取得之土地亦應調高前次移轉現值，方屬公平、合理。

(4)被告無理由補課徵非屬應稅標的之岡山區和平段549地號農業區土地增值稅額1,332,188元，此亦已剝奪原告得以在該筆土地主張土地法第39條之2第1項申請不課徵土地增值稅規定之權利，顯違憲法第19條租稅法律規定。

(二)聲明：訴願決定、復查決定及原核定處分均撤銷。

四、被告答辯及聲明：

(一)答辯要旨：

1.原告雖主張系爭分割後104與104-1地號土地為劉福登生前購買借名登記於劉國樑名下，且劉蒼明、劉國樑與劉耀聖之父劉哲郎曾於95年11月15日立約協議歸於3人共有，惟未經登記，自不生物權效力；又上開協議係將系爭分割後104與104-1地號應稅土地持分平分為3等分所共有，而原告3人僅移轉極為微小之持分（應有部分100分之1）刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事互換土地之行為，並使系爭分割後104與104-1地號應稅土地之前

01 次移轉現值總額由共有物分割前384,231.46元，增加5,607,
02 255.71元，進而取得日後移轉土地時土地漲價總數額降低之
03 經濟利益。且原告劉國樑贈與劉蒼明、劉耀聖之系爭104地
04 號土地面積僅為極小的100分之1應有部分，約3.9平方公
05 尺，顯不符合常情，其如此作法係藉由只需繳納較少土地增
06 值稅之小面積土地移轉即可形成共有關係，再以此共有關係
07 進行系爭104地號土地分割為2筆土地，並以該2筆共有土地
08 再與原告等共有之系爭549地號土地辦理共有物分割，達成
09 土地交換之結果，而原告3人刻意將分割前後應有部分價值
10 均相差在公告土地現值1平方公尺單價以下，即可免徵土地
11 增值稅，係屬租稅規避情形。是以，本案單就外觀形式而
12 論，雖係原告以藉由贈與小面積的土地創設共有，但實質上
13 顯從事土地交換之行為，在經濟實質上當已具備土地移轉之
14 課稅構成要件，被告岡山分處本於實質課稅原則，參照納稅
15 者權利保護法第7條規定意旨，按交換方式核定補徵土地增
16 值稅，並無不合。

17 2.原告主張並未移轉土地予第三人，以共有土地分割方式無法
18 獲得租稅減少或免繳納之利益，被告誤解共有物分割與交換
19 之法律意旨等語。系爭549地號土地，原為原告3人所有，應
20 有部分各3分之1；系爭104地號土地原為劉國樑單獨所有，
21 而一般正規交易常態，若由劉國樑以系爭分割後104、104-1
22 地號土地，分別與劉蒼明及劉耀聖交換系爭549地號土地之
23 應有部分，並就交換移轉之土地申報繳納土地增值稅，原告
24 3人應繳納土地增值稅共計2,488,284元。是單就外觀形式而
25 論，原告3人藉以贈與小面積土地創設共有關係，僅繳納土
26 地增值稅計24,629元，經前述形成共有關係、分割土地、共
27 有物分割等刻意安排，實質進行土地交換行為，並使得減少
28 繳納土地增值稅計2,463,655元（計算公式：2,488,284元－2
29 4,629元），而在經濟實質上當已具備土地交換之課稅構成
30 要件，被告本於實質課稅原則，依稅捐稽徵法第12條之1第6
31 項規定，調整適用土地稅法第28條等規定，並依稅捐稽徵法

第21條規定予以補徵土地增值稅計2,463,655元，於法自無不合。

3.原告訴稱分割後之土地，已喪失重劃土地於增值稅享有費用扣減及減徵之利益乙節。查被告核定系爭分割後104地號及104-1地號土地之土地增值稅時，業已依土地稅法第31條第1項規定扣除重劃費用計3,220,015元，並依同法第39條第4項規定，減徵百分之40稅額，扣減及減徵明細詳如附件2。又按土地增值稅稅額之計算，乃係「土地漲價總數額」乘以「稅率」，而本案土地之「土地漲價總數額」＝「移轉現值總額」－「按物價指數調整後原地價總額」－「土地重劃費用」，本案系爭3筆土地於107年11月14日辦理共有物分割案經認定為實質上「土地交換」之效果，依土地稅法第28條前段與土地稅法施行細則第42條之規定，應按其土地漲價總數額核定土地增值稅，被告以107年11月14日移轉時之公告現值（549地號:6,200元；104地號:25,000元；104-1地號:25,000元），且依土地稅法第33條第1項所定之法定稅率分別適用，計算補徵稅額共計2,463,655元，於法有據，計算說明詳如附件3。是以，原告訴稱除了調高劉耀聖取得土地之前次移轉現值外，連原告劉蒼明取得之土地亦應調高前次移轉現值，方屬公平、合理云云，顯對法定土地增值稅之計算有所誤解，難謂為其有利之認定。

4.又系爭549地號土地使用分區為農業區，原告3人於復查、訴願階段雖提出岡山區公所就該土地於108年10月17日核發之農業用地作農業使用證明書，然系爭549地號土地於107年11月14日與分割後104、104-1地號土地辦理共有物分割時，因原告刻意將各該土地分割前後應有部分價值差額維持在公告土地現值1平方公尺單價以下，即可免徵土地增值稅，並得免申報土地移轉現值，原告爰未於申報土地移轉現值時或於土地增值稅108年10月20日繳納期間屆滿前，檢具系爭549地號土地作農業使用證明書並提出不課徵土地增值稅之申請，嗣於108年12月26日始向被告詢問系爭549地號土地是否符合

01 不課徵土地增值稅之要件，已逾補徵土地增值稅108年10月2
02 0日繳納期間，則縱認原告之詢問有就系爭549地號土地申請
03 不課徵土地增值稅之意思，然依土地稅法第39條之3第1項規
04 定，因已逾補行申請之期間即不得申請不課徵土地增值稅。
05 再者，原告所提系爭549地號土地作農業使用之證明書係高
06 雄市○○區公所於108年10月17日所核發，按行政院農業委
07 員會90年4月6日(90)農企字第900010118號函可知，被告亦
08 難依岡山區公所於108年10月17日核發之農業用地作農業使
09 用證明書認定系爭549地號土地於107年11月14日與分割後10
10 4、104-1地號土地辦理共有物分割時有確作農業使用之事
11 實，況原告當時僅以外觀符合土地稅法施行細則第42條第2
12 項規定，達成該3筆土地移轉時均可免徵土地增值稅之目
13 的，並未以系爭549地號土地依土地稅法第39條之2第1項規
14 定申請不課徵土地增值稅。故原告訴稱被告剝奪其就系爭54
15 9地號土地得申請不課徵土地增值稅之權利云云置辯，要難
16 採憑。

17 (二)聲明：原告之訴駁回。

18 六、爭點：

19 (一)系爭104地號土地是否為原告3人之共有家產？

20 (二)原告3人有無利用系爭549及104地號土地之贈與、合併及分
21 割規避應課徵之土地增值稅？

22 (三)系爭549地號土地於分割日107年11月14日時是否為作農業使
23 用之農業用地？

24 七、本院的判斷：

25 (一)前提事實：

26 1.如爭訟概要欄所述事實，已經兩造分別陳述在卷，並有土地
27 增值稅（土地現值）申報書及（一般贈與）土地增值稅繳款
28 書（第105-108頁）、土地增值稅（土地現值）申報書及
29 （一般交換）土地增值稅繳款書（第119-122、150-153、15
30 6-158頁）、物價指數查詢（第202-206頁）、地價查詢資料
31 （第210-217頁）、地價改算通知書（第218-220頁）、土地

01 現值計算表（第221頁）、原處分（第9-11頁）、復查決定
02 書（第254-264頁）、訴願決定書（第328-340頁）等件（影
03 本）附原處分卷可稽，且為兩造所不爭，堪以認定。

04 2.系爭549地號及104地號土地之分割合併過程：

05 (1)原告3人緣於繼承而共有之系爭549地號（應有部分各1/
06 3）即重測前大寮段28-51地號，乃分割自劉福登於48年間
07 因買賣而取得應有部分2分之1之重測前大寮段28-3地號土
08 地之事實，有原告所提劉福登遺留財產明細表及該筆土地
09 重測前、後之土地登記簿謄本、土地登記第一類謄本（本
10 院卷第39、175-184頁；原處分卷第173-174）足憑；而系
11 爭104地號（即重測前岡山鎮後紅段513地號因分割而增加
12 之513-6、513-7地號，重測後分別編為文化段936、1207
13 地號，因重劃而合併為104地號）土地則於53年間即登記
14 為劉國樑單獨所有，嗣劉國樑於106年8月30日訂立贈與契
15 約，並同日申報移轉其所有之系爭104地號土地各100分之
16 1予劉蒼明及劉耀聖，形成共有關係，原告3人復於107年1
17 1月13日將系爭104地號土地分割成系爭分割後104、104-1
18 地號等2筆土地等情，亦有上述原告所提劉福登遺留財產
19 明細表及該筆土地分割、重測、重劃前、後之土地登記簿
20 謄本、土地登記第一類謄本、土地所有權贈與移轉契約
21 （本院卷第39、65-70、71-74、75-78、99-102、115-11
22 6、255-258、331頁）可查。

23 (2)原告3人透過前揭贈與方式，就系爭549及分割後104、104
24 -1地號共3筆土地形成共有關係。嗣於107年11月14日就上
25 開共有之3筆土地向地政機關申請辦理共有物分割，由劉
26 蒼明單獨取得系爭分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得
27 系爭分割後104-1地號土地；共有之系爭549地號土地應有
28 部分則變更為劉國樑100,000分之79,383、劉蒼明100,000
29 分之11,963、劉耀聖100,000分之8,654等情，有系爭分割
30 後104、104-1、549地號土地登記第一類謄本（本院卷第2
31 55-262頁）為證。因原告3人分割前後總現值增減均在各

筆土地公告現值1平方公尺單價以下，依土地稅法施行細則第42條第2項及財政部92年1月14日令意旨得免申報移轉現值，故無須繳納土地增值稅而逕向地政機關辦理登記。

(二)系爭104地號土地並非原告3人之共有家產：

1.應適用的法令：

民法第758條：「不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。前項行為，應以書面為之。」

2.按家產土地，係屬日據時期登記之物權，所稱家產為家屬全體共同共有乙節，乃臺灣光復前之民事習慣。查臺灣於民國34年10月25日光復，我國法律亦於是日起施行於臺灣。依我國民法物權編、親屬編、繼承編各編施行法之第1條規定，在各編施行前發生之物權、親屬、繼承事項，於光復後原則上雖仍應適用日據時期所行之物權、親屬、繼承等習慣，然光復後所生有關物權、親屬、繼承等事項，應悉依我國民法物權編、親屬編、繼承編等規定（參法務部編臺灣民事習慣調查報告第6版，第333頁、第519頁）。

3.原告3人自陳系爭549地號、104地號土地實係劉福登於48年及53年間取得，業如前述，足見劉福登取得系爭549地號、104地號土地之時間，已在臺灣光復之後，關於土地買賣、財產移轉所生法律關係，即應適用民法或相關法律規定，並無臺灣民事習慣之適用。

4.原告3人雖主張劉國樑6歲取得上述岡山鎮後紅段513地號土地時並無行為能力，該地實係其父劉福登生前購買並借名登記於其名下之家產，並提出上述劉福登遺留財產明細表及劉蒼明、劉國樑、劉哲朗（即劉耀聖之父）於95年11月15日為協議共有土地而簽署的契約同意書（本院卷第185頁）為證。然所謂家產制度中之「家」，應指實際共同生活團體而言，即所謂「同居共財、同居共爨」，家中所有人均仰賴家產收益生活，其個人所得亦均歸入家產中，家產由家中尊長統一支配管理；惟原告3人業已分戶獨立生活，難認存在同

財共居關係。再者，臺灣社會自清朝以降，雖有所謂家產制度，但於民法施行（即18年10月10日）後已不復使用，觀諸系爭土地及劉福登遺留財產明細表上其他土地之取得時間，已距民法施行至少30年，且原告自承並無劉登福將財產借名登記於子女名下之資料，亦未將系爭104地號土地及其他主張為共有家產之土地申報為劉登福遺產，有原告劉國樑於本院110年2月25日準備程序筆錄（本院卷第243-244頁）可參，故原告3人稱系爭104地號土地為劉福登遺留之家產，實難採憑。

(三)原告3人藉由共有物分割之形式，創設交換土地之經濟實質，依實質課稅原則，原告3人於本次移轉換出土地時，已享有土地之自然漲價利益，應課徵土地增值稅：

1.應適用的法令及函釋：

(1)行為時稅捐稽徵法第12條之1第3項、第6項：「（第3項）納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。（第6項）稅捐稽徵機關查明納稅義務人及交易之相對人或關係人有第2項或第3項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料依各稅法規定予以調整。」第21條第1項第2款、第2項：「（第1項）稅捐之核課期間，依左列規定：二、……及應由稅捐稽徵機關依稅籍底冊或查得資料核定課徵之稅捐，其核課期間為5年。（第2項）在前項核課期間內，經另發現應徵之稅捐者，仍應依法補徵或並予處罰；在核課期間內未經發現者，以後不得再補稅處罰。」

(2)土地稅法第5條第1項第1款、第2項：「（第1項）土地增值稅之納稅義務人如左：一、土地為有償移轉者，為原所有權人。（第2項）前項所稱有償移轉，指買賣、交換、政府照價收買或徵收等方式之移轉；所稱無償移轉，指遺贈及贈與等方式之移轉。」第28條：「已規定地價之土地，於土地所有權移轉時，應按其土地漲價總數額徵收土

地增值稅。但因繼承而移轉之土地，各級政府出售或依法贈與之公有土地，及受贈之私有土地，免徵土地增值稅。」第31條第1項第1款、第2項：「（第1項）土地漲價總數額之計算，應自該土地所有權移轉或設定典權時，經核定之申報移轉現值中減除下列各款後之餘額，為漲價總數額：一、規定地價後，未經過移轉之土地，其原規定地價。規定地價後，曾經移轉之土地，其前次移轉現值。

（第2項）前項第1款所稱之原規定地價，依平均地權條例之規定；所稱前次移轉時核計土地增值稅之現值，於因繼承取得之土地再行移轉者，係指繼承開始時該土地之公告現值。……。」

(3)納稅者權利保護法第7條第1至6項：「（第1項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。（第3項）納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。（第4項）前項租稅規避及第2項課徵租稅構成要件事實之認定，稅捐稽徵機關就其事實有舉證之責任。（第5項）納稅者依本法及稅法規定所負之協力義務，不因前項規定而免除。（第6項）稅捐稽徵機關查明納稅者及交易之相對人或關係人有第3項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料依各稅法規定予以調整。」

(4)土地稅法施行細則第42條：「（第1項）土地交換，應分別向原土地所有權人徵收土地增值稅。（第2項）分別共有土地分割後，各人所取得之土地價值與其分割前應有部分價值相等者，免徵土地增值稅；其價值減少者，就其減

少部分課徵土地增值稅。（第3項）公司共有土地分割，其土地增值稅之課徵，準用前項規定。（第4項）土地合併後，各共有人應有部分價值與其合併前之土地價值相等者，免徵土地增值稅。其價值減少者，就其減少部分課徵土地增值稅。（第5項）前3項土地價值之計算，以共有土地分割或土地合併時之公告土地現值為準。」

(5)財政部92年1月14日令：「共有土地分割，或兩宗以上所有權人不相同之土地合併，各共有人分割、合併前後應有部分價值相差在分割、合併後當期公告土地現值1平方公尺單價以下，依規定得免申報移轉現值之案件，准免依土地稅法第51條第1項規定辦理查欠，得逕向地政機關辦理登記。」

2.經查，原告3人原僅共有系爭549地號土地，嗣藉由贈與及分割形成共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，再經由分割共有物，而由劉蒼明單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，及3人維持原共有549地號土地，僅應有部分比例變更，且因安排分割前後總現值增減均在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，依法規得免申報移轉現值，故無須繳納土地增值稅而逕向地政機關辦理登記等情，已如前述。原告3人雖主張為家產分配，然如上所述，系爭104地號土地並非原告3人之共有家產，原告3人間並無合理之經濟上使用動機或特殊因素致須如此迂迴移轉土地，是原告3人於短時間內以「贈與」、「形成共有關係」、「共有物分割」之程序，以達成系爭分割後104、104-1地號土地分別歸屬於劉蒼明及劉耀聖2人所有之目的，顯係因劉國樑如直接移轉系爭分割後104、104-1地號土地予劉蒼明及劉耀聖2人並交換該2人於系爭549地號土地之應有部分，無法免徵土地增值稅。故原告3人藉由贈與移轉系爭104土地小部分應有部分，刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事雙方互換土地之行為，以達到規避繳納土地增值稅之目的，經濟實質上當已具

01 備土地移轉之課稅構成要件。從而，被告審認原告3人藉由
02 創造共有關係及分割共有物方式相互移轉系爭549地號土地
03 之應有部分及分割後104、104-1地號土地，實際上為交換土
04 地之有償移轉，尚無違誤。

05 3.依土地稅法第5條、第28條前段及第31條第1項第1款規定可
06 知，土地交換係屬有償移轉，應按土地漲價總數額，課徵土地
07 增值稅。原告3人間相互移轉系爭549地號土地之應有部分及分
08 割後104、104-1地號土地時既已享有自然漲價利益，被告依實
09 質課稅原則，自應改按交換行為當下已享有土地自然漲價利益
10 之原告3人為土地增值稅之納稅義務人，課徵土地增值稅。被
11 告依法以劉國樑於107年11月14日移轉時之土地公告現值（104
12 地號:25,000元；104-1地號:25,000元），按一般用地稅率計
13 算補徵土地增值稅1,131,467元，並無違誤；劉耀聖及劉蒼明
14 （移轉549地號土地）部分，除劉耀聖因106年4月11日繼承取
15 得549地號土地外，因系爭549地號土地為作農業使用之農業用
16 地，故應補徵稅額為0元。原告3人雖稱經共有物分割後之土地
17 再移轉所應課徵之土地增值稅額合計為1,343,845元，大於被
18 告聲稱應稅土地應核課土地增值稅金額1,206,821元，且並非
19 移轉與第3人，本件之增值稅是延後繳納而已等語。然查，原
20 告3人既於相互交換系爭549地號土地之應有部分及分割後10
21 4、104-1地號土地之行為當下已享有土地自然漲價利益，合於
22 應課徵土地增值稅之要件甚明，自應以其為土地增值稅之納稅
23 義務人，與土地是否移轉第3人無涉，自無須俟該土地再次移
24 轉時始得課徵土地增值稅。另原告3人逕以系爭104地號土地移
25 轉百分之2持分時所核定之應納土地增值稅24,519元，反推未
26 移轉之百分之98持分應課徵之土地增值稅為1,206,821元（本
27 院卷第333頁），小於嗣後再移轉所應課徵之土地增值稅1,34
28 3,845元（本院卷第339-341頁），並以此為據主張無規避土地
29 增值稅，僅延緩繳納。惟原告之推算，除算法過於簡略外，又
30 未考量經此共有土地分割而為改算地價後之前次移轉現值業已

01 墊高，再次移轉所應課徵之土地增值稅必然降低，是其計算金
02 額並不可採，亦難解其規避租稅之事實。

03 (四)至原告稱喪失重劃土地於增值稅享有費用扣減及減徵之利益與
04 農業用地作農業使用可免徵土地增值稅之利益等語。

05 1.經查，被告於計算系爭549地號及分割後104、104-1地號土地
06 應課徵之土地增值稅時，業依已依土地稅法第31條第1項規定
07 扣除重劃費用計3,220,015元，並依同法第39條第4項規定，
08 減徵百分之40稅額，此有被告提供之重劃費用扣減及減徵明
09 細表及補徵稅額計算說明（本院卷第361-366頁）可參，並無
10 原告所稱喪失費用扣減及減徵利益等情。

11 2.系爭549地號土地，部分於63年3月6日即為農業區、部分於95
12 年8月28日由道路用地變更為農業區，此有高雄市政府都市發
13 展局核發之土地使用分區證明書及108年12月19日高市都發開
14 字第10835189600號函（原處分卷第83、198頁）可參，故其
15 合於土地稅法第10條第1項所稱農業用地。又依被告檢附之行
16 政院農業委員會林務局農林航空測量所106年4月30日、107年
17 11月21日攝影之航照圖，其於分割日107年11月4日前、後之
18 土地使用狀態均為類似綠色植被及不規則裸露白點，並無明
19 顯變更；另依原告於本院111年1月5日言詞辯論期日提出之系
20 爭549地號土地現況照片，該土地上散落種植之樹木已成長一
21 定高度，顯非短期種植，而樹木間裸露土地則鋪蓋有塑膠帆
22 布，並無明顯之構造物、設施或大面積土石裸露、雜草灌木
23 叢生等未作農業使用情形，應可認系爭549地號土地於分割前
24 後均維持同一使用狀態。參以原告3人所提作農業使用之證明
25 書，雖係高雄市○○區公所於108年10月17日所核發（原處分
26 卷第84頁），但其認可系爭549地號土地為作農業使用之農業
27 用地，而該土地之使用狀態並未明顯變更，已如前述，應可
28 認定系爭549地號土地於分割前迄今，確實如現況照片般種植
29 樹木，屬作農業使用之農業用地。原告3人雖未於交換土地並
30 申報土地移轉現值時或於繳納期間屆滿前，檢具系爭549地號
31 土地農業使用證明書提出不課徵土地增值稅之申請，然係該

01 土地因上開分割共有物結果，依土地稅法施行細則第42條第2
02 項及財政部92年1月14日令，並無須繳納土地增值稅及免申報
03 土地移轉現值，故未及時申請不課徵土地增值稅，今經被告
04 以原告3人實質上屬交換土地而重新核定土地增值稅，即應准
05 其於重新認定時補提資料申請之，方符合公平。是被告就系
06 爭549地號土地核定補徵土地增值稅1,332,188元（本院卷第3
07 66頁），即有違誤，應予撤銷。

08 (五)綜上所述，原核定處分及復查決定以本件實質上為雙方互換土
09 地，依財政部92年7月2日函意旨及實質課稅原則，補徵劉國樑
10 移轉系爭分割後104及104-1地號土地之土地增值稅計1,131,46
11 7元，核尚無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請
12 予以撤銷，核無理由，應予駁回。至於補徵劉蒼明移轉系爭54
13 9地號土地之土地增值稅1,332,188元，因未考慮系爭549地號
14 土地於移轉當時確實為作農業使用之農業用地，原告申請不課
15 徵土地增值稅，未予核認，即有違誤，應予撤銷。又本件判決
16 基礎已經明確，兩造其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟
17 酌後，核與判決結果不生影響，無逐一論述的必要，一併說
18 明。

19 八、判決結論：原告之訴一部有理由，一部無理由。

20 中 華 民 國 111 年 1 月 19 日

21 高雄高等行政法院第一庭

22 審判長法官 蘇 秋 津

23 法官 邱 政 強

24 法官 孫 國 禎

25 以上正本係照原本作成。

26 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，其
27 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由
28 書（均須按他造人數附繕本）。未表明上訴理由者，逕以裁
29 定駁回。

30 二、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴
31 訟法第241條之1第1項前段）

三、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
（二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 111 年 1 月 19 日
書記官 楊 曜 嘉

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第256號

上 訴 人 高雄市稅捐稽徵處

代 表 人 蔡麗惠

訴訟代理人 余淑媛（兼送達代收人）

被 上 訴 人 劉蒼明

上列當事人間土地增值稅事件，上訴人對於中華民國111年1月19日高雄高等行政法院109年度訴字第322號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回高雄高等行政法院。

理 由

一、本件行政訴訟上訴後，上訴人代表人由黃惠玲變更為蔡麗惠，茲經繼任者於民國112年1月30日具狀承受訴訟，核無不合，應予准許，先此敘明。

二、緣被上訴人與原審原告劉國樑、劉耀聖（下逕稱其姓名）原分別共有高雄市岡山區和平段549地號土地（下稱549地號土地），應有部分各為3分之1，該土地使用分區為農業區，面積3,413.05平方公尺。另劉國樑原單獨所有同區大德段104地號土地（下稱104地號土地），該土地使用分區為住宅區，面積397.73平方公尺，經劉國樑於106年8月30日將104地號土地應有部分各100分之1分別贈與被上訴人、劉耀聖形成共有關係。嗣104地號土地於107年11月13日分割為104、104-1地號土地（下稱分割後104、104-1地號土地），面積分別為184.86平方公尺、212.87平方公尺；分割後104、104-1地號土地復於同年月14日與549地號土地合併辦理共有物分割，由被上訴人單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，549地號土地則由被上訴人取得應有部分100,000分之11,963、劉國樑取得應有部分100,000分之79,383、劉耀聖取得應有部分100,000分之8,654。嗣上訴人所屬岡山分處（下稱岡山分處）查得被上訴人與劉國

01 樑、劉耀聖藉由贈與小面積土地創設共有關係，再辦理共有
02 物分割，行實質交換移轉土地所有權之實，與常規交換土地
03 經濟效果相同，乃依稅捐稽徵法、土地稅法等規定，以108
04 年9月16日高市稽岡增字第1088569298號函核定按一般用地
05 稅率補徵應納之土地增值稅額為被上訴人新臺幣（下同）1,
06 332,188元、劉國樑1,131,467元，而劉耀聖則係於106年4月
07 11日因繼承取得549地號土地，故為0元。其等不服，申經復
08 查、訴願均遭駁回，乃循序提起行政訴訟，求為判決撤銷訴
09 願決定、復查決定及原核定處分。經原判決將訴願決定、復
10 查決定及原核定處分關於被上訴人移轉549地號土地應有部
11 分100,000分之21,370予劉國樑之土地增值稅1,332,188元部
12 分均撤銷，並駁回其餘之訴。上訴人遂就原判決不利其之部
13 分，提起本件上訴（劉國樑、劉耀聖敗訴部分未據其等上
14 訴，已告確定）。

15 三、被上訴人起訴之主張及上訴人在原審的答辯，均引用原判決
16 所載。

17 四、原判決為上訴人部分敗訴之判決，其理由略以：

18 (一)、被上訴人與劉國樑、劉耀聖原僅共有549地號土地，嗣藉由
19 贈與及分割形成共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，
20 再經由分割共有物，而由被上訴人單獨取得分割後104地號
21 土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，及3人維持原
22 共有549地號土地，僅應有部分比例變更，且因安排分割前
23 後總現值增減均在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，
24 依法規得免申報移轉現值，故無須繳納土地增值稅而逕向地
25 政機關辦理登記。被上訴人與劉國樑、劉耀聖間並無合理之
26 經濟上使用動機或特殊因素致須如此迂迴移轉土地，是被上
27 訴人與劉國樑、劉耀聖間於短時間內以「贈與」、「形成共
28 有關係」、「共有物分割」之程序，以達成系爭分割後10
29 4、104-1地號土地分別歸屬於被上訴人及劉耀聖2人所有之
30 目的，顯係因劉國樑如直接移轉系爭分割後104、104-1地號
31 土地予被上訴人及劉耀聖2人並交換該2人於549地號土地之

01 應有部分，無法免徵土地增值稅。故被上訴人與劉國樑、劉
02 耀聖藉由贈與移轉系爭104土地小部分應有部分，刻意創設
03 共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實
04 質從事雙方互換土地之行為，以達到規避繳納土地增值稅之
05 目的，經濟實質上當已具備土地移轉之課稅構成要件。從
06 而，上訴人審認被上訴人與劉國樑、劉耀聖藉由創造共有關
07 係及分割共有物方式相互移轉549地號土地之應有部分及分
08 割後104、104-1地號土地，實際上為交換土地之有償移轉，
09 尚無違誤。依土地稅法第5條、第28條前段及第31條第1項第
10 1款規定可知，土地交換係屬有償移轉，應按土地漲價總數
11 額，課徵土地增值稅，被上訴人與劉國樑、劉耀聖間相互移
12 轉549地號土地之應有部分及分割後104、104-1地號土地時
13 既已享有自然漲價利益，上訴人依實質課稅原則，自應改按
14 交換行為當下已享有土地自然漲價利益之被上訴人與劉國
15 樑、劉耀聖為土地增值稅之納稅義務人，課徵土地增值稅。
16 上訴人依法以劉國樑於107年11月14日移轉時之土地公告現
17 值（104地號：25,000元；104-1地號：25,000元），按一般
18 用地稅率計算補徵土地增值稅1,131,467元，並無違誤；移
19 轉549地號土地部分，劉耀聖因106年4月11日繼承取得549地
20 號土地，故補徵稅額為0元。

21 (二)、549地號土地部分於63年3月6日即為農業區、部分於95年8月
22 28日由道路用地變更為農業區，故其合於土地稅法第10條第
23 1項所稱農業用地，於分割前後均維持同一使用狀態。參以
24 被上訴人與劉國樑、劉耀聖所提作農業使用之證明書，雖係
25 高雄市○○區公所於108年10月17日所核發，但其認可549地
26 號土地為作農業使用之農業用地。被上訴人與劉國樑、劉耀
27 聖雖未於交換土地並申報土地移轉現值時或於繳納期間屆滿
28 前，檢具549地號土地農業使用證明書提出不課徵土地增值
29 稅之申請，然係該土地因分割共有物結果，經計算被上訴人
30 與劉國樑、劉耀聖分割前、後應有部分價值增減情形，劉國
31 樑增加143.5元、劉蒼明減少89.5元、劉耀聖減少54元，均

在公告土地現值1平方公尺單價6,200元以下，依土地稅法施行細則第42條第2項及財政部92年1月14日台財稅字第0910456670號令釋（下稱財政部92年1月14日令），並無須繳納土地增值稅及免申報土地移轉現值，故未及時申請不課徵土地增值稅，今經上訴人重新核定土地增值稅，即應准其於重新認定時補提資料申請之，方符合公平。是上訴人就549地號土地核定補徵被上訴人土地增值稅1,332,188元，即有違誤等詞，茲為其論據。

五、上訴理由略謂：549地號土地之使用分區為農業區，其於107年11月14日與系爭分割後104、104-1地號土地辦理共有物分割時，依土地稅法施行細則第42條第2項規定及財政部92年1月14日令，並無須繳納土地增值稅及免申報土地移轉現值，故分割移轉當下固未能慮及申請農用證明書以適用不課徵土地增值稅。然岡山分處事後於108年9月16日就被上訴人移轉549地號土地核定補徵土地增值稅1,332,188元，其隨文所檢送繳款書之繳納期間載明：自108年9月21日起至108年10月20日止，於此即得依土地稅法第39條之3第1項規定，於該繳納期間屆滿前檢具農用證明書向上訴人申請不課徵土地增值稅，惟被上訴人於接獲岡山分處所寄發之繳款書後，雖於108年10月17日取得岡山區公所核發之農用證明書，但卻未依規定於補徵土地增值稅108年10月20日之繳納期間屆滿前，由權利人（劉國樑）及義務人（被上訴人）共同提出申請並檢具農用證明書，遲至108年12月26日始以申請書向上訴人詢問549地號土地是否符合不課徵土地增值稅之要件，顯已逾本案補徵土地增值稅108年10月20日繳納期間，核與土地稅法第39條之3第1項規定要件不合，原判決有判決不適用法規之違法等語。

六、本院查：

（一）、按土地稅法第5條第1項第1款、第2項規定：「（第1項）土地增值稅之納稅義務人如左：一、土地為有償移轉者，為原所有權人。（第2項）前項所稱有償移轉，指買賣、交換、

01 政府照價收買或徵收等方式之移轉；所稱無償移轉，指遺贈
02 及贈與等方式之移轉。」第28條規定：「已規定地價之土
03 地，於土地所有權移轉時，應按其土地漲價總數額徵收土地
04 增值稅。……」第31條第1項第1款規定：「土地漲價總數額
05 之計算，應自該土地所有權移轉或設定典權時，經核定之申
06 報移轉現值中減除下列各款後之餘額，為漲價總數額：一、
07 規定地價後，未經過移轉之土地，其原規定地價。規定地價
08 後，曾經移轉之土地，其前次移轉現值。」第39條之2規
09 定：「（第1項）作農業使用之農業用地，移轉與自然人
10 時，得申請不課徵土地增值稅。……（第4項）作農業使用
11 之農業用地，於本法中華民國89年1月6日修正施行後第一次
12 移轉，或依第一項規定取得不課徵土地增值稅之土地後再移
13 轉，依法應課徵土地增值稅時，以該修正施行日當期之公告
14 土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。
15 （第5項）本法中華民國89年1月6日修正施行後，曾經課徵
16 土地增值稅之農業用地再移轉，依法應課徵土地增值稅時，
17 以該土地最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為
18 原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅……。」第39條
19 之3規定：「（第1項）依前條第1項規定申請不課徵土地增
20 值稅者，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，於土
21 地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未註明者，得
22 於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課
23 徵土地增值稅。但依規定得由權利人單獨申報土地移轉現值
24 者，該權利人得單獨提出申請。（第2項）農業用地移轉，
25 其屬無須申報土地移轉現值者，主管稽徵機關應通知權利人
26 及義務人，其屬權利人單獨申報土地移轉現值者，應通知義
27 務人，如合於前條第1項規定不課徵土地增值稅之要件者，
28 權利人或義務人應於收到通知之次日起30日內提出申請，逾
29 期不得申請不課徵土地增值稅。」可知，作農業使用之農業
30 用地移轉與自然人，原則上應按其土地漲價總數額，於土地
31 所有權移轉時徵收土地增值稅。惟其權利人及義務人於申報

01 土地移轉現值時，得於土地現值申報書註明農業用地字樣申
02 請不課徵土地增值稅；其未註明者，得於土地增值稅繳納期
03 間屆滿前補行申請。而其移轉屬無須申報土地移轉現值者
04 （例如法院拍賣之土地案件），則以權利人或義務人收到主
05 管稽徵機關得為申請不課徵土地增值稅之通知次日起30日
06 內，提出不課徵土地增值稅之申請，逾期不得申請不予課
07 徵。

08 (二)、上開土地稅法第39條之2第1項於89年1月26日修正公布前原
09 規定：「農業用地在依法作農業使用時，移轉與自行耕作之
10 農民繼續耕作者，免徵土地增值稅。」惟考量89年1月26日
11 修正公布之土地法，就農地已開放自由買賣，則農地之流通
12 性已與一般土地無差異，其所有權移轉所獲土地漲價利益，
13 已無免徵土地增值稅之必要，故將本條項原關於「免徵土地
14 增值稅」之規範，修正為「得申請不課徵土地增值稅」。又
15 鑑於農業用地移轉，是否課徵土地增值稅，買賣雙方之權益
16 係互相衝突。即課徵土地增值稅，增加本次出售土地人之稅
17 負；不課徵土地增值稅，承受人再移轉時之土地增值稅負擔
18 增加（因為其前次移轉現值並非依本次買賣時之土地公告現
19 值），乃於第39條之3明定申請不課徵土地增值稅之程序。
20 準此，土地稅法第39條之2第1項所稱之「不課徵土地增值
21 稅」，係有別於該條項修正前所規範因「合於該條項所定免
22 稅要件，當然發生免稅效果」之「免徵」土地增值稅；即
23 「不課徵土地增值稅」僅是就該次移轉原應課徵之土地增值
24 稅暫時不予課徵。而是否行使「不課徵」土地增值稅之請求
25 權，需由得享有該不課徵權利之人，依相關法令規定，以向
26 主管稽徵機關提出申請之方式為之。至其中屬土地稅法第39
27 條之3第2項規定之情形者，因該條項已明定未遵期申請之法
28 律效果為「不得申請不課徵土地增值稅」，是得享有該不課
29 徵土地增值稅權利之人，如未於收到稽徵機關通知之次日起
30 30日內提出申請，即喪失「得申請不課徵土地增值稅」之請
31 求權（本院102年度判字第599號判決意旨參照）。

01 (三)、復按行政訴訟法第4條第1項規定：「人民因中央或地方行政
02 機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經
03 依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3個月不為
04 決定，或延長訴願決定期間逾2個月不為決定者，得向行政
05 法院提起撤銷訴訟。」準此，撤銷訴訟之目的在於撤銷行政
06 機關之違法行政處分，藉以排除其對人民之權利或法律上之
07 利益所造成之損害，行政法院僅係事後審查行政處分之適法
08 性，並不自為行政處分，亦不代替行政機關為處分。又租稅
09 債務係因實現法定之租稅構成要件而成立，乃於稅捐要件合
10 致時即已發生稅捐債務，故不論該稅捐債務係由納稅義務人
11 自行報繳或由稅捐稽徵機關作成核課處分者，原則上均應為
12 稅捐要件合致時即所謂「行為時」作為判斷稅捐稽徵機關認
13 定事實及法令適用有無錯誤之基準時點。是作農業使用之農
14 業用地，移轉與自然人時，權利人及義務人未於申報土地移
15 轉現值時，於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請不
16 課徵土地增值稅，而係於稽徵機關為核課處分後，始為申請
17 者，縱未逾上述申請期間，亦不影響原已合法成立之課稅處
18 分；僅於稽徵機關核准其不課徵之申請後，稽徵機關基於原
19 核課處分所依據之事實事後發生變更，得依行政程序法第12
20 2條規定，依依職權廢止原合法課稅處分之問題，而非構成
21 原課稅處分自始違法之撤銷事由。行政法院亦不得有違司法
22 權與行政權係屬分立之原則，逕自代替稽徵機關作成准予不
23 課徵土地增值稅之處分。

24 (四)、查土地稅法施行細則第42條第1項、第2項、第5項規定：
25 「（第1項）土地交換，應分別向原土地所有權人徵收土地
26 增值稅。（第2項）分別共有土地分割後，各人所取得之土
27 地價值與其分割前應有部分價值相等者，免徵土地增值稅；
28 其價值減少者，就其減少部分課徵土地增值稅。……（第5
29 項）前3項土地價值之計算，以共有土地分割或土地合併時
30 之公告土地現值為準。」又「共有土地分割，或兩宗以上所
31 有權人不相同之土地合併，各共有人分割、合併前後應有部

分價值相差在分割、合併後當期公告土地現值1平方公尺單價以下，依規定得免申報移轉現值之案件……得逕向地政機關辦理登記。」且經財政部92年1月14日令釋在案。查原審業依調查證據之辯論結果，論明：被上訴人與劉國樑、劉耀聖原僅共有549地號土地，嗣藉由贈與及分割形成共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，再經由分割共有物，而由被上訴人單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，及3人維持原共有549地號土地，僅應有部分比例變更；其等實質從事互換土地，為交換土地之有償移轉，惟因形式上安排分割前後總現值增減均在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，依上述法令而免申報移轉現值，被上訴人於相互交換549地號土地之應有部分當下已享有土地自然漲價利益，合於應課徵土地增值稅之要件等得心證之理由，核與卷內事證並無不符，並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事，於法自無不合。是上訴人作成系爭課稅處分自係適法有據。

(五)、再查，被上訴人與劉國樑、劉耀聖雖未於交換土地並申報土地移轉現值時或於繳納期間屆滿前，檢具549地號土地農業使用證明書提出不課徵土地增值稅之申請等情，乃原審所確定之事實。原判決卻以549地號土地係作農業使用，因被上訴人與劉國樑、劉耀聖就上開分割共有物結果，依土地稅法施行細則第42條第2項及財政部92年1月14日令，並無須繳納土地增值稅及免申報土地移轉現值，故未及時申請不課徵土地增值稅，今經上訴人以被上訴人實質上屬交換土地而重新核定土地增值稅，即應准其於重新認定時補提資料申請之，方符合公平等語為由，逕謂上訴人就549地號土地核定補徵被上訴人上開土地增值稅有誤，應予撤銷等語，非惟有代上訴人為核准被上訴人之申請之嫌，且非以上訴人作成系爭課稅處分之事實狀態判斷上訴人為該處分合法性之基準時，顯有違誤。又觀之被上訴人與劉國樑、劉耀聖於000年00月00

01 日出具之申請書載明：「……有關檢附高雄市○○區公所10
02 8年10月17日核發岡山區和平段549地號土地之農用證明
03 書……是否符合土地稅法第39條之3第2項不課徵土地增值稅
04 之要件？懇請鈞處詳審，請鑒核。」（見原處分卷第232
05 頁），經復查決定書敘及：「……另申請人於000年00月00
06 日以申請書主張『高雄市○○區公所108年10月17日核發岡
07 山區和平段549地號土地之農用證明書，因該證明書核發時
08 間係在土地增值稅繳納期間內，是否符核土地稅法第39條之
09 3第2項不課徵土地增值稅之要件？懇請鈞處詳審。』乙節，
10 按土地稅法第39條之2規定（即農業發展條例第37條第1項規
11 定）申請不課徵土地增值稅，應以移轉時，該農業用地確作
12 農業使用為要件。……查和平段549地號等3筆土地辦理共有
13 物分割之時間為107年11月14日，尚難依申請人所檢附108年
14 10月17日核發之農業用地作農業使用證明書，據以認定和平
15 段549地號土地於移轉時（即107年11月14日）確作農業使
16 用，故無法依據土地稅法第39條之2第1項規定不課徵土地增
17 值稅。申請人上開主張，並不可採。……」（見原處分卷第
18 263頁）；嗣被上訴人於提起訴願時，訴願書載明：「……
19 本案和平段549地號土地得適用不課徵土地增值稅：查
20 『……』為土地稅法第39條之3第2項之規定，本案共有土地
21 分割前、後各共有人持有總現值增減額皆小於土地公告現值
22 1平方公尺之單價，屬於無須申報土地移轉現值者，原處分
23 機關應通知義務人於30日內提出不課徵土地增值稅之申請，
24 而此農業用地證明文件應可比照法院拍賣之農地應由權利人
25 或義務人於規定期限申請不課徵……，惟原處分機關未通知
26 訴願人提出不課徵土地增值稅之申請，而訴願人已提出岡山
27 區公所於108年10月17日核發岡山區和平段549地號土地之農
28 用證明書，當符合不課徵土地增值稅之條件，無須繳納土地
29 增值稅。……」（見訴願卷第72頁至第73頁），復於原審起
30 訴後，於行政訴訟補充理由狀（續一）表示：「……被告無
31 理由補徵非屬應稅標的之岡山區和平段549地號農業區土地

01 增值稅額1,332,188元，此已剝奪原告得以在該筆土地主張
02 土地稅法（誤繕為土地法）第39條之2第1項不課徵土地增值
03 稅規定之權利（附件十）……」，而該附件十即為岡山區公
04 所就549地號土地於108年10月17日核發之農業用地作農業使
05 用證明書（見原審卷第291頁及第345頁），則上訴人似有以
06 該復查決定之內容，以為否准被上訴人不課徵土地增值稅之
07 意思，而被上訴人於起訴及訴願時，容亦有併就上訴人未准
08 其不予課徵549地號土地之土地增值稅為不服之意，凡此均
09 有待原審闡明、調查、釐清。從而，原判決撤銷訴願決定、
10 復查決定及原核定處分關於被上訴人移轉549地號土地之土
11 地增值稅1,332,188元部分，既有未適用土地稅法第39條之3
12 規定（應適用該條第1項或第2項規定及其後續之法律涵攝，
13 亦待事實審釐清）及上述違誤，並影響判決結論，故上訴意
14 旨指摘原判決違法，求予廢棄，即有理由。因上開事證猶待
15 原審法院闡明釐清，本院尚無從自為判決，爰將原判決廢棄
16 發回，由原審法院更為適法之裁判。

17 七、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1
18 項、第260條第1項，判決如主文。

19 中 華 民 國 112 年 2 月 8 日

20 最高行政法院第二庭

21 審判長法官 帥 嘉 寶

22 法官 鄭 小 康

23 法官 李 玉 卿

24 法官 洪 慕 芳

25 法官 林 玫 君

26 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

27 中 華 民 國 112 年 2 月 8 日

28 書記官 邱 鈺 萍

最 高 行 政 法 院 判 決

112年度上字第701號

上 訴 人 劉蒼明

訴訟代理人 張蓉成 律師

被 上 訴 人 高雄市稅捐稽徵處

代 表 人 曾子玲

訴訟代理人 余淑媛

上列當事人間土地增值稅事件，上訴人對於中華民國112年8月17日高雄高等行政法院112年度訴更一字第3號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、緣上訴人與其弟劉國樑、姪劉耀聖原分別共有高雄市岡山區和平段549地號土地（下稱549地號土地），應有部分各為3分之1，該土地使用分區為農業區，面積3,413.05平方公尺；另劉國樑原單獨所有同區大德段104地號土地（下稱104地號土地），該土地使用分區為住宅區，面積397.73平方公尺。劉國樑於民國106年8月30日與上訴人、劉耀聖訂立贈與契約，將104地號土地持分各100分之1分別贈與上訴人、劉耀聖形成共有關係，嗣上訴人與劉國樑、劉耀聖於107年11月13日將104地號土地分割為同段104、104-1地號土地（下稱分割後104、104-1地號土地），面積分別為184.86平方公尺及212.87平方公尺；復於同年月14日將分割後104、104-1地號土地與549地號土地合併辦理共有物分割，由上訴人單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，549地號土地則由上訴人取得應有部分100,000分之11,963、劉國樑取得應有部分100,000分之79,383、劉耀聖取得應有部分100,000分之8,654，因上訴人與劉國樑、劉耀聖就上開共有土地分割前後應有部分價值增減均在公告土地

01 現值1平方公尺單價以下，而免徵土地增值稅及免申報土地
02 移轉現值。其後被上訴人所屬岡山分處查得上訴人與劉國
03 樑、劉耀聖藉由贈與小面積土地創設共有關係，再辦理共有
04 物分割，行實質交換移轉土地所有權之實，與常規交換土地
05 經濟效果相同，乃依土地稅法第28條規定，以108年9月16日
06 高市稽岡增字第0000000000號函核定按一般用地稅率補徵應
07 納之土地增值稅，其中上訴人新臺幣（下同）1,332,188
08 元、劉國樑1,131,467元，而劉耀聖係於106年4月11日因繼
09 承取得549地號土地故為0元。其等不服，申請復查、訴願均
10 遭駁回，循序提起行政訴訟，求為判決撤銷訴願決定、復查
11 決定及原核定處分。經改制前高雄高等行政法院（下稱原
12 審）以109年度訴字第322號判決將訴願決定、復查決定及原
13 核定處分關於上訴人移轉549地號土地應有部分100,000分之
14 21,370予劉國樑之土地增值稅1,332,188元部分均撤銷，並
15 駁回其餘之訴。上訴人遂就原判決不利其之部分，提起上訴
16 （關於劉國樑、劉耀聖敗訴部分，因未據其等上訴已告確
17 定），上訴部分經本院111年度上字第256號判決廢棄，發回
18 原審更為審理，嗣經原判決駁回上訴人在原審之訴，上訴人
19 遂提起本件上訴。

20 二、上訴人起訴之主張及被上訴人在原審的答辯，均引用原判決
21 所載。

22 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，判決駁回上訴人在
23 原審之訴，其理由略以：

24 (一)、上訴人與劉國樑、劉耀聖原僅共有549地號土地，嗣藉由贈
25 與及分割形成共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，再
26 經由分割共有物，而由上訴人單獨取得分割後104地號土
27 地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，及3人維持原共
28 有549地號土地，僅應有部分比例變更，且因安排分割前後
29 總現值增減均在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，依
30 法規得免申報移轉現值，故無須繳納土地增值稅而逕向地政
31 機關辦理登記。然上訴人與劉國樑、劉耀聖間並無合理之經

01 濟上使用動機或特殊因素致須如此迂迴移轉土地，是上訴人
02 與劉國樑、劉耀聖間於短時間內以「贈與」、「形成共有關
03 係」、「共有物分割」之程序，以達成系爭分割後104、104
04 -1地號土地分別歸屬於上訴人及劉耀聖2人所有之目的，顯
05 係因劉國樑如直接移轉系爭分割後104、104-1地號土地予上
06 訴人及劉耀聖2人並交換該2人於549地號土地之應有部分，
07 無法免徵土地增值稅。故上訴人與劉國樑、劉耀聖藉由贈與
08 移轉系爭104地號土地小部分應有部分，刻意創設共有型
09 態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事
10 雙方互換土地之行為，以達到規避繳納土地增值稅之目的，
11 經濟實質上當已具備土地移轉之課稅構成要件。從而，被上
12 訴人審認上訴人與劉國樑、劉耀聖藉由創造共有關係及分割
13 共有物方式相互移轉549地號土地之應有部分及分割後104、
14 104-1地號土地，實際上為交換土地之有償移轉，尚無違
15 誤。而依土地稅法第5條、第28條前段及第31條第1項第1款
16 規定可知，土地交換係屬有償移轉，應按土地漲價總數額課
17 徵土地增值稅，上訴人與劉國樑、劉耀聖間相互移轉549地
18 號土地之應有部分及分割後104、104-1地號土地時既已享有
19 自然漲價利益，惟上訴人與劉國樑、劉耀聖透過形成共有再
20 分割之法律形式安排規避此項土地增值稅，被上訴人依納稅
21 者權利保護法第7條第3項規定，認上訴人與劉國樑、劉耀聖
22 交換行為當下已享有土地自然漲價利益，原處分以上訴人就
23 549地號土地應補徵土地增值稅1,332,188元，自係適法有
24 據。

25 (二)、就上訴人與劉國樑、劉耀聖以「形成共有」、「分割」之安
26 排規避土地增值稅，經被上訴人依納稅者權利保護法第7條
27 第1項至第3項及刪除前稅捐稽徵法第12條之1第1項至第3
28 項，認上訴人之稅務安排仍具土地有償交換之實質，應核課
29 土地增值稅，遂以原處分通知上訴人與劉國樑、劉耀聖等人
30 應補徵土地增值稅，並檢附土地增值稅繳款書8份，請渠等
31 依期限繳納，並於說明八依法教示上訴人如有不服應於土地

01 增值稅繳款書繳納期間屆滿之次日起30日內敘明理由連同證
02 明文件申請復查。雖原處分並未特別指明本件仍有土地稅法
03 第39條之2第1項規定申請不課徵土地增值稅之適用，然土地
04 稅法第39條之3既已於第1項明定申請不課徵土地增值稅者，
05 應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，於土地現值申
06 報書註明農業用地字樣提出申請；其未註明者，得於土地增
07 值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增
08 值稅。則上訴人既經被上訴人以原處分核定應繳納土地增值
09 稅，若就系爭549地號土地未適用不課徵土地增值稅部分之
10 核定有疑義，即應依法於繳納期間（108年9月21日起至108
11 年10月20日止）屆滿前提出申請，然上訴人遲至108年12月2
12 6日始提出申請並檢具同年10月17日核發之農地農用證明
13 書，核已逾期申請，且因土地稅法第39條之3第1項已明定未
14 遵期申請之法律效果為「不得申請不課徵土地增值稅」，是
15 上訴人即喪失「得申請不課徵土地增值稅」之請求權，縱經
16 證明系爭549地號土地於107年11月13日完成分割登記移轉時
17 確屬農業用地，亦無從適用不課徵土地增值稅。又上訴人與
18 劉國樑、劉耀聖間於系爭549地號土地之有償交換，初始因
19 有免徵土地增值稅之避稅安排，故未主動提出不課徵之申
20 請，於此階段均不涉土地稅法第39條之3第1項、第2項之適
21 用。至系爭549地號土地之移轉經被上訴人認定屬租稅規避
22 而以原處分通知其繳納土地增值稅款後，上訴人仍得於法定
23 期間內「主動」檢具農地農用證明文件以為辦理，復因本件
24 上訴人得申請不課徵之類型，與「無須申報土地增值稅」類
25 型有別，於此自無法比附援引。

26 (三)、至上訴人主張逾期申請導因於被上訴人錯誤之行政指導部
27 分，惟上訴人並未指出被上訴人錯誤行政指導之時點，而依
28 上訴人108年11月18日及同年12月9日復查申請書、申請書內
29 容可知，上訴人於此階段檢附農地農用證明書係主張或說明
30 其形成共有、分割之安排，目的在家產分割，並非脫法避
31 稅，若被上訴人認仍應核課土地增值稅，亦應依土地稅法第

39條之2第4項修正施行日（89年1月26日）當期之公告土地現值，計徵土地增值稅之原地價（即重核土地增值稅），客觀上並無主張依同法第39條之2第1項得申請不課徵土地增值稅；嗣迨至108年12月26日始提出申請書主張符合土地稅法第39條之3第2項不課徵土地增值稅之要件，是上訴人所述亦無可採。至於兩造其餘主張之實體論述，經斟酌後認與判決結果不生影響，爰不贅予一一論究等語，茲為其論據。

四、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，結論並無違誤，茲就上訴理由再予論述如下：

（一）、按土地稅法第5條第1項第1款、第2項規定：「（第1項）土地增值稅之納稅義務人如左：一、土地為有償移轉者，為原所有權人。……（第2項）前項所稱有償移轉，指買賣、交換、政府照價收買或徵收等方式之移轉；所稱無償移轉，指遺贈及贈與等方式之移轉。」第28條規定：「已規定地價之土地，於土地所有權移轉時，應按其土地漲價總數額徵收土地增值稅。……」第31條第1項第1款規定：「土地漲價總數額之計算，應自該土地所有權移轉或設定典權時，經核定之申報移轉現值中減除下列各款後之餘額，為漲價總數額：一、規定地價後，未經過移轉之土地，其原規定地價。規定地價後，曾經移轉之土地，其前次移轉現值。」第39條之2規定：「（第1項）作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。……（第4項）作農業使用之農業用地，於本法中華民國89年1月6日修正施行後第一次移轉，或依第1項規定取得不課徵土地增值稅之土地後再移轉，依法應課徵土地增值稅時，以該修正施行日當期之公告土地現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅。（第5項）本法中華民國89年1月6日修正施行後，曾經課徵土地增值稅之農業用地再移轉，依法應課徵土地增值稅時，以該土地最近一次課徵土地增值稅時核定之申報移轉現值為原地價，計算漲價總數額，課徵土地增值稅……。」第39條之3規定：「（第1項）依前條第1項規定申請不課徵土地增

01 值稅者，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，於土
02 地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未註明者，得
03 於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課
04 徵土地增值稅。但依規定得由權利人單獨申報土地移轉現值
05 者，該權利人得單獨提出申請。（第2項）農業用地移轉，
06 其屬無須申報土地移轉現值者，主管稽徵機關應通知權利人
07 及義務人，其屬權利人單獨申報土地移轉現值者，應通知義
08 務人，如合於前條第1項規定不課徵土地增值稅之要件者，
09 權利人或義務人應於收到通知之次日起30日內提出申請，逾
10 期不得申請不課徵土地增值稅。」可知，作農業使用之農業
11 用地移轉與自然人，原則上應按其土地漲價總數額，於土地
12 所有權移轉時徵收土地增值稅。惟其權利人及義務人於申報
13 土地移轉現值時，得於土地現值申報書註明農業用地字樣申
14 請不課徵土地增值稅；其未註明者，得於土地增值稅繳納期
15 間屆滿前補行申請。而其移轉屬無須申報土地移轉現值者
16 （例如法院拍賣、政府徵收或照價收買而取得土地所有權
17 者，其原土地所有權人未能主動提出申請，是課稅捐稽徵機
18 關主動通知土地所有權人之義務，以保障納稅義務人），則
19 以權利人或義務人收到主管稽徵機關得為申請不課徵土地增
20 值稅之通知次日起30日內，提出不課徵土地增值稅之申請，
21 逾期不得申請不予課徵。

22 (二)、上開土地稅法第39條之2第1項於89年1月26日修正公布前原
23 規定：「農業用地在依法作農業使用時，移轉與自行耕作之
24 農民繼續耕作者，免徵土地增值稅。」惟考量89年1月26日
25 修正公布之土地法，就農地已開放自由買賣，則農地之流通
26 性已與一般土地無差異，其所有權移轉所獲土地漲價利益，
27 已無免徵土地增值稅之必要，故將本條項原關於「免徵土地
28 增值稅」之規範，修正為「得申請不課徵土地增值稅」。又
29 鑑於農業用地移轉，是否課徵土地增值稅，買賣雙方之權益
30 係互相衝突。即課徵土地增值稅，增加本次出售土地人之稅
31 負；不課徵土地增值稅，承受人再移轉時之土地增值稅負擔

01 增加（因為其前次移轉現值並非依本次買賣時之土地公告現
02 值），乃於第39條之3明定申請不課徵土地增值稅之程序。
03 準此，土地稅法第39條之2第1項所稱之「不課徵土地增值
04 稅」，係有別於該條項修正前所規範因「合於該條項所定免
05 稅要件，當然發生免稅效果」之「免徵」土地增值稅；即
06 「不課徵土地增值稅」僅是就該次移轉原應課徵之土地增值
07 稅暫時不予課徵。而是否行使「不課徵」土地增值稅之請求
08 權，需由得享有該不課徵權利之人，依相關法令規定，以向
09 主管稽徵機關提出申請之方式為之。

10 (三)、另土地增值稅係配合全面實施平均地權政策，本於漲價歸公
11 之精神而課徵之稅捐；至於共有物分割因是消滅共有狀態之
12 方式，亦即共有物分割結果，僅是將共有人之共有權變更為
13 單獨所有，故土地稅法施行細則第42條第2項規定：「分別
14 共有土地分割後，各人取得之土地價值與其分割前應有部分
15 價值相等，免徵土地增值稅；其價值減少者，就其減少部分
16 課徵土地增值稅。」只就共有物分割前後各土地所有人取得
17 之土地價值不等，該取得土地價值減少者，就其減少部分，
18 因實質上含有以買賣或贈與等原因為移轉外，而予課徵土地
19 增值稅；財政部且以92年1月14日台財稅字第0000000000號
20 令釋：「共有土地分割，或兩宗以上所有權人不相同之土地
21 合併，各共有人分割、合併前後應有部分價值相差在分割、
22 合併後當期公告土地現值1平方公尺單價以下，依規定得免
23 申報移轉現值之案件……得逕向地政機關辦理登記……。」
24 放寬土地稅法施行細則第42條第2項規定免徵土地增值稅之
25 適用範圍。此因共有土地分割前後應有部分價值相差在分割
26 後當期公告土地現值1平方公尺單價以下，免徵土地增值稅
27 之適用，而不必申報移轉現值之案件，核與土地稅法第39條
28 之3第2項規定所指之「無須申報移轉現值」，原係就依法應
29 課徵之土地增值稅案件，因納稅義務人無法就其應課徵之土
30 地增值稅主動申報情形有別，自無該規定之適用。

01 (四)、按土地稅法施行細則第42條第1項規定：「土地交換，應分
02 別向原土地所有權人徵收土地增值稅。」查上訴人與劉國
03 樑、劉耀聖原僅共有549地號土地，嗣藉由贈與及分割形成
04 共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，再經由分割共有
05 物，而由上訴人單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨
06 取得分割後104-1地號土地，及3人維持原共有549地號土
07 地，僅應有部分比例變更，且因安排分割前後總現值增減均
08 在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，而無須繳納土地
09 增值稅，免申報移轉現值，逕向地政機關辦理登記。上訴人
10 與劉國樑、劉耀聖間於短時間內刻意創設共有型態，再利用
11 共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事雙方互換土
12 地之行為，俾為規避繳納土地增值稅等情，乃原審依法確定
13 之事實。從而，原審論明：土地交換係屬有償移轉，應按土
14 地漲價總數額課徵土地增值稅，認上訴人與劉國樑、劉耀聖
15 交換行為當下已享有土地自然漲價利益，被上訴人以原處分
16 通知上訴人就549地號土地應補徵土地增值稅1,332,188元並
17 檢附土地增值稅繳款書，請其依期限繳納，自係適法有據，
18 雖原處分未特別指明本件仍有土地稅法第39條之2第1項規定
19 申請不課徵土地增值稅之適用，然土地稅法第39條之3既已
20 於第1項明定申請不課徵土地增值稅者，應由權利人及義務
21 人於申報土地移轉現值時，於土地現值申報書註明農業用地
22 字樣提出申請；其未註明者，得於土地增值稅繳納期間屆滿
23 前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅，上訴人既經
24 被上訴人以原處分核定應繳納土地增值稅，若就系爭549地
25 號土地未適用不課徵土地增值稅部分之核定有疑義，即應依
26 法於繳納期間（108年9月21日起至108年10月20日止）屆滿
27 前提出申請，然上訴人遲至108年12月26日始提出申請並檢
28 具同年10月17日核發之農地農用證明書，核已逾期申請，且
29 因土地稅法第39條之3第1項已明定未遵期申請之法律效果為
30 「不得申請不課徵土地增值稅」，是上訴人即喪失「得申請
31 不課徵土地增值稅」之請求權，縱經證明系爭549地號土地

於107年11月13日完成分割登記移轉時確屬農業用地，亦無從適用不課徵土地增值稅；上訴人與劉國樑、劉耀聖間於系爭549地號土地之有償交換，初始因有免徵土地增值稅之避稅安排，故未主動提出不課徵之申請，於此階段均不涉土地稅法第39條之3第1項、第2項規定之適用；至系爭549地號土地之移轉經被上訴人認定屬租稅規避而以原處分通知其繳納土地增值稅款後，上訴人仍得於法定期間內「主動」檢具農地農用證明文件以為辦理，復因本件上訴人得申請不課徵之類型，與「無須申報土地增值稅」類型有別，於此自無法比附援引等得心證之理由甚詳，依上述規定及說明，於法並無不合。上訴人主張申請不課徵土地增值稅之法律依據為土地稅法第39條之3第2項規定，原判決援用同條第1項規定係有判決適用法規不當之違法云云，顯有誤解，並無可取。再土地稅法第39條之3第1項明文規定，權利人及義務人未於土地現值申報書註明農業用地字樣申請不課徵土地增值稅者，得於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅，稅捐稽徵機關並無權裁量放寬，前已述及，是上訴人另主張其於112年4月28日提出原審之書狀表明，承辦本件共有物分割之地政士劉森添約在108年9月27日向原處分機關承辦員王寶斐請教，是否可以申請農用證明書來主張不課徵土地增值稅，經回復需在107年11月14日之土地移轉時，是上訴人雖已申請農用證明書，卻因信賴稅捐機關告知之錯誤行政指導，以致延誤申請農業用地不課徵土地增值稅之時機，判決卻聲稱上訴人並未指出錯誤行政指導之時點，判決理由違背事實云云，縱非無據，仍不影響上訴人因逾期而不得申請不課徵土地增值稅之判定，上訴意旨為此指摘，尚無足採為有利於其之論據。

(五)、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，其結論並無違誤。上訴論旨，仍執前詞，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

01 五、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1
02 項、第98條第1項前段，判決如主文。

03 中 華 民 國 113 年 7 月 30 日

04 最高行政法院第一庭

05 審判長法官 胡 方 新

06 法官 李 玉 卿

07 法官 張 國 勳

08 法官 洪 慕 芳

09 法官 林 玫 君

10 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

11 中 華 民 國 113 年 7 月 30 日

12 書記官 邱 鈺 萍

高雄高等行政法院判決

高等行政訴訟庭第三庭

112年度訴更一字第3號

民國112年8月3日辯論終結

原告 劉蒼明
被告 高雄市稅捐稽徵處

代表人 蔡麗惠

訴訟代理人 余淑媛

上列當事人間土地增值稅事件，原告不服高雄市政府中華民國109年7月10日高市府法訴字第10930713400號訴願決定，提起行政訴訟，前經本院109年度訴字第322號判決後，被告不服，提起上訴，經最高行政法院111年度上字第256號判決廢棄本院前開判決不利被告之部分，發回本院更為審理，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、第一審及發回前上訴審訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、爭訟概要：

緣原告與原判決原告劉國樑、劉耀聖原分別共有高雄市岡山區和平段549地號土地（下稱549地號土地），應有部分各為3分之1，該土地使用分區為農業區，面積3,413.05平方公尺。另劉國樑原單獨所有同區大德段104地號土地（下稱104地號土地），該土地使用分區為住宅區，面積397.73平方公尺，劉國樑於民國106年8月30日與原告、劉耀聖訂立贈與契約，將104地號土地持分各100分之1分別贈與原告、劉耀聖形成共有關係，嗣原告與劉國樑、劉耀聖於107年11月13日將104地號土地分割為同段104、104-1地號土地（下稱分割後104、104-1地號土地），面積分別為184.86平方公尺及212.87平方公尺；復於同年月14日將分割後104、104-1地號土地與549地號土地合併辦理共有物分割，由原告單獨取得分

01 割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，
02 549地號土地則由劉國樑取得應有部分100,000分之79,383、
03 原告取得應有部分100,000分之11,963、劉耀聖取得應有部
04 分100,000分之8,654，因原告與劉國樑、劉耀聖就上開共有
05 土地分割前後應有部分價值增減均在公告土地現值1平方公
06 尺單價新臺幣（下同）6,200元以下，依法規免徵土地增值
07 稅及免申報土地移轉現值。嗣被告所屬岡山分處（下稱岡山
08 分處）查得原告與劉國樑、劉耀聖藉由贈與小面積土地創設
09 共有關係，再辦理共有物分割，行實質交換移轉土地所有權
10 之實，與常規交換土地經濟效果相同，乃依稅捐稽徵法、土
11 地稅法等規定，以108年9月16日高市稽岡增字第1088569298
12 號函核定按一般用地稅率補徵應納之土地增值稅，其中劉國
13 樑1,131,467元、原告1,332,188元，而劉耀聖係於106年4月
14 11日因繼承取得549地號土地故為0元。其等不服，申請復
15 查，未獲變更，提起訴願，亦遭決定駁回，提起行政訴訟，
16 經本院（下稱原審）109年度訴字第322號判決（下稱原判
17 決）：「訴願決定、復查決定及原核定處分關於原告劉蒼明
18 移轉549地號土地之土地增值稅1,332,188元部分均撤銷。」
19 被告不服，提起上訴，經最高行政法院以111年度上字第256
20 號判決（下稱發回判決）廢棄，發回本院更為審理（劉國
21 樑、劉耀聖敗訴部分未上訴，已告確定）。

22 二、原告起訴主張及聲明：

23 （一）主張要旨：

24 1.本件農業用地移轉，屬無須申報移轉現值：

25 (1)原告以共有物分割方式辦理土地移轉，因符合財政部92
26 年1月14日台財稅字第0910456670號令（下稱財政部92
27 年1月14日令）及102年3月15日台財稅字第10200500210
28 號函（下稱財政部102年3月15日函）規定，無需申報土
29 地增值稅。原告與劉國樑、劉耀聖於107年11月12日向
30 岡山地政事務所申請審查共有物分割登記，而在107年1
31 1月14日完成產權移轉登記，整個土地產權過戶過程

01 中，原告與劉國樑、劉耀聖並未向被告申報土地移轉現
02 值。

03 (2)被告主張原告於此共有土地分割案，不能適用財政部92
04 年1月14日令及102年3月15日函，卻未提出法律依據。
05 被告應提示法律條文，依法應通知原告補辦申報土地移
06 轉現值，惟被告並未通知原告申報土地移轉現值，即逕
07 為核定土地增值稅繳款書，此已坐實本案確屬無須申報
08 土地移轉現值之案件，被告主張本件不能適用免申報土
09 地移轉現值之理由已違背被告之處分事實。況岡山分處
10 之業務承辦員、被告復查決定書、訴願答辯書均認定提
11 出農業用地作農業使用證明書(下稱農地農用證明書)時
12 間應在107年11月14日之土地移轉時，並非於土地增值
13 稅繳納期間(108年9月21日起至108年10月20日)提出
14 申請，此項見解，與被告現在主張原告逾期未申請不課
15 徵土地增值稅之理由有所不同。

16 2.本件應適用土地稅法第39條之3第2項與第39條之2第1項等
17 2項規定，被告未通知原告得主張不課徵土地增值稅之權
18 利，自無逾期申請不課徵土地增值稅之問題：

19 (1)本件共有土地分割案，依法無須申報土地移轉現值，而
20 被告亦認同無須申報土地移轉現值之見解，故未通知原
21 告補報土地移轉現值，又在誤解法律規定下，逕為核發
22 土地增值稅繳款書之處分，惟全部繳款書之容，並
23 載明納稅義務人可於土地增值稅繳納期間提出農地農用
24 證明書主張不課徵土地增值稅之文字，因此，原告僅能
25 依繳款書說明三之指示於法定期間提出復查。

26 (2)本件共有物分割案，符合土地稅法第39條之3第2項之規
27 定，被告依法應通知權利人及義務人，如合於前條第1
28 項規定不課徵土地增值稅之要件(即此要件僅指作農業
29 使用之農業用地)者，權利人或義務人應於收到通知次
30 日起30日(此處就是時間要件)提出申請，逾期不
31 申請不課徵土地增值稅。而被告並未通知原告有此項權

01 利，被告只有發出土地增值稅繳款書，並未完成合法通
02 知原告有這項不課徵土地增值稅權利意思之送達，顯
03 然，被告聲稱原告是因逾期申請不課徵土地增值稅而需
04 被課稅之問題，自始至今都不存在。被告既未通知原告
05 得主張不課徵土地增值稅之權利，當然，就無逾期申請
06 不課徵土地增值稅之問題。

07 3.航照圖與農地農用證明書皆可作為「作農業使用之農業用
08 地」之證明文件：

09 (1)被告之審查標準，並不要求申請人提供89年1月6日之農
10 地農用證明書，僅以88年與89年之航照圖代替農地農用
11 證明書，並以航照圖作為判斷農地有無作農業使用之標
12 準。而土地稅法第39條之2第1項規定，並未明定必須提
13 出何時申請之農地農用證明書，雖於土地稅法施行細則
14 第58條第1項明定：「依本法第39條之2第1項申請不課
15 徵土地增值稅者，應檢附直轄市、縣（市）農業主管機
16 關核發之農業用地作農業使用證明文件，送主管機關辦
17 理。」此亦未明訂該農地農用證明書之核發時間，必須
18 在農地移轉當日方為有效。

19 (2)被告於112年6月8日準備程序筆錄中提到：「法拍不用
20 申報，是事後被告通知要來補申請，補提農證，但拍定
21 日還是要作農業使用，即使拿到農證我們還是會審核，
22 ……。」亦即申請人無須拿到拍定日之農地農用證明
23 書，在拍定日後所申請之農地農用證明書，亦可作為農
24 地使用之證明文件，但是，被告能提出拍定日有未作農
25 地農用之事實物證，就不能核准不課徵土地增值稅，因
26 此，被告也認為農地農用證明書並非唯一決定核准不課
27 徵土地增值稅之文件，重點在於土地移轉當日是否作為
28 農業土地使用。

29 (二)聲明：訴願決定、復查決定及原處分除確定部分外均撤銷。

30 三、被告答辯及聲明：

31 (一)答辯要旨：

01 1.本案土地為一般應稅土地及農業用地以共有物分割方式移
02 轉土地所有權，經原告安排成免徵土地增值稅案件，若未
03 經原告刻意安排土地所有權移轉方式或共有物分割後各共
04 有人應有部分價差在1平方公尺單價以上，原告本應依據
05 土地稅法第28條規定向被告申報土地移轉現值，由被告核
06 定土地增值稅，自非屬上開土地稅法第39條之3第2項規範
07 農業用地移轉之無須申報案件。上開規定無須申報案件，
08 於稽徵實務上常見於經由法院或法務部行政執行署執行拍
09 賣土地案件，為稽徵機關依執行機關土地拍定價額通知核
10 定土地增值稅，由稽徵機關將核定土地增值稅繳款書逕行
11 通知執行機關依稅捐稽徵法第6條規定自拍賣或承受價額
12 中優先扣繳，是類案件納稅義務人不會收到土地增值稅繳
13 款書，故稽徵機關應依上開規定將核定土地增值稅之稅額
14 通知納稅義務人，輔導申請不課徵、減徵、免徵或適用優
15 惠稅率等，維護納稅義務人權益。本案土地移轉時(107年
16 11月14日)，並未經被告核定土地增值稅，即逕行向地政
17 機關辦理登記。原告訴訟主張，其屬上開規定農業用地移
18 轉之無須申報案件，被告應通知其申請不課徵土地增值稅，
19 被告未盡通知義務，並無逾期提出申請等情，顯有誤
20 解法令。

21 2.本案土地所有權移轉時為107年11月14日，參照財政部89
22 年5月24日台財稅第0890453867號函釋：「有關農業用地
23 移轉，所檢附主管機關核發之農業用地作農業使用證明
24 書，應自核發之日起至申報移轉現值收件之日或法院拍定
25 之日或辦竣登記之日止，在6個月內者，始得適用土地稅
26 法第39條之2第1項規定申請不課徵土地增值稅。」故原告
27 檢附之農地農用證明書核發日期為108年10月17日，已然
28 非為移轉時(107年11月14日)6個月效期內之農地農用證明
29 書，自不符合土地稅法第39條之2第1項不課徵土地增值稅
30 之規定。被告相關人員前以該農地農用證明書，不符合不
31 課徵土地增值稅要件，依法並無違誤。原告主張該農地農

01 用證明書可以符合不課徵土地增值稅條件，應有誤解。且
02 因被告相關承辦人員誤導致其未於取得該農地農用證明書
03 時，提出申請不課徵土地增值稅，亦無足採。

04 3.本案核定土地增值稅繳納期間為108年9月21日至108年10
05 月20日止，原告至108年12月26日始共同提出申請不課徵
06 土地增值稅，依據土地稅法第39條之3第1項明定申請不課
07 徵土地增值稅，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值
08 時，於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未
09 註明者，得於土地增值稅繳納期間屆滿(即108年10月20
10 日)前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅。被告
11 乃以系爭土地於108年12月26日原告始共同提出申請，已
12 逾上開申請不課徵土地增值稅期限(108年10月20日)，依
13 上開規定不得申請不課徵土地增值稅。

14 (二)聲明：原告之訴駁回。

15 四、爭點：系爭549地號土地之移轉是否符合不課徵土地增值稅
16 要件？

17 五、本院的判斷：

18 (一)前提事實：

19 爭訟概要欄所載事實，業經兩造陳明在卷，並有土地增值稅
20 (土地現值)申報書及(一般贈與)土地增值稅繳款書(第
21 105-108頁)、土地增值稅(土地現值)申報書及(一般交
22 換)土地增值稅繳款書(第119-122、150-153、156-158
23 頁)、物價指數查詢(第202-206頁)、地價查詢資料(第2
24 10-217頁)、地價改算通知書(第218-220頁)、土地現值
25 計算表(第221頁)、原處分(第9-11頁)、復查決定書
26 (第254-264頁)、訴願決定書(第328-340頁)等件(影
27 本)附原處分卷可稽，且為兩造所不爭，堪以認定。

28 (二)租稅規避之認定及原處分的作成：

29 1.納稅者權利保護法(下稱納保法)第7條規定：「……(第
30 3項)納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，
31 濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，

以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。……（第6項）稅捐稽徵機關查明納稅者及交易之相對人或關係人有第3項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料依各稅法規定予以調整。（第7項）第3項之滯納金，按應補繳稅款百分之15計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅款，依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。（第8項）第3項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。」依此可知，對於租稅規避行為，稅捐稽徵機關得根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。

- 2.其次，利用應稅土地與免徵或不課徵土地增值稅土地創造共有關係，再辦理共有物分割，與單純共有土地之分割係在消滅共有關係之情形，明顯有別。納稅義務人若藉「移轉」、「取得」、「共有物分割」及「再移轉」之程序，創設土地共有之事實後，再辦理共有物分割登記，並藉地政機關之改算地價，使其土地登記簿登載之前次移轉現值因此墊高，以達再移轉時得少繳或免繳土地增值稅之目的，屬實務上常見且由來已久之避稅類型，過往向由稽徵機關依實質課稅原則(110年12月17日刪除前稅捐稽徵法第12條之1第1項至第3項、司法院釋字第420號解釋參照)認屬租稅規避，並於土地交換者確享有土地漲價利益，仍應課徵土地增值稅，遂有財政部93年8月11日台財稅字第0000000000號令釋：「原持有應稅土地之土地所有權人，利用應稅土地與免徵或不課徵土地增值稅之土地，安排形成共有關係，經分割後再移轉應稅土地者，無論再移轉時之

納稅義務人是否為原土地所有權人名義，依實質課稅原則及土地稅法第28條、第31條規定，該土地於分割後再移轉時，應以其分割前之原規定地價或前次移轉現值為原地價，計算漲價總數額課徵土地增值稅；本解釋令發布前類此上開經共有分割且再移轉之案件，應依上述規定補徵其土地增值稅。」之作成，而該令釋係在闡明平均地權條例、土地稅法就土地自然漲價利益歸公之規範意旨，與租稅法定主義無違，得為稽徵機關適用。凡此，均為原告等106年、107年為土地移轉稅務規劃之背景事實，先此說明。

3.經查，原告與劉國樑、劉耀聖原僅共有549地號土地，嗣藉由贈與及分割形成共同持有系爭分割後104及104-1地號土地，再經由分割共有物，而由原告單獨取得分割後104地號土地，劉耀聖單獨取得分割後104-1地號土地，及3人維持原共有549地號土地，僅應有部分比例變更，且因安排分割前後總現值增減均在各筆土地公告現值1平方公尺單價以下，依法規得免申報移轉現值，故無須繳納土地增值稅而逕向地政機關辦理登記。然原告與劉國樑、劉耀聖間並無合理之經濟上使用動機或特殊因素致須如此迂迴移轉土地，是原告與劉國樑、劉耀聖間於短時間內以「贈與」、「形成共有關係」、「共有物分割」之程序，以達成系爭分割後104、104-1地號土地分別歸屬於原告及劉耀聖2人所有之目的，顯係因劉國樑如直接移轉系爭分割後104、104-1地號土地予原告及劉耀聖2人並交換該2人於549地號土地之應有部分，無法免徵土地增值稅。故原告與劉國樑、劉耀聖藉由贈與移轉系爭104地號土地小部分應有部分，刻意創設共有型態，再利用共有物分割之法律形式、名義及外觀，實質從事雙方互換土地之行為，以達到規避繳納土地增值稅之目的，經濟實質上當已具備土地移轉之課稅構成要件。從而，被告審認原告與劉國樑、劉耀聖藉由創造共有關係及分割共有物方式相互移轉549地號

01 土地之應有部分及分割後104、104-1地號土地，實際上為
02 交換土地之有償移轉，尚無違誤。而依土地稅法第5條、
03 第28條前段及第31條第1項第1款規定可知，土地交換係屬
04 有償移轉，應按土地漲價總數額，課徵土地增值稅，原告
05 與劉國樑、劉耀聖間相互移轉549地號土地之應有部分及
06 分割後104、104-1地號土地時既已享有自然漲價利益，惟
07 原告與劉國樑、劉耀聖透過形成共有再分割之法律形式安
08 排規避此項土地增值稅，被告依前揭納保法第7條第3項規
09 定，認原告與劉國樑、劉耀聖交換行為當下已享有土地自
10 然漲價利益，原處分以原告就549地號土地應補徵土地增
11 值稅1,332,188元，自係適法有據。

12 (三)原告未於土地增值稅繳納期間屆滿前申請不課徵：

13 1.應適用的法令及說明：

14 (1)土地稅法第5條第1項第1款、第2項：「(第1項)土地
15 增值稅之納稅義務人如左：一、土地為有償移轉者，為
16 原所有權人。……。 (第2項)前項所稱有償移轉，指
17 買賣、交換、政府照價收買或徵收等方式之移轉；
18 ……。」第39條之2第1項：「作農業使用之農業用地，
19 移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。」第39條
20 之3：「(第1項)依前條第1項規定申請不課徵土地增
21 值稅者，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，
22 於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未註
23 明者，得於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期
24 不得申請不課徵土地增值稅。但依規定得由權利人單獨
25 申報土地移轉現值者，該權利人得單獨提出申請。(第
26 2項)農業用地移轉，其屬無須申報土地移轉現值者，
27 主管稽徵機關應通知權利人及義務人，其屬權利人單獨
28 申報土地移轉現值者，應通知義務人，如合於前條第1
29 項規定不課徵土地增值稅之要件者，權利人或義務人應
30 於收到通知之次日起30日內提出申請，逾期不得申請不
31 課徵土地增值稅。」

01 (2)土地稅法施行細則第58條：「（第1項）依本法第39條
02 之2第1項申請不課徵土地增值稅者，應檢附直轄市、縣
03 （市）農業主管機關核發之農業用地作農業使用證明文
04 件，送主管稽徵機關辦理。（第2項）直轄市、縣
05 （市）農業主管機關辦理前項所定作農業使用證明文件
06 之核發事項，得委任或委辦區、鄉（鎮、市、區）公所
07 辦理。」

08 (3)依土地稅法第39條之3第1項申請不課徵土地增值稅應於
09 繳納期間屆滿前申請：

10 鑑於農業用地移轉，是否課徵土地增值稅，買賣雙方之
11 權益係互相衝突，即課徵土地增值稅，增加本次出售土
12 地人之稅負；不課徵土地增值稅，承受人再移轉時之土
13 地增值稅負擔增加，乃於土地稅法第39條之3明定申請
14 不課徵土地增值稅之程序。準此，「不課徵土地增值
15 稅」僅是就該次移轉原應課徵之土地增值稅暫時不予課
16 徵，故是否「不課徵」係該次移轉之權利人或義務人之
17 權利，且此請求權之行使，需由得享有該不課徵權利之
18 人，依相關法令規定，以向主管稽徵機關提出申請之方
19 式為之。而其中屬土地稅法第39條之3第1項規定之情形
20 者，因該條項已明定未遵期申請之法律效果為「不得申
21 請不課徵土地增值稅」，是得享有該不課徵土地增值稅
22 權利之人，如未於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申
23 請，即喪失「得申請不課徵土地增值稅」之請求權。

24 2.原告逾期申請而生失權效果

25 (1)原告逾期申請：

26 查就原告與劉國樑、劉耀聖以「形成共有」、「分割」
27 之安排規避土地增值稅，經被告依納保法第7條第1項至
28 第3項及刪除前稅捐稽徵法第12條之1第1項至第3項，認
29 原告之稅務安排，仍具土地有償交換之實質，應核課土
30 地增值稅，遂以原處分通知原告與劉國樑、劉耀聖等人
31 應補徵土地增值稅，並檢附土地增值稅繳款書8份（見原

處分卷第9-27頁)，請渠等依期限繳納，並於說明八、依法教示原告如有不服應於土地增值稅繳款書繳納期間屆滿之次日起30日內敘明理由連同證明文件申請復查。雖然原處分並未特別指明本件仍有土地稅法第39條之2第1項申請不課徵土地增值稅之適用，然土地稅法第39條之3既已於第1項明定申請不課徵土地增值稅者，應由權利人及義務人於申報土地移轉現值時，於土地現值申報書註明農業用地字樣提出申請；其未註明者，得於土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，逾期不得申請不課徵土地增值稅。……。則原告既經被告以原處分核定應繳納土地增值稅，若就系爭549地號土地未適用不課徵土地增值稅部分之核定有疑義，即應依法於繳納期間(108年9月21日起至108年10月20日止)屆滿前提出申請，然原告遲至108年12月26日始提出申請並檢具同年10月17日核發之農地農用證明書(見原處分卷第232頁、第84頁)，核已逾期申請，且如上所述，因土地稅法第39條之3第1項已明定未遵期申請之法律效果為「不得申請不課徵土地增值稅」，是原告即喪失「得申請不課徵土地增值稅」之請求權，縱經證明系爭549地號土地於107年11月13日完成分割登記移轉時確屬農業用地，亦無從適用不課徵土地增值稅。

(2)土地稅法第39條之3第2項規定於本件無法比附援引：

①土地稅法第39條之3第2項之規範標的為「無須申報土地移轉現值」類型：

按土地稅法第39條之3第2項所規定之由權利人單獨申報，常見情況例如法院判決、和解或調解而取得土地所有權；無須申報土地移轉現值之案件，則例如法院拍賣、政府徵收或照價收買。諸如此類情形，是因為程序上土地所有權人無法依規定主動提出申請，故規定稽徵機關應主動通知土地所有權人，其合於要件者，應於收到通知之次日起30日內提出申請，藉以保

障土地所有權人權益，其所檢具之農地農用證明書自屬收受稽徵機關通知後方申請取得。

②本件不課徵之申請與「無須申報土地增值稅」案件有別：

如上所述，原告與劉國樑、劉耀聖間於系爭549地號土地之有償交換，初始因有如上免徵土地增值稅之避稅安排，故未主動提出不課徵之申請，於此階段均不涉土地稅法第39條之3第1項、第2項之適用。至系爭549地號土地之移轉經被告認定屬租稅規避而以原處分通知其繳納土地增值稅款後，依前揭說明，原告仍得於法定期間內「主動」檢具農地農用證明文件以為辦理，復因本件原告得申請不課徵之類型，與上開「無須申報土地增值稅」類型有別，於此自無法比附援引。是以，原告主張被告於原處分作成後，未依職權通知原告得為不課徵之申請，程序並非正當，尚無可採。

(3)又如上所述，原告逾期申請，程序上已具失權效果，自無庸再為實體審究系爭549地號土地於移轉時是否確實為作農業使用之農業用地，併此說明。

(四)原告主張逾期申請導因於被告錯誤之行政指導部分：

1.原處分於108年9月16日作成後，原告於同年10月17日即取得農地農用證明書，因被告以農地農用證明書須主管機關於549地號等3筆土地辦理共有物分割之時間（107年11月14日）時所出具方屬合法，緣此錯誤之行政指導，至原告未及時提出申請等語。

2.經查，原告並未指出被告錯誤行政指導之時點，而依原告108年11月18日及同年12月9日復查申請書、申請書內容可知，原告於此階段檢附農地農用證明書（見原處分卷第84頁）係主張或說明其形成共有、分割之安排，目的在家產分割，並非脫法避稅，若被告認仍應核課土地增值稅，亦應依土地稅法第39條之2第4項修正施行日（89年1月26日）

當期之公告土地現值，計徵土地增值稅之原地價(即重核土地增值稅)，客觀上並無主張依同法第39條之2第1項得申請不課徵土地增值稅；嗣迨至108年12月26日始提出申請書主張符合土地稅法第39條之3第2項不課徵土地增值稅之要件，各有上開108年11月18日、12月9日及12月26日申請書在卷(原處分卷第1-8、185-186、232頁)可參，是原告上開所述，亦無可採。

六、綜上，原告所述，均無可採。原處分(含復查決定)予以駁回，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合。原告訴訟論旨求予撤銷，為無理由，應予駁回。至於兩造其餘主張之實體論述，經本院斟酌後認與本件判決結果不生影響，爰不贅予一一論究，併此敘明。

七、結論：原告之訴為無理由。

中 華 民 國 112 年 8 月 17 日

審判長法官 林 彥 君

法官 廖 建 彥

法官 黃 堯 讚

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造人數附繕本）。未表明上訴理由者，逕以裁定駁回。

二、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第49條之1第1項）

三、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第3項、第4項）

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任	1. 當事人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或

01

律師為訴訟代理人。	為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授。 2. 稅務行政事件，當事人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格。 3. 專利行政事件，當事人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人。
(二)非律師具有右列情形之一，經本案之行政法院認為適當者，亦得為訴訟代理人。	1. 當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人。 4. 當事人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，當事人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

02

中 華 民 國 112 年 8 月 17 日

03

書記官 江 如 青

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第20號

上 訴 人 黃中諒

訴訟代理人 張捷安 律師

被 上 訴 人 財政部中區國稅局

代 表 人 吳蓮英

上列當事人間遺產稅事件，上訴人對於中華民國110年11月3日臺中高等行政法院109年度訴字第245號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人之父黃建志於民國000年0月00日死亡，繼承人有黃詹庭育（被繼承人之配偶）、黃中涵、黃中甯、黃中慧及上訴人（被繼承人之子女），經被上訴人所屬大屯稽徵所依繼承人申請核准展延遺產稅申報期限至107年5月23日，黃詹庭育依限於107年5月21日申報遺產總額新臺幣（下同）56,801,952元，遺產淨額14,181,952元（訴願決定書誤載為30,620,000元，原處分卷第31-34頁），應納稅額278,566元；經被上訴人依申報及查得漏報被繼承人所遺存款及其他財產等，核定遺產總額60,098,429元，遺產淨額17,478,429元，應補稅額64,936元。嗣黃詹庭育於108年1月3日檢附Sinlin Investment Co., Ltd股東協議書及境外保險公司通知文件，以被繼承人死亡時遺有美金計價之境外公司投資額及7張境外保單，按被繼承人死亡時之匯率30.235元折算新臺幣，補申報境外公司投資額24,188,000元及7張境外保單金額284,574,033元；上訴人則於108年3月19日補申報被繼承人上開境外保單之保險理賠金112,109,795元。被上訴人遂依據補申報資料，重行核定被繼承人遺產總額為368,860,462元，遺產淨

01 額159,448,685元，應納稅額22,706,831元。上訴人就該7張
02 境外保單中之3張保單：Conseco Life Insurance Company
03 保單（財產種類編號AB-52）、FWD Life Insurance Compa
04 ny (Bermuda) Limited保單（財產種類編號AD-54）、HSBC L
05 ife International Limited保單（財產種類編號AH-58），
06 核定金額共計248,909,389元部分不服（下合稱系爭3張境外
07 保單），申請復查未獲變更，提起訴願亦遭駁回，循序提起
08 本件行政訴訟，經原審以109年度訴字第245號判決（下稱原
09 判決）駁回。上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

10 二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審答辯均引用原判決所載。

11 三、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：(一)系爭3張境外保單
12 購買之時間分別為90年、98年及101年，黃建志行為時點自9
13 0年間至101年間，保險法關於未經主管機關核准之境外壽險
14 保單之規定，雖有文字修正，然其主旨並無差別，均認未經
15 主管機關許可銷售之境外壽險保單，並非保險法第112條所
16 稱之保險給付，系爭3張境外保單既然未經金融監督管理委
17 員會（下稱金管會）核准，被上訴人認定系爭3張境外保單
18 之給付不得免除列入遺產計算，自屬有據。(二)上訴人主張系
19 爭3張境外保單購買之時間分別為90年、98年及101年，而被
20 繼承人黃建志檢查得知罹患肝癌為000年00月間，自難據此
21 論斷被繼承人黃建志購買系爭3張境外保單之目的即為規避
22 遺產稅，然被繼承人黃建志於罹癌後即於000年0月間變更系
23 爭3張境外保單之受益人為Gold Aroma Ltd.（下稱GA公
24 司），而GA公司係由部分繼承人黃中諒（即上訴人）、黃詹
25 庭育分別持有65%、35%股份。顯見被繼承人黃建志確知罹癌
26 後，即以指定受益人予境外GA公司之方式，使部分繼承人黃
27 中諒、黃詹庭育依據持股而間接取得系爭3張境外保單之全
28 額保險給付248,909,389元。況上訴人始終並未舉證其變更
29 指定受益人之決定，有其他合法目的，自難為其有利之認
30 定。此外，GA公司之成立乃係於被繼承人黃建志確認自身罹
31 癌後所成立，目的係作為系爭3張境外保單變更受益人之主

01 體，除此之外，上訴人並未舉證GA公司另曾參與其他商業活
02 動之具體事證，顯見其成立目的僅係為被繼承人黃建志規避
03 遺產稅，自屬濫用法律形式所為之租稅規避。縱使GA公司為
04 合法成立之境外公司，自難僅因GA公司合法設立，即為上訴
05 人有利之認定。(三)另依上訴人於108年3月26日在被上訴人談
06 話紀錄、被繼承人之配偶黃詹庭育於108年3月20日談話紀錄
07 及被繼承人黃建志之兄黃建立談話紀錄，可知被繼承人黃建
08 志於000年00月19日經診斷患有惡性肝腫瘤後即於104年3月9
09 日設立GA公司，公司原始股東上訴人、黃詹庭育、黃建立等
10 均未實質出資，亦未實際營業，目的乃係生前預作遺產分
11 配，藉此達到規避財產併入遺產總額核算遺產稅之目的，自
12 屬「租稅規避」。(四)再依臺灣臺中地方法院公證處106年度
13 中院公字第006000155號公證書本及其檢附被繼承人104年8
14 月10日所立「黃建志平安書（遺囑）」內容之記載，益證系
15 爭3張境外保單之外觀形式雖然指定GA公司為受益人，然GA
16 公司係被繼承人為規避遺產稅而設立之境外公司，且被繼承
17 人黃建志之真意亦將系爭3張境外保單之保險金列為遺產，
18 實質上由部分繼承人（上訴人及黃詹庭育）於其死亡時獲得
19 相當於遺產之保險金給付。從而，基於實質課稅及公平課稅
20 原則，系爭3張境外保單並無遺產及贈與稅法第16條第9款前
21 段及保險法第112條規定之適用。是被上訴人將系爭3張境外
22 保單之保險給付金額248,909,389元併入被繼承人黃建志之
23 遺產總額，課徵遺產稅，並無違誤，復查決定及訴願決定均
24 予以維持，亦無不合。末查，系爭3張境外保單之受益人為G
25 A公司，而GA公司僅由部分繼承人持股（即上訴人與黃詹庭
26 育分別持有65%、35%股份），雖繼承人全體如無其他特定事
27 由，自應依其應繼分共同繼承，然本件涉及被繼承人黃建志
28 另以遺囑（平安書）進行遺產分配，自不得以GA公司僅由部
29 分繼承人持股，即認系爭3張境外保單非屬遺產等語。

30 四、上訴人上訴意旨略以：(一)財政部95年6月28日台財稅字第095
31 04540210號函及金管會95年6月1日金管保三字第0950203182

01 0號函規定，將人民在生前基於財產規劃所投保的境外保單
02 遽以排除在保險法第112條規範之外，顯增加法律所無之限制。
03 本件黃建志係依據要保人在保險契約中指定受益人之規定，
04 進而更改受益人，享契約自治之規範，原判決未依據司
05 法院釋字第137號、第216號及第566號解釋審酌「私法自
06 治」、「租稅法定」，自有判決理由不備之違誤。(二)黃建志
07 就系爭3張境外保單更改受益人之時間距離其死亡時間已超
08 過兩年，被上訴人就系爭3張境外保單無從依據遺產及贈與
09 稅法課徵稅捐。又系爭3張境外保單，不論解釋為保險契約
10 或第三人利益契約，黃建志為死亡前數年即與國外保險公司
11 訂約並指定受益人，顯係基於財務規劃，然原判決逕認系爭
12 3張境外保單係為產生租稅規避之結果云云，顯然與上開事
13 實矛盾。上訴人於原審辯論終結後取得系爭3張境外保單之
14 保險契約內容，並具狀要求再開辯論以釐清受益人保單約定
15 情形及受益人之變更是否屬於「租稅規定」等事實，然未獲
16 原審准許，而原判決對上訴人主張不符合遺產及贈與稅法要
17 件之理由，亦未說明何以不採之理由，自有判決理由不備之
18 違誤。

19 五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
20 訴意旨補充論斷如下：

21 (一)按行為時遺產及贈與稅法第1條第1項規定：「凡經常居住
22 中華民國境內之中華民國國民死亡時遺有財產者，應就其
23 在中華民國境內境外全部遺產，依本法規定，課徵遺產
24 稅。」第10條第1項規定：「遺產及贈與財產價值之計
25 算，以被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；
26 ……。」第14條規定：「遺產總額應包括被繼承人死亡時
27 依第1條規定之全部財產，及依第10條規定計算之價值。
28 但第16條規定不計入遺產總額之財產，不包括在內。」第
29 16條第9款規定：「左列各款不計入遺產總額：……九、
30 約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險
31 金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助

01 金。」而前開遺產及贈與稅法第16條第9款係配合保險法
02 第112條規定：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於
03 其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺
04 產。」而訂定，故有指定受益人之人壽保險契約，其死亡
05 給付得適用前開遺產及贈與稅法第16條第9款規定者，以
06 該人壽保險契約得適用保險法第112條規定為限。

07 (二) 依保險法第1條規定：「本法所稱保險，謂當事人約定，
08 一方交付保險費於他方，他方對於因不可預料，或不可抗
09 力之事故所致之損害，負擔賠償財物之行為。」可知，保
10 險係就不可預料或不可抗力之事故，本於風險分散之原
11 理，即付出較少之代價(保費)卻能獲得較大之保障。而保
12 險業為特許事業，依保險法第137條規定內、外國保險業
13 非經主管機關許可，並依法為設立登記，繳存保證金，領
14 得營業執照後，不得開始營業。故上述遺產及贈與稅法及
15 保險法關於被保險人死亡時給付於其所指定受益人之人壽
16 保險金額，不計入遺產總額之規定，即是本於上述保險之
17 原理，從人道精神所為之立法裁量，其立法意旨，應指在
18 一般正常社會情況下，被繼承人以自己為被保險人，依我
19 國現行保險法規定，投保人壽保險，係為保障並避免其家
20 人因其死亡而失去經濟來源，致生活陷於困境，倘其所指
21 定受益人所受領之人壽保險金計入遺產總額，課徵遺產
22 稅，有違保險目的，故明定被繼承人死亡時給付於其所指
23 定之受益人之人壽保險之保險金額，不計入遺產總額，並
24 非鼓勵或容認一般人利用此方式任意規避原應負擔之遺產
25 稅。從而，非依我國保險法規定訂立之人壽保險契約，自
26 無保險法第112條規定之適用，亦無從依遺產及贈與稅法
27 第16條第9款規定主張給付金額不計入遺產總額。查系爭3
28 張境外保單為未經主管機關許可銷售之保險商品，此為原
29 審依職權調查認定之事實，原判決據此認定其給付非保險
30 法第112條之保險給付，亦不得免計入遺產總額，自無不
31 合。原判決並非逕援引行政機關函釋為論據，上訴意旨指

01 摘原判決未依據司法院釋字第137號、第216號及第566號
02 解釋審酌「私法自治」、「租稅法定」，有判決理由不備
03 之違誤云云，尚非可採。

04 (三) 況保險具有分散風險及危險分擔之功能（保險法第1條規
05 定參照），而人壽保險因係包含以人之生命為保險事故，
06 惟人之生命又非可以金錢衡量，是其保險金額應以保險契
07 約定之。至投資型保險因關於投資帳戶之風險係由要保人
08 自行承擔，故與保險之意旨不合，更與人壽保險因人身無
09 價而具定額保險之性質有悖。從而人壽保險契約中屬因投
10 資型保險所具之投資帳戶價值，縱其係約定於被保險人死
11 亡時以給付所指定受益人之形式為之，亦因其性質上不屬
12 人壽保險之死亡給付，自無遺產及贈與稅法第16條第9款
13 及保險法第112條關於「不得作為被保險人遺產」規定之
14 適用。至於若該包含以人之生命為保險事故之保險契約，
15 除具前述之投資內容外，復另有人壽保險所須具備之定額
16 保險部分，縱符合人壽保險之本質，惟如個案有租稅規避
17 之情事，依行為時稅捐稽徵法第12條之1、納稅者權利保
18 護法第7條規定，稅捐稽徵機關仍得依與實質經濟利益相
19 當之法律形式，認屬遺產範圍予以調整。查系爭3張境外
20 保單均為投資型保單，保險給付分別為184,433,500元
21 （美金6,100,000元×匯率30.235元）、34,321,670元（美
22 金1,135,163.57元×匯率30.235元）、30,154,219元（美
23 金997,328.23元×匯率30.235元），計高達248,909,389
24 元，此為上訴人不爭之事實，並有保單在卷可稽（見原審
25 卷一第131頁至第167頁）。且原判決已說明，被繼承人購
26 買保險時雖尚未罹癌，但於103年12月經診斷罹癌後，104
27 年3月9日設立GA公司，並於104年4月30日、5月12日變更
28 系爭3張境外保單受益人為GA公司，104年8月接受換肝手
29 術，於手術前預立遺囑作財產分配，其分配之財產即包括
30 系爭3張境外保單。且依上訴人、訴外人即被繼承人之配
31 偶黃詹庭育、被繼承人之兄長黃建立之談話紀錄可知，本

01 件係依會計師之建議，在境外（安圭拉）設立GA公司，目
02 的為使之成為被繼承人死後境外保單之受益人，國稅局查
03 不到。而GA公司股東為上訴人、被繼承人之配偶黃詹庭育
04 各持有65%、35%股份，原審斟酌全辯論意旨及調查證據
05 之結果，據此認定被上訴人主張被繼承人為規避遺產稅，
06 設立紙上公司GA，將未經金管會許可在台銷售之系爭3張
07 境外保單，藉外觀形式指定受益人為GA公司，實質上使繼
08 承人獲得相當於遺產之保險金，屬租稅規避而予以調整，
09 並無不合，原判決並已詳述其理由，本院經核並無違誤。
10 又，遺產及贈與稅法第4條第1項規定，本法稱財產，指動
11 產、不動產及其他一切有財產價值之權利。是遺產及贈與
12 稅法規定應計入應稅遺產總額之遺產概念，本與民商法體
13 系所稱遺產概念未必相同。況上訴人所爭執之民法第1148
14 條之1第1項規定：「繼承人在繼承開始前2年內，從被繼
15 承人受有財產之贈與者，該財產視為其所得遺產。」該條
16 視為所得遺產之規定，係為避免被繼承人於生前將遺產贈
17 與繼承人，以減少繼承開始時之繼承人所得遺產，致影響
18 被繼承人之債權人權益而設，並不影響繼承人間應繼財產
19 之計算（立法理由參照）。是上訴人執前述民法第1148條
20 之1第1項規定，主張更改保險受益人距離繼承開始超過2
21 年，而就原審認定租稅規避之相關取捨證據、認定事實之
22 職權行使，指摘其為不當及判決不備理由云云，要不足
23 採。

24 （四）綜上所述，原判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回
25 上訴人在第一審之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，
26 指摘原判決違背法令，求予廢棄，難認有理由，應予駁
27 回。

28 六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1
29 項、第98條第1項前段，判決如主文。

30 中 華 民 國 112 年 2 月 8 日

31 最高行政法院第二庭

01 審判長法官 帥 嘉 寶
02 法官 鄭 小 康
03 法官 林 玫 君
04 法官 李 玉 卿
05 法官 洪 慕 芳

06 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
07 中 華 民 國 112 年 2 月 8 日
08 書記官 張 玉 純

臺中高等行政法院判決

) FKT64W1Z1X5L0;@109年度訴字第

110年10月20日辯論終結

原告 黃中諒

訴訟代理人 張捷安 律師

被告 財政部中區國稅局

代表人 吳蓮英

訴訟代理人 詹淳惠

王盈茹

上列當事人間遺產稅事件，原告不服財政部中華民國109年7月29日台財法字第10913923850號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

理 由

一、爭訟概要：原告之父黃建志於民國106年8月23日死亡，繼承人有黃詹庭育（被繼承人之配偶）、黃中涵、黃中甯、黃中慧及原告（被繼承人之子女），經被告所屬大屯稽徵所依繼承人申請核准展延遺產稅申報期限至107年5月23日，黃詹庭育依限於107年5月21日申報遺產總額新臺幣（下同）56,801,952元，遺產淨額14,181,952元（訴願決定書誤載為30,620,000元，原處分卷第31-34頁），應納稅額278,566元；經被告依申報及查得漏報被繼承人所遺存款及其他財產等，核定遺產總額60,098,429元，遺產淨額17,478,429元，應納稅額64,936元。嗣黃詹庭育於108年1月3日檢附Sinlin Investment Co.,Ltd股東協議書及境外保險公司通知文件，以被繼承

人死亡時遺有美金計價之境外公司投資額及7張境外保單，按被繼承人死亡時之匯率30.235元折算新臺幣，補申報境外公司投資額24,188,000元及7張境外保單金額284,574,033元；原告則於108年3月19日補申報被繼承人上開境外保單之保險理賠金112,109,795元。被告遂依據補申報資料，重行核定被繼承人遺產總額為368,860,462元，遺產淨額159,448,685元，應納稅額22,706,831元。原告就該7張境外保單中之3張保單：Conseco Life Insurance Company保單（財產種類編號AB-52，下稱Conseco保單）、FWD Life Insurance Company（Bermuda）Limited保單（財產種類編號AD-54，下稱FWD保單）、HSBC Life International Limited保單（財產種類編號AH-58，下稱HSBC保單），核定金額共計248,909,389元部分不服（下合稱系爭3張境外保單），申請復查未獲變更，提起訴願亦遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

（一）主張要旨：

- 1.系爭3張境外保單均指定Gold Aroma Ltd.（下稱GA公司）為受益人，GA公司由黃中諒、黃詹庭育分別持有65%、35%股份。而黃詹庭育於108年1月3日向大屯稽徵所補申報遺產資料，主張上開3張境外保單為被繼承人黃建志之遺產，係企圖藉由此方式，將屬於GA公司基於保險契約所得的保險金改變其屬性為遺產，並進一步主張就被繼承人所有遺產（包括上開3張境外保單之保險金）進行剩餘財產分配。
- 2.原處分及訴願決定以財政部95年6月28日台財稅字第09504540210號函、行政院金融監督管理委員會（下稱金管會）95年6月1日金管保三字第09502031820號函，認定被繼承

01 人生前投保未經金管會核准之外國保險公司之人壽保險，
02 並無我國保險法第112條規定之適用，從而亦無遺產及贈
03 與稅法第16條第9款規定之適用，該境外保單所給付之保
04 險金應納入被繼承人遺產等語，然上開金管會及財政部之
05 函釋將人民在生前基於財產規劃所投保之境外保單，遽以
06 認定排除在保險法第112條之外，顯然增加母法法律所無
07 之限制，此等限制又直接影響限制人民的權利自由，有違
08 租稅公平。又以本件為例，若認定境外保險公司向GA公司
09 給付之保險金為遺產，則全體繼承人依法將平均分擔上開
10 高額稅負，然全體繼承人中並非全部都是GA公司之股東，
11 如此一來，將形成上開保險金會由實質GA公司之股東（部
12 分繼承人）享有，而其餘非屬GA公司股東之繼承人，只能
13 無奈繳納高額稅金，如此豈有公平可言。此外，主管機關
14 所為之函釋並無對外效力，解釋性的行政規則僅是上級機
15 關對下級機關，或是長官對於屬官，依其權限或職權，為
16 規範內部秩序及運作，所為之一般、抽象之規定，並無直
17 接對外發生法規範效力。司法行政機關所發司法行政上之
18 命令，如涉及審判上之法律見解，亦僅供法官參考，法官
19 於審判案件時，不受其拘束。

20 3.被告主張「境外保險是無名契約，不能是臺灣地區認定的
21 保險契約」、「本件系爭保險契約，是要保人黃建志刻意
22 規避遺產稅捐」等語。然本件被繼承人於生前在國外所投
23 保之人壽保單，本質上當然是保險，被繼承人在投保後行
24 更改受益人，屬受保險契約之規範而合法有據。又本件被
25 繼承人購買保單之時間，分別為90年、98年、101年；被
26 繼承人於103年12月間被診斷有惡性腫瘤；於104年5月間
27 變更保單受益人；於104年7月20日接受肝臟移植手術；於

106年8月23日死亡，被繼承人在被診斷出有惡性腫瘤後，積極接受治療，也接受肝臟移植手術，被繼承人根本沒有預料到自己會在兩年多後死亡。從而被繼承人在接受肝臟移植手術前更改受益人之行為自是基於保險契約中之規範，受司法自治契約自由原則之保障。縱依照被告主張系爭3張境外保單在臺灣地區不能認為是「保險契約」，而是一份「利益第三人的無名契約」，並以被繼承人死亡為無償給付第三人即GA公司一筆金錢之停止條件，然而本件被繼承人是在死亡前超過2年以上之期間更改受益人，依據民法第1148之1條、遺產及贈與稅法第15條等規定，被繼承人死亡兩年前的贈與，並無需對該贈與課徵遺產稅，則更加可以證實被繼承人無庸為了規避遺產稅或贈與稅而進行受益人更改。

4.此外，在稅捐法定主義中，稅捐乃公法上法定之債，代表著對於影響稅捐債權債務關係的成立、變更與消滅之事項稅捐主體、稅捐客體、稅捐客體之歸屬、稅基、稅率，必須以國會通過之法律規定方屬合憲，屬絕對國會保留之層級。從而，基於租稅法定原則，縱然認為境外保單之法律性質與「利益第三人契約」相似，然「第三人利益契約」畢竟與民法第1148之1條所稱「贈與契約」在契約的構成要件上並不相同，目前的法令並沒有將「利益第三人契約」列為是遺產的稅捐客體，故被告根本不應該將系爭3張境外保單或任何「利益第三人契約」列為是稅捐客體，而課徵遺產稅。綜上，被繼承人於購買系爭3張境外保單時，並非是基於惡意規避遺產稅，被繼承人嗣後更改受益人之行為，也是基於保險契約中之規範，基於契約自由所為之變更。本件被告僅憑函釋內容即對境外保單全面否決，

01 將系爭3張境外保單中之保險金均視為是被繼承人遺產而
02 課徵遺產稅，顯然有違租稅法定原則。

03 (二)聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

04 三、被告答辯及聲明：

05 (一)答辯要旨：

06 1.財政部95年6月28日台財稅字第09504540210號函：「遺產
07 及贈與稅法第16條第9款規定者，以該人壽保險契約得適
08 用保險法第112條規定者為限。被繼承人生前投保未經金
09 管會核准之外國保險公司之人壽保險，依該委員會95年6
10 月1日金管保三字第09502031820號函，並無我國保險法第
11 112條規定之適用，從而，亦無遺產及贈與稅法第16條第9
12 款規定之適用。」其意旨揭示，未經金管會核准之境外保
13 單無不計入遺產總額規定之適用，為主管機關本於職權就
14 遺產及贈與稅法16條第9款立法意旨所為之函釋，乃闡釋
15 法規原意，並未抵觸稅法規定，其內容亦符合法律規定意
16 旨，遵守一般法律解釋方法，與租稅法定主義並無牴觸，
17 其統一認定標準，乃維繫稅制公平所必要，無違租稅公平
18 原則。而系爭3張境外保單因非屬金管會核准之外國保險
19 公司之人壽保險，自無保險法第112條規定之適用，從而
20 亦無遺產及贈與稅法第16條第9款規定之適用，故被告依
21 規定將系爭3張保單之保險給付，計入遺產總額課稅，並
22 無不合。

23 2.查被繼承人黃建志生前向未經金管員會許可依法在臺設立
24 登記之3家外國保險公司投保高額人身保險，其性質為投
25 資型保單，且未經金管會核准在臺銷售。嗣被繼承人於10
26 3年底得知其罹患肝癌末期，隨即於104年4、5月間將系爭
27 3張境外保單之受益人變更為GA公司，然GA公司係於104年

01 3月9日成立，股東成員為被繼承人胞兄黃建立、原告、黃
02 詹庭育，持股比例分別為15%、55%、30%，嗣同年7月28日
03 GA公司股東變更為被繼承人、原告、黃詹庭育，持股比例
04 分別為15%、55%、30%。另經黃建立、黃詹庭育及原告分
05 別於108年3月間至被告機關備詢，其等均表示系爭3張境
06 外保單受益人GA公司是被繼承人身體狀況不佳時，為規劃
07 身後事，於安圭拉設立之境外公司，目的係管理境外保單
08 理賠金，作為被繼承人將來死亡後多張境外保單的受益公
09 司，該公司僅為紙上公司，並無實質營運，僅作為購買保
10 單資金用途，係被繼承人為規避遺產稅而設立，且設立時
11 並無實際匯出投資款項，提不出匯款證明等語。

12 3.依臺灣臺中地方法院公證處106年度中院公字第006000155
13 號公證書本及其檢附被繼承人104年8月10日所立「黃建志
14 平安書（遺囑）」內容記載，黃建志因104年8月11日要進
15 行換肝手術，先預備遺囑，其財產分配歸類為不動產、現
16 金、投資、國外部分、香港EFG私人銀行等5項，其中國外
17 部分為GA公司所開設的華美銀行金額係美金2萬元加保險
18 金，執行者：詹庭育、原告、黃明宗（被繼承人父親），
19 保險金有3家保險公司，益證系爭3張境外保單外觀形式雖
20 指定GA公司為受益人，然GA公司係被繼承人為規避遺產稅
21 而設立之紙上公司，系爭3張境外保單實質並未指定受益
22 人，且被繼承人真實意志係將系爭3張境外保單之保險金
23 價值列屬其遺產，並指定由黃詹庭育、原告及黃明宗為執
24 行人，實質上使其繼承人於其死亡時獲得相當於遺產之保
25 險金給付，被告依實質課稅原則將系爭3張境外保單之保
26 險給付金額合計248,909,389元，計入遺產總額課稅，並
27 無不合，應予維持。

01 (二)聲明：駁回原告之訴。

02 四、本件爭議關鍵即為：系爭3張境外保單有無遺產及贈與稅法
03 第16條第9款及保險法第112條規定之適用？保險給付金額應
04 否計入被繼承人黃建志之遺產總額？

05 五、本院的判斷：

06 (一)前揭爭訟概要之事實，分別有遺產稅申報書、遺產稅核准延
07 期申報簡覆證明、補申報資料、遺產稅核定通知書、復查決
08 定書、訴願決定書等附卷可稽（原處分卷第28頁至第39頁、
09 第93頁至第104頁、第174頁至第177頁、第197頁至第202頁
10 、第213頁至第219頁），此部分事實，堪以認定。又系爭3
11 張境外保單係以美金計價，被繼承人為要保人及被保險人，
12 均指定GA公司為受益人，保險給付金額按被繼承人死亡時之
13 匯率30.235元折算新臺幣後，分別為：Conseco保單184,433
14 ,500元（6,100,000美元×30.235元）、FWD保單34,321,670
15 元（1,135,163.57美元×30.235元）、HSBC保單30,154,219
16 元（997,328.23美元×30.235元），合計248,909,389元，
17 有108年1月3日遺產稅申報書及境外保險公司通知文件可稽
18 ，原告對系爭3張境外保單之保險給付金額亦無爭執，僅爭
19 執系爭3張境外保單之保險給付金額應否計入被繼承人黃建
20 志之遺產總額計算，先予敘明。

21 (二)按行為時遺產及贈與稅法第1條第1項規定：「凡經常居住中
22 華民國境內之中華民國國民死亡時遺有財產者，應就其在
23 中華民國境內境外全部遺產，依本法規定，課徵遺產稅。」第
24 10條第1項規定：「遺產及贈與財產價值之計算，以被繼承
25 人死亡時或贈與人贈與時之時價為準；……。」第14條規定
26 ：「遺產總額應包括被繼承人死亡時依第1條規定之全部財
27 產，及依第10條規定計算之價值。但第16條規定不計入遺產

總額之財產，不包括在內。」第16條第9款規定：「左列各款不計入遺產總額：……九、約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。」又依保險法第1條第1項規定：「本法所稱保險，謂當事人約定，一方交付保險費於他方，他方對於因不可預料，或不可抗力之事故所致之損害，負擔賠償財物之行為。」保險法第112條規定：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」

(三)系爭3張境外保單購買之時間分別為90年、98年及101年，黃建志行為時點自90年間至101年間，而保險法關於未經主管機關核准之境外壽險保單之規定，於時間跨距11年間，雖有文字修正，然其主旨並無差別，均認未經主管機關許可銷售之境外壽險保單，並非保險法第112條所稱之保險給付。例如90年之保險法第137條第1項規定：「保險業非申請主管機關核准，並依法為營業登記，繳存保證金，領得營業執照後，不得開始營業。」；98年及101年之保險法第137條第1項規定：「保險業非經主管機關許可，並依法為設立登記，繳存保證金，領得營業執照後，不得開始營業。」系爭3張境外保單既然未經金管會核准，依上述行為時保險法第137條第1項之規定，自非保險法第112條所稱之保險給付。從而被告認定系爭3張境外保單之給付不得免除列入遺產計算，自屬有據。

(四)次按稅捐稽徵法第12條之1第1項、第2項、第3項規定：「（第1項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。（第2項）稅捐稽徵機關認定課徵租

01 稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質
02 經濟利益之歸屬與享有為依據。（第3項）納稅義務人基於
03 獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避
04 租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，
05 為租稅規避。」另所謂「稅捐規避」是指利用私法自治、契
06 約自由原則對私法上法形式選擇之可能性，選擇從私經濟活
07 動交易之正常觀點來看，欠缺合理之理由，為通常所不使用
08 之異常法形式，並於結果上實現所意圖之經濟目的或經濟成
09 果，且因不具備對應於通常使用之法形式之課稅要件，因此
10 得以達到減輕或排除稅捐負擔之行為。因此稅捐規避與合法
11 之節稅不同，節稅乃是依據稅捐法規所預定之方式，意圖減
12 少稅捐負擔之行為，反之，「稅捐規避」則是利用稅捐法規
13 所未預定之異常或不相當之法形式，意圖減少稅捐負擔之行
14 為。故而，納稅義務人不選擇稅法上所考量認為通常之法形
15 式（交易形式），卻選擇與此不同之迂迴行為或多階段行為
16 或其他異常的法形式，以達成與選擇通常法形式之情形基本
17 上相同之經濟效果，而同時卻能減輕或排除與通常法形式相
18 連結之稅捐負擔者，即應認屬「租稅規避」，而非合法之節
19 稅。又租稅規避行為因有違課稅公平原則，故於效果上，參
20 諸司法院釋字第420號解釋意旨，應本於實質課稅原則，就
21 其事實上予以規避，然卻與其經濟實質相當之法形式作為課
22 稅之基礎；且租稅規避之效果既是以與其經濟實質相當之法
23 形式作為課稅之基礎，故就此法形式，依稅法規範之納稅主
24 體、稅目、稅率等為租稅之核課，即難謂有違租稅法定原則
25 （最高行政法院101年度判字第87號判決意旨參照）。

26 (五)關於濫用法律形式而為「租稅規避」，各國法學理論多認納
27 稅義務人必須舉證證明其所選擇之法律形式具有「非稅捐目

的（non-tax purpose）」者，始得認其係屬「節稅」而非「租稅規避」阻卻違法。上述3張境外保單雖非保險法第112條之保險給付，但其受益人則為GA公司，則GA公司所受領之保險給付，究係被繼承人黃建志生前所為財務規劃，採取利益第三人契約或其他無名契約之形式，產生合法正當之財務轉移結果？抑或被繼承人黃建志係採濫用法律形式之迂迴手段，構成「租稅規避」？即值深入分析。誠如原告主張，本件系爭3張境外保單購買之時間分別為90年、98年及101年，而被繼承人黃建志檢查得知罹患肝癌為103年12月間，購買境外保單在先，罹患惡性腫瘤在後，自難據此論斷被繼承人黃建志購買系爭3張境外保單之目的即為規避遺產稅。然而原告於罹癌後即於104年5月間變更系爭3張境外保單之受益人，「指定GA公司為受益人」，而GA公司係由部分繼承人黃中諒（即原告）、黃詹庭育分別持有65%、35%股份。顯見被繼承人黃建志確知罹癌後，即以指定受益人予境外GA公司之方式，將其海外資產轉由GA公司取得，並由部分繼承人黃中諒、黃詹庭育依據持股而間接取得系爭3張境外保單之全額保險給付248,909,389元。上述指定受益人之變更，原告始終並未舉證其變更指定受益人之決定，有何「租稅規避」以外之合法目的？自難為其有利之認定。

(六) 本件被繼承人黃建志係於90年2月12日投保Conseco保單、98年1月21日投保HSBC保單、101年9月4日投保FWD保單（本院卷第135頁、第147頁、第157頁），此3家外國保險公司均非屬經金管會許可並依法設立之機構，系爭3張境外保單亦未經金管會核准在臺銷售。嗣於103年12月19日經中國醫藥大學附設醫院新診斷患有肝硬化併惡性肝腫瘤併門脈栓塞（本院卷第265頁），被繼承人黃建志即於104年3月9日設立GA公

01 司，再分別於104年4月30日變更Conseco保單受益人為GA公
02 司、104年5月12日變更HSBC保單、FWD保單受益人為GA公
03 司（本院卷第195頁、第1209頁、第1220頁）。GA公司之成立
04 乃係於被繼承人黃建志確認自身罹癌後所成立，目的係作為
05 系爭3張境外保單變更受益人之主體，除此之外，原告並未
06 舉證GA公司另曾參與其他商業活動之具體事證，顯見其成立
07 目的僅係為被繼承人黃建志規避遺產稅，自屬濫用法律形式
08 所為之租稅規避。縱使GA公司為合法成立之境外公司，然其
09 濫用法律形式既如前述，自難僅因GA公司合法設立，即為原
10 告有利之認定。

11 (七)另依原告於108年3月26日在被告談話紀錄自承：黃建志自知
12 身體狀況不好，成立境外公司主要目的係管理境外保單理賠
13 金，該公司僅為紙上公司，並無實質營運，僅做為購買保單
14 資金用途，本人取得GA公司股權，並無實際匯出投資款項等
15 語（原處分卷第58頁）。被繼承人之配偶黃詹庭育於108年3
16 月20日談話紀錄中亦稱：黃建志因身體狀況不佳，多次進出
17 醫院開刀，自知來日不多，為規劃身後事，在會計師事務所
18 建議規劃下，設立了GA公司作為黃建志將來死亡後多張境外
19 保單的受益公司，會計師表示這樣做可以不用繳遺產稅，且
20 境外公司設立在安圭拉，國稅局會查不到，黃建志生前購買
21 了多張境外保單，我們的錢匯出去國外銀行，只有用來繳保
22 費，並沒有真的去投資GA公司的股權等語（原處分卷第48頁
23 ）。被繼承人黃建志之兄黃建立於談話紀錄中亦稱：本人確
24 有取得GA公司股權，多年來並無自國內外任何帳戶實際匯出
25 投資款項，黃建志因身體狀況不佳，為規劃身後事，設立GA
26 公司作為將來死亡後多張境外保單的受益公司，我在黃建志
27 要求下做人頭股東而已等語（原處分卷第63頁至第64頁）。

01 益證被繼承人黃建志於103年12月19日經診斷患有惡性肝腫
02 瘤後，不及3個月即於104年3月9日設立GA境外公司，公司原
03 始股東原告、黃詹庭育、黃建立等均未實質出資，亦未實際
04 營業，被繼承人黃建志嗣後將系爭3張境外保單之受益人變
05 更為GA公司，目的乃係生前預作遺產分配，減少現有財產，
06 待其身故後，系爭3張境外保單即轉換成為對受益人GA公司
07 之保險給付，藉此達到規避財產併入遺產總額核算遺產稅之
08 目的。尤其GA公司之股東成員即為黃中諒（原告）、黃詹庭
09 育分別持有65%、35%股份，使得部分繼承人經由境外保單受
10 益人之指定，獲得與遺產相同之實質經濟利益，其動機顯係
11 為規避遺產稅，並無其他「非稅捐目的」，自屬「租稅規避
12 」。

13 (八)再依臺灣臺中地方法院公證處106年度中院公字第006000155
14 號公證書本及其檢附被繼承人104年8月10日所立「黃建志平
15 安書（遺囑）」內容記載，被繼承人黃建志因104年8月11日
16 進行換肝手術，先預備遺囑，其財產分配歸類為不動產、現
17 金、投資、國外部分、香港EFG私人銀行等5項，其中國外部
18 分為GA公司所開設的華美銀行金額係美金2萬元加保險金，
19 執行者：詹庭育、原告、黃明宗（被繼承人父親），保險金
20 有3家保險公司，益證系爭3張境外保單之外觀形式雖然指定
21 GA公司為受益人，然GA公司係被繼承人為規避遺產稅而設立
22 之境外公司，且被繼承人黃建志之真意亦將系爭3張境外保
23 單之保險金列為遺產，實質上由部分繼承人（原告及黃詹庭
24 育）於其死亡時獲得相當於遺產之保險金給付。從而，基於
25 實質課稅及公平課稅原則，系爭3張境外保單並無遺產及贈
26 與稅法第16條第9款前段及保險法第112條規定之適用。是被
27 告將系爭3張境外保單之保險給付金額248,909,389元併入被

繼承人黃建志之遺產總額，課徵遺產稅，並無違誤，復查決定及訴願決定均予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，並無理由，應予駁回。

(九)本件系爭3張境外保單之受益人為GA公司，於私法關係之爭議判斷時，法院依據私法契約之法律關係認定系爭3張境外保單之受益人為GA公司，自屬當然；至於私法契約之認定結果與稅法「實質課稅原則」必須參酌經濟實質效果之本質不同，自難逕以兩者認定不同，指為原處分違法不當之瑕疵。

(十)末查，系爭3張境外保單之受益人為GA公司，而GA公司僅由部分繼承人持股（即原告與黃詹庭育分別持有65%、35%股份）。按繼承人全體如無其他特定事由，自應依其應繼分共同繼承。然則本件涉及被繼承人黃建志另以遺囑（平安書）進行遺產分配，自不得以GA公司僅由部分繼承人持股，即認系爭3張境外保單非屬遺產。換言之，系爭3張境外保單之受益人為GA公司，並由原告及黃詹庭育依其持股比例獲有保險給付之利益，如有侵害其他繼承人特留分之情事，自應由其他繼承人另循法律途徑救濟，附此敘明。

六、本件判決基礎已經明確，兩造其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述的必要，併此敘明。

七、結論：原告之訴為無理由，應予駁回。

中華民國 110 年 11 月 3 日

臺中高等行政法院第三庭

審判長法官 陳 文 燦

法官 楊 嶠 琇

法官 張 升 星

以上正本證明與原本無異。

01 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，其未表
02 明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書（均須
03 按他造人數附繕本）；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴
04 者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。未表
05 明上訴理由者，逕以裁定駁回。

06 上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書，但符合下列情
07 形者，得例外不委任律師為訴訟代理人：

08 09 10 11	得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
12 13 14 15 16 17 18 19 20	(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
21 22 23 24 25 26 27	(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

	、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 110 年 11 月 3 日
書 記 官 凌 雲 霄

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第202號

上 訴 人 陳悅玲

訴訟代理人 林志聰 會計師

被 上 訴 人 財政部高雄國稅局

代 表 人 蔡碧珍

上列當事人間綜合所得稅事件，上訴人對於中華民國107年3月20日高雄高等行政法院106年度訴字第374號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回高雄高等行政法院。

理 由

一、緣被上訴人查得上訴人於民國103年度綜合所得稅結算申報，漏報其所規避取自東南水泥股份有限公司（下稱東南水泥公司）營利所得新臺幣（下同）6,688,881元（含可扣抵稅額1,157,680元），乃於報經財政部核准後，將之調整為上訴人之營利所得，歸課核定其當年度綜合所得總額15,016,238元，應納稅額3,940,980元，並以105年10月24日105年度財高國稅法違字第03105100261號裁處書，按所漏稅額1,224,061元處0.4倍之罰鍰計489,624元。上訴人就罰鍰處分不服，循序提起行政訴訟。經原審法院判決駁回後，乃提起本件上訴。

二、上訴人於原審起訴意旨略謂：移轉股票的主要目的係上訴人具有美國護照，屬在臺居住之中美雙重國籍人士，符合美國預計於103年度實施肥咖條款（FATCA）之適用對象，故上訴人將持有之東南水泥公司股票於102年度全數透過股票公開市場公開成交方式轉讓，以減輕遭美國給予雙重課稅之不利。上訴人持有東南水泥公司股票已逾數十年，該持有期間並無任何出售且依法納稅。再者，於轉讓年度或轉讓後之各年度，東南水泥公司之經營層面暨股利政策亦無發生劇烈波動，且股利發放亦為正常，故上訴人移轉該股票亦純係為避免中美雙重國籍課稅，絕無刻意安排，以減少稅負之動機。

又上訴人移轉股票係透過股票公開市場並按公開成交價格予以轉讓，絕無故意操縱股票成交價格以達到個人任何避稅之企圖，亦無未支付交割款而僅形式上移轉之虛偽安排，此有股票成交查詢資料可稽。況且，股票受讓人即恆祥源投資有限公司（下稱恆祥源公司）係上訴人於101年度以自有資金2,000,000元設立，為1人股東所組織、登記、成立之投資公司，並無安排任何虛偽人頭為股東並藉以分散所得；則上訴人於102年間自集中市場購買東南水泥公司股票，股票價款含手續費總計款項為371,172,539元，因設立資本額不足支付股票交割款，是以上訴人將所持有東南水泥公司股票出售，並將所得股票交割款項借予恆祥源公司，作為恆祥源公司交割股票款之資金來源，其實質關係誠如同公司股本，由上訴人唯一墊借予恆祥源公司。再者，恆祥源公司尚非屬第三地之假外資或假法人，而係本國之法人且亦皆設帳載詳實之交易，確無任何虛偽或取巧之意圖。而且是項買賣交易資訊均已於恆祥源公司102年及以後年度之營利事業所得稅申報完整揭露，並無隱匿重要事項或為虛偽不實陳述或提供不正確資料等情事。上開交易經被上訴人依所得稅法第66條之8規定，於報經財政部105年2月24日台財稅字第10416022120號函核准後，按實質課稅原則，改歸課上訴人系爭營利所得並裁處罰鍰，顯有違誤。因被上訴人既以實質課稅原則課徵上訴人系爭營利所得並裁處罰鍰，則按納稅者權利保護法（下稱納保法）第7條第3項及第10項前段規定及相關立法說明，可知應予適用納保法，而無從自實質課稅原則中再行衍生區分租稅規避或租稅逃漏。是按納保法第7條第7項規定，本件應改按應補徵稅額課徵15%滯納金並加徵利息，並免除罰鍰之處分。此外，綜合所得稅申報書並無要求納稅義務人揭露未獲配之股利，亦無格式要求揭露當年度之股票買賣交易，此參被上訴人所設計之綜合所得稅申報媒體即可確認，在此前提下，上訴人自無可能會就未取得股利部分及未被要求揭露之訊息自行申報或揭露。因此，系爭股權買賣交易，恆

01 祥源公司已於102年度營利事業所得稅申報完整揭露，後續
02 年度亦以依法令規定申報營利事業所得稅，可明確得知系爭
03 股票之交易移轉日期、股數、金額、交易對象，及當年度恆
04 祥源公司獲配取得之東南水泥公司現金股利金額，並無隱匿
05 或虛偽表示之情形。且上訴人於接獲被上訴人通知後，對於
06 被上訴人於審查階段所要求提示之各項表單文據以及資金狀
07 況等資料，上訴人均已如實提供，並無納保法第7條第8項但
08 書所稱隱匿重要事項或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，
09 致使被上訴人短漏核定等語，為此請求判決撤銷訴願決定及
10 原處分（復查決定含原核定處分）。

11 三、被上訴人於原審答辯意旨略謂： 上訴人於101年12月20日
12 設立恆祥源公司（資本額為2,000,000元，上訴人為負責人
13 ，持股100%），旋即於102年4月3日至5月20日間，分22個
14 交易日，每1交易日以1、3、5或7筆等不同交易筆數方式，
15 計61筆交易行為，透過上訴人之第一商業銀行灣內分行（下
16 稱第一銀行灣內分行）帳戶及第一金證券股份有限公司灣內
17 分公司之公開市場交易，出售東南水泥公司股票計27,656,0
18 05股，並將每次交易所得款項於同日匯入恆祥源公司之第一
19 銀行灣內分行之證券交割帳戶計369,740,000元；而恆祥源
20 公司則利用上訴人上開匯入資金，亦於上開同22个交易日，
21 買進相同股數（即27,656,005股）之東南水泥公司股票，並
22 分61筆交割付款計371,172,539元（交易價金371,014,871元
23 +手續費157,668元）。恆祥源公司之股東僅上訴人1人，而
24 公司資本額僅2,000,000元，與上開鉅額交割款371,172,539
25 元顯不成比例，該公司應無資力可支付購買東南水泥公司股票
26 鉅額交割款。上訴人（即賣方）與恆祥源公司（即買方）
27 透過於同一日、同股數以相同價格下達交易買、賣單指令，
28 以達成同日、同股數成交之目的，又因恆祥源公司資本額僅
29 有2,000,000元，為避免違約交割而造成無法順利完成交易
30 ，上訴人則利用股票交割與匯付股款之時間差異，於交易日
31 出售前揭東南水泥公司股票並逐筆取得股款後，旋即將所得

款項匯入恆祥源公司證券交割銀行帳戶，以利履行買方（即恆祥源公司）匯付股款。又恆祥源公司102年12月31日資產負債表載列負債總額404,946,000元 股東往來404,920,000元（即恆祥源公司向上訴人借款）+應付費用26,000元V、權益總額（即淨值總額）4,519,837元（股本2,000,000元+保留盈餘2,519,837元）及資產總額409,465,837元（長期投資407,064,550元+銀行存款2,395,756元+現金5,334元+其他預付款197元），顯見恆祥源公司並無足夠自有資金購買東南水泥公司之鉅額股權，本件形式上雖有給付價金，但資金來源均來自上訴人，自難謂有實際支付購買股權之價款及交易之真實性。則上訴人藉成立恆祥源公司，取巧安排東南水泥公司股權移轉，將原應課徵個人40%稅率綜合所得稅之營利所得，轉換為營利事業不計入所得額課稅之投資收益，但仍可掌握該等股權支配，形成與未出售股權之效果相當，違背所得稅法立法目的，不當規避減少個人綜合所得稅之營利所得，即應依所得稅法第66條之8規定予以調整。又上訴人未依規定申報系爭營利所得6,688,881元（含可扣抵稅額1,157,680元），致漏報個人綜合所得稅額1,224,061元，核其違章行為，顯係明知並有意使其發生，或已預見其發生且縱容其發生，核屬故意為之，自應論罰。惟上訴人於裁罰處分核定前繳清本稅，經審酌上訴人之應受責難程度及所生影響等情事，就裁罰倍數（0.5倍）酌減20%，按所漏稅額1,224,061元處0.4倍 $0.5 \text{倍} \times (1 - 20\%)$ V之罰鍰489,624元，並無不合。上訴人不論直接持有東南水泥公司股票或透過不當安排將東南水泥公司股票移轉至恆祥源公司名下，而間接持有東南水泥公司股票，均屬FATCA條款應申報範圍。是以，上訴人所訴，核難採據。再者，目前各國政府越來越積極展開租稅合作來對抗跨國避稅，而上訴人竟以為避免所持有之東南水泥公司股票併入美國肥咖條款之適用範圍為理由，實達減少本國租稅負擔目的，而將東南水泥公司股票轉讓予恆祥源公司，其所為之行為實已違背前揭國際租稅之

合作目的，核無足採。 恆祥源公司之股東僅有上訴人1人，該公司除持有東南水泥公司股票外，並無投資其他公司或其他營業行為，全部收入來源僅有取自東南水泥公司所分配之股利，該公司顯未符合一般投資公司之經營常態，上訴人成立該公司之目的顯係用以承接其個人獲配東南水泥公司股利之導管。綜上，本件系爭東南水泥公司之持股雖有移轉之外觀形式，惟其經濟實質與未移轉無異，上訴人仍為系爭股票之實際持有者，是本件系爭股票交易之主要目的顯係為達成減少或免除上訴人之租稅負擔，而無其他合理商業目的，自難謂其交易係屬真實。按租稅規避行為，乃以規避者之私法交易行為，在法律外觀形式上係真實為前提，如規避者以虛偽之私法交易行為，達到減少或免除租稅負擔目的，則屬租稅逃漏行為，此有本院104年度判字第703號判決可資參照，故上訴人藉由虛偽之股權形式移轉，實質上將東南水泥公司原應分配予上訴人之現金股利，轉換成恆祥源公司當年度之投資收益，隱匿其實質上確有取得東南水泥公司股利之事實，致生短漏當年度綜合所得稅情事，即非租稅規避範疇，而應論以租稅逃漏。上訴人故意違反租稅法之立法意旨，透過出售股份之交易形式，將「可預期將來一定會發生」的「潛在性」應稅營利所得，轉換為免稅的「證券交易所得」及「公司之投資收益」，透過上開股權移轉，致使其原本應分配予個人股東歸課綜合所得稅之營利所得，轉換為證券交易所得及免稅之公司投資收益，無須繳納任何所得稅，其濫用法律上之形式或法律行為，蓄意製造外觀上或形式上存在之法律關係或法律狀態，使之不具備課稅構成要件，以減輕或免除其應納租稅之事實甚明，被上訴人依所得稅法第66條之8規定，按實質課稅原則，改歸課上訴人系爭營利所得，洵無違誤。雖上訴人於105年6月29日補繳稅款，並於同年6月30日補申報系爭營利所得及可扣抵稅額在案，惟係於調查基準日104年9月16日及財政部105年2月24日台財稅字第10416022120號函（核准按所得稅法第66條之8規定辦理）之後所

為，未符合稅捐稽徵法第48條之1自動補報繳免罰之規定。
又上訴人透過一連串的安排，並從事交易行為，即具有明知，並有意使其發生之故意，縱無故意，亦有過失，自應受罰。綜上，上訴人違反租稅法之立法意旨，濫用法律上之形成或法律行為，蓄意製造外觀上或形式上存在之法律關係或法律狀態，使之不具備課稅構成要件，以減輕上訴人應納之租稅（個人綜合所得稅之40%稅負減輕為投資公司未分配盈餘之10%稅捐），即藉由形式股權之移轉，實質上將東南水泥公司原應分配予上訴人之現金股利，轉換成恆祥源公司當年度之投資收益，規避個人綜合所得稅稅負，業符合所得稅法第66條之8所明定之逃漏稅捐樣態，為求租稅公平，除應以其實質上已具備課稅構成要件之經濟事實加以課稅外，其因而致生漏稅之結果，已構成所得稅法第110條第1項之處罰要件。又所得稅法第66條之8規定，自86年12月30日增訂迄上訴人101年間設立恆祥源公司已逾14年，上訴人當可預見並加以理解，仍為上揭漏稅行為，顯係明知並有意使其發生，或已預見其發生且縱容其發生，核屬故意為之，自應論罰。則經審酌其違章情節及考量行政罰法第18條裁處罰鍰規定之事由，乃就法定最高額2倍以下範圍內，按所漏稅額裁處0.4倍罰鍰，實已審酌上訴人之違章情節及犯後態度等情，而予適切之裁罰。又上訴人因前揭虛偽之股權交易行為，而致生之綜合所得稅短漏稅額情事，縱係經評價為租稅規避行為，惟其於辦理103年度綜合所得稅結算申報時，隱匿系爭股票交易之移轉日期、股數、金額及交易對象，及當年度恆祥源公司獲配取得之東南水泥公司現金股利金額，致使被上訴人無法正確核課其當年度之綜合所得稅稅額，故本件係屬納保法第7條第8項但書所稱之短漏稅捐案件，而無同法條第7項規定不得另課予逃漏稅捐處罰之適用，併予敘明等語，為此請求判決駁回上訴人在原審之訴。

四、原判決駁回上訴人之訴，其理由略謂：上訴人股權移轉過程，對照財政部就所得稅法第66條之8虛偽交易規避稅負認

01 定之參考基準，上訴人藉成立恆祥源公司，取巧安排東南水
02 泥公司股權移轉，將原應課徵個人40%稅率綜合所得稅之「
03 營利所得」，轉換為營利事業不計入所得額課稅之「投資收
04 益」，但仍可掌握該等股權支配，形成與未出售股權之效果
05 相當，違背所得稅法立法目的，不當規避減少個人綜合所得
06 稅之營利所得，核屬應依行為時所得稅法第66條之8規定予
07 以調整。被上訴人就本件報經財政部於105年2月24日以台財
08 稅字第10416022120號函核准按所得稅法第66條之8規定辦理
09 ，被上訴人乃將東南水泥公司103年度分配予恆祥源公司之
10 股利6,688,881元（含可扣抵稅額1,157,680元），改歸課上
11 訴人之營利所得，併課上訴人103年度綜合所得稅，依法核
12 定補徵稅額外，並無不合。至上訴人以因其具雙重國籍身分
13 ，為避免美國內地稅務局（IRS）依「肥咖條款」（FATCA）
14 對其持有之上開股票課稅，而為上開股權移轉之安排，核其
15 目的亦係出於規避跨國間之稅負，動機已有可疑，遑論其所
16 為上開稅務安排，亦得規避本國所得稅稅基之「營利所得」
17 額之計算，故其上開股權之形式移轉，實係同時可規避二國
18 稅賦之「一石二鳥」租稅規劃，且不具實質經濟目的，其以
19 此陳明無規避稅之意圖，尚無足採，併予敘明。上訴人係
20 東南水泥公司股東，藉由成立恆祥源公司及利用資金之安排
21 操作，移轉東南水泥公司股權予恆祥源公司，將「直接持有
22 」轉換為「間接持有」東南水泥公司股份，其法律形式之安
23 排，客觀上可達成規避個人原應自東南水泥公司獲配之營利
24 所得及個人綜合所得稅負之效果，且上訴人於申報過程中，
25 就其藉股權移轉規劃行為，其個人「營利所得」將反於真實
26 ，影響綜合所得稅額之計算，其就涉及稅捐實體成立要件之
27 重要事實，未誠實申報，核屬納保法第7條第8項但書所規定
28 「納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳
29 述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐」，
30 且造成短漏稅額1,224,061元，亦合致於所得稅法第110條之
31 漏稅行為。再者，上訴人在進行股權移轉之稅務規劃，目的

在所得稅額減省之稅捐利益（個人綜合所得稅40%稅率減輕為投資公司未分配盈餘之10%稅捐），過程由其掌控安排（前述股權移轉之金流得證之），對其間之因果歷程知之甚詳。且所得稅法第66條之8規定，自86年12月30日增訂迄上訴人101年間設立恆祥源公司已逾14年，即公司股東藉股權形式移轉，因影響營利所得之計算，為重要課稅事實，應為一般民眾所知悉，上訴人於103年所得稅申報時，仍隱匿未為申報，顯係明知並有意使其發生，自有之主觀歸責事由存在。此外，上訴人前開漏稅行為，亦無其他阻卻違法、有責事由。從而，被上訴人原處分按上訴人所漏稅額1,224,061元處0.4倍之漏稅罰鍰計489,624元，依法核無違誤。上訴人漏報應納稅負之結果，符合所得稅法第71條、第110條第1項短漏報「應申報課稅之所得額」之要件，被上訴人依行政罰法第18條規定，審酌上訴人明知有所得卻漏未申報，且本件逃漏稅捐金額非低，將影響國家稅收及有違租稅公平，可受責難之程度較高，然考量上訴人已於裁罰處分前繳清稅款，參據稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表關於所得稅法第110條第1項規定，本於法定裁量權審酌結果，依漏報所得應受責難及所生影響，於裁罰倍數（0.5倍）酌減20%，裁處0.4倍罰鍰，業已考量上訴人違章情節，並於法定裁罰倍數（2倍以下）範圍內為適切裁罰，並無違誤，亦無裁量怠惰、裁量逾越或裁量濫用之違法等語。

五、上訴意旨略謂：上訴人對於本案涉有違反所得稅法第66條之8並無異議，惟本案係屬發生於納保法實施之前之未確定案件，於納保法實施後應有其適用，惟原判決未予詳酌，容有判決不適用法規或適用法規不當之違法。本案爭執重點在於上訴人認為並無納保法第7條第8項但書之情形，應適用納保法第7條第3項規定，而應按同法第10項規定免除超過第7項所定滯納金及利息之總額之裁罰處分，惟原判決以上訴人無須負擔之申報義務，認定上訴人有納保法第7條第8項但書「對重要事項隱匿」之情形，容有判決違反論理法則之違法。

01 按所得稅法第71條第1項規定意旨可知，所得稅納稅義務人
02 於結算申報書應填載之申報書內容，係指各項稅捐計算基礎
03 之事實，包括構成綜合所得稅總額之項目及數額之加項事實
04 、有關減免扣除之減項事實，及經量化計算後，其應納之結
05 算稅額。故納保法第7條第8項但書所指「於申報……時，對
06 重要事項隱匿或為虛偽不實陳述……」，應指對稅捐構成要
07 件之該當事實有隱匿、假裝、通謀意思表示或虛偽行為，進
08 而將基於此一隱匿或虛偽事實之量化計算結果填具於申報書
09 ，據以向稅捐機關申報。而上訴人於申報時，既非基於稅捐
10 計算基礎事實之隱匿或虛偽行為之量化計算結果，自難謂合
11 於納保法第7條第8項但書情形。被上訴人雖主張上訴人於辦
12 理綜合所得稅申報時，未揭露「於102年4至5月間陸續將其
13 名下之東南水泥公司股份計27,656,005股，出售予101年12
14 月20日甫成立之恆祥源公司，恆祥源公司之股東僅上訴人1
15 人，恆祥源公司以上訴人之大筆資金支付其購入東南水泥公
16 司股份之價款及103年度有獲配東南水泥公司鉅額股利」等
17 情，即屬隱匿重要事項之申報行為。然現行稅法並不課徵證
18 券交易所得稅，故上訴人於證券交易市場出售系爭股票，非
19 屬所得稅計算基礎之項目，自無列入申報之必要。再者，被
20 上訴人所指系爭股票買賣、資金借貸、恆祥源公司獲配股利
21 等情事，性質上均非屬所得稅法第71條第1項所指「構成綜
22 合所得總額……之項目及數額，以及有關減免、扣除之事實
23 」，並非申報綜合所得稅應填載於申報書之事項。況依上訴
24 人103年度綜合所得稅申報書之格式，其上亦無應填載被上
25 訴人所指上開各項情事之欄位及說明，上訴人自無可能就上
26 開事項自行申報或揭露，則上訴人未予自動揭露，即不應被
27 指為有隱匿行為。而系爭股票股息分配予股東恆祥源公司，
28 形式上係屬合法，在被上訴人未依法調整為上訴人股利所得
29 之前，即不能視為上訴人之股利所得，上訴人未予申報，自
30 不能以隱匿應申報之重要事項論定。再者，租稅規避行為係
31 合法規避構成要件之該當，本質上不可能存有隱匿、假裝、

通謀虛偽意思表示等之虛偽行為，被上訴人若認定上訴人有納保法第7條第8項但書之情形，自應對此事實真偽不明之不利利益負舉證責任，惟被上訴人並未對此提出舉證，原判決亦未審酌，容有判決不備理由之違法等語，為此請求廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分（復查決定含原核定處分），或發回原審法院更為審理。

六、本院查：

按行為時所得稅法第66條之8規定：「個人……如有藉股權之移轉或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算相關納稅義務人之應納稅額，得報經財政部核准，依查得資料，按實際應分配或應獲配之股利、盈餘或可扣抵稅額予以調整。」稅捐稽徵法第12條之1第3項規定：「納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。」所得稅法第71條第1項規定：「納稅義務人應……填具結算申報書，向該管稽徵機關，申報其上一年度內構成綜合所得總額或營利事業收入總額之項目及數額，以及有關減免、扣除之事實，並應依……計算其應納之結算稅額，於申報前自行繳納……」第110條第1項規定：「納稅義務人已依本法規定辦理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額2倍以下之罰鍰。」行政罰法第7條第1項規定：「違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。」納稅者權利保護法第7條規定：「……（第3項）納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。……（第6項）稅捐稽徵機關查明納稅者及交易之相對人或關係人有第三項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料

01 依各稅法規定予以調整。（第7項）第3項之滯納金，按應補
02 繳稅款百分之十五計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆
03 滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅
04 款，依各年度1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按
05 日加計利息，一併徵收。（第8項）第3項情形，主管機關不
06 得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重
07 要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐
08 稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。……（第10項）本法
09 施行前之租稅規避案件，依各稅法規定應裁罰而尚未裁罰者
10 ，適用第3項、第7項及第8項規定；已裁罰尚未確定者，其
11 處罰金額最高不得超過第7項所定滯納金及利息之總額。但
12 有第8項但書情形者，不適用之。」

13 原判決以前揭理由，認上訴人於原審之主張經核均非可採。
14 原處分（指罰鍰）及復查決定經核並無違誤，訴願決定予以
15 維持，亦無不合，上訴人起訴意旨求為均予撤銷，為無理由
16 ，應予駁回。固非無見。

17 惟依納保法第7條第3項後段、第8項及第10項規定，對於租
18 稅規避行為，稅捐稽徵機關雖根據與實質上經濟利益相當之
19 法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息，然除
20 非納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳
21 述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐，否
22 則不得另課予逃漏稅捐之處罰。且對於納保法施行前之租稅
23 規避案件，已裁罰而於納保法施行後尚未確定者，除能證明
24 納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述
25 或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者外，
26 其處罰金額最高不得超過同條第7項所定滯納金及利息之總
27 額。而所謂「隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料」，
28 依其前後文義，應係指納稅者於申報或調查時，對於稽徵機
29 關具體要求申報或說明的重要事項，隱藏匿報或積極地為虛
30 偽不實陳述或提供不正確資料而言，如係消極未申報其所規
31 避的稅捐者，應限於對其非常規交易過程各階段所生經濟效

01 果亦不予揭露或申報，致稽徵機關無從循線查獲其所意圖規
02 避之稅負之情形，始構成所謂「隱匿」。蓋所謂租稅規避，
03 既係指以合法但非常規的交易形式，規避租稅構成要件之該
04 當，以達成與交易常規相當之經濟效果，本就不會（亦不能
05 期待）申報其所規避的經濟效果（稅捐），如果納稅者就其
06 所採取的交易形式各階段，已經分別按規定揭露或申報，即
07 無礙於稽徵機關循線查獲其所意圖規避之稅負，如僅係因其
08 消極的不申報所規避的稅捐，即一律認定為「隱匿」而課予
09 逃漏稅捐之處罰，無異認為「租稅規避」即屬「逃漏稅捐違
10 法行為」，顯然違背納保法第7條立法理由所示「稅捐規避
11 雖非屬違法行為，而與違背稅法上誠實義務之逃漏稅違法行
12 為有間，但性質上屬於鑽法律漏洞之脫法行為」之意旨，並
13 使納保法第7條第8項所明示，對於租稅規避行為，除加徵滯
14 納金及利息外，「不得另課予逃漏稅捐之處罰」之規定，形
15 同具文。又租稅規避雖濫用法律形式，但其法律形式外觀與
16 當事人真意並無不符；苟涉及以通謀虛偽之法律形式而達到
17 減免租稅負擔目的者，即非租稅規避脫法行為範疇，而應論
18 以逃漏稅捐違法行為。另依行政訴訟法第133條前段規定，
19 行政法院於撤銷訴訟，固應依職權調查證據，以期發現真實
20 ，當事人並無主觀舉證責任，然職權調查證據有其限度，仍
21 不免有要件事實不明之情形，而必須決定其不利益結果責任
22 之歸屬，故當事人仍有客觀之舉證責任，民事訴訟法第277
23 條前段規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有
24 舉證之責任。」於上述範圍內，仍為撤銷訴訟所準用（行政
25 訴訟法第136條參照）。租稅裁罰爭訟案件，係國家行使處
26 罰高權的結果，與課稅平等或稽徵便利無關，而與刑事罰類
27 似，當事人並無協力義務或責任以自證己罪或自證無違規事
28 實，且有「無罪推定」及「疑則無罪」原則之適用，故稽徵
29 機關就處罰之要件事實（就本件而言即係於申報或調查時，
30 對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使
31 稅捐稽徵機關短漏核定稅捐），應負擔證明責任（納稅者權

利保護法第11條第2項參照），且其證明程度至少應達到「幾近於真實的蓋然性」（蓋然率99.8%以上，或稱真實的確信蓋然性），始可謂其已盡舉證之責，否則法院仍應認定該處罰要件事實為不存在，而將其不利益歸於稽徵機關。

1) 本件上訴人於101年12月20日設立恆祥源公司（資本額為2,000,000元，上訴人為負責人，持股100%）。嗣於102年4月3日至5月20日間，分22個交易日，每一交易日以1筆、3筆、5筆或7筆等不同交易筆數方式，計61筆交易行為，透過上訴人第一銀行灣內分行帳戶及第一金證券股份有限公司灣內分公司之公開市場交易，出售東南水泥公司股票計27,656,005股，並將每次交易日所得款項於同日匯入恆祥源公司之第一銀行灣內分行之證券交割帳戶計369,740,000元；而恆祥公司則利用上訴人上開匯入資金，亦於上開同22個交易日，買進相同股數（即27,656,005股）之東南水泥公司股票，並分61筆交割付款計371,172,539元（交易價金371,014,871元+手續費157,668元）。因恆祥源公司資本額僅為2,000,000元，與上開鉅額交割款371,172,539元顯不成比例，本無資力可支付購買東南水泥公司股票鉅額交割款，上訴人（即賣方）與恆祥源公司（即買方）乃透過於同一日、同股數以相同價格下達交易買、賣單指令，以達成同日、同股數成交之目的；又為避免恆祥源公司違約交割而造成無法順利完成交易，上訴人利用股票交割與匯付股款之時間差異，於交易日出售前揭東南水泥公司股票並逐筆取得股款後，旋即將所得款項匯入恆祥源公司證券交割銀行帳戶，以利履行買方（即恆祥源公司）匯付股款；再者，恆祥源公司102年12月31日資產負債表載列負債總額404,946,000元【股東往來404,920,000元（即恆祥源公司向上訴人借款）+應付費用26,000元】、權益總額（即淨值總額）4,519,837元【股本2,000,000元+保留盈餘2,519,837元】及資產總額409,465,837元【長期投資407,064,550元+銀行存款2,395,756元+現金5,334元+其他預付款197元】等情，為原判決確認之事實。據此，原判

決一方面認定「恆祥源公司並無足夠自有資金購買東南水泥公司之鉅額股權，本件形式上雖有給付價金，但資金來源均來自原告，自難謂有實際支付購買股權之價款及交易之真實性」，似認為系爭股票之買賣乃虛偽交易，其目的在逃漏稅捐；然另一方面卻認定「原告藉成立恆祥源公司，取巧安排東南水泥公司股權移轉，將原應課徵個人40%稅率綜合所得稅之『營利所得』，轉換為營利事業不計入所得額課稅之『投資收益』，但仍可掌握該等股權支配，形成與未出售股權之效果相當，違背所得稅法立法目的，不當規避減少個人綜合所得稅之營利所得」、「原告係東南水泥公司股東，藉由成立恆祥源公司及利用資金之安排操作，移轉東南水泥公司股權予恆祥源公司，將『直接持有』轉換為『間接持有』東南水泥公司股份，其法律形式之安排，客觀上可達成規避個人原應自東南水泥公司獲配之營利所得及個人綜合所得稅負之效果」，似又認為系爭股權移轉僅係租稅規避行為。揆諸「逃漏稅捐違法行為」與「租稅規避脫法行為」乃不同性質，原判決認定事實已有矛盾。

ē 如上述，系爭股票交易既係透過證券集中市場，並按公開成交價格予以轉讓，即不可能為通謀虛偽意思表示，本難否定其股權移轉及支付交割款之真實性。且恆祥源公司與上訴人買賣系爭股票之行為既係分別經由證券公開集中市場為之，此有股票成交查詢資料附卷可稽，即已揭露本件非常規交易過程該階段交易之結果。又上訴人借貸資金給恆祥源公司用以買進系爭股票，以及持有系爭股票等情，稽諸恆祥源公司資產負債表，既記載於其他流動負債之業主（股東）往來項目及資產欄之長期投資項目，亦難謂其對本件非常規交易過程各階段所生經濟效果有不予揭露之情形。復查上訴人於原審主張系爭股權買賣交易，恆祥源公司已於102年度營利事業所得稅申報完整揭露，後續年度亦已依法令規定申報營利事業所得稅，可明確得知系爭股票之交易移轉日期、股數、金額及交易對象，以及當年度恆祥源公司獲配取得之東南

01 水泥公司現金股利金額，並無隱匿或虛偽表示之情形；且上
02 訴人於接獲被上訴人通知後，對於被上訴人於審查階段所要
03 求提示之各項表單文據以及資金狀況等資料，上訴人均已如
04 實提供，而被上訴人所設計之綜合所得稅申報書並無要求納
05 稅義務人揭露未獲配之股利，亦無格式要求揭露當年度之股
06 票買賣交易等語。揆諸前開規定及說明，以上事證攸關上訴
07 人就其所採取交易形式各階段產生的經濟效果，是否已經分
08 別按規定申報或揭露，並無隱匿情事，僅係消極未申報其所
09 規避的稅捐，亦無於本件綜合所得稅申報或調查時，有何對
10 於稽徵機關具體要求申報或說明的重要事項，隱藏匿報或積
11 極地為虛偽不實陳述或提供不正確資料之情事？又本件罰鍰
12 爭議既屬納保法106年12月28日施行以前已裁罰，迄今尚未
13 確定之租稅規避案件，如果認上訴人上開藉股權移轉以減少
14 個人綜合所得稅負擔之租稅規避行為，並無納保法第7條第8
15 項但書情形，自應適用納保法第7條第10項規定，裁罰金額
16 最高不得超過納保法第7條第7項所定滯納金及利息之總額。
17 原審本應加以調查釐清，詎原判決就此有利於上訴人之事證
18 恕置不論，徒以上訴人於申報過程中，就其藉股權移轉規劃
19 行為，其個人「營利所得」將反於真實，影響綜合所得稅額
20 之計算，其就涉及稅捐實體成立要件之重要事實，未誠實申
21 報，核屬納保法第7條第8項但書所規定「納稅者於申報或調
22 查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料
23 ，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐」，且造成短漏稅額1,22
24 4,061元，亦合致於所得稅法第110條之漏稅行為；再者，上
25 訴人在進行股權移轉之稅務規劃，目的在所得稅額減省之稅
26 捐利益（個人綜合所得稅百分之40稅率減輕為投資公司未分
27 配盈餘之百分之10稅捐），過程由其掌控安排（前述股權移
28 轉之金流得證之），對其間之因果歷程知之甚詳；且所得稅
29 法第66條之8規定，自86年12月30日增訂迄上訴人101年間設
30 立恆祥源公司已逾14年，即公司股東股藉股權形式移轉，因
31 影響營利所得之計算，為重要課稅事實，應為一般民眾所知

01 悉，上訴人於103年所得稅申報時，仍隱匿未為申報，顯係
02 明知並有意使其發生，自有之主觀歸責事由存在等語為由，
03 論斷原處分按上訴人所漏稅額1,224,061元處0.4倍之漏稅罰
04 鍰計489,624元，核無違誤云云，似不否認上訴人所進行系
05 爭股權移轉之稅務規劃，係屬租稅規避行為，卻僅因其於本
06 件綜合所得稅結算申報時，消極未申報系爭規避的稅捐，即
07 認定其有「隱匿」行為，揆諸前開規定及說明，於法容有不
08 合。

09 綜上所述，原判決既有前述適用法規不當、理由不備及理由
10 矛盾之情形，且影響裁判之結果，上訴人聲明將之廢棄，即
11 為有理由，爰將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。

12 據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項、第
13 260條第1項，判決如主文。

14 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

15 最高行政法院第四庭

16 審判長法官 鄭 小 康

17 法官 劉 介 中

18 法官 帥 嘉 寶

19 法官 林 樹 埔

20 法官 林 文 舟

21 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

22 中 華 民 國 108 年 4 月 25 日

23 書記官 徐 子 嵐

裁判字號：高雄高等行政法院 106 年訴字第 374 號判決

裁判日期：民國 107 年 03 月 20 日

裁判案由：綜合所得稅

高雄高等行政法院判決

106年度訴字第374號
民國107年3月7日辯論終結

原 告 陳悅玲
訴訟代理人 林志聰 會計師
被 告 財政部高雄國稅局
代 表 人 洪吉山
訴訟代理人 柳秀英
 施佩君

上列當事人間綜合所得稅事件，原告不服財政部中華民國106年7月5日台財法字第10613926060號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、程序事項：

按「（第1項）訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告同意或行政法院認為適當者，不在此限。（第2項）被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。……」行政訴訟法第111條第1項、第2項分別定有明文。查原告起訴時，訴之聲明為：「確認被告對原告因103年度綜合所得稅罰鍰事件請求撤銷裁罰處分或縱有罰鍰亦冀請按所漏稅額之最後淨額為罰鍰裁罰之標的，另為計罰罰鍰。」嗣於民國106年12月19日本院準備程序經法官闡明後變更其訴之聲明為：「訴願決定及原處分（復查決定含原核定處分）均撤銷。」被告對於原告所為上開變更並無異議而為本案言詞辯論，揆諸首揭規定，應予准許，合先敘明。

二、事實概要：

緣被告查得原告103年度綜合所得稅結算申報，漏報取自東南水泥股份有限公司(下稱東南水泥公司)營利所得新臺幣(下同)6,688,881元(含可扣抵稅額1,157,680元)，歸課核定其當年度綜合所得總額15,016,238元，應納稅額3,940,980元，並按所漏稅額1,224,061元處0.4倍之罰鍰計489,624元。原告就罰鍰處分不服，申請復查，未獲變更，提起訴願，遭決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

三、本件原告主張：

(一)原告於102年度減少東南水泥公司股票27,656,005股，動機如下：

1.移轉股票非為規避納稅義務：

(1)移轉股票的主要目的：原告具有美國護照，屬在臺居住之中美雙重國籍人士，符合美國預計於103年度實施肥咖條款(FATCA)之適用對象，故原告將持有之東南水泥公司股票於102年度全數透過股票公開市場公開成交方式轉讓，以減輕遭美國給予雙重課稅之不利。

(2)長期持有，無蓄意短線操作以達到減少稅負之動機：原告持有東南水泥公司股票已逾數十年，該持有期間並無任何出售且依法納稅。再者，於轉讓年度或轉讓後之各年度，東南水泥公司之經營層面暨股利政策亦無發生劇烈波動，且股利發放亦為正常，故原告移轉該股票亦純係為避免中美雙重國籍課稅，絕無刻意安排，以減少稅負之動機。

2.股權交易並無虛偽安排：原告移轉股票係透過股票公開市場並按公開成交价格予以轉讓，絕無故意操縱股票成交价格以達到個人任何避稅之企圖，亦無未支付交割款而僅形式上移轉之虛偽安排，此有股票成交查詢資料可稽。況且，股票受讓人即恆祥源投資有限公司（下稱恆祥源公司）係原告於101年度以自有資金2,000,000元設立，為1人股東所組織、登記、成立之投資公司，並無安排任何虛偽人頭為股東並籍以分散所得；則原告於102年間自集中市場購買東南水泥股票，股票價款含手續費總計款項為371,172,539元，因設立資本額不足支付股票交割款，是以原告將所持有東南水泥公司股票出售，並將所得股票交割款項借予恆祥源公司，作為恆祥源公司交割股票款之資金來源，其實質關係誠如同公司股本，由原告唯一墊借予恆祥源公司。再者，恆祥源公司尚非屬第三地之假外資或假法人，而係本國之法人且亦皆設帳載詳實之交易，確無任何處偽或取巧之意圖。而且是項買賣交易資訊均已於恆祥源公司102年及以後年度之營利事業所得稅申報完整揭露，並無隱匿重要事項或為虛偽不實陳述或提供不正確資料等情事。

(二)原告遭課以罰鍰，顯有違誤：

1.上開交易經被告依所得稅法第66條之8規定，於報經財政部105年2月24日台財稅字第10416022120號函核准後，按實質課稅原則，改歸課原告系爭營利所得並裁處罰鍰，顯有違誤。因被告既以實質課稅原則課徵原告系爭營利所得並裁處罰鍰，則按納稅者權利保護法（下稱納保法）第7條第3項及第10項前段規定及相關立法說明，可知應予適用納保法，而無從自實質課稅原則中再行衍生區分租稅規避或租稅逃漏。是按納保法第7條第7項規定，本件應改按

應補徵稅額課徵百分之15滯納金並加徵利息，並免除罰鍰之處分。

- 2.此外，綜合所得稅申報書並無要求納稅義務人揭露未獲配之股利，亦無格式要求揭露當年度之股票買賣交易，此參被告所設計之綜合所得稅申報媒體即可確認，在此前提下，原告自無可能會就未取得股利部分以及未被要求揭露之訊息自行申報或揭露。因此，系爭股權買賣交易，恆祥源公司已於102年度營利事業所得稅申報完整揭露，後續年度亦以依法令規定申報營利事業所得稅，可明確得知系爭股票之交易移轉日期、股數、金額及交易對象，以及當年度恆祥源公司獲配取得之東南水泥公司現金股利金額，並無隱匿或虛偽表示之情形。且原告於接獲被告通知後，對於被告於審查階段所要求提示之各項表單文據以及資金狀況等資料，原告均已如實提供，並無納保法第7條第8項但書所稱隱匿重要事項或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使被告短漏核定等情。並聲明求為撤銷訴願決定及原處分（復查決定含原核定處分）

四、被告則以：

- (一)原告利用資金之安排操作，移轉鉅額股權予恆祥源公司，不當規避其個人綜合所得稅之情形如下，原告稱無藉股權移轉安排以規避稅負一節，核無足採：

- 1.原告於101年12月20日設立恆祥源公司(資本額為2,000,000元，原告為負責人，持股100%)，旋即於102年4月3日至5月20日間，分22個交易日，每1交易日以1筆、3筆、5筆或7筆等不同交易筆數方式，計61筆交易行為，透過原告之第一商業銀行灣內分行（下稱第一銀行灣內分行）帳戶及第一金證券股份有限公司灣內分公司之公開市場交易，出售東南水泥公司股票計27,656,005股，並將每次交易所得款項於同日匯入恆祥源公司之第一銀行灣內分行之證券交割帳戶計369,740,000元；而恆祥源公司則利用原告上開匯入資金，亦於上開同22個交易日，買進相同股數(即27,656,005股)之東南水泥公司股票，並分61筆交割付款計371,172,539元(交易價金371,014,871元+手續費157,668元)，此有臺灣集中保管結算所股份有限公司客戶存券異動明細表、原告及恆祥源公司第一銀行灣內分行之證券戶存款明細等資料附卷可稽。
- 2.恆祥源公司之股東僅原告1人，而公司資本額僅2,000,000元，與上開鉅額交割款371,172,539元顯不成比例，該公司應無資力可支付購買東南水泥公司股票鉅額交割款。原告(即賣方)與恆祥源公司(即買方)透過於同一日、同股數以相同價格下達交易買、賣單指令，以達成同日、同股數成交之目的，又因恆祥源公司資本額僅有2,000,000元，為避免違約交割而造成無法順利完成交易，原告則利用股票交割與匯付股款之時間差異，於交易日出售前揭東南水

泥公司股票並逐筆取得股款後，旋即將所得款項匯入恆祥源公司證券交割銀行帳戶，以利履行買方(即恆祥源公司)匯付股款。

- 3.又恆祥源公司102年12月31日資產負債表載列負債總額404,946,000元【股東往來404,920,000元(即恆祥源公司向原告借款)+應付費用26,000元】、權益總額(即淨值總額)4,519,837元【股本2,000,000元+保留盈餘2,519,837元】及資產總額409,465,837元【長期投資407,064,550元+銀行存款2,395,756元+現金5,334元+其他預付款197元】，顯見恆祥源公司並無足夠自有資金購買東南水泥公司之鉅額股權，本件形式上雖有給付價金，但資金來源均來自原告，自難謂有實際支付購買股權之價款及交易之真實性。
 - 4.則原告藉成立恆祥源公司，取巧安排東南水泥公司股權移轉，將原應課徵個人40% 稅率綜合所得稅之營利所得，轉換為營利事業不計入所得額課稅之投資收益，但仍可掌握該等股權支配，形成與未出售股權之效果相當，違背所得稅法立法目的，不當規避減少個人綜合所得稅之營利所得，即應依所得稅法第66條之8規定予以調整。又原告未依規定申報系爭營利所得6,688,881元(含可扣抵稅額1,157,680元)，致漏報個人綜合所得稅額1,224,061元，核其違章行為，顯係明知並有意使其發生，或已預見其發生且縱容其發生，核屬故意为之，自應論罰。惟查，原告於裁罰處分核定前繳清本稅，經審酌原告之應受責難程度及所生影響等情事，就裁罰倍數(0.5倍)酌減20%，按所漏稅額1,224,061元處0.4倍【 $0.5 \times (1 - 20\%)$ 】之罰鍰489,624元，並無不合。
- (二)至於美國政府為增加稅源，且為避免美國公民和永久居民（綠卡持有者）利用外國金融機構、外國基金及外國公司，掩飾其美國身分規避稅款，乃於99年間立法通過「美國海外帳戶稅收遵從法」（Foreign Account Tax Compliance Act，下稱FATCA）條款，俗稱「肥咖條款」，該法案業於000年0月0日生效，並於103年7月1日正式實施。而該法案規定外國金融機構應與美國內地稅務局(IRS)簽署FFI協訂，履行辨識客戶身分、提報美國客戶帳戶等資料，對於不遵守FATCA之外國銀行，將就其在美國之收入直接扣繳30%重稅。而個人向美國申報之特定資產包括：1.美國以外之金融機構存款、保管帳戶。2.非美國發行之股票、有價證券，不論是否已上市。3.以投資目的持有之金融工具或契約，而該商品之發行人或交易對手不是美國機構或美國人。4.持有任何非美國企業之所有權。準此可知，原告不論直接持有東南水泥公司股票或透過不當安排將東南水泥公司股票移轉至恆祥源公司名下，而間接持有東南水泥公司股票，均屬FATCA條款應申報範圍。是以，原告所訴，核難採據。再者，目前各國政府越來越積極展開租稅合作來對抗跨國避稅，而原告竟以為避免

所持有之東南水泥公司股票併入美國肥咖條款之適用範圍為理由，實達減少本國租稅負擔目的，而將東南水泥公司股票轉讓予恆祥源公司，其所為之行為實已違背前揭國際租稅之合作目的，核無足採。

(三)此外，恆祥源公司資本額僅為2,000,000元，根本無資力可購買東南水泥公司股票371,172,539元，原告明知恆祥源公司無自有資金支付價款，仍進行股份之買賣及移轉，但為避免違約交割而造成無法順利完成交易，原告係利用股票交割與匯付股款之時間差異，於交易日出售系爭股票並逐筆取得股款後，旋即將所得款項匯入恆祥源公司證券交割銀行帳戶，以利恆祥源公司匯付股款，是本件系爭股票之交易，形式上雖有給付價金，實質上原告並未因移轉系爭股票而取得任何款項，自難謂恆祥源公司有實際支付買賣價款之真實性，此觀諸恆祥源公司103年12月31日資產負債表帳列之股東往來尚有397,810,000元（原處分卷第73頁）即可得知。次查，恆祥源公司之股東僅有原告1人，該公司除持有東南水泥公司股票外，並無投資其他公司或其他營業行為，全部收入來源僅有取自東南水泥公司所分配之股利，該公司顯未符合一般投資公司之經營常態，原告成立該公司之目的顯係用以承接其個人獲配東南水泥公司股利之導管。綜上，本件系爭東南水泥公司之持股雖有移轉之外觀形式，惟其經濟實質與未移轉無異，原告仍為系爭股票之實際持有者，是本件系爭股票交易之主要目的顯係為達成減少或免除原告之租稅負擔，而無其他合理商業目的，自難謂其交易係屬真實。按租稅規避行為，乃以規避者之私法交易行為，在法律外觀形式上係真實為前提，如規避者以虛偽之私法交易行為，達到減少或免除租稅負擔目的，則屬租稅逃漏行為，此有最高行政法院104年度判字第703號判決可資參照，故本件原告藉由虛偽之股權形式移轉，實質上將東南水泥公司原應分配予原告之現金股利，轉換成恆祥源公司當年度之投資收益，隱匿其實質上確有取得東南水泥公司股利之事實，致生短漏當年度綜合所得稅情事，即非租稅規避範疇，而應論以租稅逃漏。

(四)再者，原告故意違反租稅法之立法意旨，透過出售股份之交易形式，將「可預期將來一定會發生」的「潛在性」應稅營利所得，轉換為免稅的「證券交易所得」及「公司之投資收益」，透過上開股權移轉，致使其原本應分配予個人股東歸課綜合所得稅之營利所得，轉換為證券交易所得及免稅之公司投資收益，無須繳納任何所得稅，其濫用法律上之形式或法律行為，蓄意製造外觀上或形式上存在之法律關係或法律狀態，使之不具備課稅構成要件，以減輕或免除其應納租稅之事實甚明，被告依所得稅法第66條之8規定，按實質課稅原則，改歸課原告系爭營利所得，洵無違誤。雖然，原告於105年6月29日補繳稅款，並於同年6月30日補申報系爭營利所得及可扣抵稅額在案，惟係於調查基準日104年9月16日及

財政部105年2月24日台財稅字第10416022120號函（核准按所得稅法第66條之8規定辦理）之後所為，未符合稅捐稽徵法第48條之1自動補報繳免罰之規定。又原告透過一連串的安排，並從事交易行為，即具有明知，並有意使其發生之故意，縱無故意，亦有過失，自應受罰。

(五)綜上所述，本件原告違反租稅法之立法意旨，濫用法律上之形成或法律行為，蓄意製造外觀上或形式上存在之法律關係或法律狀態，使之不具備課稅構成要件，以減輕原告應納之租稅（個人綜合所得稅之40%稅負減輕為投資公司未分配盈餘之10%稅捐），即藉由形式股權之移轉，實質上將東南水泥公司原應分配予原告之現金股利，轉換成恆祥源公司當年度之投資收益，規避個人綜合所得稅稅負，業符合所得稅法第66條之8所明定之逃漏稅捐樣態，為求租稅公平，除應以其實質上已具備課稅構成要件之經濟事實加以課稅外，其因而致生漏稅之結果，已構成所得稅法第110條第1項之處罰要件。又所得稅法第66條之8規定，自86年12月30日增訂迄原告101年間設立恆祥源公司已逾14年，原告當可預見並加以理解，仍為上揭漏稅行為，顯係明知並有意使其發生，或已預見其發生且縱容其發生，核屬故意為之，自應論罰。則經審酌其違章情節及考量行政罰法第18條裁處罰鍰規定之事由，乃就法定最高額2倍以下範圍內，按所漏稅額裁處0.4倍罰鍰，實已審酌原告之違章情節及犯後態度等情，而予適切之裁罰。又本件原告因前揭虛偽之股權交易行為，而致生之綜合所得稅短漏稅額情事，縱係經評價為租稅規避行為，惟其於辦理103年度綜合所得稅結算申報時，隱匿系爭股票交易之移轉日期、股數、金額及交易對象，以及當年度恆祥源公司獲配取得之東南水泥公司現金股利金額，致使被告無法正確核課其當年度之綜合所得稅稅額，故本件係屬納保法第7條第8項但書所稱之短漏稅捐案件，而無同法條第7項規定不得另課予逃漏稅捐處罰之適用，併予敘明等語，資為抗辯。並聲明求為判決駁回原告之訴。

五、本件如事實概要欄所載之事實，有原告103年度綜合所得稅申報書、被告103年度綜合所得稅核定通知書、復查決定書及訴願決定書等影本附卷可稽，且經兩造各自陳明在卷，洵堪認定。則本件兩造之爭議厥為：被告依所得稅法第66條之8規定，核定東南水泥公司103年度應分配予原告營利所得，歸課原告103年度綜合所得總額，並按所漏稅額依稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表（下稱裁罰倍數參考表）處以0.4倍之罰鍰，是否適法？茲分述如下：

(一)本件應適用之法規及令釋：

- 1.按適用法令之原則為實體從舊，程序從新，是包括租稅主體、租稅客體、稅率等課稅構成要件，均應適用行為時法律（令），本件被告藉以否認原告租稅規避之所得稅法第66條之8規定，雖經總統於107年2月7日以總統華總一義字

第10700015201號令刪除，於本件原告行為時仍屬有效之法律，自應予適用。

2.次按「凡有中華民國來源所得之個人，應就其中華民國來源之所得，依本法規定，課徵綜合所得稅。」「個人之綜合所得稅，就個人綜合所得總額，減除免稅額及扣除額後之綜合所得淨額計徵之。」「個人之綜合所得總額，以其全年下列各類所得合併計算之：第1類：營利所得：公司股東所獲分配之股利總額……皆屬之。」「個人或營利事業與國內外其他個人或營利事業、教育、文化、公益、慈善機關或團體相互間，如有藉股權之移轉或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避或減少納稅義務者，稽徵機關為正確計算相關納稅義務人之應納稅額，得報經財政部核准，依查得資料，按實際應分配或應獲配之股利、盈餘或可扣抵稅額予以調整。」為行為時所得稅法第2條第1項、第13條、第14條第1項第1類及第66條之8所明定。而行為時所得稅法第66條之8規定之立法理由，以：「由於不同身分納稅義務人間，有關稅額扣抵與退還之規定各不相同，為防杜納稅義務人藉投資所得適用稅率高低之不同，不當規避或減少納稅義務，減損政府稅收，並破壞兩稅合一制度，爰參酌紐西蘭及新加坡立法例，規定稽徵機關得按納稅義務實際應獲配之股利、盈餘或可扣抵稅額，分別予以調整。」足認本條規定在於防杜納稅者，藉股權之形式交易，將營利所得移轉，逃避綜合所得稅，故以經濟觀察為準據，認此等行為與公司股東所獲分配之股利總額而屬營利所得，足表彰相當之納稅能力，而明定稽徵機關報經財政部核准，依查得資料，按實際應分配或應獲配之股利、盈餘或可扣抵稅額予以調整，是本條性質上乃係租稅規避之個別防杜條款，用以避免濫用私法所賦予契約自由原則，實質上達到規避租稅之行為。

3.末按，財政部98年7月7日台財稅字第09800297860號函以：「二、所得稅法第66條之8規定所稱藉股權之移轉或其他虛偽之安排，不當為他人或自己規避或減少納稅義務之範圍如下：(一)個人或營利事業透過虛偽交易安排，以下列方式移轉股權與租稅負擔：1.將高稅率股東應獲配之股利、盈餘及可扣抵稅額，移轉為低稅率股東所有者……。三、稽徵機關對於前項情節之審認，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據，進行查核：(一)個人或營利事業之股權交易，其價款之收付有下列情形之一，認定違反交易常規，屬虛偽之交易行為：1.全部或大部分價款並未收付者。2.安排不實之收付款資金流程，實質上並未收付價款者。3.股權買受人僅帳列股東往來(或應付帳款)未實際收付價款，俟股權移轉後始以獲配現金股利、出售股權取得價款或辦理現金增資款項等清償應付股款者。4.由交易關係人提供資金，俟股權交易完成

後，資金復回流至提供者帳戶者。5.其他僅具支付形式，實質上未收付價款者。(二)相關股權交易構成要件特性：1.移轉標的股權公司特質：(1)經營有成擁有鉅額盈餘、出售房地等獲取鉅額利益或獲配被投資公司鉅額股利者……。2.股權買賣雙方關係：股權出賣人對承買公司有控制能力或在人事、財務、業務經營、管理政策上具有重大影響力者。3.股權承買公司背景：(1)屬經營不善有鉅額虧損或於系爭股權交易前新設者。(2)負責人或股東為股權交易當事人或當事人之近親者。(3)資本額小，與購入股權成交價額顯不相當者。(4)幾無其他營業活動者。4.股權移轉時機：標的股權公司獲取鉅額處分利益後或分配盈餘前之交易行為。5.規避稅負模式：(1)藉由承買公司負擔未分配盈餘加徵10%營利事業所得稅，規避個人綜合所得稅累進稅率。(2)藉承買公司高價購買復低價出售股權，製造證券交易損失……。(4)藉股權移轉造成交叉持股，嗣安排高價向個人購買股權，俟獲配股利再將資金回流個人，規避綜合所得稅。(5)藉多家投資公司交叉持股，每年由不同投資公司獲配股利之形式，將盈餘保留於投資公司，規避綜合所得稅及未分配盈餘加徵10%營利事業所得稅……。(8)其他藉虛偽之形式法律關係之安排，規避稅負者。6.稅負影響：股權移轉後所涉相關年度整體稅負較未轉讓前有減少情形。」該函釋之內容僅闡明重申所得稅法第66條之8規定之立法原意，歸納類此案件之行為態樣，並未增加人民法律所無之稅賦或義務，參諸司法院釋字第287號解釋意旨，應自該法規生效之日起有其適用（最高行政法院101年度判字第4號判決意旨）。

(二)原告行為該當行為時所得稅法第66條之8要件之認定：

- 1.原告為東南水泥公司之股東，於102年4至5月間陸續將其名下之東南水泥公司股份計27,656,005股，出售予101年12月20日甫成立之恆祥源公司，原告藉形式上股權之移轉，不當規避其個人綜合所得稅，具體安排規劃行為如下：
 - (1)原告於101年12月20日設立恆祥源公司(資本額為2,000,000元，原告為負責人，持股100%)。嗣於102年4月3日至5月20日間，分22個交易日，每一交易日以1筆、3筆、5筆或7筆等不同交易筆數方式，計61筆交易行為，透過原告第一銀行灣內分行帳戶及第一金證券灣內分公司之公開市場交易，出售東南水泥公司股票計27,656,005股，並將每次交易日所得款項於同日匯入恆祥源公司之第一銀行灣內分行之證券交割帳戶計369,740,000元；而恆祥公司則利用原告上開匯入資金，亦於上開同22個交易日，買進相同股數(即27,656,005股)之東南水泥公司股票，並分61筆交割付款計371,172,539元(交易價金371,014,871元+手續費157,668元)，此有臺灣集中保管結算所股份有限公司客戶存券異動明細表及原告暨恆

祥源公司第一銀行灣內分行之證券戶存款明細附原處分卷可稽。

(2)因恆祥源公司資本額僅為2,000,000元，與上開鉅額交割款371,172,539元顯不成比例，本無資力可支付購買東南水泥公司股票鉅額交割款。原告(即賣方)與恆祥源公司(即買方)乃透過於同一日、同股數以相同價格下達交易買、賣單指令，以達成同日、同股數成交之目的。又為避免恆祥公司源違約交割而造成無法順利完成交易，原告利用股票交割與匯付股款之時間差異，於交易日出售前揭東南水泥公司股票並逐筆取得股款後，旋即將所得款項匯入恆祥源公司證券交割銀行帳戶，以利履行買方(即恆祥源公司)匯付股款。

(3)再者，恆祥源公司102年12月31日資產負債表載列負債總額404,946,000元【股東往來404,920,000元(即恆祥源公司向原告借款)+應付費用26,000元】、權益總額(即淨值總額)4,519,837元【股本2,000,000元+保留盈餘2,519,837元】及資產總額409,465,837元【長期投資407,064,550元+銀行存款2,395,756元+現金5,334元+其他預付款197元】，顯見恆祥源公司並無足夠自有資金購買東南水泥公司之鉅額股權，本件形式上雖有給付價金，但資金來源均來自原告，自難謂有實際支付購買股權之價款及交易之真實性。

2.綜合上開原告股權移轉過程，對照財政部上開就所得稅法第66條之8虛偽交易規避稅負認定之參考基準，原告藉成立恆祥源公司，取巧安排東南水泥公司股權移轉，將原應課徵個人40% 稅率綜合所得稅之「營利所得」，轉換為營利事業不計入所得額課稅之「投資收益」，但仍可掌握該等股權支配，形成與未出售股權之效果相當，違背所得稅法立法目的，不當規避減少個人綜合所得稅之營利所得，核屬應依行為時所得稅法第66條之8規定予以調整。被告就本件報經財政部於105年2月24日以台財稅字第10416022120號函核准按所得稅法第66條之8規定辦理，被告乃將東南水泥公司103年度分配予恆祥源公司之股利6,688,881元(含可扣抵稅額1,157,680元)，改歸課原告之營利所得，併課原告103年度綜合所得稅，依法核定補徵稅額外，揆諸首揭規定，並無不合。

3.至原告以因其具雙重國籍身分，為避免美國內地稅務局(IRS)依「肥咖條款」(FATCA)對其持有之上開股票課稅，而為上開股權移轉之安排，核其目的亦係出於規避跨國間之稅負，動機已有可疑，遑論其所為上開稅務安排，亦得規避本國所得稅稅基之「營利所得」額之計算，故其上開股權之形式移轉，實係同時可規避二國稅賦之「一石二鳥」租稅規劃，且不具實質經濟目的，其以此陳明無規避稅之意圖，尚無足採，併予敘明。

(三)原告行為構成所得稅法第110條漏稅違章之認定：

- 1.按租稅規避與逃漏租稅有其本質之不同。前者，納保法第7條第3項以：「納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果。」為其定義。而逃漏租稅，則係違法隱匿已發生之租稅構成要件該當事實，達成短少租稅義務之目的。故而，同法第7條第8項明定，有租稅規避情形者，主管機關不得另課予逃漏租稅之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定租稅者，不在此限。其立法意旨明揭：「納稅者不選擇稅法上通常之法律形式，卻以取巧方式、迂迴行為或非常規之法律形式，以避免稅捐構成要件的滿足，而減輕其稅負。此情形即屬故意濫用法律形式，規避稅捐之行為，並無值得保護之信賴利益，仍應本於實質課稅原則加以調整補稅。……稅捐規避雖非屬違法行為，而與違背稅法上誠實義務之逃漏稅違法行為有間，但性質上屬於鑽法律漏洞之脫法行為。於法理上亦無容許納稅者得主張其脫法行為，以獲取實質經濟利益之可能，主管機關應依處罰法定原則進行調整補稅。……惟若納稅者於稅捐申報或於主管機關進行課稅調查時，隱匿事實、為虛偽不實陳述或提供不正確資料等行為，致使主管機關陷於錯誤之虞，因而短漏核定稅捐者，應予裁處漏稅之罰鍰。」準此，租稅規避雖濫用法律形式，但其法律形式外觀與當事人真意並無不符，依納保法第7條第8項本文，固不得處罰；然如就課稅之重要事實，違反誠實揭露義務，亦即於所得稅申報時有隱匿事實、為虛偽不實陳述或提供不正確資料之行為，致使主管機關陷於錯誤之虞，已非租稅規避範疇，而應論以租稅逃漏，並依個別稅目之漏稅罰則處理。而本件係屬所得稅類型，其漏稅罰則之規範依據為所得稅法第110條第1項：「納稅義務人已依本法規定辦理結算、決算或清算申報，而對依本法規定應申報課稅之所得額有漏報或短報情事者，處以所漏稅額2倍以下之罰鍰。」先予敘明。
- 2.查原告係東南水泥公司股東，藉由成立恆祥源公司及利用資金之安排操作，移轉東南水泥公司股權予恆祥源公司，將「直接持有」轉換為「間接持有」東南水泥公司股份，其法律形式之安排，客觀上可達成規避個人原應自東南水泥公司獲配之營利所得及個人綜合所得稅負之效果，已如前述，且原告於申報過程中，就其藉股權移轉規劃行為，其個人「營利所得」將反於真實，影響綜合所得稅額之計算，其就涉及稅捐實體成立要件之重要事實，未誠實申報，核屬納保法第7條第8項但書所規定「納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐」，且造成短漏說額

1,224,061元，亦合致於所得稅法第110條之漏稅行為。

- 3.再者，原告在進行股權移轉之稅務規劃，目的在所得稅額減省之稅捐利益（個人綜合所得稅百分之40稅率減輕為投資公司未分配盈餘之百分之10稅捐），過程由其掌控安排（前述股權移轉之金流得證之），對其間之因果歷程知之甚詳。且所得稅法第66條之8規定，自86年12月30日增訂迄原告101年間設立恆祥源公司已逾14年，即公司股東股藉股權形式移轉，因影響營利所得之計算，為重要課稅事實，應為一般民眾所知悉，原告於103年所得稅申報時，仍隱匿未為申報，顯係明知並有意使其發生，自有之主觀歸責事由存在。
- 4.此外，原告前開漏稅行為，亦無其他阻卻違法、有責事由。從而，被告原處分按原告所漏稅額1,224,061元處0.4倍之漏稅罰鍰計489,624元，依法核無違誤。故原告主張原告故有所得稅法第66條之8之租稅規避行為，但依納保法第7條第8項不應處罰，即無可採。

(四)被告就漏稅罰之裁處，係屬合義務之裁量：

- 1.按「所得稅法（綜合所得稅）第110條第1項……一、短漏報所得屬裁罰處分核定前已填報扣免繳憑單及股利憑單之所得，且無第6點【按即夫妻所得分開申報逃漏所得稅、虛報免稅額或扣除額、以他人名義分散所得】情形者。處所漏稅額0.2倍之罰鍰。……三、短漏報屬前2點以外之所得，且無第6點情形者。處所漏稅額0.5倍之罰鍰。……」有裁罰倍數參考表可參。
- 2.查原告漏報應納稅負之結果，符合所得稅法第71條、第110條第1項短漏報「應申報課稅之所得額」之要件，已如前述，被告依行政罰法第18條之規定，審酌原告明知有所得卻漏未申報，且本件逃漏稅捐金額非低，將影響國家稅收及有違租稅公平，可受責難之程度較高，然考量原告已於裁罰處分前繳清稅款，參據裁罰倍數參考表關於所得稅法第110條第1項之規定，本於法定裁量權審酌結果，依漏報所得應受責難及所生影響，於裁罰倍數（0.5倍）酌減百分之20，裁處0.4倍罰鍰，業已考量原告違章情節，並於法定裁罰倍數（2倍以下）範圍內為適切裁罰，揆諸首揭規定並無違誤，亦無裁量怠惰、裁量逾越或裁量濫用之違法。

六、綜上所述，原告之主張經核均非可採。原處分及復查決定經核並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告起訴意旨求為均予撤銷，為無理由，應予駁回。又本件事證已臻明確，兩造其餘主張核與判決結果不生影響，爰不一一論駁，併此說明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文

中 華 民 國 107 年 3 月 20 日

高雄高等行政法院第一庭

審判長法官 邱 政 強

法官 吳 永 宋

法官 黃 堯 讚

以上正本係照原本作成。

- 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造人數附繕本）。未表明上訴理由者，逕以裁定駁回。
- 二、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段）
- 三、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
（二）非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 107 年 3 月 20 日
書記官 江 如 青

司法院裁判書系統

列印時間：114.11.16 22:18

裁判字號：最高行政法院 106 年度判字第 49 號判決

裁判日期：民國 106 年 01 月 25 日

裁判案由：贈與稅

最 高 行 政 法 院 判 決	1
106年度判字第49號	2
上 訴 人 黃偉祥	3
訴訟代理人 蔡朝安 律師	4
李益甄 律師	5
李威忠 律師	6
被 上 訴 人 財政部臺北國稅局	7
代 表 人 許慈美	8
上列當事人間贈與稅事件，上訴人對於中華民國105年4月14日臺北高等行政法院104年度訴字第2012號判決，提起上訴，本院判決如下：	9 10 11
主 文	12
上訴駁回。	13
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。	14
理 由	15
一、被上訴人代表人原為何瑞芳，業於民國106年1月6日變更為許慈美，茲據其具狀承受訴訟，核無不合。	16 17
二、上訴人為大聯大投資控股股份有限公司（下稱大聯大公司）董事長兼總經理，於99年5月7日與受託人中國信託商業銀行股份有限公司（下稱中信銀行）簽訂5年期本金自益、孳息他益之信託契約，將所持有大聯大公司股票5百萬股作為信託財產，以其子黃熙杭為信託財產孳息之受益人，並於99年5月11日辦理贈與稅申報，經被上訴人以遺產及贈與稅法（下稱遺贈稅法）第10條之2第3款本文核定99年度贈與總額新臺幣（下同）12,307,846元，應納稅額1,010,784元。嗣經被上訴人查得上訴人訂約時已可確定信託財產可得盈餘（股票股利及現金股利），乃藉信託形式贈與信託孳息予受益人，初查乃就受益人實際取得股利價值，核定99年度本次贈與總額61,049,862元，補徵本次應納稅額6,104,986元。上訴人不服，申經復查，經被上訴人於104年4月8日復查決定駁回。上訴人不服，提起訴願並提出新事證，被上訴人依訴願法第58條第2項規定就上訴人所提新事證先行審查，於104年7月2日以重審復查決定將復查決定撤銷，另以原核定認受託人撥付之現金股利9,995,630元，然受託人於99年9月28日實	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

- 際撥付至受益人現金股利為9,995,520元，追減原核定贈與總額110元後，並陳報訴願機關，上訴人嗣對重審復查決定不服，提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟，經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起本件上訴。
- 三、上訴人起訴主張：(一)上訴人並無租稅規避之意圖，於99年5月7日與中信銀行簽訂系爭信託契約，符合信託法相關規定，其孳息他益部分本應依遺贈稅法第5條之1信託贈與以規範，此經被上訴人依同法第10條之2第3款本文關於信託贈與稅基計算之規定核課確定在案。被上訴人竟指稱上訴人藉信託形式，規避稅負，否定系爭信託契約效力，擅依財政部100年5月6日台財稅字第000000000000號函釋（下稱財政部100年5月6日函）將之變更為遺贈稅法第4條第2項所稱「一般贈與」之範疇，違反租稅法定主義、法律不溯及既往原則、信賴保護原則。復且信託標的之股票於信託契約成立時，以及股利發放時間價格波動甚大，適用上開函釋，將使上訴人無法預見其租稅負擔，亦有違明確性原則。(二)又被上訴人將同一信託契約認定有二種標的之贈與，時點復不相同，違反司法院釋字第385號所揭示不得割裂法律適用及同院釋字第565號解釋所揭示租稅平等原則。是縱認本件信託契約包含股票股利之贈與，依本院102年度判字第824號判決見解，亦應以信託契約成立日（即99年5月7日）大聯大公司每股收盤價60.8元，而非孳息交付日（即同年9月29日）收盤價61.5元作為計算贈與價值之基礎；且應以99年5月7日至同年9月29日為贈與期間，按郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，複利折算現值，被上訴人之計算顯然有誤。求為判決訴願決定及原處分（含重審復查決定除追減贈與總額110元外）均撤銷。
- 四、被上訴人則以：(一)上訴人為大聯大公司之董事長兼總經理，於知悉可確定獲配高額盈餘後，始於99年5月7日訂立信託契約，足見其係透過信託孳息方式將獲配盈餘贈與直系親屬，以信託形式贈與該部分可得確定之孳息，其實質與受託人領取孳息再贈與受益人之情形並無不同，自應於受託人交付該部分孳息與受益人時，依法課徵委託人贈與稅。(二)財政部100年5月6日函，係就委託人就其訂約時已明確或可得確定之盈餘，藉信託形式為贈與者，明釋屬於遺贈稅法第4條規定之贈與行為，應依實質課稅原則課稅，並無違反租稅法律主義。而此解釋函令本身並無創設或變更法律之效力，應自上開法律生效之日起即有其適用，被上訴人援以適用核定上訴人贈與稅捐，並無不法。系爭信託之受益人實質上取得股利所生贈與稅核課，與上訴人依遺贈稅法第5條之1第1項及第10條之2規定，就關於大聯大公司股票所生他益信託之孳息已為之贈與稅申報，分屬不同之事實，依稅捐稽徵法第21條第2項規定，被上訴人本得於核課期間內就另查核之課稅事實

為贈與稅之課徵，不生信賴保護問題。至於上訴人所稱信託標的之股票於系爭信託契約訂定至交付信託孳息間之價格波動甚大，將使納稅義務人無法預見其租稅負擔，無非係因本件贈與稅核課，致未能達其僅以信託贈與方式為核定之意圖，尚與所謂行政行為明確性原則無涉等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)上訴人為大聯大公司董事長兼總經理，於99年5月7日與中信銀行簽訂本金自益、孳息他益之系爭信託契約，將所持有大聯大公司股票5百萬股作為信託財產，信託期間5年，以其子黃熙杭為受益人，並於99年5月11日申報贈與稅。而大聯大公司於99年4月27日召開董事會由上訴人擔任主席，當日旋即於公開資訊觀測站公告董事會決議通過擬配發現金股利每股2元，股票股利每股1.8元，嗣該公司於99年6月21日召開股東常會，決議配發股利確實與董事會決議之分配結果相符，有卷證資料可憑。是上訴人位居大聯大公司營運之核心，其對該公司98年度營運情形及獲利狀況之細節當知之甚詳，且就該公司98年度盈餘分配案，於上開董事會決議前，實質上即有一定之掌控力及預見，並具有一定程度控制權。是上訴人於知悉可確定獲配高額盈餘後，始於99年5月7日訂立信託契約，足見其係透過信託孳息方式將獲配盈餘贈與直系親屬，以信託形式贈與該部分可得確定之孳息，其實質與受託人領取孳息再贈與受益人之情形並無不同。又該信託孳息係屬於訂約時已屬受益人可得確定之孳息利益，尚非該信託契約訂定後，受託人於信託期間管理受託股票始產生之收益，則被上訴人據以核定上訴人99年度贈與稅，符合遺贈稅法第3條第1項、第4條第1項、第2項、第5條之1第1項、第10條第1項、第10條之2第2款、第3款及同法施行細則第28條第1項等規定。(二)按遺贈稅法第10條之2及第5條之1規定，係對信託案件，就其未來信託存續期間所生之孳息為贈與者，其贈與價值自應依該規定折算現值課稅，而財政部100年5月6日函，係針對委託人就其訂約時已明確或可得確定之盈餘，藉信託形式為贈與者，解釋屬於遺贈稅法第4條規定之贈與行為而已，除未逾越上開法律規定範疇而生租稅客體及法律效果之變動，亦非於遺贈稅法第4條外以函釋增加法律所無規定之限制，無違反租稅法律主義、法律保留原則，既無創設或變更法律之效力，自無溯及既往適用之問題。(三)系爭信託契約之受益人黃熙杭取得系爭股利，性質上應屬遺贈稅法第4條第2項規定之贈與，並非同法第5條之1第1項規範範圍，已如前述；其實質上取得系爭股利所生贈與稅核課，與上訴人依遺贈稅法第5條之1第1項及第10條之2規定，就關於大聯大公司股票所生他益信託之孳息已為之贈與稅申報，係屬不同事實，依稅捐稽徵法第21條第2項規定，被上訴人本得於核課期間內就

另查核之課稅事實為贈與稅之課徵，是本件既無何信賴基礎或表現，自無何信賴保護問題存在。(四)上訴人既係將其可得確定之系爭股利，假系爭信託契約之約定，藉由受託人之手將獲配之股利實質贈與其子黃熙杭，則本件被上訴人按遺贈稅法第4條第2項及同法第10條規定，計算贈與標的價值並予核課，亦為明確稅額之記載，並無違反明確性原則之情。再者，贈與係使財產發生移動之一種行為，贈與稅之課徵，本即著重於財產（所有權）已實際上發生移動，即受贈人實際受贈時方得為之，否則若依本件上訴人之主張，一方以自己的財產無償贈與他方，他方一為允受之意思表示，在尚未實際受贈前即應課徵贈與稅，反較被上訴人為苛，自不合理；至於信託標的之股票市價，「實際交付孳息時」價格雖極可能與「訂立信託契約時」不同，然價格高、低皆有可能，上訴人亦不能僅以本件因「實際交付孳息時」價格高於「訂立信託契約時」，即逕謂財政部100年5月6日函以「受託人交付孳息予受益人」時計算其贈與價值有違明確性原則。另上訴人所稱原處分有違本院102年度判字第824號判決意旨，惟該判決並非判例，本件本不受其拘束，況被上訴人作成原處分與本院103年度5月份第2次聯席會議決議意旨相符，是上訴人此部分之主張，亦無為其有利之認定。因將訴願決定及原處分（含重審復查決定）均予維持，駁回上訴人之訴。

六、上訴意旨略以：(一)原處分適用財政部100年5月6日令核課系爭信託契約所產生之贈與稅，有起訴意旨所主張違反租稅法定主義、法律不溯及既往原則、信賴保護原則等，原判決未予糾正，自有違背法令。(二)原判決以物權契約成立生效時（即他益孳息交付時）作為贈與稅稅捐債務成立生效時點，顯然悖於本院102年度判字第824號判決及本院102年度判字第810號判決意旨。且原判決援引本院103年5月份第2次庭長法官聯席會議，以股利交付日作為贈與股利價值之基準時點，實乃限縮遺贈稅法第5條之1及第10條之2第2款規定之適用範圍，增加上訴人法律所無之納稅義務，違反租稅法律主義，並逾越實質課稅原則。且若信託標的之股票於「系爭信託契約訂定」與「交付信託孳息」間價格波動甚大，將使納稅義務人無法預見其租稅負擔，原判決稱原處分未違反行政行為明確性原則，有判決不適用法令之違背法令。(三)上訴人係於股東會前即簽訂系爭信託契約，且無從預見股利配發之股東會決議情形，非本院103年5月份第2次庭長法官聯席會議決議所議決「信託契約係於明知董事會或股東常會決議分配股利後始簽訂」之情形，原判決認定本件屬該決議所定範疇，有判決適用法令不當之違誤。

七、本院核原判決並無違誤，茲再就上訴意旨論述如次：

(一)按「依第5條之1規定應課徵贈與稅之權利，其價值之計算，依左列規定估定之：一、……二、享有孳息以外信託利益之

權利者，該信託利益為金錢時，以信託金額按贈與時起至受益時止之期間，依贈與時郵政儲金匯業局1年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之；信託利益為金錢以外之財產時，以贈與時信託財產之時價，按贈與時起至受益時止之期間，依贈與時郵政儲金匯業局1年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之。三、享有孳息部分信託利益之權利者，以信託金額或贈與時信託財產之時價，減除依前款規定所計算之價值後之餘額為準。……」遺贈稅法第10條之2第2款及第3款前段固分別定有明文。惟依信託法第1條規定，該法所稱信託，係指「委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。」而遺贈稅法第5條之1「信託契約明定信託利益之全部或一部之受益人為非委託人者，視為委託人將享有信託利益之權利贈與該受益人，依本法規定，課徵贈與稅。……」之規定，復係因信託法之制定而增訂，之所以採取遺贈稅法第10條之2第2款、第3款計算「孳息他益信託」稅基之規定，乃採取「擬制」法律效果之立法政策而為；蓋信託契約訂定時，原則上孳息並未發生，將來也未必發生，但為稽徵便宜，節省徵納雙方勞費等意旨，故以法定推計方式折算受益權利現值，將信託期間擬制享有之孳息信託利益，估算於信託成立時之現值，據以課徵委託人贈與稅。是受益人雖於信託契約訂立後，形式上有取自受託人之利益，然該利益若實質上非屬信託契約訂立後，受託人本於信託本旨管理或處分信託財產所生之孳息，則受益人此利益之取得，即與遺贈稅法第5條之1及第10條之2之規定無涉；此際，應依稅捐稽徵法第12條之1第1項、第2項規定，按其行為之實質經濟事實關係及利益歸屬核定其稅捐。

(二)是關於信託契約訂立後，受益人取自受託人非屬信託本旨所生之利益，其贈與稅之課徵，本院103年5月份第2次庭長法官聯席會議決議在案：「課稅構成要件事實實現時，其課稅應以實質經濟事實關係及利益歸屬，暨課稅法律之立法目的為依據，始合於稅捐稽徵法第12條之1第1、2項所規定實質課稅之公平原則。納稅義務人將股票交付信託，簽訂『本金自益、孳息他益』信託契約，其中以信託契約訂立時確定或可得確定之股利（股息、紅利）為他益信託之標的，由受託人於股利發放後交付受益人，因該股利並非受託人本於信託法所規範管理或處分信託股票之信託本旨而孳生，與遺產及贈與稅法第5條之1第1項係針對信託法規定之信託而為『視為贈與』規範之意旨不合。觀其經濟實質，乃納稅義務人將該股利贈與受益人而假受託人之手以實現，並因於受益人受領時始該當遺產及贈與稅法第4條第2項所規定『他人允受』之要件，而成立該條項規定之贈與，故稽徵機關依遺產及贈與稅法第4條第2項及第10條計徵贈與稅，並無不合。至納稅

義務人上開行為涉有租稅規避情事者，亦應調整依遺產及贈與稅法第4條第2項及第10條計徵贈與稅，自不待言。」茲辨明雖同屬一「本金自益、孳息他益」信託契約形式外觀下，受益人取自受託人非屬信託本旨所生之利益，乃「一般贈與」，則應依遺產稅法第4條第2項規範，其稅基依同法第10條第1項規定，以贈與時該利益之時價計算，其贈與行為發生日依同法第4條第2項規定，以訂定贈與契約日為準據；至於受益人取自依信託本旨所生孳息，乃「視同贈與」，應依遺產稅法第5條之1規範，其稅基依同法第10條之2擬制規定計算，贈與行為發生日依同法第24條之1規定，以信託契約訂定日為準據。且以信託契約訂立時確定或可得確定之股利（股息、紅利）為他益信託之標的，實質上所贈與者，乃公司「過去」年度所發生之盈餘以股利形式發放之；而受益人就信託股票取自信託本旨所生之利益，則係信託契約訂立後，該股票因受託人管理行為而「將來」發生之利益，只是現行法以「擬制」方式使之提前發生並據以核算稅基。二者課徵贈與稅之標的有所不同，不因包裹於單一信託契約外觀下，致有混淆。如信託人藉單一信託契約形式，將贈與股利此一應稅行為「隱藏」「夾帶」於信託孳息他益應稅行為下，而依遺產稅法第5條之1、第10條之2規定申報贈與稅，以規避贈與股利此部分稅捐，依本院上開聯席會議決議意旨，此部分當依實質課稅原則以遺產稅法第4條第2項、第10條第1項規定予以核課；至於原信託他益孳息此等「視為贈與」應稅行為，仍應依遺產稅法第5條之1規範、第10條之2為核課；此係分就贈與事實不同而實質核課，並非將單一信託契約分割適用法律。上開本院決議前所作成之本院102年度判字第824號判決及本院102年度判字第810號判決，法律見解與上開決議不同部分，應以上開決議之意旨代之，合先敘明。

(三)上訴人為大聯大公司之董事長兼總經理，於99年5月7日與中信銀行簽訂本金自益、孳息他益之系爭信託契約，將所持有大聯大公司股票5百萬股作為信託財產，信託期間5年，以其子黃熙杭為受益人，並於99年5月11日申報贈與稅。而大聯大公司於99年4月27日召開董事會，並由上訴人擔任主席，當日旋即於公開資訊觀測站公告董事會決議通過擬配發現金股利每股2元，股票股利每股1.8元，嗣該公司於99年6月21日召開股東常會，決議配發股利確實與董事會決議之分配結果相符等情，為原判決依調查證據之辯論結果所依法確定之事實，核與卷證資料相符。上訴人既為大聯大公司董事長兼總經理，該公司董事會復於系爭信託契約訂立前即已決議各該年度之現金股利分配案將提請股東常會議決，則原判決認此股利分配之情，屬上訴人於簽訂信託契約時所得知悉之事實，合於經驗法則與論理法則。而此事實認定與本院103年5月份第2次庭長法官聯席會議決議所揭示之實質課稅原則無

悖，上開決議也未曾有「信託契約係於明知董事會或股東常	250
會決議分配股利後始簽訂」者始適用上開決議之意旨。上訴	251
意旨以本件信託契約訂立於股東常會之前，論證原判決有違	252
上開決議，自有未洽。	253
(四)承上，上開董事會決議案所決議將提請分配之現金股利既屬	254
系爭信託契約簽訂時已確定之股利。是上訴人就系爭信託契	255
約訂立時已確定將歸屬上訴人之股利，猶簽訂本金自益、孳	256
息他益之信託契約，使受益人得藉由受託人而實質取得於系	257
爭信託契約訂立時原即附隨系爭股票而非屬受託人管理或處	258
分受託財產所獲得之孳息，而該股利嗣後亦確實發放由受託	259
人交付受益人。原判決因認上訴人依遺贈稅法第5條之1第1	260
項所申報者為信託孳息他益部分之贈與稅，至於上訴人使受	261
益人取得系爭股利，其行為實質亦應成立遺贈稅法第4條第2	262
項之一般贈與，尚非同法第5條之1第1項規範之視同贈與，	263
並與上訴人所申報繳納「視同贈與」稅部分，乃不同贈與標	264
的。原處分就一般贈與部分之稅基，依同法第10條第1項規	265
定，以贈與時該利益之時價計算，乃依其贈與行為發生日即	266
股利發放日為股利價值之基準時點，計算應課贈與稅額，並	267
記載所據法條及計算方式，於法無違。至於原申報核定與原	268
處分，係就不同贈與事實所為之核課處分，並非割裂適用法	269
律，更無原處分將原核定撤銷，有違信賴保護原則之可能。	270
揆諸前揭說明，原判決就上開情節適用法律，合於遺贈稅法	271
相關規定，並無悖於本院103年5月份第2次庭長法官聯席會	272
議決議意旨。上訴意旨仍循信託契約單一形式之外觀，誤認	273
合於孳息他益信託部分之「視為贈與」稅與股利「贈與」稅	274
為同一，致有原判決割裂法律適用，以及系爭股利贈與稅業	275
已申報並經核定確定之誤解，因此指摘原審判決上開以撥付	276
股利日為贈與股利日，並以此為稅基基準，有失實質課稅原	277
則「調整界限」云云，均無足採。	278
(五)原處分雖引用財政部100年5月6日函以為本件核課贈與稅之	279
依據，惟原判決係以遺贈稅法相關規定為本案之論述；上訴	280
意旨以原處分援引前揭函而指摘其違反租稅法律原則、法律	281
保留原則、法律不溯及既往原則等等，核均與原判決是否違	282
背法令之判斷無涉，茲不再贅論。至於上訴意旨所稱若信託	283
標的之股票於「系爭信託契約訂定」與「交付信託孳息」間	284
價格波動甚大，將使納稅義務人無法預見其租稅負擔，原處	285
分乃有違「行政行為明確性原則」等節，則顯然對行政行為	286
明確性原則有所誤會。原處分係就「已發生」之股利發放此	287
一贈與事實為贈與稅之課徵，並記載法律依據及計算稅額方	288
式，無不明確之處，業經原判決詳予論述。上訴意旨所謂無	289
法預見其租稅負擔，應係指其藉系爭信託契約之名為股利贈	290
與之際，未預見稽徵機關依實質課稅原則就該股利贈與為稅	291
捐之課徵而已。核此與原處分是否有違明確性原則全然無關	292

，亦併指明。	293
(六) 綜上所述，上訴人之主張均無可採。原判決將訴願決定及復查決定均予維持，而駁回上訴人在第一審之訴，尚無違誤。	294
上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。	295
八、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。	296
中 華 民 國 106 年 1 月 25 日	297
最高行政法院第二庭	298
審判長法官 侯 東 昇	299
法官 林 樹 埔	300
法官 江 幸 垠	301
法官 沈 應 南	302
法官 楊 得 君	303
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異	304
中 華 民 國 106 年 1 月 25 日	305
書記官 吳 玫 瑩	306
	307
	308
	309
	310

相關法條

- 遺產及贈與稅法 第 2、3、4、5.1、10、10.2 條（104.07.01）
- 訴願法 第 58 條（101.06.27）
- 信託法 第 1 條（98.12.30）
- 稅捐稽徵法 第 2、12.1、21 條（106.01.18）
- 行政訴訟法 第 98、255 條（103.06.18）

資料來源：司法院裁判書系統

司法院裁判書系統

列印時間：114.11.16 22:19

裁判字號：臺北高等行政法院 104 年度訴字第 2012 號判決

裁判日期：民國 105 年 04 月 14 日

裁判案由：贈與稅

臺北高等行政法院判決	1
104年度訴字第2012號	2
105年3月31日辯論終結	3
原 告 黃偉祥	4
訴訟代理人 蔡朝安 律師	5
李益甄 律師	6
李威忠 律師	7
被 告 財政部臺北國稅局	8
代 表 人 何瑞芳（局長）	9
訴訟代理人 陳宜津	10
上列當事人間贈與稅事件，原告不服財政部中華民國104 年10月 27日台財訴字第10413955130號訴願決定（案號：第000000000 號 ），提起行政訴訟，本院判決如下：	11 12 13
主 文	14
原告之訴駁回。	15
訴訟費用由原告負擔。	16
事實及理由	17
一、事實概要：原告於民國99年5月7日與受託人中國信託商業銀 行股份有限公司（下稱中信銀行）簽訂5 年期本金自益、孳 息他益之信託契約，將所持有大聯大投資控股股份有限公司 （下稱大聯大公司）股票5 百萬股作為信託財產，以訴外人 即其子黃熙杭為信託財產孳息之受益人，並於99年5 月11日 辦理贈與稅申報，原核定99年度贈與總額新臺幣（下同）12 ,307,846元，應納稅額1,010,784 元。嗣經被告查得原告將 訂約時信託財產可得確定之盈餘（股票股利及現金股利）， 藉信託形式贈與信託孳息予受益人，初查乃就受益人實際取 得股利價值，核定99年度本次贈與總額61,049,862元，補徵 本次應納稅額6,104,986 元。原告不服，申經復查，經被告 於104 年4月8日復查決定駁回。原告不服，提起訴願並提出 新事證，被告依訴願法第58條第2 項規定就原告所提新事證 先行審查，於104 年7月2日以重審復查決定將復查決定撤銷 ，另以原核定認受託人撥付之現金股利9,995,630 元，然受 託人於99年9月28日實際撥付至受益人現金股利為9,995,520 元，追減原核定贈與總額110 元後，並陳報訴願機關，原告	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

嗣對重審復查決定不服，亦提起訴願，經無理由駁回後，遂
提起本件行政訴訟。

二、本件原告主張：

(一)財政部100年5月6日台財稅字第10000076610號函釋（下稱
財政部100 年5月6日函釋）以信託契約訂定時知悉或可得
知盈餘分配而訂定信託契約，涉有規避法律情事應改依一
般贈與方式課稅，此涉及租稅客體及法律效果之變動，應
以法律或法律授權之命令限制之，是財政部100 年5月6日
函釋增加法律所無規定，逕將訂約當時已知悉被投資公司
將分配盈餘之情形，遽認無遺產及贈與稅法（下稱遺贈稅
法）第10條之2第3款之適用，另為租稅客體及法律效果之
判斷，違悖租稅法律主義，被告不應適用以變更已核課確
定之贈與稅案件。

(二)依中央法規標準法第18條、稅捐稽徵法第1條之1及第34條
規定、司法院釋字第287 號解釋及最高行政法院89年度判
字第2467號判決，稅捐稽徵法第21條所稱「另發現應徵之
稅捐者」，係指未核課確定之案件，且另發現新課稅事實
或資料時，始為該當；如僅屬嗣後法律見解之變更，未發
現新課稅事實或資料，自不在得補稅之範圍。據此，當原
課稅處分已核課確定，而解釋函釋發生不利人民之變動時
，基於法安定考量，稅捐稽徵機關尚不得逕依稅捐稽徵法
第21條規定補徵稅款。本件因已於99年5 月11日經原告申
報後而告確定，縱財政部另發布100 年5月6日函釋，其僅
屬法律見解變更，而非發現新事實或新課稅資料，被告不
得依稅捐稽徵法第21條重為核定補徵稅款，原處分顯違法
律不溯及既往、法安定性原則，應予撤銷。

(三)財政部94年2月23日台財稅字第09404509000號函釋（下稱
財政部94年2 月23日函釋）係以「信託契約受益人是否特
定」區分適用遺贈稅法第4條一般贈與或第5條之1 信託贈
與之情形。若受益人特定，且委託人無保留變更受益人及
分配、處分信託利益之權利者，則應依遺贈稅法第5條之1
信託贈與方式課徵贈與稅，原告係依上開函釋進行本件信
託，且已特定孳息受益人為黃熙杭並繳交贈與稅在案。財
政部雖就信託贈與發布100 年5月6日函釋，然因本件係屬
核課確定案件且非原告據以申請之案件，揆諸稅捐稽徵法
第1條之1第2項、第3項規定及最高行政法院98年度判字第
682號判決，被告不應將財政部100年5月6日函釋適用於本
件，本件有違稅捐稽徵法第1 條之1第1項規定及信賴保護
原則，應予撤銷。縱認本件屬未核課確定案件，然依稅捐
稽徵法第1 條之1第2項規定，新發布解釋函令變更舊函令
見解，且不利於納稅義務人之情形者，應自發布日後生效
。因財政部100年5月6日函釋變更財政部94年2月23日函釋
見解且不利納稅義務人，本件並無該函釋適用。

- (四)退步言之，縱認本件原告應依一般贈與規定課徵贈與稅，
依司法院釋字第385 號解釋所揭示不得割裂法律適用之意
旨，孳息贈與日應與本金贈與日相同，而不得割裂適用，
被告將同一信託契約中之自益信託之本金以造成同一信託
契約之兩種標的之贈與時點分別作不同認定之割裂法律適
用且違反司法院釋字第565 號解釋所揭示租稅平等原則。
依最高行政法院102年度判字第824號判決見解，本件贈與
孳息之股票股利部分，應以信託契約成立日（即99年5月7
日）大聯大公司每股收盤價60.8元，而非孳息交付日（即
同年9 月29日）收盤價61.5元作為計算贈與價值之基礎；
且應以99年5月7日至同年9 月29日為贈與期間，按郵政儲
金匯業局一年期定期儲金固定利率，複利折算現值，被告
之計算顯然有誤。又訴願決定所引用最高行政法院103 年
度5月份第2次庭長法官聯席會議（下稱聯席會議）決議，
僅係認信託契約訂定日以確定或可得確定之股利進行信託
，不符信託本旨所孳生，應依遺贈稅法第4條第2項及第10
條一般贈與進行課稅。然依遺贈稅法第10條，其贈與價值
亦應以「贈與時」即信託契約成立日為計算基準時點，蓋
於信託契約成立日，原告即將孳息贈與受益人，而非於實
際交付孳息日，被告誤以孳息交付日為計算基準時點，顯
然有誤。
- (五)「委託人經由股東會、董事會等會議資料知悉被投資公司
將分配盈餘後，簽訂孳息他益之信託契約」為財政部100
年5月6日函釋所定得改按一般贈與課稅之要件，此處「知
悉」之對象，應係指分配盈餘之確定具體內容，而非泛指
分配盈餘之行為。惟分配盈餘之確定具體內容，於公開發
行之上市、櫃公司，因其於證券交易所進行交易，股權變
動不但簡單迅速而且可變動幅度極高，不乏股權被大量收
購，導致股權結構及股東會局面全然不同，從而否決董事
會分派股利決議之可能。進而，於上市公司之情形，上開
函釋所稱「知悉」，應限於「知悉股東會決議股利分派」
之情形。本件大聯大公司係上市公司，其於99年4 月27日
董事會決議為98年度股利分派，同年6 月21日股東會決議
通過。經過近2 個月期間，顯易發生股權結構全然不同之
情況；況系爭契約雖於99年5月7日簽訂，惟先前已與受託
人中信銀行商議多時，被告何能據以認定原告係先知悉將
分配盈餘，方為系爭契約之簽署，是縱認原告於知悉盈餘
分配後始簽訂孳息他益信託契約應依一般贈與課稅，原告
亦僅知該孳息於「信託契約成立日」之價值，無法確切知
悉「孳息交付日之孳息價值」，財政部100 年5月6日函釋
以「受託人交付孳息予受益人」時始計算其贈與價值，若
信託標的之股票於兩時點間價格波動甚大，將使原告無法
預見其租稅負擔，財政部100 年5月6日函釋有違明確性原

則，而不應適用。另本件贈與一次簽訂5 年，如欲為租稅
規劃，一次簽訂1 年即可，是於信託時，原告並無規避租
稅之意圖。

(六)是原告聲明：訴願決定及原處分（含重審復查決定除追減
贈與總額110元外）均撤銷。

三、被告則以：

(一)遺贈稅法第10條之2 及第5條之1規定，係對一般正常信託
案件，就其未來信託存續期間所生之孳息為贈與者，其贈
與價值自應依該規定折算現值課稅，而財政部100年5月6
日函釋，係就委託人就其訂約時已明確或可得確定之盈餘
，藉信託形式為贈與者，明釋屬於遺贈稅法第4 條規定之
贈與行為，應依實質課稅原則課稅，自無違反憲法第19條
租稅法律主義及第23條法律保留原則。又依司法院釋字第
287 號解釋意旨，解釋函令本身並無創設或變更法律之效
力，自無溯及既往適用之問題。財政部100 年5月6日函釋
係依釋字第287 號解釋意旨，應自上開法規生效之日起即
有其適用，尚與法律不得溯及既往原則無涉。

(二)納稅義務人依遺贈稅法規定辦理申報而經稅捐稽徵機關調
查核定之案件，稽徵機關如發現原處分確有錯誤短徵，為
維持課稅公平之原則，基於公益上之理由，並非不可自行
變更原查定處分，而補徵應繳稅額。稅捐機關於核課期間
內本得就另應徵之稅捐為核課處分，並非信賴基礎之國家
行為。系爭信託之受益人實質上取得股利所生贈與稅核課
，與原告依遺贈稅法第5條之1第1項及第10條之2規定，就
關於大聯大公司股票所生他益信託之孳息已為之贈與稅申
報，分屬不同之事實，依稅捐稽徵法第21條第2 項規定，
被告本得於核課期間內就另查核之課稅事實為贈與稅之課
徵，不生信賴保護問題。

(三)大聯大公司於99年4 月27日召開董事會，當日旋即於公開
資訊觀測站公告董事會決議通過擬配發現金股利每股2 元
，股票股利每股1.8元，嗣該公司於99年6月21日召開股東
常會，配發之股利確與上開董事會決議分配之結果相合。
原告為大聯大公司之董事長兼總經理，並於董事會當天擔
任主席與會，位居該公司營運之核心，其對該公司98年度
之營運情形及獲利狀況之細節當知之甚詳，且於上開董事
會決議前實質上即有一定之掌控力及預見，並具有一定程
度控制權，符合首揭財政部100 年5月6日函釋「知悉」或
「盈餘分配具有控制權」之要件。原告於知悉可確定獲配
高額盈餘後，始於99年5月7日訂立信託契約，足見其係透
過信託孳息方式將獲配盈餘贈與直系親屬，以信託形式贈
與該部分可得確定之孳息，其實質與受託人領取孳息再贈
與受益人之情形並無不同。又該信託孳息係屬於訂約時受
益人可得確定之孳息利益，尚非信託契約訂定後，受託人

於信託期間管理受託股票始產生之收益，不符遺贈稅法第	164
5條之1規定，自應於受託人交付該部分孳息與受益人時，	165
依法課徵委託人贈與稅，俾符課稅公平原則。	166
(四)原告所稱信託標的之股票於系爭信託契約訂定至交付信託	167
孳息間之價格波動甚大，將使納稅義務人無法預見其租稅	168
負擔，無非係因本件贈與稅核課，致未能達其僅以信託贈	169
與方式為核定之意圖，尚與所謂行政行為明確性原則無涉	170
。	171
(五)是被告聲明：駁回原告之訴。	172
四、上開事實概要欄所述之事實，有系爭信託契約、99年5月7日	173
大聯大公司集中市場證券行情價表、99年5月7日除權除息參	174
考價格試算、原告99年5月11日贈與稅申報書、99年5月14日	175
贈與稅應稅案件核定通知書、99年度贈與稅繳款書、99年5	176
月28日贈與稅繳清證明書、99年3至6月大聯大公司董監事持	177
股餘額明細資料、大聯大公司99年股利分派情形、99年9 月	178
29日大聯大公司個股成交價格資訊、中信銀行103 年6月9日	179
中信銀字第1032233650174 號函及所附辦理信託業務相關資	180
料、大聯大公司103年8月4日大聯大字第20140800001號函及	181
所附董事會議通知、議程內容異動通知、公司章程及董事會	182
議簽到簿資料、103年7月17日贈與稅應稅案件核定通知書、	183
中信銀行104年1月21日中信銀字第1042233650018 號函及所	184
附99年信託收益分配指示書、信託轉帳申請書、匯款申請書	185
、原告99年度贈與稅繳款書（贈與發生日期99年9月29日）	186
、訴願決定、重審復查決定及復查決定等件附於原處分卷、	187
訴願卷及本院卷可稽。是本件應審酌之爭點即為：被告以原	188
告將訂立系爭信託契約時信託財產可得確定之盈餘（股票股	189
利及現金股利），藉信託形式贈與信託孳息予受益人及其子	190
黃熙杭，以原處分核定對原告補徵贈與稅，於法是否有據。	191
五、茲就兩造之上開爭執，析述如下：	192
(一)按「（第1 項）涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅	193
法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之	194
意義及實質課稅之公平原則為之。（第2 項）稅捐稽徵機	195
關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關	196
係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。（第3 項	197
）納稅義務人基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，	198
濫用法律形式，規避租稅構成要件之該當，以達成與交易	199
常規相當之經濟效果，為租稅規避。（第4 項）項租稅規	200
避及第2 項課徵租稅構成要件事實之認定，稅捐稽徵機關	201
就其事實有舉證之責任。……（第6 項）稅捐稽徵機關查	202
明納稅義務人及交易之相對人或關係人有第2項或第3項之	203
情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資	204
料依各稅法規定予以調整。」為稅捐稽徵法第12條之1第1	205
項至第4項、第6項所明定。次按「凡經常居住中華民國境	206

內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為 207
贈與者，應依本法規定，課徵贈與稅。」「（第1 項）本 208
法稱財產，指動產、不動產及其他一切有財產價值之權利 209
。（第2 項）本法稱贈與，指財產所有人以自己之財產無 210
償給予他人，經他人允受而生效力之行為。……」「信託 211
契約明定信託利益之全部或一部之受益人為非委託人者， 212
視為委託人將享有信託利益之權利贈與該受益人，依本法 213
規定，課徵贈與稅。」「遺產及贈與財產價值之計算，以 214
被繼承人死亡時或贈與人贈與時之時價為準。……」「依 215
第5條之1規定應課徵贈與稅之權利，其價值之計算，依左 216
列規定估定之：……二、享有孳息以外信託利益之權利者 217
，……信託利益為金錢以外之財產時，以贈與時信託財產 218
之時價，按贈與時起至受益時止之期間，依贈與時郵政儲 219
金匯業局一年期定期儲金固定利率複利折算現值計算之。 220
三、享有孳息部分信託利益之權利者，以信託金額或贈與 221
時信託財產之時價，減除依前款規定所計算之價值後之餘 222
額為準。……」及「凡已在證券交易所上市（以下簡稱上 223
市）或證券商營業處所買賣（以下簡稱上櫃或興櫃）之有 224
價證券，依繼承開始日或贈與日該項上市或上櫃有價證券 225
之收盤價或興櫃股票之當日加權平均成交價估定之。…… 226
」為遺贈稅法第3條第1項、第4條第1項、第2項、第5條之 227
1第1項、第10條第1項、第10條之2第2款、第3款及同法施 228
行細則第28條第1項所規定。 229

(二)次按「課稅構成要件事實實現時，其課稅應以實質經濟事 230
實關係及利益歸屬，暨課稅法律之立法目的為依據，始合 231
於稅捐稽徵法第12條之1 第1、2項所規定實質課稅之公平 232
原則。納稅義務人將股票交付信託，簽訂『本金自益、孳 233
息他益』信託契約，其中以信託契約訂立時確定或可得確 234
定之股利（股息、紅利）為他益信託之標的，由受託人於 235
股利發放後交付受益人，因該股利並非受託人本於信託法 236
所規範管理或處分信託股票之信託本旨而孳生，與遺產及 237
贈與稅法第5 條之1第1項係針對信託法規定之信託而為『 238
視為贈與』規範之意旨不合。觀其經濟實質，乃納稅義務 239
人將該股利贈與受益人而假受託人之手以實現，並因於受 240
益人受領時始該當遺產及贈與稅法第4條第2項所規定『他 241
人允受』之要件，而成立該條項規定之贈與，故稽徵機關 242
依遺產及贈與稅法第4條第2項及第10條計徵贈與稅，並無 243
不合。至納稅義務人上開行為涉有租稅規避情事者，亦應 244
調整依遺產及贈與稅法第4條第2項及第10條計徵贈與稅， 245
自不待言。」（最高行政法院103 年度5月份第2次聯席會 246
議決議意旨參照）繼按「核釋個人簽訂孳息他益之股票信 247
託相關課稅規定：一、委託人經由股東會、董事會等會議 248
資料知悉被投資公司將分配盈餘後，簽訂孳息他益之信託 249

契約；或委託人對被投資公司之盈餘分配具有控制權，於 250
簽訂孳息他益之信託契約後，經由盈餘分配決議，將訂約 251
時該公司累積未分配之盈餘以信託形式為贈與並據以申報 252
贈與稅者，該盈餘於訂約時已明確或可得確定，尚非信託 253
契約訂定後，受託人於信託期間管理受託股票產生之收益 254
，則委託人以信託形式贈與該部分孳息，其實質與委任受 255
託人領取孳息再贈與受益人之情形並無不同，依實質課稅 256
原則，該部分孳息仍屬委託人之所得，應於所得發生年度 257
依法課徵委託人之綜合所得稅；嗣受託人交付該部分孳息 258
與受益人時，應依法課徵委託人贈與稅。二、上開信託契 259
約相關課稅處理原則如下……(二)贈與稅部分：除補徵短漏 260
稅額外，並應依遺產及贈與稅法第45條規定辦理。三、上 261
開信託契約訂定日在本令發布日以前者，准予補稅免罰。 262
……」為財政部100年5月6日函釋所明文。 263
(三)經查，本件原告於99年5月7日與中信銀行簽訂本金自益、 264
孳息他益之系爭信託契約，將所持有大聯大公司股票5 百 265
萬股作為信託財產，信託期間5 年，以其子黃熙杭為受益 266
人，並於99年5月11日申報贈與稅。而大聯大公司於99年4 267
月27日召開董事會，當日旋即於公開資訊觀測站公告董事 268
會決議通過擬配發現金股利每股2元，股票股利每股1.8元 269
，嗣該公司於99年6 月21日召開股東常會，決議配發股利 270
確實與董事會決議之分配結果相符。次以原告為大聯大公 271
司之董事長兼總經理，並於董事會當天擔任主席與會，有 272
該公司99年3至6月董監事持股餘額明細資料、董事會出席 273
簽到簿附卷可稽（原處分卷一第44至48、76頁），是原告 274
位居大聯大公司營運之核心，其對該公司98年度營運情形 275
及獲利狀況之細節當知之甚詳，且就該公司98年度盈餘分 276
配案，於上開董事會決議前，實質上即有一定之掌控力及 277
預見，並具有一定程度控制權，符合財政部100 年5月6日 278
函釋「知悉」或「盈餘分配具有控制權」之要件。是原告 279
於知悉可確定獲配高額盈餘後，始於99年5月7日訂立信託 280
契約，足見其係透過信託孳息方式將獲配盈餘贈與直系親 281
屬，以信託形式贈與該部分可得確定之孳息，其實質與受 282
託人領取孳息再贈與受益人之情形並無不同。又該信託孳 283
息係屬於訂約時已屬受益人可得確定之孳息利益，尚非該 284
信託契約訂定後，受託人於信託期間管理受託股票始產生 285
之收益，則被告據以核定原告99年度贈與稅，業已符合首 286
揭規定、聯席會議決議意旨，除難認有何違誤外，亦已符 287
課稅公平原則。 288
(四)原告雖以：被告依財政部100 年5月6日函釋為本件核定， 289
已違租稅法律主義、稅捐稽徵法第1條之1規定及法律不溯 290
及既往原則等情為主張。茲以： 291
1.按遺贈稅法第10條之2 及第5條之1規定，係對一般正常 292

信託案件，就其未來信託存續期間所生之孳息為贈與者	293
，其贈與價值自應依該規定折算現值課稅，而財政部10	294
0 年5月6日函釋，係財政部基於中央財稅主管機關職權	295
，為協助下級機關就個人簽訂孳息他益之股票信託情形	296
，如何核課贈與稅予以釋示相關課稅處理原則，實際上	297
係在統一解釋遺贈稅法第4 條於上開情形應如何正確適	298
用及認定事實之解釋性規定，易言之，即係就委託人就	299
其訂約時已明確或可得確定之盈餘，藉信託形式為贈與	300
者，明釋應依實質課稅原則課稅，其法令依據實為遺贈	301
稅法第4 條之規定，亦即該令釋係針對委託人就其訂約	302
時已明確或可得確定之盈餘，藉信託形式為贈與者，解	303
釋屬於遺贈稅法第4 條規定之贈與行為而已，除未逾越	304
上開法律規定範疇而生租稅客體及法律效果之變動，亦	305
非於遺贈稅法第4 條外以函釋增加法律所無規定之限制	306
，自無違反憲法第19條租稅法律主義及第23條規定之法	307
律保留原則。	308
2.次按「行政主管機關就行政法規所為之釋示，係闡明法	309
規之原意，固應自法規生效之日起有其適用。」司法院	310
釋字第287 號解釋意旨參照，即解釋函令乃行政機關對	311
於租稅法律、規章在適用上發生疑義時，為闡明其真意	312
，所為正確適用之釋示。其主要在說明法條真意，使條	313
文能正確適用，本身無創設或變更法律之效力，自無溯	314
及既往適用之問題。財政部100 年5月6日函釋係財政部	315
基於中央財稅主管機關職權所訂頒之解釋性規定，符合	316
行政程序法第159 條第2項第2款之規定，已如前述，參	317
諸前揭司法院釋字第287 號解釋意旨，其效力應與所解	318
釋之法規生效日相同（自遺贈稅法第4 條生效之日起，	319
即有其適用）。本件被告依財政部100 年5月6日函釋意	320
旨，就原告實質贈與之事實，依遺贈稅法第4條第2項規	321
定核課贈與稅，亦與法律不得溯及既往原則無涉。是原	322
告此部分之主張，悉與相關法律規定相悖，自無可採。	323
(五)原告次以：本件屬已確定案件，財政部100 年5月6日函釋	324
至多僅屬法律見解變更，而非發現新事實或新課稅資料，	325
被告不得依稅捐稽徵法第21條規定補稅等情為主張。惟按	326
納稅義務人依遺贈稅法規定辦理申報而經稅捐稽徵機關調	327
查核定之案件，如經過法定期間而未申請復查或行政爭訟	328
，其查定處分，固具有形式上之存續力而生不可爭性；惟	329
稽徵機關如發現原處分確有錯誤短徵，為維持課稅公平之	330
原則，基於公益上之理由，並非不可自行變更原查定處分	331
，而補徵應繳之稅額。稅捐機關於核課期間內本得就另應	332
徵之稅捐為核課處分，不生因有為信賴基礎之國家行為，	333
致是否有信賴保護原則之適用問題。經查，系爭信託契約	334
之受益人黃熙杭取得系爭股利，性質上應屬遺贈稅法第4	335

條第2項規定之贈與，並非同法第5條之1第1項規範範圍，
已如前述；其實質上取得系爭股利所生贈與稅核課，與原告
依遺贈稅法第5條之1第1項及第10條之2規定，就關於大
聯大公司股票所生他益信託之孳息已為之贈與稅申報，係
屬不同事實，依稅捐稽徵法第21條第2 項規定，被告本得
於核課期間內就另查核之課稅事實為贈與稅之課徵，是本
件既無何信賴基礎或表現，自無何信賴保護問題存在。是
原告誤解法令規定所為此部分之主張，亦難憑採。

(六)原告另以：本件有違最高行政法院102年度判字第824號判決
意旨，且原處分將同一信託契約本金及孳息之贈與時點
為不同認定，使原告無法預見其租稅負擔，顯違行政行為
明確性原則，本件應依上開判決見解，就贈與孳息部分應
以信託契約成立日（即99年5月7日）大聯大公司每股收盤
價60.8元，而非孳息交付日（即同年9月29日）收盤價61.
5 元作為計算贈與價值之基礎，且應以上開二時點為贈與
期間按郵政儲金匯業局一年期定期儲金固定利率，複利折
算現值等情為主張。惟查，原告既係將其可得確定之系爭
股利，假系爭信託契約之約定，藉由受託人之手將獲配之
股利實質贈與其子黃熙杭，則本件被告按遺贈稅法第4 條
第2 項及同法第10條規定，計算贈與標的價值並予核課，
亦為明確稅額之記載，並無違反明確性原則之情。再者，
贈與係使財產發生移動之一種行為，贈與稅之課徵，本即
著重於財產（所有權）已實際上發生移動，即受贈人實際
受贈時方得為之，否則若依本件原告之主張，一方以自己的
財產無償贈與他方，他方一為允受之意思表示，在尚未
實際受贈前即應課徵贈與稅，反較被告為苛，自不合理；
至於信託標的之股票市價，「實際交付孳息時」價格雖極
可能與「訂立信託契約時」不同，然價格高、低皆有可能
，原告亦不能僅以本件因「實際交付孳息時」價格高於「
訂立信託契約時」，即逕調財政部100 年5月6日函釋以「
受託人交付孳息予受益人」時計算其贈與價值有違明確性
原則，上開函釋洵屬有據並合於情理，被告予以援用進而
核定本件贈與價格，自屬可採。另原告所稱原處分有違最
高行政法院102年度判字第824號判決意旨，惟該判決並非
判例，本件本不受其拘束，況被告作成原處分與前揭最高
行政法院103 年度5月份第2次聯席會議決議意旨相符，是
原告此部分之主張，亦無從為其有利之認定。

六、綜上所述，原告所訴各節，均非可採。是本件被告認事用法
，並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告徒執前詞
，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第
1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 4 月 14 日

臺北高等行政法院第二庭

審判長法官 胡 方 新

法官 李 君 豪

法官 鍾 啟 煌

一、上為正本係照原本作成。

二、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241條之1第1項前段）

四、但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人。（同條第1項但書、第2項）

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 105 年 4 月 14 日

書記官 吳 芳 靜

相關法條

- 訴願法 第 58 條 (101.06.27)
- 遺產及贈與稅法 第 2、3、4、5.1、10、10.2、45 條 (104.07.01)
- 中央法規標準法 第 18 條 (93.05.19)
- 稅捐稽徵法 第 1.1、3、12.1、21、34 條 (104.01.14)
- 中華民國憲法 第 19 條 (36.01.01)
- 行政程序法 第 159 條 (104.12.30)
- 行政訴訟法 第 98、241.1 條 (103.06.18)

資料來源：司法院裁判書系統